Clarendon Law Series

THE CONCEPT OF LAW

H. L. A. Hart

Oxford University Press
1961

Г. Л. А. Харт

ПОНЯТИЕ ПРАВА

Перевод с английского

Под общей редакцией
Е. В. Афонасина и С. В. Моисеева

ИЗДАТЕЛЬСТВО
С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
2007

ББК 87.7
Х20

Перевод с английского
Е. В. Афонасина, М. В. Бабака,
А. Б. Дидикина и С. В. Моисеева

Под общей редакцией
Е. В. Афонасина и С. В. Моисеева

С послесловием С. В. Моисеева

Харт Г. Л. А

Х20 Понятие права / Пер. с англ.; под общ. ред. Е.В.Афонасина и С.В.Моисеева. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. — 302 с.

ISBN 978-5-288-04211-9

Книгу Харта «Понятие права» (The Concept of Law) нередко называют главным произведением философии права XX в. В книге дан глубокий анализ наиболее фундаментальных проблем философии права. Новаторские идеи Харта, высказанные в этой книге, до сих пор остаются чрезвычайно влиятельными. Более того, все последующее развитие философии права было в значительной степени реакцией на этот текст, и даже критики Харта неизбежно отталкиваются от этой книги. К сожалению, идеи Харта (как и вся англосаксонская традиция философии права) пока еще недостаточно известны русскоязычному читателю. Предлагаемый перевод послужит тому, чтобы заполнить этот пробел.

Знакомство с ее содержанием необходимо для специалистов-правоведов, преподавателей юридических вузов и факультетов и всех, интересующихся философией права.

ББК 87.7

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
Проект № 05-03-16066д

© Oxford University Press, 1961
© Афонасин Е. В., Бабак М.В., Дидикин А. Б, Моисеев С. В., перевод, 2006
© Моисеев С. В., послесловие, 2006
© Афонасин Е. В., статья, 2006
© Издательство С.-Петербургского университета, 2006

ISBN 978-5-288-04211-9

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Глава первая. НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Затруднения правовой теории
2. Три постоянно возникающих проблемы
3. Определения

Глава вторая. ЗАКОНЫ, КОМАНДЫ И ПРИКАЗЫ
1. Разновидности императивов
2. Право как принуждающие приказы

Глава третья. МНОГООБРАЗИЕ ЗАКОНОВ
1. Содержание законов
2. Сфера применения
3. Способы происхождения

Глава четвертая. СУВЕРЕН И ПОДДАННЫЙ
1. Повиновение по привычке и непрерывность права
2. Постоянство права
3. Правовые ограничения законодательной власти
4. Суверенитет в основе законодательства

Глава пятая. ПРАВО КАК ЕДИНСТВО ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ ПРАВИЛ
1. Новое начало
2. Идея обязательства
3. Начала права

Глава шестая. ОСНОВАНИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
1. Правило признания и юридическая действительность
2. Новые вопросы
3. Патология правовой системы

Глава седьмая. ФОРМАЛИЗМ И СКЕПТИЦИЗМ ПО ПОВОДУ ПРАВИЛ
1. Открытая структура права
2. Разнообразие форм скептицизма по поводу правил
3. Окончательность и безошибочность судебных решений
4. Неопределенность в правиле признания

Глава восьмая. СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ
1. Принципы справедливости
2. Моральные и правовые обязанности
3. Нравственные идеалы и социальная критика

Глава девятая. ПРАВО И МОРАЛЬ
1. Естественное право и юридический позитивизм
2. Минимальное содержание естественного права
3. Юридическая действительность и моральная ценность

Глава десятая. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
1. Источники сомнений
2. Обязанности и санкции
3. Обязанности и суверенитет государств
4. Международное право и мораль
5. Аналогии формы и содержания

Примечания к главам

С.В.Моисеев. «Понятие права» Герберта Харта
Е.В.Афонасин. Истоки и базовые проблемы современной философии права

ПРЕДИСЛОВИЕ

Моей целью в этой книге было развитие нашего представления о праве, принуждении и морали как различных, однако и связанных друг с другом социальных явлениях. Хотя работа изначально предназначалась для изучающих юриспруденцию, я надеюсь, что она может оказаться полезной и тем, чьи основные интересы лежат скорее в сферах моральной и политической философии или социологии, а не права в собственном смысле этого слова. Юрист будет рассматривать эту книгу как очерк аналитической юриспруденции, так как она посвящена скорее прояснению структуры правовой мысли, нежели критике права или правовой теории. Кроме того, во многих случаях я поднимал вопросы, призванные точнее определить значение понятий. Так, к примеру, я рассматривал: отличие выражения «был должен» от «имел обязанность»; то, как высказывание о том, что данное правило является действительным правилом закона, отличается от предсказания ожидаемого поведения официальных лиц; а также что мы имеем в виду, говоря, что данная социальная группа соблюдает правило, и в чем здесь сходство и отличие от утверждения, что ее члены обычно поступают некоторым образом. На самом деле одной из важнейших тем книги является утверждение, что ни право, ни любая другая форма социальной организации не могут быть поняты без осознания принципиального различия между двумя типами высказываний, которые я назвал «внутренними» и «внешними» и которые оба могут делаться относительно любого социального правила.

Несмотря на особое внимание, которое я уделяю анализу, книга может также рассматриваться как очерк дескриптивной социологии, ибо представление о том, что изучение смысла слов всего лишь проясняет слова, ложно. Многие важные и непосредственно не очевидные различия между типами социальных ситуаций или отношений наиболее ясно выявляются благодаря изучению соответствующих выражений и того, как они зависит от социального контекста, нередко явно не названного. В этой области в большей мере, чем где-либо, верно то, что мы можем использовать, как сказал профессор Дж. Л. Остин, «более четкое значение слов, чтобы яснее воспринимать явления».

Я глубоко и очевидным образом обязан другим исследователям. В самом деле, большая часть книги касается недостатков простой модели

правовой системы, сконструированной на основе императивной теории Остина. И хотя в тексте я позволил себе обойтись немногими ссылками на других авторов и свел сноски к минимуму, в дополнении, помещенном в самом конце книги, читатель найдет более обширные примечания, которые следует читать после ознакомления с содержанием каждой главы. Именно здесь мои воззрения сопоставляются с мнениями моих предшественников и современников, а также высказываются соображения о том, как можно было бы развить далее высказанные ими положения. Я избрал такую структуру работы отчасти потому, что сопоставления с другими теориям мешали бы непрерывному развитию моей аргументации. Кроме того, передо мной стояла и педагогическая задача: я надеюсь, что такая структура позволит опровергнуть мнение, что книга по теории права - это сочинение, из которого читатель в основном узнает о том, что по тому или иному поводу написано в других книгах. До тех пор пока пишущие будут придерживаться такого мнения, едва ли им удастся достигнуть прогресса в самой теории; и пока читатели согласны с этим мнением, образовательная ценность этого предмета будет невелика.

Я обязан слишком многим друзьям, помогающим мне в течение слишком длительного времени, чтобы иметь возможность высказать всем персональную благодарность. Однако я должен здесь выразить особую благодарность г-ну А. М. Оноре, чья детальная критика помогла выявить многие смысловые и стилистические недочеты. Я постарался учесть все это, однако боюсь, что все равно осталось много такого, чего он бы не одобрил. Я обязан беседам с г-ном Г. А. Полом всем тем, что есть ценного в политической философии этой книги и предложенной в ней новой интерпретации естественного права. Я благодарен ему также за чтение гранок. Наконец, я благодарен доктору Руперту Кроссу и г-ну П. Ф. Стросону, которые ознакомились с текстом и высказали ценные замечания.

Г. Л. А. Харт

ГЛАВА ПЕРВАЯ

НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ

1. ЗАТРУДНЕНИЯ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ

Не многие вопросы, касающиеся человеческого общества, задавались с такой настойчивостью, а серьезные мыслители отвечали на них столь различными, странными и даже парадоксальными способами, как это происходило с вопросом «Что есть право?» \ Даже если мы ограничим наше внимание правовой теорией последних 250 лет и не будем рассматривать классические и средневековые спекуляции о «природе» права, мы обнаружим ситуацию, не имеющую аналогов ни в каком другом предмете, систематически изучаемом как отдельная академическая дисциплина. Не существует обширной литературы по вопросам «Что такое химия?» или «Что такое медицина?», как это происходит с вопросом «Что есть право?» Несколько строк на странице какого-нибудь элементарного учебника — вот все, что предлагается рассмотреть изучающему эти науки; и ответы, которые ему даются, очень сильно отличаются от тех, кото¬рые предлагаются студенту, изучающему право. Никто не считает прояс¬няющим дело или важным настаивать на том, что медицина — это «то, что доктора делают с болезнями», или «предсказание того, что сделают доктора»; или объявлять, что то, что обычно считается характерной и главной частью химии — скажем, изучение кислот — в действительности вовсе не является частью химии. Однако в случае права часто произноси¬лись вещи, столь же странные, на первый взгляд, что и эти, — и не толь¬ко произносились, но и защищались с такими красноречием и страстью, как если бы они являлись открытием истин о праве, долго скрываемых искажениями его сущностной (essential) природы.

«То, что должностные лица предпринимают относительно споров, есть... закон»[2]; «Пророчества о том, что сделают суды... являются тем,

[1] «What is law?» Английское слово «law» может в переводе на русский язык означать как «право» (в том числе и в обобщенном смысле, как дисциплину), так и «закон». Это об¬стоятельство создает дополнительную сложность при переводе англоязычных правовых текстов. Переводчикам, как и читателям, приходится ориентироваться по смыслу. — *Примеч. пер.*

[2] Llewllyn, *The Bramble Bush* (2nd edn., 1951), p. 9.

что я подразумеваю под правом» [1]; «Статуты являются источником Права..., но не частями самого Права» [2]; «Конституционное право есть всего лишь позитивная мораль» [3]; «Не укради; если кто-то крадет — он будет наказан... Первая норма, если она вообще существует, содержится во второй, которая и является единственно подлинной нормой... Закон есть первичная норма, которая стипулирует санкции» [4].

Это лишь некоторые из множества утверждений или отрицаний, касающихся природы права, которые, на первый взгляд, выглядят странными и парадоксальными [1]. Некоторые из них, по-видимому, вступают в конфликт с наиболее прочно укорененными убеждениями и кажутся легко опровержимыми; так что возникает искушение ответить: «Конечно, статуты *являются* правом, по крайней мере одним из видов права, даже если существуют другие», «Конечно, закон не может означать просто то, что делают должностные лица или сделают суды, так как нужен закон, чтобы назначить должностное лицо или суд».

Несмотря на это, кажущиеся парадоксальными фразы не были произнесены визионерами или философами, профессионально занимающимися тем, чтобы подвергать сомнению наиболее ясные порождения (deliverances) здравого смысла. Эти фразы являются результатом длительных размышлений над правом профессиональных юристов, занимающихся тем, чтобы учить праву или практиковать его, и в некоторых случаях исполнять закон в качестве судей. Более того, сказанное ими о праве в действительности улучшило наше понимание права в свое время и в своем месте. Ибо, понятые в соответствующем контексте, такие положения *одновременно* и проясняют, и обескураживают: они гораздо более похожи на огромные преувеличения некоторых — незаслуженно забытых — истин о праве, нежели на трезвые определения. Они бросают свет, который позволяет видеть многое из того, что было скрыто в праве; но этот свет настолько ярок, что ослепляет нас в отношении всего остального и, тем самым, так и не дает нам ясно увидеть целое.

В противоположность этим нескончаемым книжным дебатам мы находим, что большинство людей способны привести, с легкостью и уверенностью, примеры закона, когда их просят сделать это. Лишь немногие англичане не знают о том, что существует закон, запрещающий убийство, или требующий уплаты налогов, или определяющий, что должно быть сделано, чтобы составить действительное завещание. Практически каждый, за исключением ребенка или иностранца, впервые сталкиваю-

[1] O.W. Holmes, "The Path of the Law" in *Collected Papers* (1920), p. 173.
[2] J. G. Gray, *The Nature and Sources of the Law* (1902), p. 276.
[3] Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (1832), Lecture VT (1954 edn., p. 259).
[4] Kelsen, *General Theory of Law and State* (1949), p. 61.

щегося с английским словом «law», легко смог бы умножить подобные примеры, а большинство людей могло бы сделать и нечто большее. Они могли бы описать, по крайней мере в общих чертах (in outline), процедуру, позволяющую обнаружить, является ли нечто законом в Англии; они знают, что существуют эксперты для консультаций и суды с окончательным авторитетным голосом по всем таким вопросам. Общеизвестным является гораздо большее, нежели это. Большинство образованных людей имеют понятие о том, что законы в Англии формируют некоего рода систему и что во Франции или Соединенных Штатах, Советской России и в действительности почти в каждой части мира, которая считается отдельной «страной», существуют правовые системы, в значительной степени сходные по своей структуре, несмотря на важные различия. Действительно, образование допустило бы серьезный огрех, если бы оставило людей в неведении относительно этих фактов, — и если бы всякий, кто знает их, смог бы сказать, каковы эти важные пункты сходства между различными правовыми системами, мы едва ли назвали бы это признаком чрезмерной утонченности. Можно ожидать, что любой образованный человек способен идентифицировать эти бросающиеся в глаза свойства хотя бы таким схематическим образом, как это сделано ниже. Они заключают в себя: (i) правила, запрещающие или предписывающие определенные типы поведения под страхом наказания; (ii) правила, требующие, чтобы люди определенным образом компенсировали ущерб тем, кому они нанесли его; (iii) правила, специфицирующие, что должно быть сделано, чтобы составить завещание, заключить контракт или другие соглашения, которые дают права или создают обязательства; (iv) суды, которые определяют, что является правилом, и ситуации, когда это правило нарушено, — и устанавливают наказание или компенсацию, которую следует возместить; (v) законодательный орган, для создания новых правила и отмены старых.

Если все это общеизвестно, то почему же вопрос «Что есть право?» продолжает фигурировать и на него было дано так много разнообразных и экстраординарных ответов? Потому ли, что помимо ясных стандартных случаев, представляемых правовыми системами современных государств, относительно которых никто не сомневается, что они являются правовыми системами, — существуют также и сомнительные случаи, и относительно их «правового качества» колеблется не только обычный образованный человек, но даже и юристы? Примитивное право и международное право в первую очередь являются такими сомнительными случаями, и общеизвестно, что многие находят причины, хотя обычно и не решающие, для того, чтобы отрицать уместность принятого ныне использования слов «право» и «закон» («law») в этих случаях. Существование этих спорных и уязвимых для критики случаев

действительно вызвало длительную и отчасти бесплодную полемику, но они, конечно, не могут объяснить затруднения, касающиеся общей природы права, которые выражены насущным вопросом «Что есть право?» То, что они не могут лежать в корне этих затруднений, как представляется, ясно по двум причинам.

Во-первых, совершенно очевидно, почему в этих случаях чувствуются колебания. Международное право не имеет законодательного органа; государства не могут быть привлечены к суду без их предварительного на то согласия, и не существует централизованной эффективной системы санкций. Определенные типы примитивного права, включая те, из которых постепенно развились некоторые современные правовые системы, также не имеют этих черт, и каждому совершенно ясно, что это их отклонение относительно стандартного случая и является тем, в результате чего их классификация становится спорной. В этом нет никакой тайны.

Во-вторых, то, что нам приходится признавать и чистые случаи, и сомнительные пограничные случаи, не является исключительной особенностью сложных терминов типа «закон» и «правовая система». Теперь известным фактом (хотя на нем когда-то слишком мало заостряли внимание) является то, что это различение должно быть сделано в случае почти всех общих терминов, которые мы используем в классификации свойств человеческой жизни и мира, в котором мы живем. Иногда разница между чистым, стандартным случаем, или образцом использования выражения, и спорными вопросами заключается лишь в количестве. Человек с сияющей гладкой головой определенно лыс; другой, с роскошной шевелюрой, — определенно нет; однако, вопрос о том, является ли третий человек, с клочками волос то тут, то там лысым, мог бы обсуждаться бесконечно, если бы его сочли стоящим того или если бы сюда вмешался какой-нибудь практический интерес.

Иногда отклонение от стандартного случая заключается не просто в количественном различии, но возникает, когда стандартный случай является в действительности комплексом обычно сопутствующих друг другу, но различных элементов, из которых один или несколько могут отсутствовать в спорных случаях, вызывающих сомнение. Является ли гидроплан «судном»? Если игра ведется без ферзя — остается ли она шахматами? Такие вопросы могут быть поучительными, поскольку они побуждают нас размышлять и делать эксплицитным наше понятие о содержании стандартного случая; но ясно, что различные пограничные случаи слишком распространены во всех областях, чтобы объяснить при их помощи эти продолжительные дебаты о праве. Более того, лишь относительно малая и неважная часть наиболее знаменитых и противоположных друг другу теорий права касается уместности использования выра-

жений «примитивное право» и «международное право» для описания случаев, в которых они, как это принято, применяются [2].

Заметив, что почти все люди способны распознать и привести пример законов, поняв, насколько многое является общеизвестным в стандартном случае правовой системы, мы, казалось бы, с легкостью могли бы положить конец дискуссиям и дать окончательный ответ на насущный вопрос «Что есть право?», просто указав сделав ряд напоминаний о том, что нам уже знакомо. Почему мы просто не повторим схематическое описание черт, присущих внутригосударственной правовой системе, которое мы вложили, возможно слишком оптимистично, в уста образованного человека страницей выше? Тогда мы могли бы просто сказать: «Это является стандартным случаем того, что имеется в виду под 'законом' и 'правовой системой'; запомните, что кроме этих случаев вы найдете также механизмы в социальной жизни, которые, разделяя некоторые из этих явных черт, не имеют некоторых других из них. Это — спорные случаи, где не может существовать никакого решающего аргумента за или против того, чтобы классифицировать их как закон».

Конечно же, такое решение вопроса было бы удобным образом кратким. Но оно не имело бы никаких других достоинств, говорящих в его пользу. Ибо, в первую очередь, ясно, что те, кто наиболее озабочен вопросом «Что есть право?», не забыли и не нуждаются в том, чтобы им напомнили об известных фактах, которые этот схематический ответ предлагает им. То глубокое замешательство, которое сохраняет актуальным этот вопрос, не состоит в игнорировании, или забывчивости, или неспособности признать феномены, к которым слово «право» обычно относится. Более того, если мы рассмотрим термины в нашем схематическом описании правовой системы, станет ясным, что оно делает немногим больше, чем утверждает, что в стандартном, нормальном случае законы различного типа не различаются (go together). Это так, поскольку и суды, и законодательство, которые появляются в этом кратком описании как типичные элементы стандартной правовой системы, сами являются порождениями права. Только после того как определенные типы законов предоставляют людям юрисдикцию в определенной области и дают им право создавать законы, возникают суд и законодательство.

Простой путь в решении вопроса, который делает немногим больше, чем напоминает вопрошающему о существующих конвенциях, управляющих использованием слов «закон» и «правовая система», является, таким образом, бесполезным. Ясно, что наилучший метод — это отложить ответ на вопрос «Что такое закон?» до тех пор, пока мы не найдем, что такое есть в законах, что на самом деле запутывало тех, кто отвечал или пытался ответить на него, даже если их знакомство с

правом и их способность понимать отдельные примеры находятся вне сомнения. Что еще хотят они знать, и почему они хотят знать это? На *этот* вопрос может быть дано нечто вроде общего ответа. Ибо существуют определенные вновь и вновь возникающие основные темы, которые составляют постоянный фокус аргументации и контраргументации относительно природы закона, и которые вызывали и вызывают преувеличенные и парадоксальные утверждения о праве, подобные тем, что мы уже приводили. Спекуляции о природе права имеют долгую и сложную историю; несмотря на это, в ретроспективе видно, что они практически постоянно фокусируются на нескольких принципиальных проблемах. Они не были выбраны или изобретены специально для наслаждения академическими дискуссиями, но касаются тех аспектов права, которые, по-видимому, естественно вызывали во все времена недоразумения; так что замешательство и, как следствие, потребность в достижении большей ясности относительно них может сосуществовать даже в умах глубокомысленных людей, обладающих знанием права и мастерски его применяющих.

2. ТРИ ПОСТОЯННО ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Сформулируем теперь три таких принципиальных вновь и вновь возникающих вопроса и покажем позже, почему они возникают вместе в форме требования дать *определение* права или ответ на вопрос: «Что такое право?», или в более туманно сформулированных вопросах, вроде таких, как: «В чем заключается природа (или сущность) права?».

Две из этих проблем возникают следующим образом. Наиболее важной общей чертой права везде и во все времена являлось то, что его существование означает, что определенные типы человеческого поведения более не являются произвольными (optional), но в *некотором* смысле обязательными. И все же эта кажущаяся простой характеристика права в действительности не является простой, ибо внутри сферы непроизвольного обязательного поведения мы можем различить разные формы. Первый, простейший смысл, в котором поведение более не является произвольным, — это когда человека принуждают делать то, что другие говорят ему, не потому, что его физически заставляют в том смысле, что его тело толкают или тянут, а потому, что другие угрожают ему неприятными последствиями, если он откажется. Вооруженный человек приказывает своей жертве отдать кошелек, угрожая выстрелить в случае отказа; если жертва соглашается, мы указываем на способ, которым его заставили сделать это, говоря, что он был *должен* это сделать. Для некоторых, по-видимому, ясно, что в этой ситуации, где одно лицо

дает другому приказ, подкрепленный угрозой и, — в этом смысле слов «обязывать» обязывает его подчиняться, — мы имеем сущность закона, или, по крайней мере, «ключ к науке юриспруденции» \ Этот исходный пункт анализа Остина оказал весьма сильное влияние на английскую юриспруденцию [3].

Кажется, нет никакого сомнения в том, что в правовой системе среди прочих аспектов часто присутствует и этот. Для уголовного статута, объявляющего некоторое поведение преступлением и определяющего наказание, которому надлежит предать преступника, сравнение с вооруженным человеком может оказаться вполне адекватным, и единственное отличие, которое можно считать второстепенным, состоит в том, что в случае статутов приказы адресованы в основном группам, которые обычно подчиняются таким приказам. Однако сколь бы привлекательным ни казалось это сведение сложного феномена закона к такому простому элементу — если исследовать его более детально — оно оказывается искажением и источником путаницы даже в случае уголовного статута, где анализ в этих простых терминах кажется наиболее правдоподобным. Как тогда закон и правовое принуждение отличаются от приказов, подкрепленных угрозами, и как они соотносятся с ними? Во все времена такой была первая важнейшая проблема, скрывающаяся в вопросе: «Что есть право?».

Вторая проблема возникает из второго способа сделать поведение не произвольным, а обязательным. Моральные правила накладывают обязательства и изымают некоторые области поведения из сферы свободного выбора индивида делать то, что он хочет. Так же, как правовая система с очевидностью содержит элементы, тесно связанные с простыми случаями приказов, подкрепленных угрозами, — ровно так она с очевидностью содержит и элементы, тесно связанные с определенными аспектами нравственности. В обоих случаях одинаково присутствует трудность в точном установлении родства и соблазн увидеть в наглядном близком сходстве тождество. Право и мораль не только имеют общий словарь, так, что существуют и правовые и моральные обязательства, обязанности и права; но и все внутригосударственные (municipal) правовые системы воспроизводят сущность (substance) некоторых фундаментальных моральных требований. Убийство и беспричинное использование насилия — лишь наиболее очевидные примеры совпадения между запрещениями права и морали. Кроме этого, существует понятие о справедливости, которое, по-видимому, объединяет обе области: это и добродетель, особо подходящая закону, и наиболее правовая из добродетелей. Мы ду-

[1] Austin, op. cit, Lecture I, p. 13. Он добавляет: «. ..и к морали».

маем и говорим о «справедливости *в соответствии с* законом», но также о справедливости или несправедливости *самих* законов.

Эти факты предлагают тот взгляд, что закон лучше всего понимать как «ветвь» нравственности или справедливости и что его соответствие (congruence) принципам нравственности или справедливости является его «сущностью» скорее, нежели то, что он содержит в себе приказы и угрозы. Эта доктрина характерна не только для схоластических теорий естественного права, но и для некоторых современных правовых теорий, критически настроенных к правовому «позитивизму», унаследованному от Остина. И снова — те теории, которые настаивают на близком уподоблении права морали, как представляется, в конечном итоге смешивают один тип обязательного поведения с другим и оставляют недостаточно места для различий между правовыми и моральными правилами и для расхождений в их требованиях. Они, по крайней мере, столь же важны, как сходства и совпадения, которые мы также можем найти. Таким образом, утверждение, что «несправедливый закон не есть закон» [1], в той же степени преувеличено и парадоксально, если не ложно, что и «статуты не являются законами» или «конституционное право не является частью законодательства» (constitutional law is not law). Для этих колебаний между крайностями, которые являются движущей силой правовой теории, характерно, что те, кто не увидел в близком сходстве права и морали ничего, кроме ошибочного вывода из того факта, что право и мораль имеют общий словарь прав и обязанностей, должны были выступать против этого в терминах в равной мере преувеличенных и парадоксальных. «Пророчества о том, что сделают суды в действительности, а не что-либо более претенциозное, — вот что я понимаю под правом» [2] [4].

Третья основная проблема, в течение многих лет побуждавшая задавать вопрос «Что есть право?», имеет более общий характер. На первый взгляд может показаться, что положение о том, что правовая система состоит — во всяком случае в общем — из *правил,* едва ли может быть подвергнуто сомнению или оказаться трудным для понимания. И те, кто нашел ключ к пониманию закона в понятии приказов, подкрепленных угрозами, и те, кто обнаружил его в связи права и нравственности, или справедливости, — сходным образом говорят о праве как содержащем правила, если не состоящем преимущественно из них. Несмотря на это, неудовлетворение, замешательство и неопределенность, касающиеся этого кажущегося непроблематичным понятия, во многом лежат в основании затруднения, связанного с природой права. Что *суть* правила? Что

[1] «Non videtur esse lex quae justa non fuerit»: St. Augustine I, *De Libero Arbitrio,* 5; Aquinas, *Summa Theologica,* Qu. XCV, Arts. 2, 4.

[2] Holmes, loc. cit.

означает сказать, что они *существуют?*. Действительно ли суды применяют правила или просто притворяются, что делают это? Как только понятие оказалось под сомнением, как это случилось в юриспруденции в этом веке, — сразу же появились большие расхождения во мнениях. Мы их здесь просто обозначим.

Истинным, конечно, является то, что существуют правила многих различных типов, — не только в том очевидном смысле, что кроме правовых правил существуют правила этикета и языка, правила игр и клубов, — но и в том менее очевидном смысле, что даже внутри любой из этих сфер то, что называется правилами, может иметь разное происхождение и может очень по-разному соотноситься с поведением, которого они касаются. Таким образом, даже внутри права некоторые правила произведены законодательством; другие не порождены каким-либо таким намеренным действием. Что более важно — некоторые правила являются обязательными в том смысле, что требуют, чтобы люди вели себя определенным образом, например воздерживались от насилия или платили налоги, желают они того или нет; другие правила, предписывающие процедуры, формальности и условия для заключения браков, составления завещаний, контрактов, — указывают, что людям следует делать, чтобы дать законный ход тому, чего они желают. Тот же контраст, что виден между двумя этими типами правил, можно также заметить и между теми правилами игры, которые запрещают определенные типы поведения под страхом наказания (грубая игра или оскорбление судьи), и теми, которые определяют, что должно быть сделано, чтобы увеличить счет или выиграть. Но даже если мы пренебрежем на мгновение этой сложностью и рассмотрим лишь первый тип правил (которые характерны для уголовного права), мы обнаружим, даже у современных авторов, широчайшие расхождения во взглядах относительно значения утверждения, что правила такого простого обязательного типа существуют. Некоторые действительно находят это понятие совершенно таинственным.

То описание, которое мы сначала, возможно, естественным образом, испытывали искушение дать обманчиво простой идее обязательного правила, вскоре придется оставить. Согласно ему, сказать, что правило существует, означает лишь, что группа людей, или большинство из них, ведут себя «как правило» — то есть *обычно* (generally), определенным схожим образом при некоторых обстоятельствах. Таким образом, сказать, что в Англии существует правило о том, что мужчина не должен находиться в шляпе в церкви, или что он должен вставать, когда играют «Боже, храни королеву», означает, при таком описании ситуации, всего лишь то, что большинство людей обычно это делают. Ясно, что этого недостаточно, даже если это и выражает часть того, что имеется в виду.

Простая согласованность в поведении между членами общественной группы может существовать (все могут регулярно пить чай за завтраком или каждую неделю посещать кинотеатр), и несмотря на это, может не существовать правила, *требующего* этого. Разница между двумя социальными ситуациями простого совпадающего поведения и существования социального правила часто являет себя в языке. Описывая последнее, мы можем, хотя это и не необходимо, использовать определенные слова, которые вводили бы в заблуждение, если бы мы намеревались лишь утверждать первое. Эти слова— «должен» («must»), «следует» («should») и «обязан» («ought to»), которые, несмотря на свое различие, разделяют определенные общие функции, указывая на присутствие правила, требующего определенного поведения. В Англии не существует правила — да ситуация и не такова, — что каждый должен (must), или обязан (ougth to), или ему следует (should) ходить в кинотеатр каждую неделю: просто истинным является то, что регулярное посещение кинотеатра каждую неделю довольно распространено. Однако *есть* правило, что мужчина должен обнажать голову в церкви.

В чем тогда ключевое различие между просто совпадающим привычным поведением в социальной группе и существованием правила, знаками которого часто являются слова «должен», «следует» и «обязан»? В этом вопросе теоретики права действительно разделились, особенно в новейшее время, когда несколько обстоятельств выдвинули эту проблему на первый план. В случае правовых правил, очень часто говорится (held), что ключевое различие (элемент «долженствования» и «обязанности») состоит в том, что отклонение от определенных типов поведения, вероятно, встретит враждебную реакцию, и в случае правовых правил оно будет наказано должностными лицами. В случае того, что может быть названо просто групповыми привычками, вроде еженедельного похода в кинотеатр, отклонения не встречаются наказанием или даже порицанием; но где бы ни существовали правила, требующие определенного поведения, — даже неправовые правила, наподобие того, что требует от мужчин обнажать голову в церкви, — результатом отклонения обычно является нечто вроде этого. В случае правовых правил эти предсказуемые последствия определены и официально организуются, в случае же неправовых правил, хотя и возможна подобная враждебная реакция на отклонения, она не организована и не определена по своему характеру.

Очевидно, что предсказуемость наказания является одним из важных аспектов правовых правил; но невозможно принять это как исчерпывающее описание того, что имеется в виду под положением, что социальное правило существует, или того, что элемент долженствования и обязательности включен в правила. Можно сформулировать множество возражений против такого предсказательного истолкования, но одно,

которое характеризует целую школу правовой теории в Скандинавии, заслуживает внимательного рассмотрения. Оно заключается в том, что если мы внимательно посмотрим на деятельность судьи или должностного лица, которое наказывает за отклонения от правовых правил (или деятельность тех частных лиц, которые выказывают осуждение или критикуют за отклонения от неправовых правил), мы увидим, что правила заключены в этой деятельности таким способом, который совершенно не объясняется этим предсказательным истолкованием. Ибо судья, вынося приговор, принимает правило в качестве *руководства,* а нарушение правила рассматривается им в качестве *основания* и *оправдания* того, что нарушитель наказывается. Он не смотрит на правило как на положение о том, что он и другие, вероятно, накажут за отклонения, хотя наблюдатель и может смотреть на правило именно таким образом. Предсказательный аспект правила (хотя и достаточно реальный) иррелевантен его (судьи) целям, в то время как статус правила как руководства и как оправдания существенен. Это же является истинным и для неформальных упреков, делаемых при нарушении неправовых правил. Они тоже являются не просто предсказуемыми реакциями на отклонения, а чем-то, руководствующимся и оправдываемым существованием правила. Так, мы говорим, что делаем выговор или наказываем человека, *потому что* он нарушил правило, а не просто, что было вероятным, что мы наказали бы его или сделали бы ему выговор [5].

Несмотря на это, некоторые из критиков, которые настаивают на этих возражениях предсказательному описанию, признают, что здесь присутствует нечто неясное, что-то, не поддающееся анализу в чистых, четких, фактических понятиях. Что может присутствовать в правиле, кроме регулярного и, следовательно, предсказуемого наказания или упрека тем, кто отклоняется от обычных моделей поведения, — отличающего его от просто групповой привычки? Может ли действительно быть что-то сверх этих ясных устанавливаемых фактов, некоторый дополнительный элемент, который руководит судьей и оправдывает или дает ему основание для наказания? Сложность выяснения того, чем именно является этот особый элемент, привела критиков предсказательной теории к тому, чтобы настаивать в этом пункте на том, что все разговоры о правилах, а соответствующее использование слов вроде «должен», «следует» и «обязан» преисполнено путаницы, которая, возможно, повышает их важность в глазах людей, но не имеет никакой рациональной основы. Мы просто *думаем,* как заявляют такие критики, что существует нечто в правиле, что заставляет нас совершать определенные вещи и руководит нами или оправдывает нас в их совершении, но это нечто является иллюзией, пусть даже и полезной. Все, что существует сверх установленных фактов группового поведения и предсказуемой реакции на отклонения, —

это наши собственные сильные «ощущения» (feelings) принуждения вести себя в соответствии с правилом и действовать против тех, кто не ведет себя соответствующим образом. Мы не признаем эти ощущения за то, чем они являются, а воображаем, что существует нечто внешнее, некая невидимая часть устройства универсума, руководящая и контролирующая нас в этих действиях. Мы здесь находимся в сфере фикции, с которой, как говорят, право всегда было связано. Лишь поскольку мы принимаем эту фикцию, мы можем говорить торжественно о правлении «законов, не людей». Этот тип критики, сколь бы ни было похвальным ее позитивное содержание, по меньшей мере взывает к дальнейшему прояснению различия между социальными правилами и просто совпадающими привычками поведения. Это различие является ключевым в понимании права, и большинство начальных глав этой книги связано с ним.

Скептицизм относительно характера правовых правил не всегда, однако, принимал крайние формы осуждения простого понятия обязывающего правила как запутанного и фиктивного [6]. Вместо этого превалирующая форма скептицизма в Англии и Соединенных Штатах призывает нас пересмотреть тот взгляд, что правовая система *всецело,* или хотя бы *в первую очередь,* состоит из правил. Вне сомнения, суды так оформляют свои решения, чтобы сложилось впечатление, что их решения являются необходимыми следствиями предопределенных правил, смысл которых фиксирован и ясен. В очень простых случаях это может быть так, но в подавляющем большинстве случаев, которые представляют проблему (trouble) для судов, ни статуты, ни прецеденты, в которых правила, как утверждается, содержатся, не позволяют достичь одного определенного результата. В большинстве важных случаев всегда присутствует выбор. Судье приходится выбирать между альтернативными значениями, которые необходимо придать словам статута, или между конкурирующими интерпретациями того, к чему сводится (amounts to) прецедент. Это лишь традиция — считать, что судьи «находят», а не «производят» закон, которая скрывает это и представляет их решения, как если бы они были заключениями, легко сделанными из ясных, уже существующих правил, без вмешательства судейского выбора. Правовые правила могут иметь центральное ядро необсуждаемого смысла, и в некоторых случаях, возможно, трудно бывает вообразить, как может разразиться спор о смысле правила. Положения ст. 9 акта о завещаниях 1837 г. о том, что должны быть два свидетеля завещания, как кажется, не может обычно вызывать проблем интерпретации. Несмотря на это, все правила имеют оттенок неопределенности, когда судья должен выбирать между альтернативами. Даже смысл кажущегося невинным положения акта о завещаниях о том, что завещатель должен *подписать* завещание, может

оказаться вызывающим сомнения в определенных обстоятельствах. Что, если завещатель использовал псевдоним? Или если его рукой водил кто-то другой? Или если он написал только инициалы? Или если он поставил свое полное правильное имя самостоятельно, но в начале первой страницы, а не в конце последней? Являлись бы все эти случаи «подписью» в смысле, указанном правовым правилом?

Если так много неопределенности может вдруг появиться в скромных сферах частного права, насколько больше мы найдем ее в высокопарных фразах конституции, таких, как пятая и четырнадцатая поправки к Конституции Соединенных Штатов, говорящих, что ни одно лицо не будет «лишено жизни, свободы или собственности без должного законного процесса (due process of law)»? Об этом один автор сказал[1], что истинный смысл этой фразы в действительности совершенно ясен. Это означает, что «ни один *w* не будет *x* или *y* без *z,* где *w, x,y,uz* могут принимать любые значения в широком диапазоне». Напоследок скептики напоминают нам, что не только правила неопределенны, но и интерпретации их судами могут быть не только авторитетными, но и окончательными. В свете всего этого, не является ли понятие закона как, по существу, содержания правил большим преувеличением, если не ошибкой? Такие мысли приводили к парадоксальному отрицанию, которое мы уже цитировали: «Статуты — источники права, но не само право»[1].

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Следовательно, существует три постоянно возникающих вопроса: Чем право отличается от приказов, подкрепленных угрозами, и как оно связано с ними? Чем правовая обязанность отличается от моральной и как связана с ней? Что такое правила и в какой степени право есть дело правил (affair of rules)? Основной целью большинства размышлений о «природе» права было — развеять сомнения и затруднения по этим трем вопросам. Ныне можно видеть, почему эти размышления предпринимались обычно как поиск определения права, а также почему, по крайней мере известные формы определений, сделали так мало для разрешения насущных трудностей и сомнений. Определение, как предполагает это слово, — это, в первую очередь, вопрос проведения границ или различения между одним типом вещей и другим, что язык фиксирует отдельным словом. Необходимость в таком проведении границ ощущается только теми, кто в совершенстве использует в повседневной речи обсуждаемое

[1] J. D. March, "Sociological Jurisprudence Revisited", 8 *Stanford Law Review* (1956), p. 518.

[2] Grag, loc. cit.

слово, но не может установить или объяснить различия, которые, как они чувствуют, отделяют один тип вещей от другого. Все мы иногда попадаем в такое положение. В полной мере это относится к человеку, который говорит: «Я могу опознать слона, когда вижу его, но не могу дать ему определения». Та же самая ситуация была выражена знаменитыми словами св. Августина[1] о понятии времени. «Что тогда есть время? Если никто не спрашивает меня, я знаю; если же я пытаюсь объяснить это, когда меня спрашивают, — я не знаю». Таким же образом, даже опытные юристы ощущают, что хотя они знают право, существует масса всего в праве и в его отношениях к другим вещам, чего они не могут объяснить и не вполне понимают. Подобно человеку, который может из одной точки знакомого города попасть в другую, но не может объяснить или показать другим, как сделать это, тем, кто настаивает на определении, нужна карта, ясно показывающая отношения, которые, как они смутно чувствуют, существуют между законом, который они знают, и другими вещами.

Иногда в таких случаях определение слова может предоставить подобную карту: в одно и то же время оно может эксплицировать скрытый принцип, который руководит нами в использовании слова, и может обнажить отношения между тем типом феноменов, к которым мы применяем слово, и другими феноменами. Иногда говорится, что определение «просто словесное» или «просто о словах» («merely verbal* or «just about words»); но более всего может вводить в заблуждение, когда определяется выражение, постоянно используемое. Даже определение треугольника как «трехсторонней прямолинейной фигуры» или определение слона как «четвероногого, отличающегося от других тем, что оно имеет толстую кожу, клыки и хобот», скромно указывает нам на стандартное использование слов и на вещи, к которым эти слова применяются. Определение такого известного типа делает сразу две вещи. Оно одновременно предоставляет код, или формулу, переводящую слово в другие, хорошо понимаемые термины, и выделяет для нас тип вещей, для обозначения которых используется это слово, указывая на те черты, которые оно, в общем, разделяет с широким семейством вещей, и на те, которые выделяют его среди других, принадлежащих к тому же семейству. Ища и находя такие определения, мы «смотрим не просто на слова... но также и на те реалии, для разговора о которых мы используем слова. Мы используем обостренное знание слов для того, чтобы заострить наше восприятие явлений» [1].

[1] Исповедь, XIV. 17.

[2] J.L. Austin, "A Plea for Excuses", Proceedings of Aristotelian Society, vol. 57 (1956-1957), p. 8.

Эта форма определения *(per genus et differentiam),* которую мы видим в простом случае треугольника или слона, является простейшей и наиболее удовлетворительной для некоторых, поскольку дает нам форму слов, которой можно всегда заменить определяемое слово. Но определение не всегда можно дать, а если можно — то оно не всегда проясняет дело. Его успех зависит от условий, которые не всегда выполняются. Главное из них заключается в том, что должно быть более широкое семейство вещей, или *род,* характер которых нам ясен, и внутри которого определение выделяет то, что оно определяет; ибо ясно, что определение, которое говорит нам, что нечто является членом семейства, не может помочь нам, если у нас есть лишь смутное ли запутанное представление о характере семейства. Именно это требование в случае права делает эту форму определения бесполезной, ибо здесь нет известной, хорошо понимаемой общей категории, членом которой является закон. Наиболее очевидный кандидат, на использование таким образом в определении закона, — это общее семейство *правил поведения;* но, понятие правила, как мы уже видели, вызывает столько же затруднений, сколько и понятие самого закона, так что определения закона, которые начинают с того, что называют законы видами правил, обычно нисколько не продвигают наше понимание закона. Для этого требуется нечто более фундаментальное, нежели эта форма определения, которая успешно используется для выделения некоторого особого, подчиненного типа внутри некоторого известного, хорошо понимаемого общего типа вещей [7].

Существуют, однако, и другие существенные препятствия, мешающие эффективно использовать эту простую форму определения в случае права. Предположение, что общее выражение может быть определено этим путем, покоится на негласном допущении, что все примеры того, что надлежит определить как «треугольники» и «слоны», имеют общие характеристики, которые обозначаются определяемым выражением. Конечно, даже на относительно элементарном этапе существование пограничных случаев бросается в глаза, и это демонстрирует, что допущение, согласно которому несколько примеров общего термина должны иметь общие характеристики, может быть догматическим. Очень часто обыденное или даже техническое использование термина совершенно «открыто» в том, что оно не *запрещает* распространения термина на случаи, когда присутствуют лишь некоторые из обычно сопутствующих признаков. Это, как мы уже видели, истинно для международного права и определенных форм примитивного права, так что всегда можно правдоподобно аргументировать за и против такого расширения терминов. Что более важно — это что отдельно от таких пограничных случаев некоторые примеры общего понятия часто связаны друг с другом путями, совершенно отличными от постулируемых простой формой определения.

Они могут быть связаны по аналогии, когда мы говорим о «ноге» («foot») человека и о «подножии» («foot») горы. Они могут быть связаны *различными* отношениями с центральным элементом. Такой унифицирующий принцип виден в применении слова «здоровый» не только к человеку, но и к его комплекции и к его утренним упражнениям; при этом второе — это *знак,* а третье — *причина* его первой центральной характеристики. Или снова — и здесь, возможно, мы имеем принцип, схожий с тем, который унифицирует различные типы правил, которые составляют правовую систему, — несколько примеров могут быть различными составляющими некоторой сложной деятельности. Использование прилагательного «железнодорожный» не по отношению к поезду, но также к путям, станции, носильщику и к товариществу с ограниченной ответственностью, управляется этим типом унифицирующего принципа [8].

Конечно, существует много других типов определений, помимо очень простой традиционной формы, которую мы обсудили, но, по-видимому, ясно, когда мы вспоминаем характер трех основных проблем, которые мы указали как лежащие в основании постоянно возникающего вопроса «Что есть право?», что ничто, достаточно четкое для того, чтобы быть признанным как определение, не могло бы дать удовлетворительного ответа на него. Лежащие в основании проблемы слишком отличны друг от друга и слишком фундаментальны, чтобы их можно было разрешить таким образом. История попыток дать четкие определения показала это. Несмотря на это, инстинкт, который часто подводил эти три вопроса вместе под один или искал определение, не был ошибочен; ибо, как мы покажем по ходу книги, имеется возможность изолировать и охарактеризовать центральный набор элементов, которые формируют общую часть ответа на все три вопроса. Что это за элементы и почему они заслуживают того, чтобы им было отведено важное место в этой книге, лучше всего станет ясно, если мы сначала рассмотрим подробно недостатки теории, которая так сильно повлияла на английскую юриспруденцию, с тех пор как Остин изложил ее. Это — утверждение, что ключ к пониманию закона следует искать в простом понятии приказа, подкрепленного угрозами, который сам Остин обозначил термином «команда». Исследование недостатков этой теории займет последующие три главы. Давая сначала ее критику и откладывая на дальнейшие главы этой книги рассмотрение ее главного конкурента, мы сознательно оставляем в стороне исторический порядок, в котором развивалась современная правовая теория, ибо соперничающее утверждение, что право лучше всего понимается в его «необходимой» связи с нравственностью, — это более старая доктрина, которую Остин, как и Бентам до него, рассматривал в качестве основного объекта критики. Нашим оправданием этого неисторического толкования, если оно необходимо, является то, что ошибки

простой императивной теории — лучший указатель истины, нежели ее более сложные соперники [9].

В различных местах этой книги читатель найдет рассмотрение пограничных случаев, когда теоретики права ощущали сомнения насчет применения выражения «право» или «правовая система», но предложенное разрешение этих сомнений, которое он также найдет здесь, — это лишь второстепенная задача этой книги. Ибо ее цель — не представить определение закона в смысле правила, ссылкой на которое корректность использования этого слова может быть проверена, — цель заключается в том, чтобы продвинуть вперед правовую теорию, предложив улучшенный анализ отличительной структуры внутригосударственной правовой системы и уяснив сходства и различия между правом, принуждением и нравственностью как типами социальных феноменов. Набор элементов, определяемых в ходе критического обсуждения в трех последующих главах и подробно описанных в главах 5 и 6, служит этой цели способами, указанными в конце книги. Именно по этой причине они трактуются как центральные элементы в понятии права и имеют первостепенное значение в его прояснении.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЗАКОНЫ, КОМАНДЫ И ПРИКАЗЫ

1. РАЗНОВИДНОСТИ ИМПЕРАТИВОВ

В наиболее чистом виде и наиболее полная попытка анализа понятия права в терминах простых, на первый взгляд, элементов — команды и привычки — была сделана Остином в «Province of Jurisprudence Determined*. В этой и последующих двух главах мы сформулируем и подвергнем критике ту позицию, которая, по сути, совпадает с доктриной Остина, но, возможно, отклоняется от нее в определенных моментах. Ибо наш принципиальный интерес касается не Остина, а достоинств определенного типа теории, привлекательность которой не ослабевает, каковы бы ни были ее недостатки. В тех случаях, когда смысл сказанного Остином сомнителен и его взгляды, по-видимому, непоследовательны, мы позволим себе отступать от его слов и сформулируем более ясную и последовательную позицию. Более того, там, где Остин лишь намекает на аргументы, которыми можно ответить на возражения критиков, мы их разовьем (частично в том направлении, которым следуют новейшие теоретики, такие как Кельзен) для того, чтобы рассматриваемая и критикуемая нами доктрина была представлена в своей сильнейшей форме [10].

Во многих различных ситуациях общественной жизни одно лицо может выразить желание, чтобы другое лицо сделало нечто или воздержалось от некоторого действия. Когда такое желание выражается не просто как интересная информации или сознательное самовыражение, но с намерением, чтобы лицо, к которому обращено пожелание, подчинилось выраженному желанию, — тогда в английском и многих других языках обычно, хоть и не с необходимостью, используется специальная языковая форма, называемая *повелительное наклонение:* «Ступай домой!», «Иди сюда!», «Стой!», «Не убивай его!» Социальные ситуации, в которых мы обращаемся к другим в императивной форме, чрезвычайно разнообразны; несмотря на это, они включают некоторые постоянно возникающие типы, важность которых выражается некоторыми известными классификациями [11].

«Передайте, пожалуйста, соль» обычно является просто *просьбой,* так как обыкновенно говорящий обращается к тому, кто может оказать ему

услугу, и не предполагается ни крайней безотлагательности, ни намека на то, что будет, если просьбу не выполнить. «Не убивай меня!» обычно произносится как *мольба,* когда говорящий зависит от милости того, к кому он обращается, или находится в затруднительном положении, из которого последний имеет власть его вызволить. «Не двигайся!», с другой стороны, может быть *предупреждением,* если говорящий знает о некоторой опасности (например, змея в траве), угрожающей тому, к кому обращено предупреждение, и которой еще можно избежать.

Разновидности социальной ситуации, в которой характерным, хоть и не неизменным, является использование императивных форм языка, — не только многочисленны, но и сливаются друг с другом; а термины вроде «мольба», «просьба» или «предупреждение» используются лишь для того, чтобы провести немногие грубые разграничения. Наиболее важной из этих ситуаций является та, в которой слово «повеление», по-видимому, наиболее приемлемо. Это то, что иллюстрируется случаем вооруженного грабителя, который говорит банковскому клерку: «Давай деньги или я буду стрелять». Отличительная черта этого случая, которая заставляет нас говорить о грабителе, *приказывающем,* а не просто *просящем,* и еще менее *умоляющем* клерка отдать деньги, — это то, что говорящий, чтобы обеспечить согласие с выражаемым им желанием, угрожает сделать нечто, что нормальный человек рассматривал бы как вредное и неприятное, и делает удержание денег намного менее возможным выбором поведения для клерка. Если грабитель добивается успеха, мы опишем его как *принудившего* клерка, а самого клерка — как находящегося в этом смысле во власти грабителя. Множество тонких лингвистических вопросов может возникнуть из этого случая: мы можем обоснованно сказать, что грабитель *приказал* клерку отдать деньги и клерк подчинился, но было бы некоторым заблуждением сказать, что грабитель *отдал приказ* клерку отдать их, так как это скорее по-военному звучащая фраза предполагает некоторое право или власть отдавать приказы, что отсутствует в нашем случае. Было бы, однако, совершенно естественным сказать, что грабитель отдал приказ своему сообщнику охранять дверь.

Нет необходимости вдаваться здесь в эти тонкости [12]. Хотя предположение о власти и уважении к власти часто может быть связано со словами «приказ» и «повиновение», мы будем использовать выражение «приказы, подкрепленные угрозами», и «принуждающие приказы» (coercive orders) для указания на приказы, которые, как приказы грабителя, поддерживаются только угрозами, и будем использовать слова «повиновение» и «повиноваться», подразумевая подчинение этим приказами. Однако важно заметить, хотя бы из-за огромного влияния, которое оказало на юристов Остиново определение понятия команды, что простая ситуация, когда лишь угрозы нанесения вреда и ничего более, ис-

пользуются для того, чтобы вызвать подчинение, *не* является ситуацией, когда мы естественно говорим о «командах». Это слово, которое не очень распространено вне военного контекста, передает своими весьма сильными импликациями, что существует относительно устойчивая иерархическая организация людей, такая, как армия или группа последователей, где командующий занимает позицию превосходства. Обычно это генерал (не сержант), который является командующим и отдает команды, хотя и другие формы превосходства описываются в этих же терминах, как, например, когда о Христе в Новом Завете говорится, что он командовал своими последователями. Более важен — ибо это ключевое различие между разными формами «императива» — тот момент, что в такой ситуации (когда отдается команда) нет нужды, чтобы обязательно присутствовала угроза вреда в случае неповиновения. Командовать обычно означает осуществлять власть над людьми, а не способность причинять ущерб, и хотя это может соединяться с угрозами вреда, команда в первую очередь является апелляцией не к страху, а к уважению к власти.

Очевидно, что понятие команды с ее очень крепкой связью с властью гораздо ближе к понятию закона, чем к приказу грабителя, подкрепленному угрозами, хотя последнее — пример того, что Остин, игнорируя различия, указанные в последнем абзаце, ошибочно называет командой. Команда, однако, слишком близка к закону для нашей цели; ибо элемент авторитета, содержащийся в законе, всегда был одной из помех на пути любого простого объяснения того, что такое закон. Следовательно, проясняя закон, мы не можем выгодно использовать понятие команды, которое также включает в себя этот элемент. Действительно, достоинством анализа Остина, каковы бы ни были его недостатки, является то, что элементы ситуации с грабителем, в отличие от элемента авторитета, не являются сами по себе неясными или нуждающимися в дальнейшем объяснении, и, следовательно, мы последуем за Остином в попытке выстроить из этого понятие закона. Мы не будем, однако, в отличие от Остина рассчитывать на успех, скорее надеясь извлечь урок из нашей ошибки [13].

2. ПРАВО КАК ПРИНУЖДАЮЩИЕ ПРИКАЗЫ

Даже в сложном большом обществе, таком как современное государство, возникают случаи, когда должностное лицо персонально приказывает индивиду сделать что-то. Полицейский приказывает конкретному водителю остановиться или конкретному нищему уйти. Но эти простые ситуации не являются и не могут являться стандартными способами функционирования закона хотя бы потому, что никакое общество не могло

бы содержать то количество должностных лиц, которое необходимо для того, чтобы обеспечить, чтобы каждый член этого общества был отдельно и официально информирован о каждом акте, совершение которого от него требуется. Вместо этого такие обособленные формы контроля либо применяются в исключительных случаях, либо являются вспомогательными сопровождениями или подкреплениями общих форм предписаний, а не обращены к отдельным индивидам, не именуют их и не указывают на отдельные действия, которые надлежит совершить. Следовательно, *стандартная* форма даже уголовного статута (который из всех разновидностей закона имеет наибольшее сходство с приказом, подкрепленным угрозами) является общей двояким образом; она указывает общий тип поведения и применяется к общему классу лиц, которые, как ожидается, видят, что она к ним применяется и им надлежит принять ее. Официальные персональные указания индивидам играют здесь второстепенную роль: если первичным общим указаниям не подчиняется отдельный индивид, должностные лица могут обратить его внимание на эти указания и потребовать соответствия им, как это делает налоговый инспектор. Иначе неподчинение может быть установлено и возникнет угроза наказания за него, которое накладывается судом.

Правовой контроль, следовательно, в первую очередь, хотя и не исключительно, есть контроль посредством указаний, которые в этом двояком смысле являются *общими.* Это первая черта, которую мы должны добавить к простой модели с грабителем, чтобы она воспроизводила для нас характеристики закона. Круг лиц, подверженных воздействию, и тот способ, которым этот круг указывается, могут изменяться в зависимости от различных правовых систем и даже в зависимости от различных законов. В современном государстве обычно понимается, что, в отсутствие особых обозначений, сужающих или расширяющих класс, его общие законы распространяются на все лица внутри территориальных границ этого государства. В каноническом праве присутствует сходное понимание того, что обычно все члены церкви находятся внутри области действия ее права, за исключением того случая, когда указывается более узкий класс. Во всех случаях сфера применения закона является вопросом интерпретации частного закона, где помогают такие общие понимания. Стоит здесь заметить, что хотя юристы, и Остин среди них, говорят иногда о законах, *обращенных*[1] к группам лиц, — это вводит в заблуждение, предполагая параллель ситуации «лицом - к — лицу», которая реально не существует и не имеется в виду теми, кто использует эти выражения. Приказ людям делать какие-то вещи — это форма коммуникации, и она действительно предполагает «обращение» к ним, то есть при-

[1] Adressed to the community at large", Austin, above, p. 1 n. 4 at p. 22.

влечение их внимания или принятие шагов, чтобы привлечь его, но принятие законов для людей этого не делает. Таким образом, грабитель одним и тем же выражением — «Давай эти банкноты» — выражает свое желание, чтобы клерк сделал нечто, и действительно *обращается* к клерку, то есть делает то, чего вполне достаточно для того, чтобы клерк обратил свое внимание на это выражение. Если бы грабитель не сделал последнего, а просто произнес те же слова в пустой комнате, он бы вообще не обратился к клерку и не *приказал* бы ему сделать что-либо, мы могли бы описать эту ситуацию как такую, где грабитель просто произнес слова: «Давай эти деньги». В этом отношении законотворчество отличается от приказания людям делать нечто, и мы должны принимать в расчет это отличие, используя эту простую идею в качестве модели права. Действительно, может оказаться желательным, чтобы законы, после того как они были приняты, как можно скорее были предложены вниманию тех, к кому они применяются. Цель законодателя при создании законов была бы не достигнута, если бы это обычно не делалось, и правовые системы часто обеспечивают это с помощью специальных правил, касающихся обнародования. Но законы могут быть полноценными законами и до того, как это сделано, и даже если это вовсе и не сделано. В отсутствие особых правил, предписывающих противоположное, законы являются валидно принятыми, даже если тем, кто подлежит их действию, приходится самостоятельно искать, какие законы были приняты и к кому они относятся. Что обычно имеется в виду теми, кто говорит о том, что законы «обращены» к определенным лицам, — так это то, что существуют лица, к которым отдельный закон применяется, то есть от кого он требует вести себя определенным образом. Если мы используем здесь слово «обращен», нам, может, не удастся заметить важную разницу между принятием закона и отдачей персонального приказа, а также мы можем спутать два различных вопроса: «К кому этот закон применяется?» и «Кому он был оглашен?»

Кроме введения свойства всеобщности, в ситуации грабителя мы должны сделать и более фундаментальное изменение, если нам необходимо иметь более правдоподобную ситуацию, в которой присутствует закон. Истинным является то, что в некотором смысле грабитель обладает контролем над клерком или властью над ним; это заключается в его временной способности сделать угрозу, которая вполне может быть достаточной для того, чтобы заставить клерка выполнить то конкретное дело, которые ему сказано сделать. Не существует никакой другой формы отношения превосходства и подчинения между двумя людьми, кроме этой кратковременной принудительной формы. Но для целей грабителя этого может быть достаточно, ибо простой приказ лицом к лицу «Давай эти деньги, или я буду стрелять» прекращает существование вместе с

этой ситуацией. Грабитель не отдает банковскому клерку (хотя он и может делать это в отношении банды своих соучастников) *постоянных приказов,* которым следуют время от времени те или иные группы лиц. Несмотря на это, законы преимущественно имеют эту «постоянную» или устойчивую характеристику. Следовательно, если мы используем это понятие приказов, подкрепленных угрозами, как объяснение того, что такое закон, мы должны попытаться воспроизвести этот продолжительный характер, который имеют законы.

Значит, мы должны предположить, что существует общая убежденность со стороны тех, к кому применяются общие приказы, в том, что за неподчинением, вероятно, последует приведение угроз в действие не только при первом оглашении приказа, но непрерывно до тех пор, пока приказ не будет отменен или аннулирован. Эта непрерывная убежденность в последствиях неподчинения, можно сказать, сохраняет исходные приказы живыми или устойчивыми, хотя, как мы увидим позже, существует трудность в анализе устойчивого характера законов в этих простых терминах. Конечно, совпадение многих факторов, которые невозможно воспроизвести в ситуации с грабителем, может в действительности требоваться для того, чтобы такая общая убежденность в вероятности претворения угроз в реальность существовала: может быть так, что власть исполнять угрозы, прилагаемая к таким постоянным приказам, может осуществляться в действительности и считаться существующей лишь тогда, когда было бы известно, что некоторое значительное количество населения готово и само подчиняться добровольно, то есть независимо от страха наказания, и содействовать исполнению наказания в отношении тех, кто не подчинился.

Каким бы ни было основание этой всеобщей убежденности в вероятности приведения угроз в исполнение, мы должны отличать от этого следующую необходимую черту, которую мы должны добавить к ситуации с грабителем, если хотим приблизить ее к установленной ситуации, в которой присутствует закон. Мы должны предположить, что, каковы бы ни были мотивы, большинству приказов большинство тех, к кому они обращены, чаще подчиняются, чем не подчиняются. Мы здесь назовем это, следуя Остину, «общей привычкой подчинения» и заметим, как и он, что, подобно многим другим аспектам права, это существенно расплывчатое и неточное понятие. Вопрос о том, какое количество людей и какому количеству приказов должно подчиняться и в течение какого времени, для того, чтобы имелось право, позволяет дать на него ответ не в большей степени, нежели вопрос о том, насколько мало волос должен иметь человек, чтобы быть лысым. Но в этом факте общего подчинения содержится ключевое различие между законами и исходным простым случаем с приказом грабителя. Простое временное господство одного

человека над другим естественно считается полярно противоположным закону с его относительно продолжительным и определенным характером, и, конечно, в большинстве правовых систем осуществить такую краткосрочную принудительную власть (какую, например, имеет грабитель) означало бы совершить уголовное преступление. Действительно, остается неочевидным, достаточно ли на самом деле этого простого, хотя и, по общему признанию, туманного, понятия общего привычного подчинения общим приказам, подкрепленным угрозами, для того чтобы воспроизвести определенный (settled) характер и непрерывность, которые имеет правовая система.

Понятие общих приказов, подкрепленных угрозой наказания, отдаваемых кем-то, кому обычно подчиняются, которое мы сконструировали путем последовательных добавлений к простой ситуации с грабителем, явно ближе всего подходит к уголовному статуту, установленному законодательством современного государства, чем к любой другой разновидности закона. Ибо существуют такие типы законов, которые на первый взгляд (prima facie) весьма отличаются от таких уголовных статутов, и нам придется позже рассмотреть утверждение, что эти другие разновидности закона также, вопреки тому что они по виду противоположны, в действительности суть лишь усложненные или закамуфлированные версии все той же формы. Но если нам надлежит воспроизвести черты даже уголовного статута в нашей сконструированной модели общих приказов, которым в основном подчиняются, необходимо сказать что-то большее о лице, которое отдает приказы. Правовая система современного государства характеризуется определенным типом *верховной власти (supremacy)* на своей территории и *независимостью* от других систем, которые мы еще не воспроизвели в своей простой модели. Эти два понятия не столь просты, как это может показаться, но то, что с точки зрения здравого смысла (который может оказаться неадекватным) присуще им, можно выразить следующим образом. Английское право, французское право и право любой современной страны регулирует поведение населения, которое занимает территорию со вполне определенными географическими границами. Внутри территории каждой страны может присутствовать множество разных лиц или органов, отдающих общие приказы, подкрепленные угрозами и обеспечивающие привычное подчинение. Но нам следует различать некоторые эти лица или органы (например LCC или министр, исполняющий то, что мы определяем как полномочия делегированного законодательства) — в качестве *подчиненных* законодателей в противоположность Королеве в парламенте, которая занимает верховную должность. Мы можем выразить это отношение в простой терминологии привычек, говоря, что, в то время как Королева в парламенте, законодательствуя, никому привычно не подчиняется, подчиненные зако-

нодатели держатся внутри границ, предписанных статутами, и таким образом, можно сказать, являются, производя законы, агентами Королевы в парламенте. Если бы они вели себя не так, значит, мы имели бы не одну систему права в Англии, а множество систем, в то время как в действительности, — поскольку Королева в парламенте занимает в этом смысле верховное положение по отношению ко всем на территории Англии, а остальные органы — нет, — мы имеем в Англии одну систему, в которой мы различаем иерархию верховных и подчиненных элементов.

Та же негативная характеристика Королевы в парламенте как *не* подчиняющейся по привычке приказам других грубо определяет понятие *независимости,* которое мы используем, говоря о независимых (separate) правовых системах разных стран. Высший законодательный орган в Советском Союзе не имеет привычки подчиняться Королеве в парламенте, и что бы она ни постановила относительно советских событий (хоть это и составит часть права Англии), не станет частью права в СССР. Так было бы только в том случае, если бы Королеве в парламенте привычно подчинялась бы легислатура СССР.

При таком простом понимании вопроса, которое нам позже придется критически исследовать, должны быть (всюду, где есть правовая система) некоторые лица или органы, издающие общие приказы, подкрепленные угрозами, которым обычно подчиняются, и должна быть общая убежденность в том, что эти угрозы будут, вероятно, осуществлены в случае неподчинения. Это лицо или орган должен быть во внутреннегосударственном плане верховным и внешнеполитически независимым. Если, следуя Остину, мы назовем такое верховное и независимое лицо или орган сувереном, законы любой страны будут общими приказами, подкрепленными угрозами, которые исходят либо от суверена, либо от подчиненных, повинующихся суверену.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МНОГООБРАЗИЕ ЗАКОНОВ

Если мы сравним множество различных видов закона в современной системе, такой как английское право, с простой моделью принуждающих приказов, описанной в предыдущей главе, то на ум приходит масса возражений [14]. Конечно, не все законы предписывают людям поступать или не поступать определенным образом. Не будет ли заблуждением классифицировать таким образом законы, предоставляющие права частным лицам составлять завещания, заключать контракты или вступать в брак и законы, уполномочивающие должностных лиц, в том числе судью — рассматривать дела, министра — устанавливать правила, а Совет графства — принимать подзаконные акты? Конечно, не все законы принимаются в законодательном порядке, и также все они не являются выражением чьего-то желания, как общие приказы нашей модели. Это представляется неверным в отношении обычая, который занимает определенное, хотя и скромное место в большинстве современных правовых систем. Несомненно, что законы даже при осмысленном их принятии в виде статутов, не обязательно должны быть только приказами, отдаваемыми *другим.* Разве свод законов зачастую не распространяется и на самих законодателей? И наконец, должны ли принятые законы, для того, чтобы быть законами, реально выражать какие-либо реальные желания, намерения или волю законодателя? Разве принятое надлежащим образом постановление не будет законом, если (как должно быть в случае со многими частями английского Финансового акта) те, кто за него голосовал, не знали его смысла?

Вот лишь некоторые из наиболее важных возможных возражений, каковых множество. Очевидно, что некоторая модификация первоначальной простой модели будет необходима для того, чтобы иметь с ними дело, когда же они все будут учтены, то обнаружится, что идея общих приказов, подкрепленных угрозами, изменена до неузнаваемости.

Возражения, о которых мы говорили, распадаются на три основные группы. Некоторые из них касаются *содержания* законов, другие — *способа их происхождения* (их источника), и третьи — *сферы применения.* Все правовые системы, по-видимому, содержат законы, которые в отноше-

нии по крайней мере одного из этих соображений отклоняются от созданной нами модели общих приказов. В этой главе мы рассмотрим по отдельности все эти три типа возражений. Мы оставим до следующей главы более фундаментальную критику, согласно которой, наряду с возражениями против этой теории с точки зрения содержания, способа происхождения и сферы применения законов, сама концепция верховного и независимого суверена, которому подчиняются по привычке, является ошибочной, так как ей мало что соответствует в любой реальной правовой системе [15-16].

1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАКОНОВ

Уголовное право — это нечто, чему мы или подчиняемся или не подчиняемся, и о том, что требуют от нас его нормы, говорят как об «обязанностях». Если мы не подчиняемся, то говорится, что мы «нарушаем» закон, и все, что мы совершили, является «противоправным» действием, «нарушением обязанности» или «правонарушением». Уголовный кодекс выполняет социальную функцию установления и определения некоторых видов поведения, которого следует избегать либо совершать по отношению к тем, к кому оно применяется, независимо от их желания. Наказание, или «санкция», присоединяется законом к нарушениям или преступлениям против уголовного права (каким бы иным целям не служило наказание) для того, чтобы установить еще один мотив для воздержания от подобных действий. Во всех этих отношениях налицо по меньшей мере сильная аналогия между уголовным правом и его санкциями и общими приказами, подкрепленными угрозой, о которых говорится в нашей модели. Есть некоторая аналогия (несмотря на многие важные различия) между подобными общими предписаниями и деликтным правом (law of torts), главная цель которого — обеспечить возмещение вреда, нанесенного одним лицам в результате действий других. Здесь снова нормы, устанавливающие виды поведения, составляющего неправомерные действия, описываются как налагающие на лица, независимо от их желаний, «обязанности» (или, реже, «обязательства») воздерживаться от такого поведения. Это поведение само по себе именуется «нарушением обязанности», а возмещение или другие средства судебной защиты — «санкцией». Но существуют важные классы законов, где эта аналогия с приказами, подкрепленными угрозами, не работает, поскольку они выполняют совершенно иные социальные функции. Правила, определяющие порядок составления действительных контрактов, завещаний, заключения браков, не требуют от лиц никаких действий, которые бы не зависели от их желания. Такие законы не налагают обязанностей или

обязательств. Вместо этого они предоставляют лицам *средства* для осуществления их желаний, наделяя их правомочиями создавать, с помощью специальных процедур, ограниченных определенными условиями, системы прав и обязанностей в рамках принудительных структур права [17-18].

Власть, которой таким образом наделяются частные лица — формировать свои правовые отношения с другими на основе договоров, завещаний, брачных соглашений и т. д. является одним из важнейших вкладов права в организацию социальной жизни; и это свойство права затемняется представлением о том, что все законы являются в конечном итоге приказами, подкрепленными угрозами. Радикальное отличие в функциях между законами, предоставляющими такую власть, и уголовными статутами отражается в том, как мы обычно говорим об этом классе законов. Мы можем «подчиняться» или не «подчиняться» при составлении завещания положению ст. 9 Закона о завещаниях 1837 г. о количестве свидетелей. Если мы не подчинимся, то созданный нами документ не будет «юридически действительным» завещанием, создающим права и обязанности — оно будет «ничтожным», без юридической «силы» и «последствий». Но хотя оно будет ничтожным, наша неспособность подчиниться положениям статута не является «неисполнением» или «нарушением» какого-либо обязательства либо обязанности и не является «преступлением», так что мыслить об этой ситуации в таких понятиях было бы недоразумением.

Если мы исследуем разнообразные юридические нормы, предоставляющие законные полномочия частным лицам, то обнаружим, что они сами по себе распадаются на различные виды. Таким образом, за правомочием составления завещания или заключения договора стоят нормы, относящиеся к правоспособности или минимуму персональной квалификации (такой как совершеннолетие или вменяемость), которой необходимо обладать для осуществления этого правомочия. Другие правила детализируют способ и форму реализации этого правомочия и определяют, должны ли завещания или договоры совершаться в устной или письменной форме, и если в письменной, то какова должна быть форма их исполнения и удостоверения. Остальные нормы определяют границы разнообразия, или максимальный или минимальный срок действия структуры прав и обязанностей, которые индивиды могут реализовать через такие законные акты. Примерами таких правил являются государственная политика в отношении контрактов либо нормы против совпадения прав на одно имущество в завещании или акте распоряжения имуществом.

Далее мы рассмотрим попытки правоведов свести законы, предоставляющие возможности или правомочия и указывающие «если вы хо-

тите это сделать, то надо делать так» к уголовным законам, которые, как приказы, подкрепленные угрозами, предписывают «поступать так, желаете ли вы или нет». Однако рассмотрим еще один класс законов, которые также наделяют правовыми полномочиями, но в отличие от тех, о которых только что шла речь, эти полномочия имеют скорее публичную и официальную, нежели частную природу. Примеры таких правил могут быть найдены во всех трех ветвях власти, на которые обычно, хотя и несколько расплывчато, делится публичная власть, — судебной, законодательной и административной.

Сначала рассмотрим те законы, которые лежат в основании действия суда. В случае с судом некоторые правила точно определяют объект и содержание судебной юрисдикции или, как говорится, дают «полномочия по рассмотрению» определенной категории дел. Другие правила устанавливают способ назначения, наличие квалификации и срок пребывания на судебной должности. Остальные устанавливают принципы правильного поведения судей и определяют процедуры, которых следует придерживаться в суде. Примеры таких правил, составляющих нечто вроде судейского кодекса, содержатся в Законе о судах графств 1959 г., Законе об апелляционном суде по уголовным делам 1907 г. либо в статье 28 Кодекса законов США. Полезно отметить разнообразие положений, содержащихся в этих статутах, призванных определить организацию и нормальное функционирование судов. Немногие из них на первый взгляд выглядят как требования, обращенные к судье, действовать определенным образом либо воздержаться от каких-либо действий. Хотя, конечно, нет никаких причин, по которым закон не мог бы содержать специальных положений, запрещающих судье под угрозой наказания превышать полномочия или рассматривать дела, в которых он имеет материальную заинтересованность, эти правила, налагая подобного рода обязанности, оказываются дополнениями к другим правилам, которые, собственно, и облекают его правовой властью и определяют его юрисдикцию. Ведь задачей правил, дающих подобную власть, является не предотвращение злоупотреблений со стороны судьи, но определение условий и пределов, при которых судебные решения будут действительны.

Это полезно рассмотреть более детально на основе типовых положений, конкретизирующих пределы юрисдикции судов. В качестве простого примера можно взять статью 48 (1) Закона о судах графств 1959 г. с изменениями, которая устанавливает юрисдикцию судов графств в вопросах возвращения земель. Формулировка, язык которой весьма далек от так называемых «предписаний», выглядит так:

> «Суд графства обладает компетенцией рассматривать и разрешать споры о возвращении земельных участков в случае, если чистый ежегодный доход от этого земельного участка не превышает 100 фунтов стерлингов».

Если судья суда графства превысит свою компетенцию, рассматривая дело о возвращении земельного участка с чистым ежегодным доходом более чем 100 фунтов стерлингов и издаст судебный приказ в отношении этой земли, то ни он, ни стороны не совершат *преступления.* Однако эта ситуация не вполне похожа на ту, когда частное лицо совершает действия, являющиеся «недействительными» из-за несоблюдения некоторых условий, существенных для надлежащего осуществления законных полномочий. Если бы завещатель не подписал свое завещание или не пригласил двух свидетелей, то оно не имело бы юридического статуса или последствий. Однако судебный приказ не истолковывается таким же образом, даже если прямо выходит за пределы компетенции суда. Очевидно, что в интересах общественного порядка, чтобы судебное решение обладало юридической силой до тех пор, пока вышестоящий суд не объявит его недействительным, даже это решение выносить не следовало по правовым соображениям. Следовательно, пока судебный акт не приостановлен в результате апелляции как судебный приказ, изданный с превышением компетенции, он сохраняет юридическую силу, а стороны обязаны его исполнять. Но этот судебный акт имеет юридический дефект: он *подлежит* приостановке или отмене апелляционной инстанцией из-за отсутствия компетенции. Следует отметить, что есть важное различие между тем, что обычно называется в Англии «отменой» вышестоящим судом решений нижестоящих судов и «аннулированием» решения при отсутствии компетенции. Если судебное решение отменено, то это означает, что либо закон, подлежащий применению, либо обстоятельства дела рассмотрены нижестоящим судом неверно. Но решение нижестоящего суда, отмененное из-за превышения компетенции, может быть безупречным в обоих этих отношениях. Здесь неправомерным является не то, *что* судья в нижестоящем суде утверждал или требовал в судебном решении, но то, что это *он* утверждал или требовал это. Он намеревался совершить то, на что он не был юридически уполномочен, хотя другие суды могут иметь соответствующие полномочия. Но вся сложность в том, что в интересах общественного порядка решение, принятое с превышением компетенции, сохраняет юридическую силу до отмены вышестоящим судом, то есть соблюдение или неспособность соблюсти правила компетенции подобно соблюдению или несоблюдению правил, определяющих условия действительного применения юридических полномочий частными лицами. Это отношение между правилом и действием в согласии с ним плохо передается словами «подчиняться» и «не подчиняться», которые более уместны в случае с уголовным правом, где правила аналогичны приказам.

Статут, предоставляющий законодательные полномочия подчиненному органу законодательной власти, сходным образом представляет

собой вид юридического правила, которое не может без искажений приравниваться к общему приказу. Здесь, как и при осуществлении частных полномочий, соответствие условиям, оговоренным правилами, предоставляющими законодательные полномочия, является шагом, подобным ходу в шахматной игре; имеются последствия, описанные в понятиях правил, которыми система позволяет лицам достигать определенных целей. Законодательство — это осуществление правовых полномочий, действующих или эффективных при создании юридических прав и обязанностей. Несоблюдение условий наделяющего полномочиями правила влечет за собой неэффективность действия, и, таким образом, его ничтожность для данной цели.

Правила, лежащие в основе применения законодательных полномочий, сами по себе даже более разнообразны, чем те правила, которые лежат в основе судебной юрисдикции, так как они должны обеспечить многие различные аспекты законодательства. Таким образом, отдельные правила определяют объект законодательной компетенции; другие устанавливают квалификацию или характеристики членов законодательного органа; иные — способы и формы законодательной деятельности и процедуры, которым должна следовать законодательная власть. Это лишь некоторые вопросы, имеющие отношение к делу; и достаточно взглянуть на любые законодательные акты, такие как Закон о муниципальных корпорациях 1882 г., устанавливающий и определяющий полномочия нижестоящего органа законодательной власти или правотворческого органа, чтобы увидеть многое другое. Последствия несоблюдения таких правил не обязательно будут одинаковыми, но всегда будут некоторые правила, неспособность соблюсти которые влечет за собой ничтожность применения законодательных полномочий, либо, как в случае с решением нижестоящего суда, подлежит объявлению недействительным. Иногда документ, заверяющий, что требуемая процедура была соблюдена, может, в соответствии с законом, закрывать вопрос, как в случае с внутренней процедурой, иногда же лица, не удовлетворяющие установленной правилом квалификацией, однако участвующие в законодательном процессе, могут быть подвергнуты наказанию на основе специальных уголовных норм, квалифицирующих их действия как преступление. Но, хотя и частично скрытое этими сложностями, существует коренное различие между правилами, устанавливающими и определяющими способы осуществления законодательных полномочий, и нормами уголовного права, которые, по крайней мере, похожи на приказы, подкрепленные угрозами.

В некоторых случаях сравнение этих двух типов правил было бы чрезмерным преувеличением. Если та или иная мера получает требуемое большинство голосов в законодательном органе, а следовательно, является принятой на основе предписанной процедуры, голосующие за дан-

ную меру не «подчиняются» закону, требующему достижения большинства голосов, равно как и те, кто голосовал против, ни «подчинились» и ни «не подчинились» этому закону; то же самое, разумеется, верно и в случае, если данная мера не получила поддержки большинства и, следовательно, закон не прошел. Коренное функциональное различие между этими типами правил делает бессмысленным использование в подобных случаях терминологии, соответствующей поведению по отношению к нормам уголовного права.

Более полная таксономия видов закона, входящих в современную правовую систему, свободная от предрассудка, что все *должно* быть сведено к одному простому виду правил, еще не создана. Наше разделение законов на два очень грубо очерченных класса— (1) законы, наделяющие полномочиями, и (2) законы, налагающие обязанности, и подобные приказам, подкрепленным угрозами, — это только первый шаг. Но, возможно, сделано достаточно для того, чтобы показать, что некоторые из отличительных признаков правовой системы характеризуются правилами такого типа, предоставляющими полномочия частным лицам и публичным институтам. Если бы такие правила этого особого типа не существовали, у нас не было бы некоторых из самых знакомых понятий социальной жизни, поскольку они логически предполагают наличие таких правил. Как не было бы преступлений или правонарушений и не было бы убийств и краж, если бы не существовали императивные нормы уголовных законов, сходные с приказами, подкрепленными угрозами, точно так же не было бы купли-продажи, дарения, завещаний или браков, если бы не существовали правила, предоставляющие полномочия. Ибо все это, как и предписания судов и постановления законодательных органов, состоит как раз в юридически действительном применении правомочий.

Однако стремление к достижению единообразия в юриспруденции сильно. И поскольку оно ни в коей мере не является чем-то нереспектабельным, нам следует рассмотреть два альтернативных аргумента в его пользу, поддерживаемых известными юристами. Эти аргументы призваны показать, что различие между видами законов, на которое мы указали, носит поверхностный характер или вообще нереально, и что «в конечном итоге» понятие приказов, подкрепленных угрозой, столь же адекватно для анализа правил, дающих полномочия, как и для правил уголовного права. Как и для большинства теорий, продолжающих существовать в юриспруденции, в этих аргументах есть доля правды. Есть, конечно, некоторые элементы сходства между двумя выделенными нами типами правил. В обоих случаях действия могут критиковаться или оцениваться отсылкой к правилам, определяющих их как деяния, «правильные» или «неправильные» с точки зрения права. Так правила, дающие власть, например, составить завещание, и правила уголовного права, за-

прещающие насилие под угрозой наказания, утверждают *стандарты,* в соответствии с которыми должны оцениваться отдельные действия. Возможно, это и подразумевается, когда и о тех, и о других говорят как о правилах. Далее, важно понимать, что правила, дающие полномочия, хотя они и отличаются от правил, налагающих обязанности и подобных приказам, подкрепленным угрозами, всегда связаны с этими последними; ведь полномочия, которую дают эти правила, являются властью создавать общие правила последнего типа или налагать обязанности на отдельных лиц, которые в противном случае не имели бы их. Очевидно, что перед нами тот случай, когда данные полномочия являются тем, что на обычном языке можно было бы назвать властью законодательствовать. И как мы увидим далее, это верно и для других типов правовых полномочий. И можно сказать, хотя и несколько неточно, что если правила, подобные уголовно-правовым нормам, налагают обязанности, то правила, дающие власть, являются средством создания обязанностей.

Ничтожность как санкция

Первый аргумент, призванный показать, что между двумя типами правил существует фундаментальное единство, и представляющий оба этих типа как принудительные приказы, опирается на понятие «ничтожность», которое возникает, когда некоторые существенные условия для реализации власти не выполнены [19]. Утверждается, что она подобна наказанию, присущему уголовному праву, угрозе или санкции, предписанной правом в случае нарушения правила, хотя и признается, что в отдельных случаях эта санкция может быть сведена лишь к незначительному неудобству. В таком свете нам предлагают рассмотреть случай, когда некто, желая скрепить законом, как обязывающим контрактом, некое данное ему обещание, вдруг к своему великому сожалению обнаруживает, что из-за отсутствия печати это обещание является ничтожным с правовой точки зрения. Точно так же нам предлагают считать, что правило, согласно которому завещание, сделанное в отсутствие двух свидетелей, будет ничтожным, так же мотивирует свидетелей подчиниться ст. 9 Закона о завещаниях, как нас приводит в повиновение уголовному праву мысль о возможном заключении.

Никто не станет отрицать, что в отдельных случаях существуют эта связь между ничтожностью и такими психологическими факторами, как разочарование в том, что соглашение оказалось юридически недействительным. Тем не менее распространение идеи санкции на ничтожность является источником (и признаком) смешения понятий. Некоторые элементарные возражения по этому поводу хорошо известны. Так, во многих случаях ничтожность не может считаться «злом» для лица, которое не соблюдало отдельные условия, требуемые для того, чтобы его действие

имело юридическую силу. Судья может не иметь материальной заинтересованности и может быть равнодушным к юридической неоспоримости его судебного приказа; сторона, которая является ответчиком в суде и обнаруживает, что договор не создает для нее обязательств из-за ее недееспособности по малолетству либо по причине отсутствия подписи на письменном документе, которая необходима для определенных договоров, едва ли усмотрит в этом «угрозу вреда» или «санкцию». Но если отвлечься от этих тривиальностей, которые можно, при достаточной изобретательности, истолковать нужным образом, ничтожность по более важным причинам не может приравниваться к наказанию, предусмотренному правилом в качестве стимула, заставляющего воздержаться от противоправных действий. В случае с нормой уголовного права мы можем вычленить и различить два обстоятельства: определенный тип поведения, который норма запрещает, и санкцию с целью препятствовать подобному поведению. Но возможно ли в этом же свете рассматривать такие желательные общественные действия, как обоюдное соглашение, которое не заключено с соблюдением должных формальностей? То, что по нормам закона, оговаривающим правовые формы договоров, подлежит запрещению, не похоже на уголовно наказуемое поведение. Правила подобного рода всего лишь отказывают некоторым соглашениям в правовом признании. Еще абсурдней считать санкцией последствия, наступающие в случае, если та или иная законодательная мера, если за нее не проголосует требуемое большинство, не принимается в качестве закона. Сравнивать этот факт с санкциями уголовного права — это почти то же самое, что думать о правилах счета в игре как о требовании, призванном устранить все движения, кроме забивания голов или передач пасов. Если бы это было так, то всякой игре пришел бы конец. Ведь лишь считая, что правила, дающие власть, созданы для того, чтобы заставить людей поступать определенным образом, а их «ничтожность» нужна для создания стимула для повиновения, мы сможем отождествить такие правила с приказами, подкрепленными угрозами.

Смешение понятий, неизбежное для теории, трактующей ничтожность аналогично угрозе наступления негативных последствий или санкций уголовного права, может быть выявлено иначе. В случае с нормами уголовного права логически возможным и желаемым может быть то, чтобы такие нормы были, даже без угрозы наказания или иных негативных последствий. Конечно, в подобных случаях можно возразить, что они не будут *правовыми* нормами. Тем не менее мы можем ясно отличить правило, запрещающее определенное поведение, от установления наказания за нарушение этого правила и допустить, что первое существует без последнего. В этом смысле можно убрать санкцию, но все же сохранить понятные стандарты поведения, которые это правило должно под-

держивать. Однако мы не можем провести подобное же логическое разграничение между правилом, требующем соблюдения определенных условий, например наличия свидетелей при составлении завещания, и так называемой «санкцией в виде ничтожности». В этом случае, если бы несоблюдение этого существенного условия не влекло за собой ничтожности, мы не могли бы осмысленно утверждать, что данное правило остается правилом и без санкции, даже в качестве неправового правила. Положение о ничтожности является *частью* этого вида правил как таковых, в то время как наказание, сопутствующее правилам, налагающим обязанности — нет. Если бы неспособность забить мяч в ворота не влекла за собой «ничтожность» отсутствия гола, то о правилах счета нельзя было бы сказать, что они существуют.

Аргумент, который здесь критикуется, призван доказать фундаментальное тождество правил, дающих власть, и принудительных приказов, путем *расширения* области значения термина «санкция» или «угроза наступления негативных последствий так, чтобы они включали в себя ничтожность правового действия в случае невыполнения соответствующих правил. Второй аргумент, к рассмотрению которого мы переходим, подходит к делу с другой, и даже противоположной, стороны. Если в первом случае предпринимается попытка показать, что эти правила являются подвидом принудительных приказов, то во втором случае данным правилам вообще отказывают в правовом статусе. С этой целью сужается само понятие «право». Общая форма этого аргумента, встречающаяся в более или менее крайних формах у различных юристов, сводится к утверждению, что подобного рода правила, о которых в обыденной речи говорят как о полноценных правилах, на самом деле являются несовершенными фрагментами принудительных правил, которые и являются «настоящими» законами.

Правила, дающие власть, как фрагменты законов

В своей наиболее радикальной форме этот аргумент отказывает даже правилам уголовного права в том виде, как они обычно формулируются, в статусе настоящих законов [20]. Именно в таком виде он принимается Кельзеном: «Право — это первичная норма, которая определяет (stipulates) санкцию» \ Не существует закона, запрещающего убийство: есть лишь закон, предписывающий должностным лицам применять определенные санкции в соответствующих обстоятельствах к тому, кто убивает. С этой точки зрения то, что обычно понимается как содержание закона, призванного руководить поведением рядовых граждан, является лишь антецедентом или придаточным условным предложением (if-

[1] General Theory of Law and State, p. 63.

clause) в правиле, которое адресовано не к ним, а к должностным лицам, и требует от последних применения соответствующих санкций, если выполнены конкретные условия. Все реальные законы, таким образом, представляют собой условные предписания должностным лицам по применению санкций. Все они выражены в следующей форме: «Если нечто вида X совершено, или упущено, или случилось, то примени санкцию вида Y».

Посредством все более подробной разработки этого антецедента или условного положения, правовые правила любого типа, в том числе и правила, дающие право и определяющие способ осуществления частной и публичной власти, могут быть переформулированы в виде подобного условного предложения. Так, положение Закона о завещаниях, требующее наличия двух свидетелей, может выступать в качестве общей части множества различных указаний судам по применению санкций к душеприказчику, который в нарушение условий завещания отказывается выплачивать наследства: «Если, и только если, существует завещание, засвидетельствованное должным образом и содержащее эти условия, и если...то к нему должны применяться санкции». Аналогичным образом, правило, определяющее объем судебной юрисдикции, является общей частью условий, которые должны быть выполнены прежде, чем применена санкция. Также и правила, предоставляющие законодательные полномочия и определяющие порядок и форму законодательной деятельности (включая положения конституции, относящиеся к высшему законодательному органу), могут быть переформулированы и представлены в качестве определения некоторых общих условий, для исполнения которых (кроме всего прочего) суды должны применять санкции, указанные в статутах. Таким образом, эта теория требует от нас выявления сущности закона, которая затемняется его формой. Далее мы увидим, что конституционные формы, такие как «все, что Королева постановляет в Парламенте, является законом», или положения Конституции США относительно правотворческих полномочий Конгресса, только уточняют основные условия, при наличии которых судами применяются санкции. Эти формы оказываются по своей сути условиями (if-clauses), а не полноценными правилами: фразы *«если* Королева в Парламенте постановила...» или *«если* Конгресс в пределах, установленных Конституцией, постановил...» являются формами условий, общих для многочисленных указаний судам по применению санкций либо наложению взысканий за определенные виды поведения.

Так выглядит эта значительная (formidable) и интересная теория, направленная на раскрытие истинной, единой природы права, скрытой под множеством общих форм и выражений, затемняющих ее. Прежде чем рассматривать ее дефекты, следует заметить, что в своей крайней

форме данная теория включает в себя сдвиг в первоначальном понимания права как приказов, которые поддерживаются угрозами применения санкций в случаях, если приказы нарушены. Вместо этого теперь основной упор делается на приказы должностным лицам применять санкции. С этой точки зрения не является необходимым, чтобы санкция предписывалась за *нарушение* каждого закона; необходимо лишь, чтобы каждый «подлинный» закон предписывал применение некоей санкции. Так что вполне может случиться, что официальное лицо, проигнорировавшее это указание, не понесет наказания; и, конечно, подобные случаи сплошь и рядом происходят во многих правовых системах.

Эта общая теория, как уже сказано, может быть сформулирована в двух формах, одна из которых менее экстремальна, нежели другая. В менее экстремальной форме первоначальное понимание права (многими интуитивно воспринимаемое как более приемлемое) как совокупности подкрепленных угрозами приказов, адресованных простым гражданам, сохраняется по крайней мере в отношении тех правил, которые, с точки зрения обыденного сознания, касаются прежде всего поведения обычных граждан, а не только лишь должностных лиц. Нормы уголовного права в рамках такой более умеренной позиции являются законами, как они есть; нет никакой необходимости переформулировать их в качестве фрагментов более полных правил, так как они уже являются приказами, подкрепленными угрозами. Но в случае с другими законами исправление необходимо. Правила, предоставляющие правовые полномочия частным лицам, в данной теории, как и в более радикальной ее форме, представляют собой лишь фрагменты реальных полных законов — приказов, подкрепленных угрозами. Последнее обстоятельство выявляется посредством вопроса: кому именно закон предписывает поступить определенным образом и угрожает наказанием в противном случае? Когда это обстоятельство выяснено, положения таких правил, как Акта о завещаниях 1837 г. в отношении свидетелей, и иные правила, предоставляющие полномочия индивидам и определяющие условия для их надлежащего осуществления, могут быть переформулированы как условные предложения, определяющие определенные условия, при которых такая правовая обязанность в конечном итоге возникает. Тогда они предстанут частью антецедента, или пункта «если...» условных приказов, подкрепленных угрозами или правил, налагающих обязанности. «Если и только если завещание подписано завещателем и засвидетельствовано двумя свидетелями определенным способом и если...то душеприказчик (или иной законный представитель) должен исполнять положения завещания». Правила, относящиеся к заключению договора, также окажутся лишь фрагментами правил, предписывающих лицам, если определенные обстоятельства имеют место, либо нечто сказано, либо сделано (если участник сделки

достиг совершеннолетия, его слова заверены печатью и т.д.), совершить действия, которые по договору должны быть совершены.

Переформулировка правил, предоставляющих законодательные полномочия (включая положения Конституции о высшей законодательной власти), имеющее целью представить их в качестве фрагментов «настоящих» правил, может быть проведена способом, подобным тому, о котором уже говорилось ранее в связи с более радикальной версией этой теории. Единственное отличие будет состоять в том, что в рамках более умеренной теории, правила, дающие полномочия, будут представлены антецедентами или условиями правил, предписывающих обычных гражданам под угрозой применения санкций выполнять определенные действия, а не условиями указаний должностным лицам по применению санкции, как в более экстремальной версии.

Обе версии этой теории призваны свести представляющиеся различными разновидности правовых правил к одной форме, которая якобы выражает квинтэссенцию права. Обе, хотя и различным образом, превращают санкцию в элемент центральной важности, и обе потерпят неудачу, если удастся показать, что право вполне постижимо и без санкций. Общая критика этих теорий будет проведена впоследствии. Конкретным возражением, против обеих форм теории, которое будет развернуто здесь, заключается в том, что эти теории покупают желаемое единство образцов, к которым можно было бы свести все право, слишком дорогой ценой, а именно, ценой искажения тех различных социальных функций, которые выполняют различные виды правовых правил. Этот порок присущ обоим вариантам теории, однако он наиболее очевиден в более радикальном ее варианте в связи с требуемой ей переформулировкой уголовного права.

Искажение как цена единообразия

Искажение, вносимое изменениями подобного рода, стоит рассмотреть, ибо в результате выявляется много различных аспектов права. Существует множество технических приемов, при помощи которых можно контролировать общество, при этом метод уголовно-правового контроля состоит в том, что некоторые типы поведения посредством определенных правил утверждаются в качестве стандартов, которым должны следовать либо члены общества в целом, либо отдельные классы внутри него. Без какой-либо посторонней помощи и вмешательства со стороны официальных лиц они должны понимать смысл правил, осознавать, что они касаются именно их, и поступать в соответствии с ними. Только при нарушении закона, когда эта первичная задача права оказывается невыполненной, должностные лица должны установить факт нарушения и применить к нарушителю те санкции, которыми угрожали. В отличие от

ситуации непосредственного приказа официального лица, отдаваемого, например, регулировщиком водителю транспортного средства, в данном случае членам общества предоставляется право самостоятельно познать эти правила и согласовывать свое поведение с ними. В этом смысле они сами «применяют» правила по отношению к себе, хотя мотивом подобного поведения может быть добавленная к правилу санкция. Очевидно, что мы упустим из виду особенности функционирования права в данном случае, если сконцентрируемся на правилах, предписывающих судам налагать наказания в случае неповиновения, либо выведем эти последние правила на первый план. Ведь правила подобного рода предусматривают лишь действия в случае нарушения или невыполнения первичной задачи системы. Возможно, они необходимы, однако играют вспомогательную роль.

Идея о том, что функция (и, шире, смысл) субстанциональных правил уголовного права заключается в руководстве не только должностными лицами, отвечающих за функционирование системы наказаний, но и обычными гражданами в повседневной жизни, не может быть отброшена без устранения важных разграничений и затемнения специфической роли права в качестве средства социального контроля. Наказание за преступление в виде штрафа — это не то же самое, что налог на определенную деятельность, хотя оба вида включают в себя указания должностным лицам по взысканию той же суммы денег. Эти идеи различаются тем, что первая включает, а вторая — нет правонарушение либо неисполнение обязанности в форме нарушения правила, предписывающего определенное поведение обычным гражданам. Верно, что это, как правило, ясное различие может при определенных обстоятельствах размываться. Налоги могут взиматься не только с целью увеличения государственных доходов, но и для ограничения налогооблагаемой деятельности, хотя в законе и не говорится в явном виде, что деятельность подобного рода должна быть прекращена, как это происходит, когда закон «объявляет ее преступной». И наоборот, штрафы, которые взыскиваются за уголовные преступления, могут из-за обесценения денег стать настолько небольшими, что с радостью уплачиваются. В результате они, возможно, воспринимаются как «всего лишь налоги», а «правонарушения» часты потому, что в подобных ситуациях утрачено чувство того, что данное правило, как и большинство правил уголовного права, следует воспринимать серьезно как образец поведения [21].

Иногда в качестве позитивной особенности этой теории преподносят тот факт, что, переформулировав закон в виде предписаний должностным лицам по применению санкций, мы достигаем большей ясности, отчетливо формулируя то, что желает знать о праве «плохой человек». Возможно, это действительно так, однако едва ли адекватно для обосно-

вания теории. Почему право не может в равной, если не в большей степени интересоваться мнением «озадаченного» или «неосведомленного человека», который согласен вести себя как требуется, если ему объяснят, в чем конкретно состоят требования? Либо «человека, который решил привести в порядок свои дела», если ему объясняют, как это делать? Разумеется, для понимания права важно знать, как действует суд, когда дело доходит до применения санкций. Однако не следует думать, что все, что нам нужно знать, связано с тем, что происходит в судах. Основные функции права как средства социального контроля проявляются отнюдь не в судебных тяжбах или уголовном преследовании, которые представляют собой существенные, но все же вспомогательные средства исправления ошибок функционирования системы. Они проявляются в различных способах, которыми право используется для того, чтобы контролировать, управлять и планировать жизнь за дверями суда.

В экстремальной форме этой теории вспомогательное и принципиальное меняются местами, что можно со следующим предложением по переформулированию правил игры. Теоретик, рассматривающий правила игры в крикет или бейсбол, может заявить, что он обнаружил единообразие, скрываемое терминологией правил и обыденными представлениями, что часть этих правил прежде всего предназначена для игроков, часть — для официальных лиц (арбитра и счетчика очков), а остальные — для тех и других. «Все эти правила, — может заявить теоретик, — *в действительности* представляют собой правила, предписывающие должностным лицам совершать конкретные действия при определенных условиях». Правила, определяющие, что определенные движения после удара по мячу представляют собой пробежку (a run), или, что будучи застигнутым за совершением запрещенных действий игрок удаляется с поля, на самом деле являются сложными указаниями официальным лицам; в первом случае счетчику очков — записать в книге подсчета очков «пробежку», а в другом арбитру — приказать игроку «уйти с поля» («off the field»). Однако такая интерпретация вызывает естественный протест, потому что это единообразие, достигаемое за счет преобразования правил, скрывает механизм действия правил, и то, как игроки применяют их, руководствуясь ими в своей целенаправленной деятельности. В результате затемняется их роль в том основанном на сотрудничестве, хотя и конкурентном социальном предприятии, которым является игра.

Менее радикальная форма теории оставляет уголовное право и все другие виды законодательства, налагающие обязанности, нетронутыми, так как они уже соответствуют простой модели принудительных приказов. Однако она сводит все правила, наделяющие правовыми полномочиями и определяющие способы их реализации, к этой единой форме. В этом смысле она может быть подвергнута той же критике, что и более

радикальная теория. Если мы взираем на все право с точки зрения лиц, на которых оно налагает обязанности, и сводим все остальные его аспекты к выявлению статуса более или менее разработанных условий, при выполнении которых эти обязанности становятся действенными, то мы начинаем считать всего лишь подчиненными некоторые другие элементы права, по меньшей мере столь же характерные для права и значимые для общества, как и собственно обязанности. Правила, предоставляющие полномочия частным лицам, следует рассматривать с точки зрения тех лиц, которые их используют. В этом случае они раскрываются перед нами в качестве дополнительных элементов, вводимых правом в жизнь общества, помимо принудительного контроля. И это так, потому что, обладая этой правовой властью, частное лицо, которое в их отсутствие было бы всего лишь носителем обязанностей, превращается в частного законодателя. В сферу его компетенции входит определение правоотношений в области своих договоров, поручительства, завещаний и других правовых структур, которые он вправе самостоятельно создавать. Почему правила, используемые таким образом и дающие эти огромные и особые удобства, не признаются в качестве чего-то отличного от правил, налагающих обязанности, присутствие которых в действительности частично определено осуществлением подобных полномочий? Правила подобного рода, дающие власть, осмысливаются, выражаются и используются в общественной жизни иначе, нежели правила, налагающие обязанности, и оцениваются на основании различных критериев. Неужели требуется какая-либо дополнительная проверка, подтверждающая это различие? *[22]*

Сведение правил, предусматривающих и определяющих законодательные и судебные полномочия, к формулировке условий, при которых возникают обязанности, приводит к подобному же пороку в сфере публичного права. Те, кто использует данные полномочия для создания действительных постановлений и приказов, используют эти правила в ходе сознательной деятельности, природа которой кардинально отличается от исполнения долга или подчинения принудительного контроля. Представлять такие правила в качестве аспектов либо фрагментов обязывающих правил — значит затемнять, причем более, чем в частноправовой сфере, отличительные особенности права и формы деятельности, возможные в его рамках. Ведь появление в обществе дополнительных правил, позволяющих законодателям изменять старые и создавать новые правила, налагающие обязанности, а судьям решать, при каких конкретно обстоятельствах правила могут считаться нарушенными, — это нововведение столь же важное с точки зрения прогресса общественных отношений, как изобретение колеса. Это нововведение было не просто важным шагом, но кардинальным изменением, которое, как мы покажем

в четвертой главе, обусловило переход общества из доправового состояния к правовому [23].

2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Очевидно, что из всех разновидностей закона в простой модели принудительных приказов ближе всего подходит уголовный кодекс. Однако, даже эти законы имеют определенные свойства, рассматриваемые в этом разделе, которые затемняются данной моделью, и мы не сможем их адекватно понять до тех пор, пока не избавимся от ее влияния. Приказ, подкрепленный угрозами, — это, в сущности, выражение желания, чтобы *другие* исполнили нечто либо воздержались от совершения определенных действий. Конечно, законодательство может принять такую форму, когда приказы обращены исключительно вовне (other-regarding form). Абсолютный монарх, обладающий законодательными полномочиями, может в определенных системах рассматриваться свободным от власти им же созданных законов; и даже в демократической системе могут устанавливаться такие законы, которые не применяются в отношении законодателей, но касаются лишь особых групп, прямо указанных в законе. Однако сфера применения права всегда есть вопрос его истолкования. В результате истолкования может оказаться, что право применимо или не применимо к тем, кто его создает, и в настоящее время создается множество законов, налагающих правовые обязательства на тех, кто их принимает. Законодательство, в отличие от приказов *другим* лицам совершать определенные действия под страхом наказания, вполне может обладать такой связывающей законодателя силой (self-binding force). В нем нет ничего такого, что было бы *по своей сущности* обращенным только на других. Этот правовой феномен выглядит загадочным лишь до тех пор, пока мы думаем, под влиянием нашей модели, что законы всегда должны устанавливаться одним человеком или группой людей, стоящими выше их, для других, которые обязаны им подчиняться.

Такой вертикальный или «нисходящий» ("top-to-bottom") образ законодательной деятельности, столь привлекательный в своей простоте, может быть примирен с действительностью лишь в том случае, если мы проведем различение между законодателем в его официальном качестве и им же, но в качестве частного лица. Действуя в первом качестве, он создает закон, налагающий обязательства на другие лица, включая его самого «в качестве частного лица». В этих выражениях нет ничего неприемлемого, однако представление о различных качествах, как мы увидим в четвертой главе, разумно объяснимо лишь в терминах правил, дающих власть, которые не могут быть сведены к принудительным приказам. Пока же можно

отметить, что это сложное построение на самом деле не необходимо; самоограничительное свойство законодательного акта мы можем объяснить и без него. Как в законодательной деятельности, так и в повседневной жизни мы располагаем кое-чем еще, позволяющим нам намного лучше понять это. Речь идет о действии *обещания,* которое во многих отношениях является лучшей моделью, нежели модель принудительных приказов для объяснения многих, хотя и не всех, особенностей права.

Обещать — значит сказать нечто такое, что создает обязательство, связывающее обещающего. Для того, чтобы слова имели такой эффект, должны существовать правила, предусматривающие, что если слова используются надлежащими лицами в соответствующих обстоятельствах (например вменяемыми лицами, осознающими свое положение и свободными от различных видов давления), то те, кто их использует, связывают себя тем самым обязательством совершить необходимые действия. Таким образом, давая обещание, мы прибегаем к определенным процедурам, изменяющим наше моральное положение, налагая на себя обязательства и предоставляя другим права. Выражаясь юридическим языком, мы осуществляем «власть», предоставленную нам правилами, позволяющими это делать. Разумеется, возможно, однако бесполезно различать в одном обещающем два разных лица, одно из которых действует в качестве создателя обязанностей, а другое — в качестве лица обязывающегося, то есть, думать, что одно лицо приказывает другому нечто совершить.

Точно так же мы можем избавиться от этой схемы для объяснения самосвязывающей силы законодательства. Ведь создание закона, как и обещания, предполагает существование определенных правил, управляющих этим процессом: слова в устной или письменной форме, высказанные соответствующими этим правилам лицами, и при следовании установленной этими правилами процедуре, создают обязательства для всех, явно или неявно обозначенных этими словами. Они могут включать и тех, кто участвует в законодательном процессе.

Разумеется, хотя такая аналогия и объясняет самосвязывающий характер законодательства, существует множество различий между обещанием и созданием закона. Правила, регулирующие правотворчество, имеют более сложный и двусторонний характер, отсутствующий в случае обещания. В последнем случае обычно нет такого лица, *которому* дается обещание и которое получает специальное, если не уникальное, право на его выполнение. В этом смысле иные формы связывания самого себя обязательством, известные в английском праве, например, когда лицо провозглашает себя доверительным лицом, управляющим чужим имуществом, выглядят как более близкие аналогии самоограничивающего аспекта законодательства. Однако в целом правотворчество в виде при-

нятия законов лучше всего можно понять, учитывая именно такие частные способы возникновения определенных правовых обязательств.

Что более всего требуется для коррекции модели принудительных приказов или правил, так это свежая концепция процесса законотворчества как введения или изменения общих стандартов поведения, которым должно следовать общество в целом. Законодатель не всегда выступает в качестве лица, отдающего приказы остальным, кем-то по определению стоящим над собственным законом. Подобно дающему обещание, он осуществляет полномочия, предусмотренные правилами: очень часто он может, а как обещающий *обязан* сам подпадать под их власть.

3. СПОСОБЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

До сих пор в нашем обсуждении разнообразных форм права мы ограничивались статутами, которые, несмотря на отмеченные нами особенности, имеют одно бросающееся в глаза сходство с принудительными приказами. Издание закона, как и отдача приказа, *является* сознательным датируемым (datable) действием. Участники законодательной деятельности для создания закона сознательно используют определенную процедуру; точно так же человек, который отдает приказания, сознательно выбирает такие выражения, которые ясно выражают его намерения и обеспечивают подчинение им. Поэтому теории, которые используют при анализе права модель принудительных приказов, утверждают, что все право в целом может быть осмыслено, если убрать обманчивые наслоения по аналогии с законодательной практикой, и обязано своим статусом закона сознательному правотворческому акту. Формой права, наиболее очевидно противоречащей такому утверждению, является обычай; но дискуссия о том, является ли обычай реальным правом, часто возникает из нежелания разобраться в двух спорных вопросах. Первый вопрос заключается в том, является ли «обычай как таковой» правом или нет. Здравый смысл, лежащий в основе отрицания того, что обычай как таковой является правом, основывается на той простой истине, что во многих обществах существуют обычаи, которые не являются частью права. Отказ снимать шляпу перед дамой не будет нарушением какой-нибудь нормы права: он не имеет правового статуса, разве что только в том смысле, что разрешен правом. Отсюда видно, что обычай является правом, только если относится к классу обычаев, которые «признаются» в качестве права определенной правовой системой. Второй спорный вопрос касается смысла «правового признания». Что означает для обычая быть легально признанным? Не выражается ли это признание, как того требует модель принудительных приказов, в том факте, что кто-нибудь, суверен либо его

представитель, приказал следовать обычаю, так что его статус в качестве закона зависит от процедуры, в некотором отношении схожей с законодательным актом?

Обычай не является важным «источником» права в современном мире. Обычно он является второстепенным в том смысле, что законодательство может лишить обычное правило правового статуса; и во многих системах критерии, которыми руководствуются суды при определении того, следует ли признавать тот или иной обычай и является ли обычай соответствующим правовому признанию, включают в себя такие изменчивые понятия, как, например, «разумность» («reasonableness»), что дает основание считать, что в процессе принятия или непринятия обычая суды пользуются почти бесконтрольным правом усмотрения. Но если это действительно так, то определять правовой статус обычая на основании того, «приказал» ли законодатель, суверен или суд его признавать, — значит расширить значение понятия «приказ» до такой степени, что он совершенно утрачивает первоначальный смысл.

Для того чтобы рассмотреть доктрину правого признания, мы должны вновь напомнить о роли суверена в концепции права как принудительного приказа. Следуя этой теории, право представляет собой приказ суверена или его подчиненного, которому он дает распоряжение от своего имени. В первом случае право создается приказом суверена в буквальном смысле этого слова. Во втором случае приказ, отданный подчиненным, будет являться правом только в том случае, если он, в свою очередь, отдан во исполнение другого приказа самого суверена. Подчиненный должен обладать некоторыми полномочиями, делегированными сувереном, для вынесения предписаний от своего имени. Иногда это может быть предусмотрено прямым указанием министру «сделать распоряжения» по определенному поводу. Если бы данная теория этим ограничилась, то она, очевидно, вступила бы в противоречие с фактами; потому она расширяется за счет утверждения, что иногда суверен может выразить свою волю в менее приказной форме. Его предписания могут быть «молчаливыми» («tacit»); он может, не давая определенного указания, выразить свои намерения, чтобы его подданные действовали определенным образом, не вмешиваясь, когда подчиненные отдают приказания своим подчиненным и наказывают их за неповиновение.

Пример из военной службы может прояснить идею «молчаливого» приказа настолько, насколько это вообще возможно сделать. Предположим, что некий сержант, который сам подчиняется вышестоящим начальникам, требует от своих солдат выполнения определенной тяжелой работы и наказывает их при неподчинении. Генерал, узнав об этом, допускает продолжение этой работы, хотя если бы он приказал сержанту прекратить это делать, то тот выполнил бы приказ. В данных обстоятель-

ствах можно считать, что генерал молчаливо выразил свою волю и пожелал, чтобы солдаты выполняли тяжелую работу. Его невмешательство, когда он мог бы вмешаться, является молчаливой заменой слов, которые он мог бы произнести, приказав продолжать работу.

Именно с этой точки зрения нам предлагается рассматривать обычные правила, которые имеют статус закона в правовой системе. Пока суды их применяют в отдельных судебных делах, такие правила являются просто обычаями и ни в коем смысле не правом. Правовое признание эти правила получают лишь тогда, когда суды их используют и выносят в соответствие с ними обязательные для исполнения судебные решения. Суверен, вмешавшись, может молча приказать подчиненным исполнять судебные решения, «оформленные» на манер ранее существовавшего обычая [24].

Такая оценка правового статуса обычая открыта для критики двоякого рода. Во-первых, вовсе не очевидно, что обычные правила не имеют правового статуса до того, как использованы в судебном разбирательстве. Утверждение, что это *необходимо* так, либо просто догма, либо не различает действительно необходимое от того, что может иметь место в некоторых правовых системах. Почему законы, принятые определенным образом, являются правом еще до применения их судами в отдельных судебных делах, в то время как по крайней мере некоторые обычаи таковым не являются? Разве не обстоят дела таким образом, что как суды признают связывающим принцип, согласно которому законом является все то, что постановил законодатель, так же точно они могут признать в качестве общего принципа положение, согласно которому законом является все то, что определено обычаями определенного рода? Почему утверждение, что в отдельных делах наряду с законом суды применяют предписанное обычаем, как если бы это уже был закон или поскольку это закон, кажется некоторым абсурдным? Конечно, вполне может быть, что в конкретной правовой системе предусмотрено положение, согласно которому ни одно обычное правило не может получить статуса закона до тех пор, пока суды по своему неограниченному усмотрению (uncontrolled-discretion) не решат, что это должно быть так. Но это лишь один из возможных вариантов, который не исключает возможность существования систем, где суды не имеют такой свободы действий. Каким же образом можно доказать общее утверждение, что обычное правило не может иметь статуса права до применения в суде?

Ответы на эти возражения иногда сводятся не более чем к повторению догмы, согласно которой ничто не может быть правом до тех пор, пока кто-либо не установил это своим *приказом.* Предлагаемая параллель между отношениями судов к закону и к обычаю затем отвергается на том основании, что перед применением судом закон уже утвержден прика-

зом, а обычай нет. Менее догматичные аргументы неадекватны, поскольку опираются на слишком частные особенности отдельных правовых систем. В качестве аргумента в пользу того, что обычай не является правом до того, как применен судами, часто приводится тот факт, что в английском праве обычай может быть отвергнут судами, если он не удовлетворяет критерию «разумности». Однако это положение доказывает лишь, что таков статус обычая в английском праве. Но даже это утверждение не может быть обосновано, если не считать, как это делают некоторые, что бессмысленно отличать систему, в которой суды обязаны применять некоторые обычное правила, если они разумны, от системы, в которой они обладают неограниченной свободой действий.

Второе возражение против теории, согласно которой обычай получает правовой статус благодаря молчаливому приказу суверена, более фундаментально. Даже если принять, что обычай не является правом до его применения судом в определенном деле, то можем ли мы трактовать невмешательство суверена как его желание, чтобы подобные правила выполнялись? Даже в простом примере из военной службы, приведенном страницей ранее, из того факта, что генерал никак не отреагировал на приказы сержанта, с необходимостью не следует, что он желал, чтобы они исполнялись. Возможно, он принял сторону нижестоящего чина и решил, что солдат найдет способ уклонения от тяжелых работ. Несомненно, в некоторых случаях мы можем прийти к выводу, что он желал выполнения тяжелых работ, однако в таком случае материальной составляющей наших данных будет уверенность в том, что генерал знал о приказе, имел возможность его обдумать и решил ничего не предпринимать. Основным возражением против использования идеи молчаливого волеизъявления суверена в объяснении правового статуса обычая служит замечание, что в современном государстве только в редких случаях возможно приписать суверену, будь то высший законодательный орган или электорат, такое знание, размышление и сознательное решение не вмешиваться. Конечно, верно, что в большинстве правовых систем обычай как источник права стоит ниже статута. Это значит, что законодатель мог бы лишить его правового статуса, однако отказ сделать это не может автоматически считаться волеизъявлением законодателя. Внимание законодателя, и тем более электората, очень редко непосредственно обращено на обычные правила, применяемые судами. Поэтому их невмешательство не может сравниваться с невмешательством генерала в примере с сержантом; даже если в последнем случае мы готовы признать, что генерал желал, чтобы приказы подчиненных выполнялись.

Тогда в чем же состоит правовое признание обычая? Что же в таком случае придает обычному правилу правовой статус, если это не решение суда, который применил его в конкретном деле, и не молчаливый приказ

верховной законодательной власти? Возможно ли, чтобы он стал законом, подобно статуту, еще до того, как применен судом? На эти вопросы можно дать исчерпывающий ответ только после подробного рассмотрения доктрины, согласно которой закон имеет место лишь в том случае, когда он устанавливается явными или молчаливыми приказами суверенного лица или лиц. Об этом речь пойдет в следующей главе, пока же подведем итоги этой главы, которые сводятся к следующему.

Теория права как принудительных приказов сразу же наталкивается на возражение, согласно которому во всех правовых системах имеют место формы права, которые в трех основных аспектах не соответствуют этому описанию. Во-первых, даже уголовный статут, более всего напоминающий приказ, нередко имеет сферу применения, отличную от той, которую он должен был бы иметь, будь он приказом, адресованным другим; ведь такой закон, наряду со всеми остальными, может налагать обязанности и на его создателей. Во-вторых, другие статуты отличаются от приказов тем, что они не требуют от лиц совершения действий, но напротив, предоставляют им права; они не налагают обязанностей, но открывают возможности для свободного создания юридических прав и обязанностей в пределах принудительной структуры (coercive framework) закона. В-третьих, хотя процедура принятия статута некоторым образом аналогична отдаче приказа, отдельные правила законодательства возникают из обычая, а не получают правовой статус в результате сознательного правотворческого акта.

От этих возражений теорию пытались защитить различными средствами. Исходно простая идея угрозы неблагоприятных последствий (threat of evil) или «санкции» была расширена за счет включения понятия ничтожности юридических сделок; в то же время понятие легального правила было ограничено таким образом, чтобы исключить такие правила, которые наделяют властью; эти последние рассматривались лишь в качестве фрагментов законов; для объяснения самообязывающего эффекта некоторых законов в физически едином законодателе было выявлено два лица; понятие приказа было расширено и стало применяться не только по отношению к устным распоряжениям, но и в связи с «молчаливым» волеизъявлением, которое можно свести к невмешательству в распоряжения подчиненных. При всей изобретательности этих мер модель приказов, подкрепленных угрозами, скрывает в правовой сфере больше, нежели выявляет; попытка свести все разнообразие законов к этой простой и единой форме приводит к тому, что праву навязывается ложное единообразие. На самом деле поиск единообразия в данном случае ведет к ошибкам, ибо, как это будет видно из пятой главы, важнейшей особенностью права является слияние в нем различных типов правил [25].

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СУВЕРЕН И ПОДДАННЫЙ

Критикуя простую модель принуждающих приказов, мы до сих пор не поднимали вопроса о лице или лицах, обладающих «суверенной» властью, чьи приказы, согласно данной концепции, составляют право в любом обществе [26]. В самом деле, обсуждая адекватность идеи приказа, подкрепленного угрозами, в качестве описания законов различного типа, мы условно предположили, что в любом обществе с правом действительно есть суверен, характеризующийся утвердительно или отрицательно ссылкой на привычку к повиновению. Это лицо или группа лиц отдает приказы, которым большинство общества привычно повинуется, в то время как он сам привычно не повинуется приказам каких-либо других лиц или органов.

Рассмотрим эту общую теорию, касающуюся оснований всех правовых систем в некоторых деталях; ведь, невзирая на крайнюю простоту, доктрина суверенитета не является чем-то меньшим. Она утверждает, что в каждом человеческом сообществе с правом, как в демократическом государстве, так и при абсолютной монархии, в конечном итоге за всем разнообразием форм политической жизни лежит эта простая связь между подданными, которые по привычке повинуются, и сувереном, который привычно не повинуется никому. Эта вертикальная структура, как утверждается в данной теории, столько же существенна для любого общества, в котором существует право, как позвоночник для человека. При наличии такой связи мы можем говорить об обществе и его суверене как независимом государстве, и о *его* праве. Если же такой связи не существует, мы не можем употреблять ни одно из этих выражений, так как, согласно данной теории, отношения между сувереном и подданными являются составной частью самого их (выражений) смысла.

Два положения этой теории особо важны, и мы уделим им здесь особое внимание в достаточно абстрактной форме перед тем, как наметить те направления критики, которые будут детально рассматриваться в оставшейся части главы. Первое положение касается идеи *привычки* к повиновению (habit of obedience), — единственного, что требуется от тех, к кому применяются законы суверена. Здесь мы рассмотрим, достаточно ли

привычки такого рода для того, чтобы породить две важнейшие особенности любой правовой системы: *непрерывность* власти создавать право, которая последовательно передается от одного законодателя к другому, и *сохранение* права в течение длительного периода уже после того, как законодатель и привычно повинующиеся ему подданные ушли в мир иной. Второй особенностью является позиция суверена, который находится выше закона: он создает право для других, налагая обязанности или «ограничения» на них, в то время как сам, согласно этой теории, не является и не может быть ограничен правом. Нам следует выяснить, является ли такой статус неограничимости правом верховного законодателя необходимым условием для существования права, а также может ли наличие или отсутствие правовых ограничений законодательной власти быть понято в простых терминах обычая и повиновения, к которым эта теория сводит данные понятия.

1. ПОВИНОВЕНИЕ ПО ПРИВЫЧКЕ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРАВА

Идея повиновения, как и многие другие идеи, не подвергнутые пристальному изучению, выглядят простыми лишь на первый взгляд и не лишены сложностей. Оставим в стороне уже отмеченную сложность, связанную с тем, что слово «повиновение» нередко указывает на уважение к авторитету, а не только лишь подчинение приказам, подкрепленным угрозами. Даже в случае простого приказа, который отдается одним человеком другому, не всегда легко установить, какая именно связь должна быть между отдачей приказа и совершением обозначенного им действия для того, чтобы последнее могло быть названо «повиновение». Например, как связан с этой ситуацией случай, когда человек, которому отдается приказ, все равно поступил бы точно таким же образом и без приказа? Эти затруднения особенно характерны для законов, которые запрещают людям делать такие вещи, которые многие из них и никогда и не подумали бы делать. До тех пор пока это и подобные затруднения не разрешены, идея «всеобщей привычки повиновения» законам той или иной страны выглядит несколько туманной. Однако мы можем, для наших целей, представить себе очень простой случай, когда слова «привычка» и «повиновение», возможно, были бы вполне очевидно применимы.

Представим себе, что население живет на территории, где в течение очень длительного времени правит абсолютный монарх (Рекс): он контролирует своих подданных посредством приказов, подкрепленных угрозами, заставляя их поступать определенным образом и воздерживаться от определенных действий, причем если бы не было этих приказов, то

они никогда бы не делали этого по собственной воле и предпочли бы обратное. В самом начале правления ему было сложно, однако впоследствии ситуация стабилизировалась и стало возможным полагаться на повиновение людей. Поскольку требования Рекса нередко обременительны, а соблазн ослушаться приказа и пойти на риск наказания вполне существенен, едва ли можно утверждать, что повиновение, хотя и всеобщее, в данном случае будет «привычкой» («habit») или «привычным» («habitual») в полном или наиболее обычном смысле этого слова. Люди могут в буквальном смысле приобрести привычку выполнять определенные законы: езда по левой стороне дороги, вероятно, является для англичан парадигмальным примером подобной приобретенной привычки. Однако там, где законы, направлены против наших сильных наклонностей, как, например, законы, предписывающие платить налоги, наше, в конечном итоге, повиновение им, даже будучи регулярным, не имеет нерефлексивного, не требующего усилий и укоренившегося характера привычки. Тем не менее, хотя в повиновении Рексу часто будет отсутствовать этот элемент привычки, для него будут характерны другие важные ее особенности. Утверждение, что данный господин имеет, к примеру, привычку просматривать прессу за завтраком, предполагает, что он делает это в течение длительного времени и скорее всего продолжит делать это и в будущем. Если это так, то и в нашем воображаемом обществе большинство людей, после некоторого периода нестабильности в начале правления Рекса, обычно подчиняются приказам монарха и скорее всего будут поступать таким же образом и в будущем.

Отметим, что в таком обществе привычка повиновения основывается на личных отношениях между монархом и каждым отдельно взятым подданным: каждый регулярно выполняет то, что Рекс приказывает в числе прочих лично ему. Если мы скажем, что *население* «имеет такую привычку», то это утверждение, как и то, что обычно люди субботние вечера проводят в тавернах, будет означать лишь то, что обычаи многих людей схожи: каждый из них обычно подчиняются Рексу подобно тому, как каждый из них имеет привычку проводить субботний вечер в таверне.

Заметим, что в этой очень простой ситуации единственное, что требуется от общества для того, чтобы Рекс был сувереном, — это повиновение каждого из членов этого общества. Каждый из них, со своей стороны, должен лишь повиноваться; и как только повиновение станет регулярным, никому в этом обществе не потребуется осознавать правильность своих действий или высказывать мнение о том, является ли его собственное или других людей повиновение Рексу правильным, подобающим или законным. Разумеется, общество, описанное нами для того, чтобы как можно более буквально применить понятие привычки к повиновению, устроено очень просто. Оно, вероятно, устроено слишком

просто, чтобы соответствовать какой-либо реальной ситуации, и в любом случае не похоже на примитивное общество, так как в примитивных обществах практически неизвестны абсолютные властители, подобные Рексу, а члены этих обществ не только повинуются, но и высказывают свои взгляды по поводу правильности повиновения тех, кого это касается. И все же, общество, управляемое Рексом, конечно, обладает рядом особенностей, характерных для обществ, управляемых законом, по крайней мере на протяжении жизни Рекса. Оно обладает некоторым единством, что позволяет назвать его «государством». Это единство определяется тем фактом, что все члены общества подчиняются одному и тому же лицу, даже если они не рассматривают вопроса о том, правильно это или нет.

Теперь предположим, что после успешного правления Рекс умирает, оставляя после себя сына Рекса II, который тут же начинает отдавать общие приказы. Из того факта, что Рексу I все привычно повиновались при его жизни, вовсе не следует, что все будут привычно выполнять приказы Рекса II. Так что, если мы не имеем в своем распоряжении ничего, кроме факта повиновения Рексу I и вероятности того, что *ему* продолжат повиноваться, мы не сможем сказать о первом приказе Рекса II, как могли бы сказать о последнем приказе Рекса I, что он был отдан сувереном, а следовательно, является законом. Привычка повиновения Рексу II еще не сформировалась. Только время покажет, будут ли приказам Рекса II повиноваться так же, как и приказам его отца. Лишь тогда мы сможем сказать, в соответствии с теорией, суверен он или нет и являются ли правом его приказы. Ничто не делает его сувереном с самого начала. Лишь после того как мы узнаем, что его приказам повинуются в течение некоторого времени, мы сможем сказать, что привычка повиноваться ему установилась. Тогда, но не до этого, мы сможем сказать о любом последующем приказе, что он уже является законом, когда отдается и до того, как ему повинуются. До этого имело место своего рода междуцарствие, когда никакой новый закон не мог быть принят.

Подобное положение дел, конечно, возможно, и иногда реализовывалось во времена смут; однако опасности подобного разрыва очевидны и обычно его стремятся избегнуть. Напротив, даже при абсолютной монархии правовая система стремится сохранить непрерывность законодательной власти при помощи правил, которые помогают совершить переход от одного законодателя к другому. Такие правила *заранее* определяют порядок престолонаследия, описывая или определяя в общих понятиях требуемые качества и способ определения законодателя. В современных демократических обществах эти условия очень сложны и касаются формирования законодательного органа с изменяющимся составом, однако существенные элементы, обеспечивающие непрерывность власти, сохраняются и для нашего простейшего случая воображаемой монархии. Если

существует правило, согласно которому отцу наследует старший сын, то Рекс II имеет *право* наследовать своему отцу. Он получает *право* принимать законы после смерти своего отца, и когда издаются первые же его приказы, у нас могут быть хорошие основания сказать, что они уже являются правом, еще до того, как между ним и подданными установятся отношения личного и привычного повиновения. На самом деле подобные отношения могут и не установиться. И все же его слово будет законом — ведь Рекс II может также умереть вскоре после того, как отдаст первые приказы, так что у него не будет времени сформировать у подданных привычку повиновения, и все же у него будет *право* законодательствовать, и его приказы будут законом [27-28].

Объясняя непрерывность законодательной власти при изменяющейся последовательности индивидуальных законодателей, естественно употреблять такие выражения, как «правило определения наследника», «титул наследника», «право наследования» и «право принимать законы». Ясно, что с этими выражениями мы вводим набор новых элементов, которые не могут быть адекватно описаны в терминах привычки повиновения общим приказам, при помощи которых, следуя нашей теории суверенитета, мы сконструировали простейший правовой порядок Рекса I. Ведь в этом мире изначально не было каких-либо правил, а также прав и титулов, а следовательно, a fortiori никакого права или титула наследника: в нашем распоряжении был лишь тот факт, что приказы отдавались Рексом I и подданные им привычно повиновались. Для того чтобы утвердить Рекса в качестве суверена на протяжении его жизни и сделать его приказы законом, ничего более не было нужно; однако этого недостаточно для того, чтобы описать *права* его наследника. В самом деле, идея привычного повиновения, по двум, хотя и связанным причинам, не в силах объяснить непрерывность, характерную для любой нормальной правовой системы, когда один законодатель сменяет другого. Во-первых, простая привычка повиноваться приказам, отданным одним законодателем, не может дать новому законодателю *права* наследовать старому и отдавать приказы вместо него. Во-вторых, привычное повиновение старому законодателю само по себе не делает вероятным и не создает презумпцию того, что приказы нового законодателя также будут по привычке исполняться. Для того, чтобы это право и эта презумпция были в момент наследования, во время правления предыдущего законодателя в обществе где-то должна была присутствовать социальная практика более сложная, нежели та, которая может быть описана в понятиях привычки повиновения: именно, должно было бы существовать признание правила, определяющее условия наследования нового законодателя старому.

Какова эта более сложная практика? Что значит признание такого правила? Здесь следует резюмировать уже сказанное в первой главе. Для

ответа нам следует на мгновение оставить в стороне этот специальный случай правовых правил. Чем привычка отличается от правила? В чем состоит различие между ситуацией, когда о группе можно сказать, что она имеет привычку, например ходить в кино по субботним вечерам, и утверждением, что существует правило, предписывающее мужчинам снимать шляпу при входе в церковь? В первой главе мы уже упомянули о некоторых элементах, которые следует принимать во внимание при анализе правил этого типа, теперь нам следует сделать следующий шаг.

Есть один момент сходства между социальными правилами и привычками: в обоих случаях поведение (например, снятие головного убора в церкви) должно быть общим, хотя не обязательно неизменным; это означает, что в определенных случаях большая часть населения поступает именно так в той мере, в какой это предполагается во фразе: «Они, как правило, делают это». Но, хотя и есть это сходство, существуют и три важных отличия.

Во-первых, для того, чтобы группа имела обыкновение поступать определенным образом, достаточно того, чтобы их поведение на самом деле было сходным. Отклонение от этого обычного хода действий может и не быть предметом какой-либо критики. Но подобное сходство или даже идентичность поведения не достаточны для того, чтобы создать правило, такое поведение предписывающее. Там, где существует такое правило, отклонения от него обычно рассматриваются как ошибки и виновное поведение, заслуживающие критики. Угроза таких отклонений встречается с давлением в пользу соответствия правилу, хотя формы критики и давления различаются в различных случаях.

Во-вторых, при наличии подобных правил такая критика не только осуществляется, но отклонения от стандарта поведения, обычно расценивается как *хорошее основание* для критики. Критика отклонения от правила расценивается в подобном случае как законная и оправданная реакция на него, равно как и требование согласовывать свое поведение с правилом. Более того, за исключением закоренелых нарушителей, подобная критика и требования расцениваются как законные и оправданные или выдвинутые с хорошими основаниями как теми, кто создает эти правила, так и теми, кто должен их выполнять. Какая часть группы должна принимать такое правило и считать его нарушение основанием для критики, а также насколько часто и в течение сколь длительного времени эти люди должны поступать так для того, чтобы оправдать утверждение, что в данном случае группа действительно следует определенному правилу, — это вопрос не простой. Однако он должен занимать нас не более вопроса о том, сколько у человека должно быть волос на голове, чтобы его все еще можно было считать лысым. Мы только должны помнить, что утверждение о том, что группа следует определенному

правилу, совместимо с существованием меньшинства, которое не только нарушает это правило, но и отказывается считать его образцом поведения либо для себя, либо и для других.

Третья особенность, отличающая правила от обычаев, имплицитно содержится в том, что уже было сказано, однако она настолько важна и настолько часто игнорируется или не понимается юристами, что на ней следует остановиться подробней. Эту особенность на страницах данной книги мы будем называть *внутренним аспектом* правил (internal aspect of rules). Когда обычай универсален для всей группы, это выражается лишь в том, что наблюдаемое поведение большей части группы соответствует определенному стереотипу. Для существования обычая ни один из членов группы вовсе не должен думать о нем как всеобщем стереотипе поведения или даже осознавать тот факт, что данное поведение носит универсальный характер. Еще менее он должен испытывать потребность специально обучать ему или поддерживать его. Достаточно того, что каждый фактически поступает так же, как и другие. Напротив, для существования социального правила необходимо, чтобы по крайней мере некоторая часть группы рассматривала соответствующее поведение в качестве общего стандарта, которому должна следовать вся группа как целое. Социальное правило имеет некоторый «внутренний» аспект в дополнение к «внешнему» аспекту, который характерен и для социального обычая и состоит в регулярном и единообразном поведении, которое может зафиксировать наблюдатель.

Этот внутренний аспект может быть проиллюстрирован на примере любой игры. Игроки в шахматы не только имеют обыкновение двигать ферзя одинаково, как это может показаться внешнему наблюдателю, ничего не знающему об отношении игроков к тем ходам, которые они делают. Вдобавок к этому они обладают рефлективным критическим отношением к такому поведению: они считают его стандартом для всех играющих в эту игру. Каждый из игроков не просто двигает ферзя определенным образом, но «имеет взгляды» на такого рода движения как обязательные для всех игроков. Его убеждение может найти выражение в критике по отношению к другому игроку, который отклоняется или может отклониться от правила, а также в признании законности подобной критики и требований соблюдать правила по отношению к себе. Для выражения критики, требований и признания используется различная «нормативная» лексика: «Я (Вы) не должен (должны) двигать ферзя таким образом», «Я (Вы) должен (должны) делать так», «Это правильно», «Это неправильно».

Внутренний аспект правил часто ошибочно противопоставляется наблюдаемому с точки зрения внешней позиции поведению как всего лишь «ощущения» участников событий. Несомненно, в ситуации, когда

правила получают всеобщее признание со стороны социальной группы и поддерживаются критикой и давлением со стороны общества, отдельные лица могут психологически воспринимать требования соблюдать правила как ограничение или принуждение. Говоря, что они «чувствуют себя обязанными» поступать определенным образом, они могут иметь в виду именно этот опыт. Но такие чувства не необходимы и недостаточны для существования «обязывающих» правил. Нет никакого противоречия в том, что люди могут принимать определенные правила, однако не испытывать в их связи ощущения принуждения. Напротив, критическое и рефлективное отношение к определенным образцам поведения, рассматриваемым как общий стандарт, необходимо, и оно должно проявляться в критике (в том числе своего собственного поведения), требованиях соблюдать правила и признании того, что критика и требования подобного рода оправданны. Все это выражается при помощи таких нормативных оборотов, как «вам следует», «вы должны», «вам надлежит», «правильно», и «неправильно».

Таковы важнейшие особенности, которые отличают правила от всего лишь обычного поведения той или иной группы. Помня об этом, вернемся снова к праву. Можно предположить, что наша социальная группа может руководствоваться не только правилами, которые, как в случае требования снимать головные уборы в церкви, задают стандарт должного поведения, но и правилом, которое обеспечивает выявление стандартов поведения более косвенным образом, указывая на слова определенного лица, произнесенные или записанные. В простейшем случае это правило может состоять в требовании выполнять все, что сказал Рекс (возможно, при определенных формальных обстоятельствах). Это положение изменяет исходную ситуацию, ранее описанную в терминах привычки повиновения Рексу: ведь как только это правило признано, Рекс не только фактически определяет должное поведение, но и получает *право* делать это; так что будет иметь место не просто всеобщее повиновение его приказам, но и всеобщее убеждение в том, что повиновение ему *правильно.* Рекс станет фактическим законодателем с *авторитетной властью* издавать законы, то есть устанавливать новые стандарты поведения в жизни группы, причем нет никаких причин, — поскольку мы сейчас говорим о стандартах, а не «приказах», — которые препятствовали бы ему самому быть связанным собственным законодательством.

Социальные практики, лежащие в основе такой законодательной власти, будут по сути теми же, что и лежащие в основе простых правил поведения, подобных требованию снимать головной убор в церкви, которые мы теперь можем обозначить как просто правила обычая; таким же образом они будут отличаться и от общих привычек. *Слово* Рекса теперь задает стандарт поведения, так что отклонения от предписанного

им поведения вызовут критику; на его слово теперь будут ссылаться в качестве основания для критики и требований выполнять правило.

Для того чтобы понять, как эти правила объясняют непрерывность законодательной власти, достаточно лишь заметить, что в некоторых случаях, еще то того как новый законодатель начал свою законодательную деятельность, может быть ясно, что уже существует четко установленное правило, предоставляющее ему, как представителю определенного класса или династии, право делать это в свою очередь. Так в течение жизни Рекса I группа может придерживаться правила, согласно которому лицо, которому следует повиноваться, не сводится к Рексу I как индивиду, но к тому, кто соответствует определенным требованиям, например является старшим живым наследником по прямой линии некоторого предка. Рекс I всего лишь конкретное лицо, соответствующее таким требованиям в данное время. Правило подобного рода, в отличие от привычки повиноваться Рексу I, направлено в будущее, так как касается не только нынешнего законодателя, но и всех, кто придет после него.

Принятие, а значит, существование, такого правила на протяжении жизни Рекса I выражается как в повиновении ему, так и в признании, что он имеет право на повиновение такого рода потому, что соответствует тем требованиям, которые общее правило предъявляет к лицам подобного рода. Так как такое правило, будучи принятым определенной группой, определяет условия преемственности законодательной власти, его принятие позволяет обосновать *как* положение правового характера, о том, что преемник имеет право законодательствовать еще до того, как он начал это делать, *так* и положение фактического характера, что новому законодателю скорее всего будут подчиняться так же, как и его предшественнику.

Разумеется, признание этого правила обществом в определенный момент времени *не гарантирует* его признания в другой период времени. Может случиться революция, и общество перестанет признавать это правило. Это может произойти либо при жизни одного законодателя, Рекса I, или же в момент перехода к другому, Рексу II, и если это случится, то Рекс I утратит или Рекс II не получит законодательные полномочия. Ситуация может быть более темной: возможны промежуточные стадии, когда еще непонятно, имеем ли мы дело с восстанием или временным нарушением старого правила, или же полномасштабным действительным отказом от него. Однако в принципе ситуация ясна. Утверждение, что новый законодатель имеет право законодательствовать, предполагает наличие в социальной группе правила, которое дает ему это право. Если правило, в соответствии с которым он получает этот свой статус, было установлено во времена его предшественника, статус которого также определялся им, то естественно предположить, если ничто не

указывает на противоположное, что это правило не оставлено и по-прежнему в силе. Подобная же преемственность наблюдается и в игре, когда судья, если ничто не говорит о том, что правила изменились со времен предыдущего матча, засчитывает новому игроку очки по обычным правилам.

Рассмотрение простых законодательных миров Рекса I и Рекса II, возможно, достаточно для того, чтобы показать, что непрерывность законодательной власти, характерная для большинства правовых систем, зависит от той формы социальной практики, которая поддерживает правило, и отличается указанным способом от простого и фактического повиновения по привычке. Мы можем суммировать эту аргументацию следующим образом. Даже если мы признаем, что определенное лицо, такое, как Рекс, чьи общие приказы привычно исполняются, может быть названо законодателем, а его приказы законами, привычки повиноваться каждому из сменяющих друг друга законодателей такого рода недостаточно для того, чтобы объяснить *право* наследника сменять своего предшественника, и непрерывность законодательной власти. Во-первых, привычки не носят «нормативного» характера, поэтому они не могут наделять кого бы то ни было правами или властью. Во-вторых, поскольку привычка повиноваться одному лицу не может, в отличие от правила, распространиться на класс или династию будущих законодателей, или сделать повиновение им вероятным. Так что сам по себе факт повиновения по привычке одному законодателю не позволяет заключить, что его преемник также будет иметь право законодательствовать; не следует отсюда и фактуальное утверждение, что ему, вероятно, будут также подчиняться.

Сейчас следует отметить еще один важный момент, который будет более детально разработан в следующей главе. Он составляет одну из сильных сторон теории Остина. Стремясь выявить важнейшие различия между принятыми правилами и обычаями, мы взяли в качестве примера очень простую модель общественного устройства. Прежде чем оставить этот аспект суверенитета, нам следует рассмотреть, насколько точно наше описание принятия правила, дарующего авторитетное право законодательствовать, может быть перенесено на современное общество. Обращаясь к нашему простейшему обществу, мы говорили о нем так, как будто большинство обычных людей не только исполняли законы, но и понимали и принимали правило, определяющее порядок перехода власти от одного законодателя к другому. Возможно, именно так обстояли дела в простейшем обществе; однако в современном государстве было бы абсурдным думать о большинстве населения, сколь бы оно ни было законопослушным, что оно имеет сколько-нибудь ясное представление о правилах, специфицирующих квалификацию законодательного органа,

состав которого постоянно изменяется. Говоря о «признании» этих правил населением, мы должны предположить, что обычные люди понимают конституционное устройство во всей его сложности так же хорошо, как члены небольшого племени понимали и признавали авторитет сменяющих друг друга вождей. На самом деле подобным знанием должны обладать лишь официальные лица и специалисты, суды, которые ответственны за определение того, что есть право, а также юристы, к которым обращаются обычные граждане по вопросам права.

Указанные отличия в организации простейшего племени и современного общества заслуживают самого пристального внимания. В каком же смысле мы тогда говорим о непрерывности законодательной власти Королевы в Парламенте, сохраняющейся при смене законодателей и базирующейся на неком фундаментальном и всеми признаваемом правиле или правилах? Ясно, что всеобщее признание в данном случае будет сложным явлением, в некотором смысле разделенным между официальными лицами и простыми гражданами, которые вносят свой вклад в него и тем самым в *существование* правовой системы различным образом. Можно сказать, что официальные лица эксплицитно признают эти фундаментальные правила, наделяющие законодательной властью: законодатели делают это, принимая законы в соответствии с правилами, которые дают им соответствующие полномочия; суды — идентифицируя в качестве подлежащих применению законов решения тех, кто вправе создавать законы, а эксперты — помогая обычным гражданам указаниями на принятые таким образом законы. Простой гражданин в основном выражает принятие этих правил посредством согласия с результатами действий официальных лиц. Он придерживается закона, принятого и идентифицированного таким образом, выдвигая требования, и пользуясь правами, которые закон ему предоставляет. Однако он может почти ничего не знать о происхождении этого закона и самих законодателях: некоторые могут вообще ничего не знать о законах кроме того, что это «закон». Закон запрещает определенные действия, которые рядовые граждане могли бы желать совершить, и они знают, что могут быть арестованы полицейским и посажены в тюрьму по решению суда, если не будут повиноваться закону. Сильной стороной доктрины, которая настаивает на том, что в основании правовой системы лежит обычное повиновение приказам, подкрепленным угрозами, является то, что она заставляет нас думать реалистично об этом относительно пассивном аспекте сложного феномена, который мы называем существованием правовой системы. Но слабой стороной этой доктрины является то, что в результате она затемняет или искажает другой относительно активный аспект, который виден в основном, хотя и не исключительно, в законодательной практике, идентификации законов и в их применении официальными лицами и

экспертами. Оба эти аспекта следует иметь в виду, если мы желаем понять этот сложный социальный феномен таким, как он есть на самом деле [29].

2. ПОСТОЯНСТВО ПРАВА

В 1944 г. в Англии была осуждена женщина, обвиненная в предсказании будущего в нарушение *Акта о колдовстве* 1735 г.[1] Это всего лишь живописный пример известного правового феномена: статут, принятый столетия назад, может быть правом и поныне. И это постоянство права, как бы оно ни было нам знакомым, не может быть объяснено в понятиях простой схемы, согласно которой законы являются приказами, отдаваемыми лицом, которому повинуются по привычке. В этом случае мы сталкиваемся с обратной стороной проблемы непрерывности законодательной власти, о которой только что шла речь. Ранее мы спрашивали, как, основываясь на простой схеме привычки повиновения, можно утверждать, что первый же закон, изданный наследником предыдущего законодателя, *уже* является законом до того, как сформировалась привычка повиноваться именно ему? Теперь нас интересует следующий вопрос: как может закон, изданный законодателем много лет назад, *по-прежнему* оставаться законом в обществе, которое уже давно не повинуется ему по привычке? Как и в первом случае, никакой проблемы не возникнет, если речь идет о времени жизни самого законодателя. Это предположение, как кажется, прекрасно объясняет, почему *Акт о колдовстве* был законом в Англии, но не был бы во Франции, даже если бы его положения распространялись и на французских граждан, предсказывающих будущее во Франции, хотя, конечно, мог бы применяться к тем французам, которым случилось предстать перед английским судом. Простым объяснением будет утверждение, что в Англии в то время привычно повиновались тому, кто издал этот акт, в то время как во Франции — нет. Поэтому он был законом в Англии, но не во Франции.

Однако мы не можем ограничивать законы временем жизни их авторов, ведь наша задача состоит в том, чтобы объяснить то обстоятельство, что законы способны пережить своих создателей и тех, кто по привычке им повиновался. Почему *Акт о колдовстве* для Англии все еще закон, в то время как он не был законом для французов во время его принятия? Очевидно, даже с очень большой натяжкой невозможно сказать, что в наши дни англичане по привычке повинуются Георгу II и его Парламенту. В этом отношении современная Англия и тогдашняя Фран-

[1] R. v. Duncan [1944] 1 KB 713.

ция похожи: они не повинуются и не повиновались создателю закона. *Акт о колдовстве* мог бы быть единственным актом, сохранившимся с тех пор, и все-таки он и ныне был бы законом в Англии. Ответ на вопрос: «Почему это все еще закон?» — в принципе тот же, что и ответ на наш предыдущий вопрос: «Почему уже закон?», — и предполагает замену слишком простого понятия привычки повиновения конкретному суверену понятием принятых в настоящее время фундаментальных правил, специфицирующим класс или династию лиц, чье слово задает стандарты поведения в обществе, то есть тех, кто имеет *право* законодательствовать. Такое правило, хотя оно должно существовать сейчас, в некотором смысле может быть вневременным: оно может не только смотреть вперед и касаться законодательной деятельности будущих законодателей, но и смотреть назад и указывать на действия законодателей прошлого.

Будучи представленной в простых понятиях династии Рекса, ситуация выглядит следующим образом. Каждый из династии законодателей, Рексы I, II и III, становятся таковыми согласно общему правилу, которое передает право законодательной власти старшему из ныне живущих наследников по прямой линии. После смерти данного законодателя изданные им законы продолжают жить; и это основывается на общем правиле относительно каждого законодателя, когда бы он ни жил, которое последующие поколения в данном обществе продолжают уважать. В простейшем случае Рексов I, II и III каждый из них, согласно этому общему правилу, имеет право устанавливать нормы поведения своим законодательством. В большинстве правовых систем ситуация не столь проста, так как в настоящее время правило, на основании которого признается законодательство прошлых лет, может отличаться от правила, определяющего ситуацию с современным законодательством. Однако при условии принятия основного правила непрерывность права становится явлением, загадочным не более чем тот факт, что решения арбитра после смены состава игроков во втором раунде будут учитываться при определении общего счета игры; то же произойдет, если в третьем раунде сменится сам арбитр. И все же, хотя и не столь загадочное, понятие признанного правила, наделяющего авторитетной властью приказы прошлых, будущих и настоящих законодателей, является более сложным и изощренным, нежели идея привычки повиновения современному законодателю. Можно ли избавиться от этого усложнения при помощи какого-либо хитроумного расширения простого понятия приказов, подкрепленных угрозами, показав, каким образом непрерывность права в конечном итоге базируется на простом факте повиновения по привычке нынешнему суверену?

Была предпринята по крайней мере одна подобная попытка: так считал Гоббс, а за ним следом Бентам и Остин утверждали, что «законо-

дателем является не тот, чьей авторитетной властью были созданы первые законы, но тот, чьей авторитетной властью они сейчас продолжают оставаться законами» [1]. Из этого положения непосредственно не ясно, чем может отличаться «авторитет» законодателя от его «власти», если мы избавимся от понятия правила в пользу более простой идеи привычки. Однако общий смысл утверждения вполне ясен. Он в том, что, хотя источник или происхождение закона, такого как *Акт о колдовстве* в историческом смысле слова является результатом законодательной деятельности бывшего суверена, своим современным статусом в качестве закона Англии он обязан признанием его в этом качестве со стороны нынешнего суверена. Это признание принимает форму не *эксплицитного* приказа, как в случае со статутами, принимаемыми нынешними законодателями, но *молчаливому* выражения воли суверена. Это состоит в том, что он не возражает, хотя и мог бы, против использования органами власти (судами и, возможно, исполнителями приговора) статута, принятого много лет назад.

Это, конечно, та же теория молчаливых приказов, рассмотренная ранее и призванная объяснить правовой статус разнообразных обычных правил, по поводу которых, как представляется, никто никогда не издавал никакого приказа. Очевидно, что критика этой теории в третьей главе еще лучше подходит в случае с непрерывным признанием законов, принятых в прошлом. Ведь, учитывая право широкого усмотрения судов, которые могут отвергать неразумные обычные правила, резонно предположить, что до тех пор пока суд не применил то или иное обычное правило в конкретном случае, оно не имеет статуса закона, однако едва ли резонно считать, что статут, изданный прошлым «сувереном», не является законом до тех пор, пока суд не применил его в конкретном случае, и это решение не получило законной силы благодаря согласию со стороны действующего суверена. Если эта теория верна, то отсюда следует, что суды не придают законную силу этому статуту потому, что он уже является законом; и было бы абсурдным выводить это заключение из того факта, что нынешний законодатель мог бы повторить законы, изданные прошлыми законодателями, однако не воспользовался предоставленной ему властью. Ведь в современной Англии совершенно одинаковый правовой статус имеют как викторианские статуты, так и те, что провозглашены Королевой в Парламенте. Все они являются законами еще до того, как применены судами и, когда соответствующие случаи действительно возникнут, суды применяют викторианские и современные статуты именно потому, что они уже являются законами. Ни в одном случае эти законы не становятся законами лишь после их примене-

[1] Leviathan, chap. xxvi. См. также примечание 30 в конце книги.

ния; и в обоих случаях их статус в качестве законов обусловлен тем фактом, что они были провозглашены лицами, чья законодательная деятельность ныне признается авторитетной в соответствии с принятыми правилами, независимо от того, живы эти лица или нет.

Неадекватность теории, согласно которой статуты прошлых лет сохраняют свой статус в качестве законов потому, что современный законодатель соглашается с тем, что они используются судами, проявляется наиболее ясно в том, что она не в силах объяснить, почему современные суды должны делать различия между викторианскими статутами, которые не были отменены, считая их все еще законами, и статутом, отмененным во времена Эдуарда VII, не считая их более законами. Очевидно, что, проводя подобное различение, суды (а также юристы и любой простой гражданин, понимающий смысл права) пользуются в качестве критерия фундаментальным правилом или правилами, определяющими, что для судов законом является как настоящее, так и прошлое законодательство: они не базируют свое решение в выборе между двумя статутами на знании о том, признал ли нынешний суверен молчаливо (то есть позволил применять) тот или иной статут.

По-видимому, единственным достоинством отвергнутой нами теории является то, что она представляет собой размытую версию реалистичного напоминания (realistic reminder). В данном случае это напоминание, что если официальные лица, и прежде всего суд, не принимают правило, благодаря которому законодательный акт, современный или прошлых времен, считается авторитетным, то он лишается важнейшего свойства закона. Однако этот довольно банальный реализм не должен низводиться до уровня теории, некогда известной как теория правового реализма, основные особенности которой будут рассмотрены позже; в соответствии с некоторыми версиями этой теории статут вообще не считается законом до тех пор, пока он не применен судом. Существует различие, важное для понимания сущности права, между верным утверждением, что если статут является законом, то суды должны признавать правило, что определенные законодательные акты создают право, и вводящей в заблуждение теорией, согласно которой никакой акт не является законом до тех пор, пока не применен судом в конкретном случае. Некоторые версии правового реализма идут гораздо далее ошибочного объяснения феномена непрерывности законодательства, которую мы критиковали, так как они доходят до того, что отрицают правовой статус любого статута, современного или древнего, до тех пор, пока суд не применил его в конкретном случае. И все же объяснение непрерывности права, которое не признает полномасштабную теорию правого реализма и основывается на положении, что статуты современного суверена, в отличие от законов прошлого суверена, являются законами до того, как они применены судом, еще хуже и

совершенно абсурдно. Эта половинчатая позиция неверна потому, что мы не обладаем критерием, позволяющим различить правовой статус статута современного законодателя и неповторенного статута прошлого суверена. Либо они оба (как признают обычные юристы), либо ни один из них (как решит радикальный правовой реалист) не является законом до того, как применен современным судом к определенному казусу.

3. ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Доктрина суверенитета как всеобщей привычки повиновения подданных предполагает, что, напротив, сам суверен по привычке никому не подчиняется. Он создает право для подданных, сам находясь за пределами права. Для его законодательной деятельности нет и не может быть никаких правовых ограничений. Важно понимать, что суверен не ограничен правом по определению: теория всего лишь утверждает, что правовое ограничение может возникнуть, если законодатель будет выполнять приказы другого законодателя, которому он подчиняется по привычке; однако в этом случае он перестанет быть сувереном. Если он суверен, то не должен подчиняться другому законодателю, а значит, его законодательная власть не ограничена законными средствами. Важность этой теории, разумеется, не в этих определениях и выводах, которые с необходимостью следуют из них и из которых мы не можем извлечь никаких сведений о фактах. Она выражена в утверждении, что в каждом обществе, где есть право, должен быть суверен с этими атрибутами. Возможно, нам придется взглянуть за пределы правовых и политических форм, которые показывают, что всякая законодательная власть ограничена и ни одно лицо или лица не занимают того положения вне права, которое мы приписали суверену. Однако если мы хотим найти решение, то должны, как советует теория, попытаться найти действительность, скрывающуюся за фактами [31].

Не следует ошибочно интерпретировать эту теорию, усиливая или ослабляя положения, которые она развивает на самом деле. Теория не только утверждает, что существуют общества, где власть суверена не ограничена правом, но и что сам факт существования права предполагает наличие суверена подобного рода. С другой стороны, теория не настаивает на том, что власть суверена ничем не ограничена. Утверждается лишь, что она не может быть ограничена правовыми средствами. Так, создавая законы, суверен, к примеру, может учитывать мнение народа, либо из страха вызвать недовольство, либо полагая, что он обязан прислушиваться к народному мнению по моральным соображениям. Ограничивать его может множество факторов, и если страх перед народными вол-

нениями или же моральное убеждение заставили его законодательствовать не так, как он хотел бы, то он может воспринимать это обстоятельство и говорить о нем как об «ограничениях» своей власти. Однако это не правовые ограничения. Суверен не связан правовой обязанностью воздерживаться от провозглашения таких законов, а суды, решая, имеют ли они дело с законом суверена, не должны прислушиваться к аргументам, что тот или иной закон противоречит мнению народа, или же не может считаться законом по моральным соображениям, за исключением того случая, когда суверен приказал им поступать именно таким образом.

Достоинства этой теории в качестве общего определения права очевидны. Она, как кажется, дает нам удовлетворительно простой ответ на два важнейших вопроса. Каждый раз, когда мы видим суверена, которому подчиняются по привычке, причем сам он не подчиняется никому, мы можем выявить два обстоятельства. Во-первых, именно в его приказах мы увидим право данного общества, которое теперь можно отличить от множества иных правил, принципов или стандартов, моральных или всего лишь обычных. Во-вторых, в сфере права мы сможем понять, имеем ли мы дело с независимой правовой системой, или же речь идет о подчиненной части более широкой правовой системы.

Обычно говорят, что Королева в Парламенте, в качестве воплощения наследственной законодательной власти, удовлетворяет этой теории, и в этом же проявляется суверенитет Парламента. Сколь бы ни было верным это утверждение (и мы обсудим некоторые его аспекты в шестой главе), в простом мире Рекса I мы без затруднений сможем воспроизвести основные элементы того, что предписывает эта теория. Полезно сделать это перед тем, как перейти к более сложному случаю, приближенному к современному сложному государству, так как именно таким способом мы сможем проследить наиболее явные следствия этой теории. Для того чтобы применить к нашему случаю критические замечания, высказанные в первом разделе этой главы по поводу понятия привычки повиновения, лучше всего описать ситуацию в терминах правил, а не обычаев. Представим себе общество, в котором действует правило, признаваемое судами, официальными лицами и простыми гражданами, согласно которому каждое распоряжение Рекса задает стандарт поведения для всей группы. Возможно, для того чтобы отличить приказы от частных «пожеланий», которым Рекс не желает придавать «официальный» статус, могут существовать дополнительные правила, определяющие специальный стиль, которого монарх должен придерживаться, отдавая приказы «в качестве монарха», а не частного лица, отдающего распоряжения своим слугам, жене или любовнице. Эти правила, определяющие стиль и форму законодательной деятельности, должны строго соблюдаться для того, чтобы выполнять свою задачу, и могут в некоторых случаях создавать

неудобства для Рекса. Однако, хотя мы вполне можем считать их правовыми правилами, их не следует рассматривать в качестве «ограничения» его законодательной власти, так как, следуя предписанной процедуре, он может законодательствовать по любому поводу, и ничто не ограничивает его волю. «Сфера» законодательной деятельности, в отличие от «формы», правом не ограничена.

Эта теория не может претендовать на общую теорию права потому, что существование суверена, подобного Рексу в нашем воображаемом обществе, чья власть не ограничена законодательными средствами, не является необходимым условием и предпосылкой существования права. Для того чтобы показать это, нам не нужно прибегать к примерам сомнительных или экзотических типов права. Так что наш аргумент не базируется на системах обычного или международного права, которые некоторые авторы вообще отказываются называть правовыми системами, так как в этих случаях законодательная власть отсутствует. Однако нам нет необходимости ориентироваться на эти случаи, так как концепция суверена, власть которого не ограничена правом, искажает характер права во многих современных государствах, наличие права в которых сомнений не вызывает. В этих случаях законодательная власть есть, однако верховный законодатель отнюдь не находится за пределами права. Писаные конституции могут ограничивать компетенцию законодателя не только специфицируя форму и способ законодательной деятельности (которые мы не будем считать правовыми ограничениями), но и полностью исключая из сферы их законодательной деятельности определенные предметы, налагая на законодателя субстанциональные правовые ограничения [32].

И еще, прежде чем обратиться к более сложному случаю современного государства, полезно посмотреть, что в действительности могут означать в простейшем мире верховного законодателя Рекса «правовые ограничения его законодательной власти» и почему эта концепция вполне согласованна.

В простейшем обществе Рекса может быть принято правило (в форме писаной конституции или в любой другой форме), согласно которому ни один закон, изданный Рексом, не может иметь силу, если он лишает коренных жителей их земли или предписывает их заключение в тюрьму без суда. Так что любой приказ, нарушающий эти положения, будет недействительным, и все будут к нему относиться именно таким образом. В этом случае власть Рекса в области законодательства будет ограничена правилами, которые вполне можно считать правовыми, хотя мы и воздержимся от названия этого фундаментального конституционного правила «законом». В отличие от случая пренебрежения мнением народа или народными моральными устоями, которые могут заставить его законо-

дательствовать не так, как он хотел бы, в данной ситуации несоблюдение этих специфических ограничений делает его приказы ничтожными автоматически. И суды будут относиться к этим случаям не так, как они относятся к моральным или de facto ограничениям осуществления его законодательной власти. И все же, несмотря на эти правовые ограничения, распоряжения Рекса в области их применимости заведомо являются законами, и в государстве существует независимая правовая система.

Имеет смысл остановиться на этих правовых ограничениях подробнее по-прежнему на примере нашего воображаемого государства. Положение Рекса можно описать утверждением, что он «не может» издать закон, предписывающий заключение граждан без суда. Примечательно сопоставить это утверждение со случаем, когда гражданин, будучи связанным правовой обязанностью или обязательством, «не может» что-либо делать. Выражение «не может» в этом последнем случае используется в смысле, например, фразы: «Вы не можете ездить на велосипеде по автостраде». Конституция, эффективно ограничивая законодательную власть законодательного органа в этой системе, достигает требуемого эффекта, не налагая обязанности на законодательный орган не издавать законов определенного типа; вместо этого она устанавливает, что любой закон, противоречащий этому правилу, будет ничтожным. Она не налагает правовые обязанности, но устанавливает, что нечто в силу правовых ограничений невозможно. «Ограничение» в данном случае предполагает не наличие обязанности, а отсутствие правовой власти.

Подобные ограничения на законодательную власть суверена вполне могут называться конституционными. И они не являются всего лишь соглашениями или моральными ограничениями, которые суд может не принимать во внимание. Они являются частью правила, которое предоставляет законодательную власть суверену, и жизненно важны для судов, так как последние используют это правило для того, чтобы определять действительность того или иного закона. И все же, хотя эти ограничения являются правовыми, а не моральными или условными, их наличие или отсутствие не может быть выражено в терминах наличия или отсутствия привычки повиновения Рексу со стороны остальных людей. Сам Рекс может быть связан этими ограничениями и никогда не нарушать их, однако нет никого, кому он повинуется по привычке. Он всего лишь выполняет условия, необходимые для действительного закона. Он может также нарушить это ограничение, приказав нечто противоречащее этому правилу, однако и в этом случае он выкажет неповиновение кому бы то ни было. Он не нарушит закона какого-либо высшего законодателя и не нарушит правовую обязанность. Он не создаст действующего закона (хотя и не нарушает его). С другой стороны, если конституционное правило, предоставляющее Рексу законодательную власть, не содержит правовых

ограничений подобного рода, тот факт, что Рекс по привычке подчиняется приказам правителя соседнего государства Тиррана, сам по себе не лишает его распоряжений законодательной силы и не означает, что его законодательство является лишь частью более широкой правовой системы, в которой высшим авторитетом является Тирран.

Указанные выше простые соображения проясняют некоторые моменты, существенно затемненные простой теорией суверенитета, однако имеющие большое значение для понимания оснований правовой системы. Резюмировать это можно следующим образом. Во-первых, правовые ограничения, налагаемые на законодательную власть, состоят не в положительных обязанностях, наложенных на законодателя, повиноваться некоему высшему законодателю, но в невозможности совершать некоторые действия, указанные в правиле, которое предоставляет ему высшую законодательную власть.

Во-вторых, для того чтобы определить, является ли то или иное положение правом, нам нет необходимости возводить его к явному или молчаливому приказу законодателя, который обладает «суверенной» или «неограниченной» властью в том смысле, что его законодательный авторитет не ограничен правовыми средствами, или в том смысле, что он является тем лицом, которое по привычке не подчиняется никому. Вместо этого мы должны показать, что закон издан законодателем, который получил эту власть на основе правила, которое либо не содержит никаких ограничений, либо эти ограничения не касаются данного закона.

В-третьих, для того чтобы показать, что перед нами независимая правовая система, нет необходимости доказывать, что верховный законодатель не ограничен правовыми средствами и не подчиняется по привычке другому лицу. Нам достаточно показать лишь, что правила, которые предоставляют законодательную власть суверену, не предоставляют также верховной власти лицам, которые обладают верховной властью над другими территориями. Напротив, из того факта, что он неподвластен иностранному авторитету подобного рода, не следует, что его авторитет на своей территории ничем не ограничен.

В-четвертых, мы должны делать различие между законодательной властью, не ограниченной законными средствами, и законодательной властью, которая, хотя и ограничена, является верховной в рамках данной системы. Рекс вполне может быть высшей законодательной властью, известной в данном государстве в том смысле, что любой другой закон отменяется его приказом, хотя его законодательная власть и ограничена конституцией.

Наконец, в-пятых, в случаях, когда наличие или отсутствие правил, ограничивающих компетенцию законодателя, принципиально, привычка повиновения ему имеет в лучшем случае косвенное вспомогательное

значение. Значение того факта, если это действительно факт, что законодатель не подчиняется по привычке иному лицу, состоит лишь в том, что он может предоставлять некоторые, хотя и неокончательные, свидетельства, показывающие, что законодательный авторитет данного суверена не подчинен конституционным или иным правилам законодательной власти другого суверена. Аналогичным образом единственным значением того факта, что суверен подчиняется кому-либо по привычке, является то, что он показывает, в какой мере правило, предоставляющее ему законодательную власть, ставит его в подчинение другой власти.

4. СУВЕРЕНИТЕТ В ОСНОВЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В современном мире существует много правовых систем, в которых орган, рассматриваемый в качестве высшей законодательной власти этой системы, ограничен в реализации этой власти правовыми средствами; и все же (и с этим согласятся как юристы, так и теоретики права) акты этого законодательного органа в рамках его ограниченной власти — это закон. Так что в подобных случаях, если мы желаем сохранить теорию, согласно которой закон возможен лишь при наличии суверена, чья воля не связана правовыми средствами, нам следует искать суверена, стоящего за ограниченным правовыми средствами законодательным органом. Нам следует рассмотреть вопрос о том, можно ли его найти [33].

На время оставим ограничения, присутствующие в той или иной форме в каждой правовой системе, хотя и не обязательно в виде писаной конституции, касающиеся квалификации законодателя, а также «способа и формы» выражения его законодательной воли. Эти ограничения скорее касаются идентификации законодательного органа, а также того, что он должен делать, чтобы издать законодательный акт, нежели собственно правовых ограничений сферы его законодательной власти. Правда, как показывает случай с Южной Африкой[1], трудно установить общий критерий, который позволил бы удовлетворительно отличить простые требования к «способу и форме» законодательной деятельности или определения законодательного органа от «существенных» ограничений.

Простые примеры субстанциональных ограничений можно найти, например, в конституциях США или Австралии, которые разграничивают полномочия центрального правительства и штатов, а также закрепляют определенные гражданские права, которые не могут быть изменены простыми законодательными средствами. В этих случаях любой законодательных акт, изданный законодательным органом штата или федера-

[1] Harris v. Dunges [1952] 1 TLR 1245.

ции, направленный на изменение положения конституции, несовместимый с установленным в ней разграничением полномочий или защищаемыми ею гражданскими правами, трактуется как *ultra vires* и объявляется судами недействительным как противоречащий конституции. Наиболее известным правовым ограничением подобного рода является пятая поправка к Конституции США. Среди всего прочего в ней устанавливается, что никто не может быть лишен «свободы или имущества без подобающего судебного решения», и статуты Конгресса признаются судами недействительными, если оказывается, что они конфликтуют с этим или иными ограничениями, налагаемыми конституцией на законодательную власть.

Разумеется, существует много других средств, защищающих конституцию от деятельности законодателя. В некоторых случаях, как это принято в Швейцарии, отдельные положения, касающиеся прав кантонов, входящих в федерацию, или свобод граждан, по форме обязательные, трактуются как «лишь политические» и желательные (hortatory, увещевательные). В таких случаях суды не вправе «пересматривать» акты федерального законодательного органа и объявлять их недействительным, даже если они находятся в явном конфликте с положениями конституции, определяющими компетенцию законодательных органов[1]. Некоторые положения Конституции США также, как считается, касаются «политических вопросов», поэтому, если тот или иной казус попадает в эту категорию, суды не рассматривают вопрос о том, не нарушает ли данный статут конституцию.

Когда на нормальную работу высшей законодательной власти конституцией налагаются ограничения, они могут обладать иммунитетом против определенных форм правовых изменений. Это зависит от того, какая процедура предусмотрена в конституции для внесения поправок в эту сферу. Большинство конституций допускают разнообразные поправки, которые могут вносить органы, отличные от обычного законодателя, либо члены обычного законодательного органа, однако с использованием особой процедуры. Примером первого способа внесения поправок в конституцию является положение статьи 5 Конституции США, согласно которой поправка к конституции возможна, если ее ратифицировали три четверти законодательных собраний штатов или между тремя четвертями достигнуто согласие. Примером второго способа является положение раздела 152 Акта 1909 г. Южной Африки. Однако не все конституции допускают внесение поправок, и иногда, даже если возможность поправок предусмотрена, некоторые положения конституции налагают ограничения на компетенцию законодательной власти, вынося определенные

[1] См. статью 113 Конституции Швейцарии.

вопросы за пределы их власти. В этом случае можно утверждать, что сама возможность внесения поправок ограничена. Это явление можно наблюдать (хотя некоторые из подобных ограничений ныне уже не важны с практической точки зрения) даже в Конституции США. Так, статья 5 устанавливает, что никакие поправки, сделанные ранее 1808 г., не должны никоим образом влиять на первое и четвертое положения (clauses) девятого раздела первой статьи и что ни один штат (state) не может без его согласия быть лишен права равного представительства (equal suffrage) в Сенате.

В случаях, когда на законодательный орган наложены ограничения, которые, как в Южной Африке, могут быть устранены членами законодательного собрания при помощи определенной процедуры, ясно, что этот законодательный орган может быть идентифицирован с сувереном, чья власть не ограничена правовыми средствами, как это и предписано теорией. Сложными с точки зрения этой теории будут случаи, когда ограничения на законодательную власть, как это предусмотрено в Конституции США, могут быть устранены лишь при помощи специального органа, либо когда они вообще не могут быть устранены.

Так как в данной теории содержится претензия на согласованное объяснение и этих случаев, следует вспомнить, так как об этом часто забывают, что сам Остин, развивая свою теорию, не отождествлял суверена с законодателем даже в Англии. Он считал именно так, хотя, согласно общепринятому мнению, Королева в Парламенте свободна от правовых ограничений ее законодательной власти, и этот пример нередко приводится в качестве парадигмы того, что обычно называется «законодательством суверена» в отличие от Конгресса или другого законодательного органа, связанного «жесткой» конституцией. И все же, по мнению Остина, в любом демократическом обществе суверенитет принадлежит не избранному представительному собранию, но самим избирателям. Поэтому в Англии, «строго говоря, члены палаты общин являются лишь поверенными того органа, который их избрал и назначил, а следовательно, суверенитет всегда разделен между королевскими Пэрами и избираемым органом общин» [1]. Аналогичным образом, он утверждал, что в США государственный суверенитет каждого штата, а также суверенитет «всего государства, образующего Федеральный союз (also of the larger state arising from the Federal Union)», принадлежит правительствам штатов (resided in the states governments), вместе формирующим одно совокупное образование, причем правительства штатов, по его представлению, — это не обычный законодательный орган (ordinary legislature), но собрание граж-

[1] Austin, Province of Jurisprudence Determined, Lecture VI, pp. 230-231.

дан, которые его избирают \

С этой точки зрения различие между правовой системой, в которой законодательная власть свободна от правовых ограничений, и другой системой, в которой законодатель ограничен, сводится всего лишь к различию формы, в которой суверенный электорат предпочитает осуществлять свою суверенную власть. Согласно этой теории в Англии единственным проявлением суверенитета электората является акт избрания представителей в Парламент, которым и делегируется суверенная власть. Это делегирование в некотором смысле является абсолютным, так как обязанность не злоупотреблять полученной властью в данном случае подкреплена лишь моральными санкциями, и суды не имеют с этим дела, в отличие от случаев нарушения ограничений, налагаемых на законодательную власть правовыми средствами. Напротив, в США, как и в любом демократическом обществе, где законодатель связан правовыми средствами, электорат не просто делегирует свою суверенную власть избранным делегатам, но и связывает их правовыми ограничениями. В этом случае электорат может рассматриваться как «экстраординарная и последняя законодательная инстанция» (extraordinary and ulterior legislature), имеющая власть над ординарным законодателем, который «связан» законом и обязан выполнять конституционные ограничения, и в случае конфликта суды признают акт, изданный ординарным законодательным органом, недействительным. В этом случае лишь электорат обладает суверенной властью, свободной от всех правовых ограничений, как того требует теория [34].

Очевидно, что в вышеописанных случаях исходная теория суверенитета претерпела важные изменения, если не радикальную трансформацию. Описание суверена как «лица или лиц, которым большая часть населения повинуется по привычке», является, как мы показали в первом разделе этой главы, почти буквальным применением теории к простейшему обществу, в котором Рекс является абсолютным монархом и где не существует никаких правил, определяющих способ передачи его власти преемнику. Как только появляется правило подобного рода, феномен преемственности законодательной власти — важнейшая особенность современных правовых систем — уже не может быть описана в простых терминах повиновения по привычке и требует существования того, что мы назвали правилом признания, которое предоставляет преемнику законодательную власть еще до того, как он приступит к своей деятельности и ему начнут повиноваться по привычке. Однако идентификация суверена с электоратом демократического государства уже совершенно не вписывается в рамки этой теории, если только не истолковать такие

'Ibid., p. 251.

ключевые для нее понятия, как «повиновение по привычке» и «персона или персоны», в смысле, совершенно отличном от того исходного и простейшего смысла, в котором они употреблялись в исходной теории. А истолковать их требуемым образом можно, лишь исподтишка введя правило признания. Простая схема повиновения приказам суверена по привычке не сможет нас уже удовлетворить.

То, что это действительно так, можно показать разными способами. Наиболее ясно это проявится, если мы рассмотрим современную демократию, в которой из числа избирателей исключены лишь дети и умалишенные, то есть электорат составляет большую часть населения, либо если мы представим себе социальную группу, состоящую из взрослых людей, каждый из которых обладает избирательным правом. Если мы попытается отождествить электорат и суверена и применить к этому обществу понятия исходной теории, то окажется, что «большинство» населения по привычке повинуется самому себе. В результате исходный и ясный образ этого общества разделяется на два сегмента: суверена, свободного от правовых ограничений, который отдает приказы, и подданных, которые по привычке этим приказам повинуются. Так образ общества размывается, и оказывается, что большинство подчиняется приказам, отданным большинством или всеми. Очевидно, что в этом случае понятия «приказ» (как выражение желания, чтобы другие поступали определенным образом) и «повиновение» используются далеко не в традиционном смысле.

В ответ на эту критику можно провести различие между членами общества как частными лицами и теми же лицами в их официальном статусе как избирателями и законодателями [35]. Такое различение вполне понятно, и многие правовые и политические явления хорошо описываются в этих терминах. Однако это не спасает теорию суверенитета, даже если мы согласимся, что индивидуальные лица в их официальном статусе превращаются в иное лицо, которому по привычке повинуются. Ведь если мы спросим, что означает тот факт, что определенная группа, избирая представителей или издавая распоряжения, действует не в качестве частных лиц, но в официальном статусе, то ответом будет, что они получают эту квалификацию на основании определенного правила и в соответствии с иными правилами, которые определяют, что именно они должны сделать для того, чтобы избрание или законодательство были действительными. Лишь на основании подобного рода правил мы сможем идентифицировать действие группы людей как избрание или издание закона. Причем сделать это в случае с группой людей не так легко, как в случае с отдельным лицом, когда мы просто считаем, что его слова, высказанные в устной или письменной форме, выражают его волю.

Что же создает эти правила? Поскольку правила определяют, как должны поступать граждане данного общества для того, чтобы выступить в роли электората (а также, в интересах нашей теории, в качестве суверена), то они не могут иметь статус приказов, изданных сувереном; эти правила уже должны были существовать, и им должны были следовать.

Можем ли мы утверждать, что эти правила являются всего лишь частью описания всенародной привычки к повиновению? В простом случае, когда сувереном является одно лицо, которому большая часть общества подчиняется, если и только если он отдает свои приказания в определенной форме, например в письменной форме, скрепленные собственноручной подписью и визами министров, мы можем сказать (с учетом возражений по поводу использования в данном случае понятия «обычай», высказанных в первом разделе), что правило, устанавливающее порядок издания законодательных актов, является частью описания всенародной привычки повиновения: население по привычке повинуется суверену, когда он отдает приказы таким образом. Однако в тех случаях, когда суверен не может быть определен независимо от правил, мы не можем переформулировать правила подобным образом, сведя их к терминам или условиям, при выполнении которых население по привычке повинуется суверену. Эти правила носят конституирующий характер по отношению к самому суверену, а не сводятся лишь к одному из пунктов описания привычки повиновения суверену. Следовательно, в данном случае мы не можем сказать, что эти правила специфицируют процедуру, в соответствии с которой общество, состоящее из множества отдельных людей, подчиняется самому себе в качестве электората, ибо фраза «себе в качестве электората» не является указанием на лицо, определяемое помимо этих правил. Это сокращенное указание на тот факт, что избиратели выполнили необходимые требования при избрании своих представителей. В лучшем случае мы можем утверждать (учитывая сказанное в первом разделе), что правила устанавливают условия, согласно которым избранным лицам по привычке повинуются; однако это положение вернет нас назад к теории, согласно которой законодатель, а не электорат, является сувереном, так что все сложности, порожденные тем фактом, что законодательные полномочия этого суверена должны быть ограничены правовыми средствами, останутся неразрешенными.

Данные аргументы против этой теории, как и те, что были высказаны ранее, носят фундаментальный характер в том смысле, что они показывают, что ошибки теории — это не мелкие детали, а право не может быть адекватно описано в таких простых терминах, как приказы, подкрепленные угрозой, привычка и повиновение. Вместо этого требуется ввести понятие правила, предоставляющего власть, которая может быть

ограниченной или неограниченной, лицам, квалифицированным определенным образом осуществлять законодательную деятельность с соблюдением определенной процедуры.

Кроме того, что можно назвать концептуальной неадекватностью теории, существует ряд вспомогательных возражений против попытки совместить с ней тот факт, что как правило высший законодательный орган подлежит правовым ограничениям. Если мы отождествим суверена с электоратом, то, даже в случае, когда электорат имеет право вносить любые поправки, удалив тем самым все возможные ограничения на полномочия ординарного законодательного органа, позволительно спросить, являются ли эти ограничения правовыми потому, что электорат отдал приказ, которому ординарный законодательный орган повинуется по привычке? Возражение может быть ослаблено замечанием, что определение правовых ограничений законодательной власти как приказов и обязанностей, которые они налагают, искажает ситуацию. Можем ли мы в таком случае считать, что эти ограничения являются обязанностями, осуществлять которые законодательный орган должен в соответствии с молчаливым приказом электората? Все возражения, высказанные ранее по поводу молчаливых приказов, применимы в данном случае как никогда явственно. Неспособность воспользоваться властью внести поправки, прибегнув к сложной процедуре, вроде той, которая предусматривается Конституцией США, сама по себе не указывает на желание или нежелание электората, однако нередко служит свидетельством того, что электорат либо недостаточно информирован либо безразличен [36]. В данном случае дела обстоят совершенно не так, как в нашем примере с генералом, который, возможно удовлетворительным для нас образом, может быть рассмотрен в рамках модели молчаливых приказов, если он просто согласится с тем, что приказал его подчиненным сержант.

И снова — что подсказывает нам наша теория в случае, если мы столкнемся с ограничениями на законодательную деятельность, принципиально отличными от того права внесения поправок, которое предоставлено избирателям? Между тем, это не только возможно, но и в ряде случаев действительно наблюдается. Электорат в этом случае ограничивается правовыми средствами, и хотя его продолжают называть экстраординарной легислатурой, в действительности он не свободен от правовых ограничений, а следовательно не является сувереном. Неужели и в этом случае мы скажем, что суверен — это в действительности общество как целое, а эти правовые ограничения были молчаливо установлены *им самим,* так как оно не пожелало отменить их революционным путем? Достаточным основанием для признания такого положения дел бессмысленным является хотя бы то, что в этом случае исчезает различие между революцией и законодательным процессом.

Наконец, теория, согласно которой сувереном является электорат, применима лишь к ограниченному числу законодательных актов в демократическом государстве, где установлена процедура выборов. Однако мы видели, что представление о монархе вроде Рекса, который одновременно ограничен в своем законотворчестве и является высшей властью в рамках данной системы, также вполне разумно.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПРАВО КАК ЕДИНСТВО ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ ПРАВИЛ

1. НОВОЕ НАЧАЛО

На протяжении первых трех глав мы видели, что во многих важнейших случаях простая модель права как принуждающего приказа суверена не способна воспроизвести некоторые важнейшие особенности правовой системы. Чтобы показать это, мы не прибегали (как это делают многие авторы) к примерам из международного или первобытного права, которые некоторые могут расценить как спорные и пограничные явления. Вместо этого мы обратили внимание на некоторые особенности современного внутригосударственного права и показали, что они либо искажаются, либо вообще не представлены в этой слишком упрощенной теории.

Основные причины, по которым эта теория ошибочна, достаточно примечательны и заслуживают еще одного краткого повторения. Во-первых, стало ясно, что, хотя из всех видов права положения уголовного права, запрещающие или предписывающие некоторые действия под страхом наказания, больше всего напоминают подкрепленные угрозами приказы одного лица другим, эти положения, тем не менее, отличаются от таких приказов в том важном отношении, что обычно они применимы не только к подданным, но и к самим законодателям. Во-вторых, существуют другие сферы права, прежде всего наделяющие законной властью осуществлять судопроизводство или издавать законы (публичная власть), или же создавать или изменять правоотношения (частноправовая власть), которые никоим образом не могут быть поняты в терминах приказов, основанных на принуждении. В-третьих, существуют правовые нормы, которые отличаются от приказов по своему происхождению, так как возникают по причинам отличным от тех, в результате которых возникают явные предписания. Наконец, анализ права в категориях суверена, которому подчиняются в силу обычая и который с необходимостью избавлен от каких-либо правовых ограничений, не в силах объяснить непрерывность законодательной власти, которая характерна для современных правовых систем, равно как и то, что суверен или суверены не

могут быть однозначно идентифицированы ни с электоратом, ни с легислатурой современного государства.

Вспомним, что, критикуя концепцию права как принуждающих приказов суверена, мы также рассмотрели целый ряд вспомогательных построений, которые нарушают изначальную простоту теории ради избавления от тех трудностей, с которыми она сталкивается. Однако они также не выдерживают критики. Одно из таких нововведений — понятие *молчаливого* приказа — неприменимо к сложной действительности современных правовых систем, и работает лишь в таких упрощенных ситуациях, как в примере с генералом, который сознательно воздерживается от отмены или исправления приказаний, отданных его подчиненными. Другие уловки, такие, как истолкование правил, наделяющих властью, в качестве частного случая правил, налагающих обязанности, или же рассмотрение всех правил как адресованных лишь официальным лицам, искажают то, как эти правила в действительности высказываются, понимаются и используются в повседневной жизни. Как нам кажется, эта теория не лучше утверждения, что все правила игры в действительности являются инструкциями для подсчета очков, адресованными судье. Для того чтобы совместить очевидный самоограничивающий характер законодательства и положение о том, что статут — это приказ, отданный *другим,* различают между законодателями в их официальном статусе и ими же, но уже в качестве частных лиц. Это предположение, само по себе безупречное, дополняет теорию элементом, который в ней не содержится: идеей правила, которое определяет, что необходимо делать, чтобы законодательствовать; ибо только в соответствии с таким правилом законодатели получают некий официальный и особый личный статус, отличающийся от того, которым они обладают в качестве частных лиц.

Итак, первые три главы имели дело с ошибками теории. Так что новое начало представляется необходимым. Как бы то ни было, эти ошибки нас многому учат, поэтому они заслуживали столь внимательного рассмотрения. Ведь в каждом случае, когда теория оказывалась не соответствующей фактам, было возможно хотя бы в общих чертах понять, почему так происходит, что послужило тому причиной и что можно сделать, чтобы исправить это положение. Источником всех ошибок оказались сами исходные элементы, на основании которых построена теория, такие, как понятия приказа, повиновения, привычки и угроз, так как они не включают в себя и не могут породить из себя идею правила, без которой невозможно понять даже самые элементарные формы права. Верно, что идея правила никоим образом не проста: как мы уже видели в третьей главе, учитывая сложность правовой системы, возникает необходимость делать различие между двумя различными, хотя и связанными друг с другом типами правил. Правила первого типа, которые можно

считать базовыми или первичными, предписывают делать что-либо или воздерживаться от определенных действий вне зависимости от желания. Правила второго типа оказываются в некотором роде паразитическими или вторичными по отношению к первым, ибо они позволяют людям путем совершения определенных действий, ввести новые правила первого типа, удалить или изменить старые или различными способами изменить сферу их применимости и установить контроль над их исполнением. Правила первого типа устанавливают обязанности; правила второго дают власть, публичную или частную. Правила первого типа касаются действий, состоящих в физических движениях или изменениях; правила второго типа позволяют совершать действия, которые приводят не только к физическим движениям или изменениям, но и к созданию или модификации обязанностей или обязательств.

Мы уже предварительно рассмотрели смысл утверждения о том, что правила этих двух типов существуют в данной социальной группе. В этой главе мы не только продолжим это исследование, но и обоснуем общее положение о том, что именно в комбинации этих двух типов правил заключено то, что Остин по ошибке находил в своем понятии принуждающего приказа, а именно «ключ к науке юриспруденции». Мы не утверждаем, что каждый раз, когда слово «право» используется «подобающим образом», необходимо искать эту комбинацию первичных и вторичных правил. На самом деле ясно, что все разнообразие случаев, в которых уместно говорить о праве, не подчинено столь простой однородности. Однако всегда имеет место косвенная связь — нередко основывающаяся на аналогии формы или содержания, — отдельных вариантов с центральным случаем. В этой и последующей главах мы попытаемся показать, что большая часть тех особенностей права, которые оказались наиболее озадачивающими и вызвали безуспешные попытки дать им определение, могут быть лучше всего объяснены, если мы поймем два этих типа правил и взаимодействие между ними. Мы отводим этому единству первых элементов центральную роль, учитывая их объяснительную силу в процессе прояснения понятий, конституирующих костяк правовой мысли. Оправдание использования термина «право» для всего разнообразия гетерогенных случаев — это следующая задача, к которой надлежит перейти после того, как понят смысл центральных элементов.

2. ИДЕЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Вспомним, что теория права как принуждающих приказов, несмотря на ее ошибки, исходит из совершенно верного наблюдения, что при наличии права человеческое поведение становится не произвольным, но в

некотором роде обязательным. Исходя из этой посылки, авторы данной теории поступали вполне разумно, и мы, развивая наше представление о праве как взаимодействии первичных и вторичных правил, должны начать с той же самой идеи. И именно на этом важнейшем начальном этапе мы сможем извлечь больше всего уроков из ошибок наших предшественников.

Вспомним ситуацию с вооруженным грабителем. А приказывает Б отдать деньги, угрожая в противном случае убить его. Согласно теории принуждающих приказов эта ситуация иллюстрирует понятие обязательства или обязанности в целом. Правовые обязательства могут быть обнаружены и определены на основании этой ситуации; А должен быть сувереном, которому по привычке повинуются, а приказы должны носить общий характер и предписывать типы поведения, а не совершение отдельных действий. Правдоподобие схемы с вооруженным грабителем для объяснения смысла понятия «обязанность» обусловлено тем фактом, что это именно тот случай, когда мы уверенно можем сказать, что Б, если он принял решение повиноваться, будет «должен» отдать свои деньги. Однако, с другой стороны, ясно, что мы ошибочно истолкуем смысл ситуации, если скажем, что Б «имел долг» или «обязанность» отдать деньги. Так что с самого начала ясно, что для понимания смысла понятия «обязанность» мы нуждаемся в чем-то еще. Нам предстоит объяснить различие между утверждением, что некто *был должен* совершить определенные действия, и утверждением, что он *имел обязанность* совершить его. В первом случае речь как правило идет о побуждениях и мотивах для совершения действия: в случае с грабителем Б должен был отдать свои деньги потому, что думал, что в противном случае с ним случится нечто весьма неприятное, и выполнил приказание для того, чтобы избежать этих последствий. В подобных случаях перспектива, которая открывается перед агентом, стоящим перед выбором, в случае, если он откажется повиноваться, делает действия, которые он предпочел бы совершить в противном случае (сохранить свои деньги) заведомо менее приемлемыми.

Два других элемента несколько осложняют понятие обязанности совершить определенные действия. Ясно, что мы не будем считать Б обязанным отдать свои деньги, если угроза, по общим понятиям, была тривиальной по сравнению с серьезными неприятностями, которые последуют для самого Б или других людей, если он выполнит приказ. Эта ситуация могла бы реализоваться, если бы, к примеру, в случае невыполнения приказа грабитель угрожал ущипнуть Б. Подобным же образом мы едва ли будем считать Б обязанным, если реализация угрозы грабителя причинить относительно серьезный вред в данной ситуации представляется маловероятной. И все же, хотя подобные ссылки на общие представ-

ления о серьезности вреда и разумную оценку вероятности его нанесения имплицитно присутствуют в этой ситуации, утверждение, что этот человек был обязан повиноваться другому, в целом носит психологический характер и касается представлений и мотивов, на основании которых совершается действие. Однако утверждение, что некто *имел обязанность* совершить определенные действия, принципиально отличается от данного, на что указывает множество признаков. Дело не только в том, что в случае с вооруженным грабителем, факторы, определяющие поведение Б, а также его оценку ситуации и мотивы выбора того или иного способа действия достаточны, чтобы обосновать утверждение, что Б был должен отдать свой кошелек, однако недостаточны, чтобы обосновать утверждение, что этот человек имел обязанность совершить данное действие. Верно также и то, что факторы подобного рода, то есть факты, касающиеся оценки и мотивов, *не являются необходимыми* для того, чтобы сделать утверждение о том, что человек имел обязанность, истинным. Именно поэтому утверждение, что человек имеет обязанность, например, сказать истину или явиться на службу в армии, является истинным, даже если он (основательно или нет) полагает, что об этом никто никогда не узнает и его действия в случае неповиновения останутся безнаказанными. Более того, утверждение, что он имел обязанность, не зависит от того, действительно ли он явился на службу в армии, в то время как утверждение о том, что он был обязан совершить нечто, обычно предполагает, что он на самом деле сделал это.

Некоторые теоретики, в том числе и Остин, видя относительную неважность личных представлений, страхов и мотивов для решения вопроса о том, имеется ли в данном случае обязанность или нет, определили это понятие не через эти субъективные факторы, но в терминах *шанса* или *вероятности* того, что человек, связанный обязательством, понесет наказание или испытает «зло» от рук других в случае его неповиновения [37]. В результате высказывания об обязанностях трактуются не как суждения психологической природы, но как предсказания или подсчет шансов того, что в данном случае лицо понесет наказание или испытает «зло». Многие последующие теоретики восприняли эту мысль как откровение, позволяющее приземлить ускользающее понятие и переопределить его в таких же ясных, точных и эмпирических терминах, как те, что используются в естественных науках. Действительно, иногда она принималась в качестве единственной альтернативы метафизическим представлениям об обязанности или долге как незримых объектах, загадочным образом существующим «над» или «за пределами» мира обычных, наблюдаемых фактов. Однако есть много причин отвергнуть эту интерпретацию утверждений об обязанностях как предсказаний, к тому же она не является единственной альтернативой туманной метафизике.

Фундаментальное возражение состоит в следующем. Предсказательная интерпретация затемняет тот факт, что при наличии правил отклонения от них являются не только основанием для предсказания, что за ними последует соответствующая негативная реакция и суд применит соответствующие санкции к тем, кто их нарушил, но и основанием или оправданием подобной реакции и таких санкций. В четвертой главе мы уже обратили внимание на то, что данная теория упускает из виду этот внутренний аспект правил, и подробнее рассмотрим его позже в данной главе.

Кроме того, существует и второе, более простое, возражение против предсказательной теории обязательств. Если бы было верным, что высказывание о том, что человек имеет обязанность, означает лишь то, что *он,* вероятно, пострадает в случае неповиновения, то противоречивым было бы утверждение о том, что у него была обязанность, например, явиться на военную службу, но что, благодаря тому, что он нашел возможность избежать правосудия или подкупить полицию или суд, в действительности не было ни малейшего шанса, что он будет пойман и пострадает. Однако в действительности в этом случае нет противоречия, и подобные высказывания нередко делаются и адекватно понимаются.

Разумеется, верно, что в нормальной правовой системе, где санкции предусмотрены за большую часть преступлений, преступник обычно рискует быть наказанным; так что утверждения, что человек имеет обязанность и что он, вероятно, понесет наказание, истинны одновременно. В действительности связь между этими двумя утверждениями еще более тесная: по крайней мере в сфере внутригосударственного права может быть верным то, что, если бы правонарушения, *как правило* не наказывались, было бы мало или никакого смысла в конкретных высказываниях об обязанностях того или иного лица. В этом смысле подобные высказывания предполагают убежденность в непрерывном и нормальном функционировании системы санкций, подобно тому как в крикете утверждение «он вне игры» предполагает, хотя и не утверждает явно, что игроки, судьи и счетчики очков предпримут соответствующие действия. И все-таки для понимания идеи обязанности важно осознавать, что в отдельных случаях утверждение, что человек имеет обязанность в соответствии с определенным правилом, и предсказание, что он, вероятно, понесет наказание в случае неповиновения, могут различаться.

Ясно, что обязанности не встречаются в ситуациях, подобных встрече с вооруженным грабителем, хотя более простое понятие быть должным сделать нечто может быть определено при помощи элементов, которые присутствуют и здесь. Для того чтобы понять общую идею обязанности (что является необходимым предварительным условием для уяснения ее специфики в качестве правового термина), нам следует обра-

титься к иному социальному контексту, в котором, в отличие от случая с грабителем, присутствуют социальные правила. Подобная ситуация будет способствовать пониманию утверждение о том, что некто имеет обязанность, двояким образом. Во-первых, существование подобных правил, делающих определенные типы поведения образцовыми, является обычным, хотя и неявным фоном или должным контекстом для такого утверждения. И во-вторых, отличительной особенностью этого утверждения является то обстоятельство, что оно прилагает общее правило подобного рода к конкретному лицу, указывая ему на то, что данный случай подходит под это правило. Как мы уже видели в четвертой главе, существование каждого отдельного социального правила предполагает соединение правильного поведения и особого отношения к этому поведению как образцовому. Мы также видели, что эти правила по многим причинам отличаются от обычаев, бытующих в социуме, а также рассмотрели, как различная нормативная лексика («должен», «обязан», «следует») маркирует образец и отклонения от него и помогает формулировать требования, критические высказывания и признания, которые на нем базируются. Причем слова «долг» и «обязанность» образуют важный подкласс класса слов со значением нормативности, для которого характерны значения, не обязательно присущие другим элементам этого класса. А поэтому вычленение элементов, благодаря которым можно отличить социальные правила от обычаев, несомненно, необходимо для понимания смысла обязательств и обязанностей, однако само по себе недостаточно.

Утверждение, что некто имеет обязанность или обязан, предполагает существование правила. Однако дело не всегда обстоит таким образом, что при наличии правил стандарт поведения, ими предписываемый, осознается в понятиях обязанности. Высказывания «Он должен был» («He ought to have») и «Он имел обязанность» («He had an obligation to») не всегда взаимозаменяемы, хотя оба они имплицитно указывают на существующие стандарты поведения или используются для выведения заключений в частных случаях на основании общего правила. Правила этикета или правописания несомненно являются правилами, ведь они являются чем-то большим, нежели сходные обычаи или регулярности в поведении. Им обучают и предпринимают известные усилия для их поддержания. К ним апеллируют, критикуя свое поведение или поведение других, используя характерную лексику со значением нормативности: «Вам следует снять шляпу», «неправильно говорить: "вы был"». Однако было бы ошибочным, а не только стилистически странным говорить об «обязанностях» и «долге» в связи с правилами подобного рода. В этом случае мы бы ошибочно представили действительный смысл социальной ситуации, ведь, хотя линия, разделяющая правила, определяющие обя-

занности от всех остальных правил, довольно тонка, основания для такого различения все же вполне ясны.

Правила мыслятся и описываются как предписания, налагающие обязанности в том случае, когда существует настоятельное общее требование им соответствовать, подкрепленное значительным давлением со стороны социума против тех, кто не соблюдает их или пытается это сделать. Подобные правила могут по происхождению полностью основываться на обычаях; может не существовать централизованной системы наказания для тех, кто их нарушает, а давление со стороны общества может сводиться лишь к всеобщей неодобрительной или критической реакции, не подкрепленной физическими санкциями. Она может состоять в словесном осуждении или призыве уважать нарушаемое правило, а также опираться на чувство стыда, раскаяния или вины. В последнем случае правила можно классифицировать как относящиеся к морали данной социальной группы, а обязанности, возникающие в результате, как моральные обязанности. Напротив, если физические санкции возможны или типичны для давления определенного рода, даже если они не определены и не осуществляются официальными лицами, но обществом в целом, мы склонны считать такие правила примитивной или рудиментарной формой права. Разумеется, в некоторых случаях одно и то же правило поведения может обеспечиваться обоими типами социального давления, причем мы не обнаружим никаких указаний на то, какой из этих типов рассматривается как первичный, а какой как вторичный. В таком случае вопрос о том, моральное ли это правило или рудиментарное право, остается открытым. Однако в данный момент оставим в стороне вопрос о возможности провести четкую границу между правом и моралью. Важно то, что именно *серьезность* социального давления по отношению к нарушителям правил является первостепенным фактором, определяющим ситуации, когда речь идет об обязанностях.

Две другие характеристики обязанности естественным образом сочетаются с этим важнейшим фактором. Правила, подкрепленные таким серьезным давлением, считаются важными потому, что они рассматриваются как необходимые элементы поддержания социальной жизни или некоторых особо ценных ее проявлений. Характерно, что правила, важность которых очевидна, как, например, требование ограничивать применение насилия, мыслятся в понятиях обязанностей. Точно так же правила, требующие соблюдать честность, говорить правду, или исполнять обещания, или правила, уточняющие, что должен делать тот или иной человек, выполняющий определенную роль или функцию в социальной группе, также мыслятся в форме обязанностей или, возможно чаще, долга. Во-вторых, общепризнанно, что поведение, предписанное этими правилами и совершающееся во благо других, может противоречить жела-

ниям того, кто обязан исполнять свой долг. Следовательно, обязанности и долг предполагают определенную степень жертвенности и самоотречения, и постоянная возможность конфликта между долгом и обязанностями с одной стороны и личным интересом — с другой относится к числу банальностей правоведов и моралистов во всех обществах.

Образ «пут», связывающих того, кто взял на себя обязательство, скрывается в латинском термине «obligation», равно как и в понятии «моральный долг» скрывается связь с долговым обязательством, что вполне объяснимо в терминах трех вышеупомянутых факторов, позволяющих выделить правила, связанные с обязанностями или долгом из совокупности всех остальных правил [38]. Этот образ, уже долгое время преследующий правоведов, представляет давление со стороны социума в виде неких пут или «цепей», связывающих тех, кто имеет на себя обязанности и лишился возможности поступать так, как ему вздумается. Другой конец этой «цепи» иногда держит в своих руках общество или же его официальные представители, которые и настаивают на исполнении обязанности или осуществляют наказание; иногда эта функция передается группой отдельным частным лицам, которые вольны выбирать, должна ли в данном случае обязанность быть исполнена или произведена эквивалентная замена исполнения. Первая ситуация типична для обязанностей, налагаемых уголовным правом, а вторая более характерна для гражданского права, когда обязательства одних согласуются с правами других.

Хотя эти образы, или метафоры, могут показаться естественными, не следует злоупотреблять ими, так как в этом случае мы рискуем оказаться в плену ошибочной концепции обязанности как чего-то по своей сути состоящего в некотором ощущении давления или принуждения, испытываемом теми, кто имеет обязательства. Тот факт, что правила, накладывающие обязанности, обычно поддерживаются серьезным социальным давлением, не означает, что иметь обязанность в соответствии с правилами значит испытывать чувства давления или принуждения. Поэтому нет противоречия в том, чтобы сказать о закоренелом жулике, что он имел обязанность заплатить арендную плату, но не испытывал никаких таких чувств, когда сбежал, не сделав этого. *Чувствовать* себя обязанным и быть обязанным — это разные, хотя часто и сопутствующие друг другу вещи. Отождествлять их было бы ложным истолкованием обязанности как психологического чувства, хотя психологическое отношение и является важным внутренним аспектом правил, на что мы уже обращали внимание в третьей главе.

В самом деле, нам необходимо еще раз обратиться к внутреннему аспекту правил, прежде чем мы сможем окончательно избавиться от формулировок, возникающих в рамках предсказательной теории. Ведь ее

приверженцы вполне резонно могут спросить нас: если давление со стороны социума является важной особенностью правил, связанных с обязанностями, то почему мы столь упорно настаиваем на неадекватности предсказательной теории? Ведь именно в рамках этой теории данная особенность занимает центральное место в силу того, что обязанность определяется в терминах вероятности того, что угроза наказания или враждебная реакция последует за отклонения от определенной линии поведения. Может показаться незначительной разница между анализом высказывания об обязанности как предсказания или подсчета вероятности того, что за отклонением последует враждебная реакция, и нашим утверждением, что, хотя это высказывание предполагает, что отклонение от правила повлечет за собой негативную реакцию, однако обычно применяется не для не предсказания этого, но для того, чтобы сказать, что данный случай подходит под данное правило. Однако в действительности эта разница существенна. И до тех пор, пока ее важность не понята, мы не сможем уяснить тот особый стиль человеческого мышления, говорения и действия, который предполагает существование правил и который создает нормативную структуру общества [39].

Следующий контраст, опять же сформулированный в терминах «внутренних» и «внешних» аспектов правил, выявляет огромную важность этого различения для понимания не только права, но и в целом структуры любого общества [40]. Когда какая-то социальная группа признает определенные правила поведения, этот факт дает возможность сформулировать много связанных друг с другом, однако различных утверждений. Ведь к правилам можно относиться либо с позиции наблюдателя, который сам их не принимает, либо с позиции члена социальной группы, который принимает и использует их как руководство к действию. Мы можем назвать это соответственно «внешней» и «внутренней» точками зрения. Утверждения, сделанные с внешней точки зрения, также могут быть различного рода. Внешний наблюдатель может, не принимая данных правил, утверждать, что группа признает их, а следовательно, извне воспринимать их как правила, которые *они* используют со своей внутренней точки зрения. Однако какими бы ни были эти правила — правилами ли игры наподобие шахмат или крикета, или же моральными и правовыми правилами, — мы можем, если пожелаем, встать на позицию наблюдателя, который вообще не ссылается таким образом на внутреннюю точку зрения группы. Такой наблюдатель ограничится лишь фиксацией регулярностей в наблюдаемом поведении, в чем отчасти состоит подчинение правилам, и следующим за ними другим регулярностям, выражающимся в форме негативной реакции, осуждения или наказания, которыми встречают отклонения от правил. Со временем внешний наблюдатель может, на основе наблюдаемых регулярностей,

соотнести отклонения с негативной реакцией на них и достаточно успешно предсказать или определить вероятность того, что отклонения от нормального поведения, принятого в группе, будут встречены негативно и нарушители будут наказаны. И такое знание позволит ему не только узнать многое о группе, но даже жить в ней без опасения встретиться с негативной реакцией по отношению к себе, что было бы невозможно для любого другого постороннего, не обладающего знанием подобного рода.

Однако если этот наблюдатель будет упорно занимать такую крайнюю отстраненную позицию и не попытается описать то, как сами члены группы, принимающие эти правила, воспринимают свое регулярное поведение, его описание их жизни вообще не будет в категориях правил, а следовательно не будет сформулировано в терминах, зависящих от правил понятий обязанностей или долга. Вместо этого речь будет идти о наблюдаемых регулярностях поведения, о предсказании, вероятностях и знаках. Для такого наблюдателя отклонение от правила, допущенное каким-либо членом группы, будет лишь знаком того, что за ним с определенной вероятностью последует негативная реакция, и более ничем. Подобным образом мог бы рассуждать человек, который, наблюдая за переключением светофора на улице, сделал бы вывод, что каждый раз, когда загорается красный свет, велика вероятность того, что движение остановится. Свет воспринимается им как естественный *знак* того, что люди поступят тем или иным образом. Подобным же образом можно считать тучи *знаком* того, что скоро пойдет дождь. Рассуждая таким образом, он упускает из виду целое измерение социальной жизни, ведь для людей, поведение которых он наблюдает, красный свет — это не просто знак того, что другие остановятся. Они воспринимают его как *сигнал, предписывающий им* самим остановиться в соответствии с правилом, согласно которое делает остановку на красный свет указывает образцом поведения и обязанностью. Понимание этого обстоятельства дает возможность уяснить отношение самой группы к своему поведению и раскрывает внутренний аспект правил с ее внутренней точки зрения.

Описанная внешняя точка зрения очень близко воспроизводит способ функционирования правил в жизни тех членов группы, которые отвергают ее правила и выполняют их только потому, что стремятся избежать тех негативных последствий, которые может повлечь неисполнение. О своем поведении они, скорее всего, скажут: «Мне пришлось сделать это», «Меня могут наказать, если я не...», «Вы будете наказаны, если не...», «Вам сделают то-то, если...» Но им не понадобятся выражения вроде: «Моей обязанностью было...», «Вы обязаны», ибо они требуются только тем, кто рассматривает свое поведение и поведение других с внутренней точки зрения. Внешняя точка зрения, ограничивающаяся наблюдением регулярностей поведения, не в силах воспроизвести то, как пра-

вила функционируют в качестве правил в жизни тех, кто обычно составляет большинство общества. К этому большинству относятся чиновники, юристы и частные лица, которые используют их в повседневных ситуациях в качестве руководства в социальной жизни и как основания для требований, признания, критики или наказания, то есть во всех случаях, регулируемых этими правилами. Для них нарушение правила — это не только основание для предсказания, что за ним может последовать негативная реакция, но и *причина,* по которой эта реакция должна последовать.

В любой момент в жизни любого социума, который живет по правилам, правовым или нет, могут возникнуть трения между теми, кто, с одной стороны, принимает и добровольно содействует исполнению права и воспринимает свое собственное поведение и поступки других людей в свете этих правил, и, с другой стороны, теми, кто отвергает эти правила и относится к ним с внешней точки зрения как к знакам, предупреждающим о возможном наказании за их нарушение. Необходимость учитывать обе эти точки зрения — это одна из трудностей, с которой сталкивается любая правовая теория, стремящаяся описать положение дел во всей его сложности. Наша критика предсказательной теории обязательств, по сути, сводится к тому, что она не учитывает внутреннего аспекта правил, налагающих обязанности.

3. НАЧАЛА ПРАВА

Можно представить себе общество, в котором не было бы законодателей, судов и официальных лиц любого типа [41]. Существует множество исследований примитивных обществ, в которых не только доказывается, что такая возможность действительно реализовалась, но и подробно описывается жизнь сообщества, социальный контроль в котором осуществляется исключительно благодаря всеобщему признанию группой стандартных для нее норм поведения подобных тем, которые мы охарактеризовали как правила обязательства. Социальная структура подобного рода нередко называется «обычной» *(основывающейся на обычаях),* однако мы не будем использовать этот термин, так как он предполагает, что правила, установленные обычаем, очень древние и поддерживаются при помощи меньшего давления со стороны общества, нежели другие правила. Для того чтобы избежать этих допущений, назовем такую социальную структуру структурой, основанной на первичных правилах обязательства. Если общество живет исключительно по таким первичным правилам, то, учитывая некоторые очевидные банальности о природе человека и мира, в котором мы живем, должны будут выполняться несколько очевидных

условий. Одним из таких условий будет то, что эти правила обязательно должны будут включать в себя определенные ограничения на применение насилия, а также наказания за кражу и обман, так как подобные действия должны подавляться, если люди желают сосуществовать друг с другом. И действительно, правила подобного рода приняты во всех известных нам примитивных обществах. Кроме того, существуют и другие правила, налагающие на отдельных членов сообщества позитивные обязанности, предписывающие выполнение определенных действий, вносящих вклад в общественную жизнь. Во-вторых, хотя в таком сообществе может существовать напряженность между теми, кто принимает эти правила, и теми, кто отвергает их и подчиняется только в силу давления со стороны социума и из страха перед возможным наказанием за их неисполнение, ясно, что эти последние должны составлять меньшинство. Ведь сообщество людей примерно равных по физической силе не сможет стабильно существовать, если те, кто противится правилам, не будут ощущать достаточно сильного давления со стороны общества. И это также подтверждается исследованиями примитивных обществ, в которых, при наличии определенного числа инакомыслящих и злодеев, большинство живет по правилам, воспринимаемым с внутренней точки зрения.

Для наших целей более важным является следующее соображение. Ясно, что только небольшое сообщество, связанное узами родства, близостью мировоззрений и верований и помещенное в стабильную среду, может успешно существовать под управлением подобного рода неофициальных правил. При других обстоятельствах такая простейшая форма контроля неизбежно окажется недостаточной, и для исправления ее недостатков потребуются дополнительные меры. Прежде всего, правила, по которым живет эта группа, не образуют системы, представляя собой всего лишь набор определенных стандартов, отдельно не идентифицируемых и не связанных друг с другом ничем, кроме, разумеется, того обстоятельства, что все они признаются определенной группой людей. В этом отношении они напоминают наши правила этикета. Поэтому каждый раз, когда возникает сомнение относительно того, в чем конкретно состоит то или иное правило, мы не будем иметь возможности прибегнуть к стандартизированной процедуре, позволяющей развеять это сомнение, такой, как обращение к авторитетному тексту или официальному лицу, чьи заявления по данному поводу обладают авторитетом. Ведь ясно, что такая процедура и признание решения авторитетного текста или персоны предполагает существование правил, отличных по природе от тех правил обязательства и обязанности, которые, согласно нашей гипотезе, существуют в данном обществе. Этот дефект простой социальной структуры, основанной лишь на первичных правилах, мы назовем *неопределенностью.*

Вторым дефектом является *статичность* этих правил. Единственным приемлемым способом изменения правил для такого общества является процесс медленной трансформации, при котором определенные правила поведения сначала считаются возможными, затем обычными или типичными, и только затем необходимыми, и напротив, процесс упадка того или иного правила состоит в том, что сначала за его нарушение сурово наказывают, затем к нарушениям начинают относиться более терпимо и наконец перестают их замечать. В подобном обществе не существует механизма сознательной адаптации правил к изменяющимся обстоятельствам путем уничтожения старых правил или введения новых, так как подобная процедура возможна только при наличии правил, отличных от тех правил первичных обязательств, по которым живет данное общество. В крайнем случае эти правила могут быть статичными в более решительном смысле. И этот гипотетический случай, возможно, никогда не реализуемый в действительности, следует также учесть, так как средства для его преодоления суть нечто очень характерное для права. Предположим, что в нашем обществе не только не существует способа сознательного изменения общего правила, но и обязанности, которые следуют из него в конкретных случаях, не могут быть изменены или модифицированы на основе сознательного выбора того или иного частного лица. Каждый член общества в этом случае будет обязан выполнять определенные действия и воздерживаться от совершения определенных поступков. Во многих случаях в результате надлежащего исполнения подобных обязательств одни лица будут получать выгоду от действия других. Однако если существуют только первичные правила обязательств, они не смогут освободить своих должников от исполнения должного или же передать выгоды от исполнения этих обязательств в пользу других лиц. Ведь для того чтобы освободить должника от исполнения обязательства или же уступить право требования другому лицу, необходимо создать изменения в изначальных первичных правилах обязательств, для чего потребуются правила, отличные от этих первичных правил.

Третьим дефектом такой простейшей формы социальной жизни является *неэффективность* того распыленного социального давления, благодаря которому поддерживается исполнение правил. Споры о том, нарушено ли в данном случае правило или нет, неизбежно возникнут и, за исключением очень маленьких и сплоченных обществ, будут продолжаться до тех пор, пока не появится орган, имеющий право окончательно и авторитетно установить факт нарушения. Отсутствие подобной ясности и авторитетности в установлении факта нарушения следует отличать от другой слабости этой системы. Речь идет о том, что наказание за нарушение правила и другие формы социального давления, которые предполагают физическое воздействие или применение силы, также в

данном случае не организованы и остаются во власти заинтересованных лиц или общества в целом. Очевидно, что потеря времени в процессе неорганизованных усилий группы поймать и наказать нарушителей, равно как и бесконечная вендетта в ситуации отсутствия официальной монополии на исполнение «санкций», могут породить значительные проблемы. История права учит нас, однако, что отсутствие официальных органов для авторитетного выявления самого факта нарушения правила является более значительным дефектом. Именно поэтому во многих обществах именно эта проблема решалась намного раньше других [42].

Исправление указанных трех дефектов этой простейшей формы социальной жизни возможно, если к *первичным* правилам обязательства добавятся *вторичные* правила, имеющие другую природу. Исправление каждого из этих дефектов можно рассматривать как последовательные шаги на пути от доправового к правовому миру [43]. Каждый из этих шагов вносит в социальную жизнь элементы того, что свойственно именно праву, а исправление всех трех указанных дефектов является достаточным условием для того, чтобы исходный режим первичных правил превратился в настоящую правовую систему. Рассмотрим последовательно эти шаги и покажем, почему право может лучше всего быть охарактеризовано именно как единство первичных правил обязательства и вторичных правил подобного рода. Однако сначала отметим одно обстоятельство общего характера. Хотя исправление этих дефектов предполагает введение правил, отличных друг от друга и от тех первичных правил обязательств, которые они дополняют, они имеют много общих характеристик и связаны друг с другом различными способами. Так, обо всех этих новых правилах можно сказать, что они находятся на уровне, отличном от первичных правил, кроме того, все они являются высказываниями *о первичных правилах.* Иными словами, если первичные правила касаются действий, которые то или иное лицо должно совершать или нет, вторичные правила касаются только самих первичных правил. Они уточняют, как первичные правила должны удостоверяться, вводиться, удаляться, изменяться, а также как должен устанавливаться факт их нарушения.

Простейшим способом исправления дефекта *неопределенности* режима первичных правил может быть введение того, что мы назовем «правилом признания» [44]. Именно оно должно указать признак или признаки, наличие которых в том или ином правиле признается в качестве конечного утвердительного указания на то, что перед нами именно такое правило, которое группа должна поддерживать социальным давлением. Подобные правила признания могут быть сформулированы в различных формах, простых и сложных. Они могут, как это действительно имело место во многих древних обществах, быть записаны в виде авто-

ритетного списка правил, облеченных в форму письменного документа или высеченных на публичном монументе. В ходе исторического развития этот шаг от доправового состояния к правовому может включать в себя ряд отдельных этапов начиная с фиксации в письменной форме правил, существовавших доселе в устной традиции. Сам по себе этот шаг не является решающим, хотя он и важен. Действительно, важно то, что этот записанный текст или надпись признаются *авторитетными,* то есть именно к ним следует отныне обращаться в случае любых сомнений в существовании, понимании или толковании того или иного правила. В данном случае мы имеем дело с простейшей формой вторичного правила: оно указывает, где следует искать первичные правила обязательств [45].

В более развитой правовой системе правила признания сложнее. Вместо определения правил исключительно отсылкой к тексту или списку они указывают на некоторые общие характеристики, свойственные первичным правилам. К таким характеристикам могут относиться факт их принятия определенным органом, указание на их долгое бытование в обществе или ссылка на судебное решение. Кроме того, в случае, если в качестве идентифицирующего критерия предлагаются несколько таких характеристик, в правиле может быть указан способ преодоления возможного конфликта между ними, к примеру путем расположения их в иерархическом порядке, согласно которому обычай или прецедент должны уступать по значению статуту или закону, который должен считаться «высшим источником» права. Подобные осложняющие обстоятельства делают правила признания в современных правовых системах весьма отличными от простого признания авторитетности определенного текста, однако даже в этой простейшей форме это правило включает в себя много элементов, характерных для права. Придавая правилу признак авторитетности, оно в зачатке содержит идею правовой системы, так как правила благодаря ему перестают быть простым набором предписаний и становятся чем-то единым. Кроме того, в простой операции по выяснению, обладает ли данное правило тем свойством, что оно перечислено в авторитетном списке, уже заложена идея правовой значимости.

Избавлением от дефекта *статичности* первичных правил будет введение того, что можно назвать «правилами изменения». Простейшей формой такого правила является правило, дающее власть одному лицу или группе лиц вводить новые первичные правила, регулирующие жизнь остальных членов группы или определенного класса в ее рамках, и отменять старые правила. Как уже отмечалось в четвертой главе, в подобных терминах, а не при помощи теории приказов, подкрепляемых угрозами, следует понимать истоки идеи законодательного введения и отмены новых правил. Правила изменения могут быть очень простыми или весьма

сложными. Полномочия, которыми они наделяют, могут быть неограниченными или же ограниченным различными способами. Кроме определения круга лиц, обладающих законодательной властью, правило может более или менее строго определять саму законодательную процедуру. Очевидно, что между правилом изменения и правилом признания будет существовать тесная связь: если существует первое, второе должно будет обязательно ссылаться на законодательную процедуру как отличительную черту всех правил, хотя и не обязательно касаться всех деталей, связанных с процедурой издания законов. Как правило, официальный сертификат или его официальная копия признаются достаточным доказательством того, что данное правило должным образом санкционировано. Если социальная структура настолько проста, что единственным «источником права» признается законодательство, то «правило признания» сведется к установлению факта введения закона в силу в качестве единственного идентификационного знака или критерия действенности правила. Именно так будут обстоять дела в воображаемом царстве Рекса I, о котором говорилось в четвертой главе. Правило признания в данном случае сведется к утверждению, что правом является все то, что Рекс I установил в качестве закона.

Мы уже довольно детально описали правила, которые предоставляют отдельным лицам право варьировать их исходную позицию, определенную в рамках первичных правил. Без подобных правил о наделении полномочиями частных лиц общество утратило бы многие из тех важнейших благ и удобств, которые ему предоставляет право. Наличие подобных правил делает возможным составление завещания, заключение договора, передачу права собственности и многие другие добровольные формы установления прав и обязанностей, которые модернизируют жизнь в рамках права [46]. Кроме того, элементарная форма такого правила, предоставляющего власть, лежит в основании морального института обещания. Очевидно также родство этих правил с правилом изменения, которое лежит в основании понятия законодательства. Как недавно доказано, например, в теории Кельзена, многие особенности институтов договора и права собственности, понимание смысла которых долгое время вызывало затруднение, становятся более понятными, если акт заключения договора или передачи права собственности рассматривать в качестве примера реализации ограниченной законодательной власти частными лицами.

Третьим добавлением к простейшему режиму первичных правил, исправляющим дефект *неэффективности* его диффузной системы социального давления, могут быть вторичные правила, предоставляющие отдельным лицам право давать авторитетный ответ на вопрос о том, нарушено ли в данном конкретном случае определенное первичное правило или нет. В вынесении такого определения состоит минимальная

функция суда, поэтому назовем подобные вторичные правила «правилами суда». Кроме определения тех лиц, которым предоставляется право выносить судебные решения, эти правила должны также определить процедуру, которой необходимо следовать. Как и другие вторичные правила, эти правила расположены на уровень выше по сравнению с первичными правилами: хотя к ним могут добавляться правила, предписывающие судьям выносить решение, эти правила не налагают на них обязательств, но дают им судебную власть и специальный статус, позволяющий выносить решение о нарушении обязательств. Как и остальные вторичные правила, эти правила определяют целый ряд важных правовых понятий, таких, как судья, суд, юрисдикция и судебное решение или приговор. Правила суда не только похожи на другие вторичные правила, но и тесно с ними связаны. В самом деле, система, в которой существуют правила суда, должна в той или иной форме содержать правило признания. Ведь если суды имеют право выносить авторитетное определение по поводу того, нарушено ли в данном случае правило или нет, это решение само по себе не может не рассматриваться в качестве авторитетного определения того, что есть правило. Так, правило, согласно которому выносится судебное решение, оказывается одновременно и правилом признания, определяющим первичные правила через решения суда, которые в данном случае окажутся «источником» права. Разумеется, такая форма правила признания, неотделимая от минимальных функций суда, будет очень несовершенной. В отличие от авторитетного текста, кодекса законов или книги статутов, эти решения не будут сформулированы в общем виде, и их использование в качестве авторитетных указателей на наличие правил будет основываться на довольно зыбких выводах, сделанных на основании решений по конкретным поводам, надежность которых будет сильно зависеть от индивидуальных способностей истолкователя и последовательности позиции судей от случая к случаю.

Разумеется, только немногие правовые системы ограничиваются всего лишь вынесением авторитетного определения по поводу факта нарушения правила. В большинстве случаев ясно, что социальное давление должно быть еще более централизованным. В особенности это относится к запрету на самостоятельное исполнение решений и насильственные действия по отношению к нарушителям со стороны частных лиц. В результате первичные правила обязательства дополняются новыми вторичными правилами, специфицирующими или, в крайнем случае, ограничивающими наказания за нарушения и предоставляющими судьям, установившим факт нарушения правила, исключительное право передавать нарушителей в руки других официальных лиц, в обязанности которых входит осуществление наказания.

Если мы еще раз окинем взором ту структуру, которая возникла из комбинации первичных правил обязательства и вторичных правил признания, изменения и суда, то станет ясно, что таким образом мы не только ухватили важнейшую суть правовой системы, но и получили эффективное средство для анализа того, что в течение долгого времени вызывало трудности как у юристов, так и политологов.

В терминах комбинации этих элементов хорошо проясняются не только такие специфические правовые концепты, как обязательства и права, применимость права и его источники, законодательство, юрисдикция и санкция. Понятия государства, авторитета и официального лица (центральные не только для права, но и для политической теории) также нуждаются в аналогичном анализе, если мы желаем развеять ту неопределенность, которая до сих пор в них присутствует. Причина, благодаря которой анализ в терминах первичных и вторичных правил обладает объяснительной силой, лежит на поверхности. Большая часть недоразумений и несоответствий при анализе правовых и политических понятий происходит из-за того, что этот анализ предполагает отсылку к той точке зрения, которую мы назвали внутренней, то есть позиции тех, кто не только описывает и предсказывает поведение в соответствии с правилами, но и *использует* эти правила в качестве стандарта для оценки как своего поведения, так и действий других людей. Это требует более пристального внимания к анализу правовых и политических понятий, нежели это обычно считается необходимым. В простейшем режиме первичных правил внутренняя точка зрения реализуется в ее наиболее элементарной форме; эти правила рассматриваются в качестве основания для оценки, обоснования требований им соответствовать и оправдания социального давления и наказания в случае их нарушения. Ссылка на это наиболее элементарное проявление внутренней точки зрения необходима для анализа базовых понятий обязательства и обязанностей. С добавлением системы вторичных правил сфера того, что говорится и делается с внутренней точки зрения, значительно расширяется и приобретает разнообразие. Вместе с этим расширением появляется целый ряд новых концептов, и для адекватного анализа они предварительно также должны быть помещены в подобающий контекст с внутренней точки зрения. Сюда относятся такие понятия, как законодательство, судебное решение, законность, и, в целом, власть права, как частного, так и публичного. И нередко возникает искушение проанализировать эти понятия в терминах обыденного или «научного» дискурса, устанавливающего факты или предсказывающего поведение. Однако в этом случае перед нами открывается только их внешний аспект: для того чтобы должным образом оценить их внутренний аспект, мы должны рассмотреть, каким образом деятельность законодателя по созданию законов, процедура вынесения су-

дами решения, осуществление частной и публичной власти и другие элементы «права в действии» связаны со вторичными правилами.

В следующей главе мы покажем, как идеи юридической силы права и источников права, а также элементы истины, скрытые среди ошибок доктрин суверенитета, могут быть перефразированы и прояснены в терминах правила признания. В заключение данной главы следует сделать одну оговорку: хотя комбинация первичных и вторичных правил заслуживает того центрального места, которое ей отведено, следует помнить, что, объяснив многие аспекты права, она не может прояснить каждую проблему. Единство первичных и вторичных правил находится в центре правовой системы, однако по мере продвижения от центра к периферии мы должны будем обратиться к элементам иной природы. Об этом пойдет речь в последующих главах.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ОСНОВАНИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ

1. ПРАВИЛО ПРИЗНАНИЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Согласно теории, подвергнутой критике в четвертой главе, основания правовой системы состоят в ситуации, когда большинство членов социальной группы привычно повинуются приказам, подкрепленным угрозами суверенного лица или лиц, которые сами привычно не повинуются никому. Такая социальная ситуация для данной теории является и необходимым, и достаточным условием существования права. Мы уже достаточно детально показали неспособность этой теории объяснить некоторые из бросающихся в глаза особенностей современной системы внутригосударственного права; но, тем не менее, как показывает продолжающееся господство этой теории над умами многих мыслителей, она содержит, хотя и в неясной и искаженной форме, некоторые истины относительно некоторых важных аспектов права. Однако эти истины могут быть ясно выражены и их важность правильно оценена только в контексте более сложной социальной ситуации, когда принимается вторичное правило признания и используется для выявления первичных правил обязанностей. Если что-то и заслуживает того, чтобы называться основаниями правовой системы, то именно эта ситуация. В этой главе мы рассмотрим различные элементы этой ситуации, которые получили только частичное или искаженное выражение в теории суверенитета и где-либо еще [47].

Везде, где принимается такое правило признания, и частные, и официальные лица получают надежный критерий для идентификации первичных правил обязанности. Полученные таким образом критерии могут, как мы видели, принимать любую из множества форм: в их число входит ссылка на авторитетный текст; на законодательное постановление; на обычную практику; на общие декларации определенных лиц или на прошлые судебные решения по конкретным делам. В очень простой системе, такой, как мир Рекса I, описанный в четвертой главе, где только то, что он постановляет, является правом и на его законодательную

власть не накладываются никакие юридические ограничения ни обычаями, ни конституционными документами, единственным критерием идентификации права будет простая ссылка на факт постановления Рекса I. Существование этого простого правила признания будет проявляться в обычной практике идентификации правил с помощью этого критерия как частными, так и официальными лицами. В современной правовой системе, где есть множество «источников» права [48], правило признания, соответственно, более сложно: критерии идентификации права многочисленны и обычно включают писаную конституцию, постановления парламента и судебные прецеденты. В большинстве случаев принимаются меры для предотвращения конфликта этих критериев путем их ранжирования в порядке относительного первенства и подчинения. Именно таким образом в нашей системе «обычное право» подчинено «статутам».

Важно отличать это относительное *подчинение* одного критерия другому от *выведения,* поскольку ложное подкрепление того представления, что все право по сути или «на самом деле» (даже если только «по умолчанию») есть продукт законодательной деятельности, было получено от смешения этих двух идей. В нашей собственной системе обычай и прецедент подчинены законодательству, так как правила обычая и обычного права могут быть лишены их статуса права статутом. Но они обязаны своим статусом права, каким бы ненадежным он ни был, не «молчаливому» применению законодательной власти, но принятию правила признания, которое отводит им эту независимую, хотя и подчиненную роль. Опять же, как и в простом случае, существование такого сложного правила признания проявляется в общей практике идентификации правил с помощью такого критерия.

В повседневной жизни правовой системы ее правило признания очень редко нарочито формулируется как правило, хотя время от времени суды в Англии могут провозглашать в общей форме положение одного критерия права по отношению к другому, как, например, когда они утверждают приоритет парламентских актов перед другими источниками или предполагаемыми источниками права. По большей части правило признания не формулируется, но его существование *демонстрируется* тем, как идентифицируются конкретные правила либо судами или другими официальными органами, либо частными лицами или их советниками. Конечно, есть разница в том, как суды применяют критерии, содержащиеся в правиле признания, и как используют их все остальные, ибо когда суды достигают конкретного решения на том основании, что конкретное правило верно идентифицировано в качестве закона, то, что они говорят, имеет особый авторитетный статус, которым их наделили другие правила. В этом отношении, как и во многих других, правило признания в правовой системе подобно правилу ведения счета в игре. В ходе

ходе игры редко формулируется общее правило, определяющее те виды деятельности, которые составляют счет (пробежки, голы и т. д.); вместо этого оно *применяется* официальными лицами при идентификации тех или иных фаз игры, которые значимы для выигрыша. Здесь также декларации официальных лиц (судьи или счетчика очков) имеют особый авторитетный статус, приданный им другими правилами. Более того, в обоих случаях есть возможность конфликта между этими авторитетными применениями правила и общим пониманием того, что явно требует правило согласно его положениям. Это, как мы увидим позже, есть осложнение, которому должно уделяться внимание в любом описании того, что для такой системы правил означает «существовать».

Использование недекларированных правил признания судами и всеми остальными при идентификации отдельных правил системы характерно для внутренней точки зрения. Те, кто применяют их (правила признания) таким образом, тем самым проявляют свое принятие их как руководящих правил, и с этим отношением приходит и соответствующая лексика, отличная от характерной для естественного выражения внешней точки зрения. Возможно, простейшее из таких выражений — «это закон, что...», которое бывает на устах не только судей, но и обычных людей, живущих в правовой системе, когда они определяют одно из правил, данных в этой системе. Это, как и выражение «аут» или «гол», есть язык того, кто оценивает ситуацию, обращаясь к правилам, которые он, вместе с другими, признает уместными для этой цели. Это отношение разделяемого принятия правил может быть противопоставлено отношению наблюдателя, который фиксирует ab extra тот факт, что социальная группа принимает такие правила, но сам их не принимает. Естественным выражением такой внешней точки зрения является не «это закон, что...», но «в Англии они считают законом... все, что постановляет Королева в Парламенте...». Первый из этих видов высказываний мы назовем *внутренним утверждением,* потому что оно выражает внутреннюю точку зрения и естественным образом используется теми, кто, принимая правило признания и не декларируя тот факт, что оно принято, применяет правило при признании какого-либо отдельного правила системы в качестве действительного. Второй вид высказывания мы назовем *внешним утверждением,* потому что оно является естественным языком внешнего наблюдателя системы, который, сам не принимая ее правила признания, констатирует факт, что другие его принимают.

Если такое использование принимаемого правила признания при высказывании внутренних утверждений понято и тщательным образом различается от внешнего утверждения о том факте, что правило принято, многие неясности, связанные с понятием юридической «действительно-

сти», исчезают [49]. Ибо слово «действительный» чаще всего, хотя и не всегда, используется именно в таких внутренних утверждениях при применении к отдельным правилам правовой системы невысказанного, но принимаемого правила признания. Сказать, что данное правило действительно, означает признать, что оно проходит все испытания, содержащиеся в правиле признания, и, таким образом, является правилом этой системы. Мы даже можем просто сказать, что утверждение о том, что то или иное правило действительно, означает, что оно удовлетворяет всем критериям, содержащимся в правиле признания. Это неверно только в той степени, что может затемнить внутренний характер таких утверждений, ибо, как «аут» в крикете, такие утверждения о действительности обычно применяют к частному случаю правило признания, принятое говорящим и остальными, а не открыто констатируют, что требования этого правила удовлетворяются.

Некоторые из затруднений, связанных с идеей юридической действительности, как говорят, касаются взаимосвязи между действительностью и «эффективностью» права. Если под «эффективностью» имеется в виду тот факт, что норма права, требующая некоторого вида поведения, чаще соблюдается, чем нет, ясно, что нет необходимой связи между действительностью любого конкретного правила и *его* эффективностью, если только правило признания этой системы не включает, среди своих критериев (как это и делают некоторые правила признания), положения (иногда называемого «правилом устарелости») о том, что никакое правило не должно считаться правилом системы, если оно давно перестало быть эффективным.

От неэффективности отдельного правила, которая может рассматриваться как свидетельство его недействительности, а может и нет, мы должны отличать общее пренебрежение правилами системы. Оно может быть настолько полным по своему характеру и настолько продолжительным, что мы должны сказать, если речь идет о новой системе, что она не утвердилась как правовая система данной социальной группы, или, в случае с когда-то установившейся системой, что она перестала быть правовой системой данной группы. В любом из этих случаев нормальный контекст или фон для высказывания внутренних утверждений в категориях правил системы отсутствует. В таких случаях было бы в общем *бессмысленным* либо оценивать права и обязанности отдельных лиц, ссылаясь на первичные правила системы, либо оценивать действительность любого из ее правил, соотнося его с правилами признания системы. Настаивать на применении системы правил, которая либо никогда не была действенной, либо была отброшена, было бы (за исключением особых обстоятельств, отмеченных ниже) столь же бесполезным, как и оценивать развитие игры, ссылаясь на правило ведения счета, которое никогда не применялось или было отменено.

О том, кто делает внутреннее утверждение о действительности отдельного правила системы, может быть сказано, что он *исходит из* истинности внешнего утверждения о том, что эта система в целом эффективна. Ибо обычное применение внутренних утверждений имеет место в таком контексте общей эффективности. Однако было бы неправильным сказать, что утверждения о юридической действительности «означают», что система в целом действенна. Ибо, хотя обычно бесцельными или праздными являются рассуждения о действительности правила системы, которая никогда не устанавливалась или была отброшена, тем не менее они не бессмысленны и не всегда бесцельны. Один из наглядных способов преподавать римское право — рассуждать так, *как будто бы* эта система все еще эффективно действует, и обсуждать действительность отдельных правил и решать проблемы с их точки зрения. Один из способов лелеять надежды на реставрацию старого порядка и отвергать новый — продолжать придерживаться критериев юридической действительности старого режима. Это имплицитно осуществляется теми русскими «белыми», которые претендуют на собственность согласно некоторому правилу наследования, которое было действительным правилом в царской России.

Понимание нормальной контекстуальной связи между внутренним утверждением, что данное правило системы действительно, и внешним утверждением, что система в целом эффективна, поможет нам увидеть в должном свете обычную теорию о том, что утверждать действительность правила означает предсказывать, что оно будет проводиться в жизнь судами, или будет предпринято какое-то иное официальное действие. Во многих отношениях эта теория аналогична предсказательному анализу понятия обязанности, который мы рассмотрели и который отвергли в предыдущей главе. В обоих случаях мотивом выдвижения предсказательной теории является убеждение, что только так можно избежать метафизических интерпретаций: говоря о том, что правило действительно, мы либо приписываем этому правилу некоторое таинственное свойство, которое невозможно обнаружить эмпирическими методами, либо считаем его предсказанием будущего поведения официальных лиц. В обоих случаях своим правдоподобием теория обязана одному и тому же важному факту: а именно, что истинность внешнего фактического утверждения, которое мог бы записать наблюдатель, что система в общем эффективна и, скорее всего, будет оставаться таковой, обычно подразумевается любым из тех, кто принимает правила и делает внутреннее утверждение об обязанности или юридической действительности. Оба они, конечно, очень тесно связаны. Наконец, в обоих случаях ошибка этой теории одна и та же: она состоит в пренебрежении особым характером внутреннего утверждения и подходе к нему как к внешнему утверждению о действии официального характера.

Эта ошибка немедленно становится очевидной, когда мы рассмотрим, какую роль собственное убеждение судьи, что конкретное правило юридически действительно, играет при вынесении решения судом [50]. Хотя и здесь, делая такое утверждение, судья подразумевает, но не констатирует общую эффективность системы, он явно не заботится о том, чтобы предсказать свое собственное официальное действие или такие же действия других. Его заявление о том, что правило действительно, является внутренним утверждением, признающим то, что правило удовлетворяет тестам на то, чтобы считаться законом в этом суде, и составляет (его заявление) не пророчество, но часть *оснований* для его решения. Действительно, говорить, что утверждение о действительности правила есть предсказание, выглядит более правдоподобно, когда такое утверждение делается частным лицом. Ибо в случае конфликта между неофициальными утверждениями о юридической действительности или недействительности и таковыми же утверждениями суда при вынесении решения по делу часто вполне разумно заявить, что первые должны быть взяты назад. Но даже здесь, как мы увидим, когда будем рассматривать в седьмой главе значимость подобных конфликтов между официальными декларациями и ясными требованиями правил, может оказаться догматичным исходить из допущения, что они берутся назад как утверждения, чья *ошибочность* теперь продемонстрирована, так как они ложно *предсказали,* что скажет суд. Ибо есть больше причин для того, чтобы отзывать заявления, чем тот факт, что они ложны, а также больше способов оказаться неправым, чем допускает эта концепция.

Правило признания, обеспечивающее критерии, по которым оценивается юридическая действительность других правил системы, является, в важном смысле, который мы попытаемся прояснить, *окончательным* правилом; и там, где, как это обычно происходит, имеется несколько критериев, ранжированных по порядку их относительного подчинения и первенства, один из них является *наивысшим.*

Эти идеи окончательности правила признания и верховенства одного из его критериев заслуживают некоторого внимания. Важно отделить их от той теории, которую мы отвергли, теории о том, что в любой правовой системе где-нибудь за формами права должна таиться суверенная законодательная власть, являющаяся юридически неограниченной.

Из двух этих идей, наивысшего критерия и окончательного правила, легче дать определение первому. Можно сказать, что критерий юридической действительности или источника права является наивысшим, если правила, выявляемые путем обращения к этому критерию, по-прежнему остаются правилами системы, даже если они противоречат правилам, выявленным путем обращения к другим критериям. И в то же время правила, выявленные путем обращения к последним, не признаются

правилами, если противоречат правилам, выявленным путем обращения к наивысшему критерию. Аналогичное объяснение в сравнительных понятиях может быть дано идеям «высшего» и «подчиненных» критериев, которые мы уже применяли. Ясно, что понятия высшего и наивысшего критериев всего лишь относятся к их *относительному* положению на шкале и не вносят никакой идеи юридически *неограниченной* законодательной власти. Но «наивысший» и «неограниченный» легко спутать — по крайней мере в теории права. Одна из причин этого в том, что в простых видах правовой системы идеи окончательного правила признания, высшего критерия и юридически неограниченной легислатуры, как кажется, сливаются. Ибо там, где есть легислатура, не подчиненная никаким конституционным ограничениям и обладающая полномочиями своим постановлением лишить все иные нормы права, исходящие из других источников, статуса закона, частью правила признания в такой системе является то, что постановление этой легислатуры есть высший критерий юридической действительности. Таково, согласно конституционной теории, положение в Соединенном Королевстве. Но даже если, как в Соединенных Штатах, нет такой юридически неограниченной легислатуры, правовые системы вполне могут содержать окончательное правило признания, обеспечивающее набор критериев юридической действительности, один из которых является наивысшим. Так будет там, где законодательная компетенция обычной легислатуры ограничена конституцией, не допускающей возможности внесения поправок или делающей некоторые положения не подлежащими поправкам. Здесь нет юридически неограниченной легислатуры, даже в самом широком понимании этого слова, но в положениях своей конституции система, несомненно, содержит окончательное правило признания и наивысший критерий юридической действительности [51].

Лучше всего можно понять, в каком смысле правило признания является *окончательным* правилом системы, если следовать очень знакомой цепочке юридических аргументов. Если встает вопрос о том, является ли некоторое предполагаемое правило юридически действительным, мы должны, для того чтобы ответить на этот вопрос, использовать критерий действительности, который обеспечивает некоторое другое правило. Является ли это якобы постановление совета графства Оксфордшир юридически действительным? Да, потому что оно было сделано в осуществление полномочий, которыми наделен этот орган, и в соответствии с процедурой, регламентированной официальным распоряжением министра здравоохранения. На этой первой стадии официальное распоряжение задает критерии, по которым оценивается юридическая действительность постановления. На практике может не быть необходимости идти дальше, но имеется постоянная возможность это сделать. Мы мо-

жем задаться вопросом о юридической действительности официального распоряжения и оценить его действительность в соответствии со статутом, наделяющим министра правом делать такие распоряжения. Наконец, когда действительность статута поставлена под вопрос и оценена в соотнесении с правилом, что то, что Королева постановляет в Парламенте, является законом, мы останавливаемся в вопрошании о юридической действительности. Ибо мы достигли правила, которое, как и промежуточные официальное распоряжение и статут, обеспечивает критерии для оценки действительности других правил; но оно отличается от них тем, что не существует правила для оценки его собственной юридической действительности.

Конечно, существует множество вопросов, которые могут подниматься в связи с этим правилом. Мы можем спросить, обычная ли это практика для судов, законодательных органов, официальных и частных лиц в Англии — действительно использовать это правило как окончательное правило признания? Или же наш процесс юридической аргументации является праздной игрой с критериями действительности ныне отброшенной системы? Мы можем спросить, является ли удовлетворительной такая система, в корне которой такое правило? Создает ли она больше добра, чем зла? Есть ли продиктованные благоразумием причины поддерживать ее? Существует ли моральная обязанность делать это? Все это, очевидно, очень важные вопросы. Но столь же очевидно, что, когда мы задаем их о правиле признания, мы более не пытаемся ответить на такие же вопросы о нем, на которые мы отвечали о других правилах с помощью правила признания. Когда мы переходим от утверждения, что то или иное постановление имеет юридическую силу, потому что удовлетворяет правилу «то, что постановляет королева в парламенте, является законом», к утверждению, что в Англии это правило используется судами, официальными и частными лицами как окончательное правило признания, мы перешли от внутреннего утверждения о праве, касающегося действительности правила системы, к внешнему утверждению о факте, которое мог бы сделать наблюдатель, даже если он сам не принимает этой системы. Таким же образом, когда мы переходим от утверждения, что то или иное постановление действительно, к утверждению, что правило признания данной системы великолепно и система, основанная на нем, заслуживает поддержки, мы перешли от утверждения о юридической действительности к ценностному суждению.

Некоторые авторы, подчеркивавшие юридическую окончательность правила признания, выражают это, заявляя, что, в то время как юридическая действительность других правил системы может быть продемонстрирована по соотнесению с ним, юридическая действительность самого этого правила не может быть продемонстрирована, но «допускается»,

или «постулируется», или является «гипотезой». Это, однако, может вводить в серьезное заблуждение. Утверждения о юридической действительности отдельных правил, высказываемые в повседневной жизни правовой системы судьями, юристами или обычными гражданами, действительно несут с собой некоторые исходные допущения. Это — внутренние утверждения о праве, выражающие точку зрения тех, кто принимает правило признания системы и по существу оставляет невысказанным многое из того, что могло бы быть высказано во внешних утверждениях об этой системе. То, что таким образом остается невысказанным, формирует нормальный фон или контекст утверждений о юридической действительности и поэтому, как говорят, «предполагается» ими. Но важно четко видеть, каковы именно эти предполагаемые материи, и не затемнять их характер. Есть две стороны этого. Во-первых, человек, серьезно утверждающий действительность некоторой данной нормы права, допустим, того или иного статута, сам применяет правило признания, которое он признает уместным для идентификации права. Во-вторых, это тот случай, когда данное правило признания, через которое он оценивает действительность конкретного статута, не только принимается им, но и является правилом признания, реально принятым и применяемым в общем функционировании системы. Если бы истинность этого предположения вызывала сомнения, ее можно было бы установить, обратившись к реальной практике: к тому, как суды определяют то, что будет считаться правом, и к общему принятию или примирению с такой идентификацией права.

Ни одно из этих двух предположений не может быть удачно охарактеризовано как «допущение» о «действительности», которая не может быть продемонстрирована. Мы нуждаемся в понятии «юридическая действительность» и обычно используем его только для того, чтобы отвечать на вопросы, возникающие *внутри* системы правил, где статус правила как элемента этой системы зависит от того, удовлетворяет ли оно некоторым критериям, которые дает правило признания. Таких вопросов не может возникнуть по поводу действительности самого правила признания, которое обеспечивает эти критерии: оно не может быть ни действительным, ни недействительным, но просто принимается как подходящее для использования таким образом. Выражать этот простой факт туманным высказыванием о том, что его действительность «предполагается, но не может быть продемонстрирована», подобно высказыванию о том, что мы предполагаем, но никогда не можем продемонстрировать, что эталонный метр в Париже, являющийся конечным тестом на правильность всех измерений в метрах, сам правилен.

Более серьезное возражение состоит в том, что разговоры о «допущении», что окончательное правило признания действительно, скрывает

фактуальный, по сути, характер второго предположения, стоящего за утверждениями юристов о действительности. Несомненно, что практика судей, официальных лиц и других, в которой и состоит реальное существование правила признания, является сложным делом. Как мы увидим дальше, несомненно, существуют ситуации, в которых вопросы о точном содержании и диапазоне действия такого вида правила, и даже о его существовании, могут не иметь ясного или определенного ответа. Тем не менее важно отличать «исходя из действительности» и «предполагая существование» такого правила, хотя бы только потому, что неспособность сделать это затемняет смысл утверждения о том, что такое правило *существует.*

В простой системе первичных правил обязанности, обрисованной в предыдущей главе, утверждение, что то или иное правило существует, могло быть только внешним утверждением о факте, каковое мог сделать наблюдатель, сам не принимающий этих правил, и проверить, удостоверившись в том, принимается ли данный вид поведения как образец и сопровождается ли теми чертами, которые, как мы видели, отличают социальные правила от всего лишь сходных обычаев. Именно таким образом мы ныне должны интерпретировать и проверять утверждение о том, что в Англии существует правило — хотя и не законодательное, — что мы должны обнажать голову, входя в церковь. Если обнаруживается существование подобных этим правил в реальной практике социальной группы, нет заслуживающего обсуждения отдельного вопроса об их действительности, хотя, конечно, их ценность или желательность может быть поставлена под сомнение. Как только их существование установлено как факт, мы только будем запутывать дело, утверждая или отрицая, что они действительны, или говоря, что «мы исходим из» их действительности, но не можем ее показать. С другой стороны, там, где, как в зрелой правовой системе, у нас имеется система правил, включающая правило признания, так что статус правила как части этой системы теперь зависит от того, удовлетворяет ли оно некоторым критериям, содержащимся в правиле признания, — это приносит с собой новое употребление слова «существовать». Утверждение, что правило существует, теперь может больше не быть тем, чем оно было в простом случае с правилами обычного права, — внешним утверждением того *факта,* что некоторый вид поведения на практике общепризнан в качестве нормы. Теперь оно может быть внутренним утверждением, применяющим принятое, хотя и невысказанное правило признания, и (примерно) означающим «действительно в рамках критериев действительности системы». В этом отношении, однако, как и в других, правило признания не похоже на другие правила этой системы. Утверждение, что оно существует, может быть только внешним утверждением факта. Ибо, в то время

как подчиненное правило системы может быть действительным и в этом смысле «существовать» даже если все его игнорируют, правило признания существует только в сложной, но обычно согласованной деятельности судов, официальных и частных лиц по выявлению права через обращение к некоторым критериям. Его существование — это вопрос факта.

2. НОВЫЕ ВОПРОСЫ

Как только мы откажемся от представления о том, что основания правовой системы состоят в привычном повиновении не ограниченному законом суверену и вместо этого примем концепцию окончательного правила признания, обеспечивающего критериями юридической действительности систему правил, перед нами встает ряд важных и увлекательных вопросов. Это относительно новые вопросы, ибо они были скрыты до тех пор, пока юриспруденция и политическая теория были привержены старым мыслительным традициям. Это также трудные вопросы, требующие для полного ответа понимания, с одной стороны, некоторых фундаментальных аспектов конституционного права и, с другой, той характерной манеры, в какой правовые формы могут молчаливо изменяться. Поэтому мы рассмотрим эти вопросы ровно настолько, насколько они касаются мудрости или глупости настаивания на том, что в разъяснении понятия права главное место должно быть отведено союзу первичных и вторичных правил.

Первая трудность связана с классификацией, ибо правило, которое в последней инстанции используется для определения права, не укладывается в обычные категории, используемые для описания правовой системы, хотя эти категории часто считают исчерпывающими. Так, английские конституционалисты со времен Дайси обычно повторяли утверждения о том, что конституционное устройство Соединенного Кололевства состоит отчасти из законов в строгом смысле слова (статутов, законов, издаваемых от имени короля и тайного совета (orders in council) и норм, воплощенных в прецедентах), и отчасти из конвенций, являющихся всего лишь способами употребления, понимания или обычаями [52]. Последние включают важные правила, такие, как то, что Королева не может не дать согласия на билль, в соответствии с должной процедурой принятый палатами лордов и общин; однако не существует закона, обязывающего Королеву дать на него свое согласие, и такие правила называются конвенциями, потому что суды не признают их в качестве налагающих правовые обязанности. Ясно, что правило, гласящее, что «то, что Королева постановляет в парламенте, есть право», не попадает ни в одну из этих категорий. Это не конвенция, поскольку суды самым непосредст-

венным образом принимают его во внимание и используют в выявлении права. Но это и не правило того же уровня, что и «законы в строгом смысле слова», которые идентифицируются с его помощью. Даже если бы оно было введено в действие статутом, это не свело бы его до уровня статута, ибо правовой статус такого введения закона в силу с необходимостью зависел бы от того факта, что правило существует до и независимо от провозглашения статутом. Более того, как мы показали в предшествующем разделе, его существование, в отличие от существования статута, должно состоять в реальной практике.

Это положение дел исторгает у некоторых крик отчаяния: как мы можем показать, что фундаментальные положения конституции, которые, конечно, являются правом, действительно суть право? Другие отвечают на это утверждением, что в основании правовых систем есть нечто не являющееся правом, нечто «до-правовое», «мета-правовое» или просто «политический факт». Это затруднение есть верный знак того, что категории, используемые для описания этой самой важной черты любой системы права, слишком грубы. Основание для того, чтобы называть правило признания «правом», состоит в том, что правило, дающее критерии для идентификации других правил системы, может с хорошими на то причинами мыслиться как определяющая особенность системы права и, таким образом, само заслуживать наименования «права». Основание для того, чтобы называть его «фактом», состоит в том, что утверждать, что такое правило существует, по сути, означает делать внешнее утверждение о реальном факте, касающемся того способа, каким идентифицируются правила «эффективной» системы. Оба этих аспекта претендуют на наше внимание, но мы не можем справедливо поступить в отношении их обоих, избрав один из ярлыков — «право» или «факт». Вместо этого мы должны помнить, что окончательное правило признания может рассматриваться с двух точек зрения. Одна из них выражается во внешнем утверждении о том факте, что правило существует в реальной практике системы. Другая выражается во внутренних утверждениях о юридической действительности, делаемых теми, кто использует это правило при выявлении права [53].

Вторая группа вопросов возникает из скрытой сложности и неясности утверждения о том, что правовая система *существует* в данной стране или в данной социальной группе. Когда мы делаем это утверждение, мы на самом деле ссылаемся в сжатой форме на ряд гетерогенных социальных фактов, обычно сопутствующих друг другу [54]. Стандартная терминология юридической и правовой мысли, развившаяся в тени ошибочной теории, склонна чрезмерно упрощать и затемнять эти факты. Но когда мы снимем очки этой терминологии и посмотрим на факты, станет ясным, что правовая система, как и человеческое существо,

может на одной стадии быть еще не рожденной, на другой — частично зависящей от своей матери, затем наслаждаться здоровым, независимым существованием, позже прийти в упадок и, наконец, умереть. Эти промежуточные стадии между рождением и нормальным, независимым существованием и, опять же, между ним и смертью, приводят в расстройство наши обычные способы описания правовых явлений. Они заслуживают изучения потому, что какими бы трудными они ни были, они рельефно демонстрируют всю сложность того, что мы принимаем как само собой разумеющееся, когда — в обычном случае — делаем уверенное и правильное утверждение, что в данной стране правовая система существует.

Один из способов понять эту сложность — увидеть, где именно простая формула Остина об общей привычке повиновения приказам не способна воспроизвести или искажает сложные факты, составляющие минимальные условия, которым должно соответствовать общество, чтобы иметь правовую систему. Мы можем допустить, что эта формула действительно указывает одно необходимое условие, а именно, что там, где законы налагают обязанности, им должны, в общем и целом, повиноваться, или по крайней мере нужно чтобы не было всеобщего неповиновения. Но это, хотя и очень важно, учитывает только то, что можно было бы назвать «конечным продуктом» правовой системы там, где она воздействует на жизнь частного лица; в то время как ее повседневное существование состоит также в официальном законотворчестве, официальном выявлении и официальном использовании и применении права. Существующая здесь связь с правом может быть названа словом «повиновение» только если значение этого слова будет настолько расширено за пределы его обычного использования, что оно перестанет информативно описывать такую деятельность. Ни в каком обычном значении слова «повиноваться» законодатели не повинуются правилам, когда, принимая законы, они делают это в соответствии с правилами, наделяющими их законодательной властью, разумеется, за исключением тех случаев, когда правила, наделяющие их такой властью, подкрепляются правилами, налагающими обязанность им следовать. Также, когда они делают это с нарушением правил, нельзя сказать, что они «не повинуются» закону, хотя могут оказаться неправомочны принять закон. Нельзя сказать, и что слово «повиноваться» хорошо описывает то, что делают судьи, когда применяют правило признания системы и признают статут имеющим юридическую силу правом и используют его в разрешении споров. Конечно, мы можем, если захотим, сохранить простую терминологию «повиновения» перед лицом фактов, идя на многие хитрости. Одна из них — представлять, к примеру, использование судьями общих критериев юридической действительности при оценке статута как случай повиновения

приказам, данным «отцами-основателями Конституции», или (там, где нет никаких «отцов») повиновения «депсихологизированной команде», то есть команде без командира. Но это последнее, возможно, должно притязать на наше внимание не больше, чем понятие племянника без дяди. В качестве альтернативы мы также могли бы закрыть глаза на всю официальную сторону права и отказаться от описания использования принятых правил в законодательной и судебной деятельности и вместо этого думать обо всем официальном мире как одном лице («суверене»), отдающем, через различных посредников и представителей приказы, которым привычно повинуются граждане. Но это либо не более чем удобное сокращенное изложение сложных фактов, все еще ожидающих описания, либо безнадежно путаная мифология.

Естественной реакцией на провал попыток описать, что означает существование правовой системы в простых понятиях привычного повиновения, которое действительно характерно для отношения рядового гражданина к праву (хотя не всегда исчерпывающе описывает это отношение), будет совершить противоположную ошибку. Она состоит в том, чтобы принять то, что характерно для официальной деятельности (хотя опять же не исчерпывает ее), особенно для отношения судей к праву, и истолковывать это как адекватное описание того, что должно существовать в социальной группе, имеющей правовую систему. Это равнозначно замене простого представления о том, что большая часть общества по привычке повинуется закону, представлением о том, что они должны, в общем и целом, разделять, принимать или рассматривать как обязывающее окончательное правило признания, устанавливающее критерии, по которым в конечном итоге оценивается юридическая действительность законов. Конечно, мы можем представить (как это было сделано в третьей главе) простое общество, в котором знание и понимание источников права широко распространено. Там «конституция» настолько проста, что не будет выдумкой приписать знание и принятие ее рядовому гражданину, так же как и официальным лицам и юристам. В простом мире Рекса I мы вполне могли бы сказать, что имеет место нечто большее, чем просто привычное повиновение большинства населения его слову. Там вполне могло бы быть так, что и большинство населения, и официальные лица «принимают» одним и тем же явным, сознательным образом правило признания, определяющее слово Рекса в качестве критерия действительного права для всего общества, хотя подданным и официальным лицам пришлось бы играть разные роли и вступать в различные взаимоотношения с нормами права, идентифицируемыми с помощью этого критерия. Настаивать на том, что это состояние дел, вообразимое в простом обществе, всегда или обычно существует в сложном современном государстве, означало бы настаивать на фикции. Несо-

мненно, здесь ситуация такова, что значительная часть рядовых граждан — возможно, большинство — не имеет общего представления о правовой структуре или ее критериях юридической действительности. Закон, которому он повинуется, есть нечто, известное ему только как «закон». Он может повиноваться ему в силу разных причин, и среди них часто, хотя и не всегда, будет осознание того, что так поступать будет для него лучше всего. Он знает об общих вероятных последствиях неповиновения: что есть официальные лица, которые могут арестовать его, и другие официальные лица, которые будут судить его и отправят в тюрьму за нарушение закона. Пока законам, юридически действительным в соответствии с критериями действительности системы, повинуется большинство населения, это, конечно, и есть тот признак, который нам необходим для того, чтобы установить, что та или иная правовая система существует.

Но именно потому, что правовая система есть сложный союз первичных и вторичных правил, этот признак не является всем, что необходимо для описания взаимоотношений с правом, связанных с существованием правовой системы. Это должно быть дополнено описанием соответствующих отношений официальных лиц системы ко вторичным правилам, являющимся предметом их внимания в качестве официальных лиц. Здесь чрезвычайно важно то, чтобы было единое или общее официальное принятие правила признания, содержащего критерии юридической действительности системы. Но именно здесь простое понятие общего повиновения, подходящее для того, чтобы охарактеризовать необходимый минимум в случае с рядовыми гражданами, оказывается неадекватным. Дело не в (или не только в) «лингвистическом» аспекте, то есть в том, что слово «повиновение» обычно не употребляется для характеристики того, как суды и другие официальные органы уважают эти вторичные правила в качестве правил. Мы могли бы найти, если бы это было необходимо, какое-то общее выражение вроде «следуют», «подчиняются» или «действуют в соответствии», которое характеризовало бы и то, что делают рядовые граждане по отношению к закону, когда являются на воинскую службу, и что делают судьи, когда определяют в судах тот или иной статут как закон на том основании, что то, что королева постановляет в парламенте, является законом. Но эти всеохватывающие понятия будут просто маскировать существенные различия, которые должны быть осознаны для понимания минимальных условий существования сложного социального феномена, который мы называем правовой системой.

Что делает слово «повиновение» вводящим в заблуждение в качестве описания того, что делают законодатели, действуя в соответствии с правилами, наделяющими их полномочиями, или судьи, применяя принятое

окончательное правило признания? То, что повиновение правилу (или приказу) может *не* требовать со стороны повинующегося никакой мысли о том, что исполняемое им является правильным и для него, и для остальных. Он может не иметь никакого представления о том, что, делая это, он следует стандарту поведения для других членов социальной группы. Ему не обязательно думать о своем подчиняющемся поведении как о «правомерном», «правильном» или «обязательном». Другими словами, его отношение не обязано иметь какой-либо из тех решающих особенностей, которые проявляются тогда, когда социальные правила принимаются и виды поведения рассматриваются как стандарты для всех. Он не обязан (хотя и может) разделять внутреннюю точку зрения, принимая правила как стандарты для всех, к кому они применимы. Вместо этого он может думать о правиле как о чем-то требующем от *него* действия под угрозой наказания. Он может повиноваться ему из страха перед последствиями или по инерции, не думая о себе и других как обязанных так поступать и не будучи склонным критиковать себя или других за отклонения от такого поведения. Но это чисто личное отношение к правилам, которое *может быть* всем тем, что есть у рядового гражданина для повиновения им, не может характеризовать отношение судов к правилам, в рамках которых они действуют в качестве судов. Это особенно наглядно проявляется в случае с окончательным правилом признания, по которому оценивается действительность других правил. Оно, для того чтобы существовать, должно рассматриваться с внутренней точки зрения как общественный, общий стандарт правильности судебных решений, а не как нечто, чему каждый судья всего лишь, со своей стороны, повинуется. Хотя отдельные суды системы иногда могут отклоняться от таких правил, в целом они должны критически относиться к таким отклонениям как прегрешениям против стандартов, которые по своей сути являются общими или общественными. Это не просто вопрос эффективности или здоровья правовой системы, но логически необходимое условие нашей способности говорить о существовании единой правовой системы. Если бы некоторые судьи действовали «только от своего имени» на том основании, что то, что королева постановляет в парламенте, является правом, и никак не критиковали бы тех, кто не уважает это правило признания, характерное единство и преемственность правовой системы исчезло бы. Ибо оно зависит от принятия в этом важнейшем вопросе общих стандартов юридической действительности. В промежутке между этими странностями поведения судей и тем хаосом, который в конце концов последовал бы, когда рядовой человек сталкивался бы с противоположными распоряжениями судов, мы были бы в растерянности относительно описания этой ситуации. Мы присутствовали бы при *lusus naturae* (игре природы. — *Примеч. пер.),* заслуживающей осмысления только пото-

му, что она обостряет наше осознание того, что часто слишком обычно для того, чтобы быть замеченным.

Поэтому есть два минимальных условия, необходимых и достаточных для существования правовой системы. С одной стороны, тем правилам поведения, которые действительны согласно окончательным критериям действительности системы, должны, в общем и целом, повиноваться. И, с другой стороны, ее правила признания, конкретизирующие критерии юридической действительности, должны действительно приниматься официальными лицами в качестве общих публичных стандартов их поведения в официальном качестве. Первое условие — единственное, которому *должны* удовлетворять частные лица: каждый может повиноваться ему «только со своей стороны» и исходя из любого мотива, хотя в здоровом обществе они действительно часто принимают эти правила как общие нормы поведения и признают обязанность повиноваться им или даже выводят эту обязанность из более общей обязанности уважать конституцию. Второму условию должны также удовлетворять официальные лица. Они должны рассматривать эти правила как общие стандарты их поведения в качестве официальных лиц и критически оценивать отклонения от них — свои собственные и со стороны других — как прегрешения. Конечно, верно и то, что помимо них будет иметься множество первичных правил, которые применимы к официальным лицам, только когда они выступают как частные лица, и которым они обязаны только повиноваться.

Утверждение, что правовая система существует, является поэтому двуликим, как Янус, высказыванием, смотрящим и на повиновение рядовых граждан, и на принятие вторичных правил официальными лицами в качестве критических общих стандартов официального поведения. Этот дуализм не должен нас удивлять. Это — всего лишь отражение сложного характера правовой системы в сравнении с простой децентрализованной доправовой формой социальной структуры, состоящей только из первичных правил. В этой простой структуре, так как в ней нет официальных лиц, правила должны широко приниматься как задающие критические стандарты поведения группы. Там, если внутренняя точка зрения широко не распространена, логически не может быть никаких правил. Но там, где есть союз первичных и вторичных правил, который, как мы утверждаем, есть наиболее плодотворное понимание правовой системы, принятие правил в качестве общих стандартов группы может быть отделено от относительно пассивного обычного индивидуального примирения с правилами путем повиновения им только «со своей стороны». В экстремальном случае внутренняя точка зрения с ее характерным нормативным использованием юридического языка («это действительное правило») может быть ограничена официальным миром. В такой

более сложной системе только официальные лица могут принимать и использовать имеющиеся в данной системе критерии юридической действительности. Общество, в котором так происходит, может быть прискорбно напоминающим стадо овец: овцы могут закончить на бойне. Но есть мало оснований думать, что оно не может существовать или отрицать его право называться правовой системой.

3. ПАТОЛОГИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ

Свидетельства о существовании правовой системы должны, следовательно, черпаться из двух различных областей общественной жизни. Нормальным, не вызывающим проблем случаем, когда мы можем с уверенностью сказать, что правовая система существует, является как раз тот, когда ясно, что две эти области совпадают в своем отношении к праву. Грубо говоря, когда факты таковы, что правилам, признаваемым действительными на официальном уровне, в общем и целом повинуются. Иногда, однако, официальная сфера может оказаться оторванной от частной в том смысле, что более не существует общего повиновения правилам, действительным согласно критериям действительности, используемым в судах. Многообразие путей, какими это может случиться, принадлежит к патологии правовых систем, ибо они представляют разрыв в сложной согласованной практике, на которую мы ссылаемся, когда делаем внешнее фактическое утверждение, что правовая система существует. Здесь имеет место частичная неудача того, что предполагается, когда внутри конкретной правовой системы мы делаем внутренние утверждения о праве. Такой разрыв может быть результатом различных нарушающих порядок факторов. «Революция», когда соперничающие притязания на власть выдвигаются внутри группы, есть только один из случаев и, хотя это всегда включает нарушение некоторых законов существующей системы, но может влечь за собой только юридически несанкционированную смену группы официальных лиц, а не новую конституцию или правовую систему. Вражеская оккупация, когда соперничающие притязания на власть приходят извне, является другим случаем, и простой крах упорядоченного правового контроля перед лицом анархии или бандитизма без политических претензий на власть — еще одним.

В каждом из этих случаев могут быть промежуточные стадии, когда суды функционируют на территории страны или в ссылке и все еще используют критерии юридической действительности старой, некогда твердо установившейся системы; но их решения не действуют на этой территории. Стадия, на которой является правильным сказать, что данная правовая система окончательно прекратила существование, есть

вещь, не подлежащая точному определению [55]. Ясно, что если имеется существенный шанс реставрации или если нарушение в деятельности установившейся системы есть инцидент в ходе войны, исход которой все еще неясен, никакое безоговорочное утверждение, что она более не существует, не может быть обоснованным. Это верно потому, что утверждение, что правовая система существует, является достаточно широким и общим и допускает прерывания; оно не верифицируется или фальсифицируется тем, что происходит за короткие промежутки времени.

Конечно, после того как такие прерывания сменятся восстановлением нормальных отношений между судами и населением, могут возникнуть трудные вопросы. Правительство возвращается из эмиграции после изгнания оккупантов или разгрома мятежников, и тогда возникают вопросы о том, что было или не было «правом» на данной территории в предшествующий этому период. Самое важное здесь — понимать, что этот вопрос может быть *не* вопросом факта. Если бы он был вопросом факта, его пришлось бы решать, спрашивая, был ли перерыв настолько продолжительным и полным, что ситуацию можно описать как прекращение существования прежней системы и создание новой, аналогичной прежней, по возвращении властей из эмиграции. Вместо этого вопрос может быть поставлен как вопрос международного права или, несколько парадоксально, как вопрос о праве в рамках самой системы права, существующей с момента реставрации. В последнем случае вполне может быть, что реставрированная система содержит ретроспективный закон, объявляющий ее постоянно действовавшим правом на данной территории (или, более откровенно, «считающимся» постоянно действовавшим). Это может быть сделано, даже если перерыв был настолько длительным, чтобы сделать такую декларацию очень отличающейся от тех выводов, к которым можно было бы прийти, если бы это рассматривалось как вопрос факта. В таком случае нет причин, по которым эта декларация не может быть правилом реставрированной системы, определяющим право, которое ее суды должны применять к событиям и сделкам, происходившим во время перерыва в функционировании системы.

Парадокс здесь будет иметь место, только если мы будем думать о формулировках закона в какой-либо правовой системе, касающихся того, что должно считаться периодами ее прошлого, настоящего или будущего существования, как о соперниках фактических утверждений о ее существовании, делаемых с внешней точки зрения. За исключением явной трудности с самореференцией, правовой статус положения в существующей системе, относительно периода, когда она должна считаться существовавшей, не отличается от закона в одной системе, провозглашающего, что некоторая система по-прежнему существует в другой стране, хотя последнее вряд ли будет иметь много практических последствий. Нам на самом деле совершенно ясно, что правовая система,

ствий. Нам на самом деле совершенно ясно, что правовая система, существующая на территории Советского Союза, фактически не система царского режима. Но если бы статутом Британского парламента было провозглашено, что законодательство царской России по-прежнему является правом на российской территории, это действительно имело бы смысл и юридические последствия как часть британского права, относящаяся к СССР, но не повлияло бы на истину фактического утверждения, содержащегося в предыдущем предложении. Сила и значение этого статута была бы только в том, чтобы определять, какое право должно применяться в английских судах и, таким образом, в Англии, к делам с российской компонентой.

Противоположное только что описанной ситуации можно видеть в захватывающие переходные моменты, когда новая правовая система появляется из утробы старой иногда только после кесарева сечения [56]. Недавняя история Британского Содружества представляет собой восхитительную область для исследования этого аспекта эмбриологии правовых систем. Схематичный, упрощенный очерк этих событий можно представить следующим образом. В начале этого периода имеется колония с местными законодательными, судебными и исполнительными органами. Эта конституционная структура задана статутом, принятым Парламентом Соединенного Королевства, который сохраняет полную юридическую правомочность законодательствовать для колонии; это включает полномочия вносить поправки или отменять местные законы и любой из своих собственных статутов, включая относящиеся к конституционному устройству колонии. На этой стадии правовая система колонии очевидным образом является подчиненной частью большей системы, характеризующейся предельным правилом признания, что то, что королева постановляет в Парламенте, есть право для *{inter alia)* этой колонии. В конце этого периода развития мы находим, что предельное правило признания поменяло свое место, ибо юридическая компетенция Вестминстерского парламента законодательствовать для бывшей колонии более не признается в ее судах. По-прежнему остается верным то, что значительную часть конституционной системы бывшей колонии можно найти в исходном статуте Вестминстерского парламента: но теперь это лишь исторический факт, ибо эта система более не обязана своим современным правовым статусом на данной территории власти этого парламента. Правовая система в бывшей колонии теперь имеет «местные корни» в том отношении, что правило признания, определяющее предельные критерии юридической действительности, более не ссылается на постановления законодательного органа другой территории. Этот новое правило основывается просто на том факте, что оно принимается и используется в качестве такового правила в судебной и иной официальной деятельности местной системы, чьим правилам в

деятельности местной системы, чьим правилам в целом повинуются. Поэтому, хотя состав, способ введения законов в силу и структура местной легислатуры может все еще оставаться такой же, как предписано в первоначальной конституции, постановления этого законодательного органа сейчас действительны не потому, что они есть проявление полномочий, дарованных юридически действительным статутом Вестминстерского парламента. Они действительны потому, что, согласно принятому здесь правилу признания, введение закона в действие местной легислатурой является предельным критерием юридической действительности.

Такое развитие может осуществиться различными способами. «Родительская» легислатура может, после некоторого периода, когда она на самом деле не реализует свои формальные законодательные полномочия в колонии, разве что с согласия последней, окончательно уйти со сцены, отказавшись от законодательной власти над бывшей колонией. Здесь следует отметить, что существуют теоретические сомнения по поводу того, признают ли суды Соединенного Королевства юридическую компетенцию Вестминстерского парламента так необратимо сокращать свои полномочия. С другой стороны, отсоединение может быть достигнуто одним насилием. Но в каждом из этих случаев в конце этих событий мы видим две независимые правовые системы. Это фактическое утверждение, и его не делает менее фактическим то, что оно касается существования правовых систем. Главным свидетельством этого является то, что в бывшей колонии правило признания, ныне принятое и используемое, более не включает в число своих критериев действительности какую-либо отсылку к деятельности легислатур иных территорий [57].

Однако — и здесь история Британского Содружества снова дает интригующие примеры — возможно, что, хотя на самом деле правовая система колонии уже независима от родительской, родительская система может не признавать этот факт [58]. Частью английского права может оставаться то, что Вестминстерский парламент сохранил или может законно возвратить полномочия законодательствовать для колонии; и местные суды в Англии могут, если в каких-то рассматриваемых ими делах будет иметь место конфликт между Вестминстерским статутом и законодательством колониальной легислатуры, придать силу именно такому представлению. В таком случае кажется, что положения английского права находятся в противоречии с фактами. Право колонии *не* признается английскими судами тем, что оно есть на самом деле: независимой правовой системой со своим местным предельным правилом признания. На деле будут существовать две правовые системы, а английское право будет настаивать, что только одна. Но именно потому что одно утверждение есть констатация факта, а другое — положение (английского) права, логически они не противоречат друг другу. Чтобы прояснить это

положение, мы можем, если захотим, сказать, что констатация факта истинна, а положение английского права «корректно в английском праве». Аналогичные разграничения между фактическим утверждением (или отрицанием) того, что две независимые правовые системы существуют, и положениями права о существовании правовой системы надо иметь в виду, рассматривая соотношение между публичным международным правом и внутригосударственным правом. Некоторые очень странные теории обязаны своим единственным элементом правдоподобия пренебрежению этим различием [59].

Чтобы закончить этот грубый обзор патологии и эмбриологии правовых систем, следует отметить и другие формы частичного отсутствия нормальных условий, сочетание которых утверждается в безоговорочном заявлении, что правовая система существует. Единство среди официальных лиц, существование которого обычно предполагается, когда в системе делаются внутренние утверждения о праве, может частично распасться. Может оказаться так, что по некоторым конституционным вопросам (и только по ним) есть разногласия в официальном мире, немедленно ведущие к разногласиям среди судейского корпуса. Начало такого раскола по поводу предельных критериев, которые должны использоваться в идентификации права, было видно в конституционных проблемах Южной Африки в 1954 г., которые встали перед судами в деле «Харрис против Денгеса» \ Здесь легислатура действовала, исходя из иных представлений о своей юридической компетенции и полномочиях, чем суды, и принимала меры, которые суды объявляли незаконными. Ответом на это было создание легислатурой специального апелляционного «суда» для рассмотрения апелляций на основе решений обычных судов, объявлявших недействительными постановления легислатуры. Этот суд своевременно рассматривал такие апелляции и отменял решения обычных судов. В свою очередь обычные суды объявляли создание легислатурой специальных судов недействительным и их решения юридически ничтожными. Если бы этот процесс не был остановлен (потому что правительство нашло неразумным проводить свою линию такими средствами), мы имели бы бесконечные колебания между двумя представлениями о компетенции легислатуры и, таким образом, о критериях юридически действительного права. Нормальные условия официальной, и особенно судебной гармонии, при которой только и можно определить правило признания системы, перестали бы существовать. Но огромный массив юридической деятельности, не затрагивающей эту конституционную проблему, продолжался бы как и ранее. До тех пор, пока не разделилось бы само население и «закон и порядок» не рухнул, было бы ошибочным

[1] [1952] I TLR 1245. См. также примечание 60 в конце книги.

утверждать, что первоначальная правовая система прекратила существование, ибо выражение «та же самая правовая система» слишком широко и гибко, чтобы допускать всеобщий консенсус среди официальных лиц по *всем* исходным критериям юридической действительности в качестве необходимого условия того, чтобы правовая система оставалась «той же». Все, что мы могли бы сделать, это описать ситуацию (как это и было сделано) и пометить ее в качестве нестандартного, ненормального случая, содержащего в себе угрозу того, что правовая система разложится.

Последний случай выводит нас на более широкую тему, которая будет рассматриваться в следующей главе в соотношении как с высокими конституционными вопросами о предельных критериях юридической действительности правовой системы, так и с ее «рядовым» правом. Все правила предусматривают распознавание или классификацию отдельных случаев в качестве проявлений общих понятий, и в ситуации со всем, что мы готовы назвать правилом, можно различить ясные основные случаи, когда оно явно применимо, и иные, когда есть основания и для утверждения, и для отрицания его применимости. Ничто не может устранить этот дуализм «ядра определенности» и «полутени сомнений», когда мы подводим отдельные случаи под общие правила. Это придает всем правилам пограничную зону неясности или «открытой структуры» и может повлиять на правило признания, конкретизирующее предельные критерии, используемые в идентификации права, столь же, как и на тот или иной статут. Этот аспект права часто понимают как якобы демонстрирующий то, что любая попытка прояснить понятие права через правила должна быть вводящей в заблуждение. Попытки настаивать на этом перед лицом реальной ситуации часто клеймятся как «концептуализм» или «формализм», и именно к оценке этого обвинения мы сейчас обратимся.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ФОРМАЛИЗМ И СКЕПТИЦИЗМ ПО ПОВОДУ ПРАВИЛ

1. ОТКРЫТАЯ СТРУКТУРА ПРАВА

В любой большой группе общие правила, образцы и принципы должны быть основным инструментом социального контроля, а не частными указаниями, даваемыми каждому индивиду отдельно. Если бы не было возможным сообщить общие образцы поведения, которые массы индивидов могли бы без дальнейших указаний понять как требующие от них определенного поведения в соответствующих обстоятельствах, не могло бы существовать ничего, что мы признавали бы законом. Следовательно, закон, главным образом, — но ни в коем случае не исключительно, — должен указывать на *классы* лиц и на *классы* действий, вещей и обстоятельств, и его успешное действие в обширных областях социальной жизни зависит от широко распространенной способности признавать частные действия, вещи и обстоятельства как примеры общих классификаций, которые проводит закон.

Два главных механизма, на первый взгляд весьма отличных друг от друга, используются для сообщения таких общих образцов поведения, предпосланных последующим случаям, когда их надлежит применять. Один из них максимально, а другой минимально используют общие классифицирующие слова. Первый представляется тем, что мы называем законодательством, а второй — прецедентом. Мы можем видеть отличающие их черты на следующих простых неправовых примерах. Один отец, перед тем как войти в церковь, говорит своему сыну: «Каждый мужчина и мальчик должен снимать шляпу, входя в церковь». Другой, обнажая голову при входе в церковь, говорит: «Смотри: так надо правильно вести себя в таких случаях».

Сообщение образцов поведения или обучение им посредством примеров могут принимать различные формы, гораздо более изощренные, нежели наш простой случай. Наш случай в большей степени напоминал бы правовое использование прецедента, если бы вместо того чтобы гово-

рить мальчику в отдельной ситуации, чтобы тот обратил внимание на его поведение при входе в церковь как на пример правильного поведения, отец полагал бы, что ребенок относится к нему как к авторитету в области правильного поведения и наблюдает за ним для того, чтобы научиться вести себя. Чтобы еще более приблизиться к правовому использованию прецедента, мы должны предположить, что отец представляется себе и другим тем, кто присоединился к традиционным образцам поведения и не вводит новые.

Сообщение посредством примера, во всех его формах, хотя и сопровождается некоторыми общим вербальным указаниями вроде «Делай, как делаю я», может оставить спектр возможностей, а следовательно, и сомнения относительно того, что имеется в виду, равно как и относительно тех нюансов, которые лицо, пытающееся сообщить образец, само ясно предусмотрело. Насколько точно необходимо имитировать внешнее поведение? Имеет ли значение, что шляпа снимается левой рукой, а не правой? То, что она снимается медленно или быстро? То, что ее кладут под сиденье? То, что ее не надевают снова на голову внутри церкви? Ниже перечислены все варианты общих вопросов, которые ребенок мог бы задать себе: «Каким именно образом должно мое поведение быть похожим на его, чтобы быть правильным?», «Что именно такого есть в его поведении, что должно направлять меня?» В понимании примера мальчик больше внимания уделяет одним его аспектам, а не другим. Делая так, он руководствуется здравым смыслом и знанием общих типов вещей и целей, которые взрослые считают важными, и своей оценкой общего характера ситуации (хождение в церковь) и типа поведения, соответствующего ей [61].

В противоположность этим неопределенностям примеров, сообщение общих образцов посредством эксплицитных общих форм языка («Каждый человек должен снимать шляпу, входя в церковь») кажутся ясными, надежными и определенными. Черты, которые надлежит брать в качестве общих указателей для поведения, определены здесь в словах; они словесно проговорены, не оставлены скрытыми вместе с другими в конкретном примере. Для того чтобы знать, что делать в других случаях, ребенку не приходится больше гадать, что имеется в виду или что будет одобрено; ему не нужно размышлять по поводу того, каким образом его поведение должно быть похоже на пример, чтобы быть правильным. Вместо этого у него есть словесное описание, которое он может использовать, чтобы выяснить, что именно он должен делать в будущем и как он должен делать это. Ему нужно только распознавать случаи, выраженные в ясных словесных терминах, чтобы «подвести» отдельные факты под общие классификационные понятия и сделать простое силлогическое заключение. Он не сталкивается с альтернативой выбора на свой

страх и риск и не должен искать дополнительных авторитетных указаний. Он имеет правило, которое может применять сам к себе.

Многое в юриспруденции в этом столетии состояло в постепенном осознании (а иногда и в преувеличении) важного факта, что различие между неопределенностью сообщения посредством авторитетного примера (прецедента) и определенностью сообщения посредством авторитетного общего языка (законодательство) гораздо менее устойчиво, чем предполагает это наивное противопоставление. Даже когда используются сформулированные словами общие правила, неопределенности, относящиеся к форме требуемого ими поведения, могут вдруг выступить в отдельных конкретных случаях. Частные фактические ситуации не ожидают нас уже выделенные друг относительно друга и помеченные как примеры общего правила, применение которого обсуждается; не могут также и правила сами по себе выступать вперед и предъявлять относящиеся к ним примеры. Во всех сферах опыта, не только среди правил, существует предел, заложенный в природе языка, для тех указаний, которые общий язык может предоставить. Действительно, бывают ясные случаи, постоянно возникающие в сходных контекстах, к которым общие выражения четко применяются («Если что-либо является средством передвижения, то автомобиль им является»), но нередко встречаются и ситуации, когда неясно, применимо оно или нет. (Включает ли в себя использованное здесь понятие «средство передвижения» велосипеды, аэропланы, роликовые коньки?) Последние являются фактическими ситуациями, постоянно провоцируемыми природой или человеческими изобретениями, которые обладают лишь некоторыми из черт, характерных для ясных случаев, остальных же требуемых черт у них нет. Каноны «интерпретации» не могут элиминировать эти неопределенности, хотя и могут уменьшить их, ибо эти каноны сами являются общими правилами по использованию языка и пользуются общими терминами, которые также требуют интерпретации. Они бессильны, так же как и другие правила, обеспечить собственную интерпретацию. Ясный случай, когда кажется, что общее правило не нуждается в интерпретации и когда признание примеров выглядит беспроблемным (или автоматическим), возникает лишь в хорошо знакомых и постоянно происходящих в сходных контекстах ситуациях, когда существует общее согласие в суждении относительно применимости классифицирующих терминов.

Общие термины были бы бесполезны для нас в качестве средства общения, если бы не было таких знакомых, в целом неоспоримых случаев. Но варианты того, что является знакомым, также требуют классификации в общих терминах, которые в любой данный момент составляют часть наших языковых ресурсов. Здесь проявляется нечто вроде кризиса коммуникации: существуют доводы и за и против использования общего

термина, но нет никакой устойчивой договоренности или соглашения, которое определяло бы его использование или, с другой стороны, отказ от них со стороны лица, озабоченного классификацией. Чтобы сомнения в таких случаях были преодолены, всякий, кто хочет разрешить их, должен сделать нечто вроде выбора между явными альтернативами.

В этом смысле авторитетный общий язык, на котором выражается правило, может руководить столь же неопределенно, как и авторитетный пример. Ощущение того, что язык правил позволит нам с легкостью выхватывать легко узнаваемые примеры, теперь исчезает; рассуждение и вывод силлогического заключения не являются более нервом обоснования, содержащегося в определении того, как правильно поступать. Вместо этого язык правил кажется теперь лишь выделяющим авторитетный пример, то есть пример, конституируемый ясным случаем. Это может использоваться во многом также как и прецедент, хотя язык правил ограничит множество аспектов, требующих внимания, с большей регулярностью и более четко, нежели это делает прецедент. Столкнувшись с вопросом, применимо ли правило, запрещающее использование средств передвижения в парке, в некоторой комбинации обстоятельств, когда оно оказывается неопределенным, все, что может сделать человек, которому нужно ответить на этот вопрос, — это рассмотреть (как делает тот, кто использует прецедент), «в достаточной ли мере» похож настоящий случай на ясный случай в «относящихся к делу» своих аспектах. Свобода действий, предоставляемая, таким образом, этому человеку языком, может быть весьма широкой; так что если он применяет правило, то заключение, пусть даже оно и не будет случайным или иррациональным, есть результат выбора. Он по своему выбору добавляет к ряду случаев новый случай из-за сходств, которые могут обоснованно защищаться и как релевантные в правовом смысле, и как достаточно близкие. В случае правовых правил критерии релевантности и близости сходств зависят от многих сложных факторов, пронизывающих правовую систему, и от целей (aims or purposes), достижение которых могут приписывать правилу. Охарактеризовать это — значит охарактеризовать все, что специфично для правового обоснования или свойственно ему.

Какой бы механизм, прецедент или законодательство ни выбрать для сообщения образцов поведения, они, как бы гладко ни работали среди огромной массы обычных случаев, окажутся в некоторый момент, когда их применение будет под вопросом, неопределенными: они будут обладать тем, что терминологически выражается как *открытая структура* (open texture) [62]. Пока что мы представляли это как общее свойство человеческого языка; неопределенность в пограничных случаях — это цена, которую приходится платить, чтобы использовать общие классифицирующие термины в любой форме сообщения, касающегося фак-

тов. Естественные языки, как например английский, при таком использовании с неизбежностью имеют открытую структуру. Важно, однако, обратить внимание на то, почему (помимо этой зависимости от языка — такого, какой он есть в действительности, с его свойствами свободной структуры) нам не следует лелеять надежду на то, что возможна, даже в идеале, концепция правила настолько разработанного, что вопрос о том, применимо оно или нет к конкретному случаю, был бы разрешен заранее и никогда не содержал бы в себе в момент действительного применения свежего выбора между открытыми альтернативами. Если говорить кратко, причина в том, что необходимость данного выбора присуща нам, поскольку мы люди, а не боги. Свойством используемых человеком (в том числе и в законодательных целях) логических категорий является то, что какие бы мы ни находили способы урегулировать, недвусмысленно и заранее, некоторую сферу поведения посредством общих образцов, которые использовались бы без дальнейших официальных указаний в конкретных случаях, — мы не можем избежать двух недостатков. Первый — это наше относительное незнание фактов; второй — наша относительная неопределенность касательно цели. Если бы мир, в котором мы живем, описывался лишь конечным числом свойств и все они, вместе со всеми комбинациями, в которых они могут встречаться, были бы известны нам, тогда можно было бы предусмотреть заранее каждую возможность. Мы бы создали правила, применение которых в отдельных случаях никогда не приводило бы к дальнейшему выбору. Все было бы известно, и в каждом случае, поскольку он был бы известен, можно было бы сделать нечто и специфицировать это заранее с помощью правила. Это был бы мир, пригодный для «механической» юриспруденции [63].

Определенно, этот мир — не наш мир; законодатели — люди и не могут иметь столько знаний обо всех возможных сочетаниях обстоятельств, которые может принести будущее. Эта неспособность предвидеть влечет за собой относительную неопределенность цели. Когда мы достаточно внятно сформулировали некоторое общее правило поведения (например правило о том, что нельзя брать в парк никаких средств передвижения), язык, используемый в этом контексте, фиксирует некоторые условия, которым что-либо должно удовлетворять, чтобы оставаться внутри допускаемой этим правилом сферы, и определенные ясные примеры того, что явно находится в этой сфере, могут ясно быть представлены в уме. Это парадигматические, ясные случаи (машины, автобус, мотоцикл), и наша цель при составлении закона до этих пор остается определенной, поскольку мы сделали определенный выбор. Мы изначально разрешили вопрос о том, что тишину и спокойствие в парке надлежит поддерживать ценой исключения этих вещей во что бы то ни стало. С другой стороны, пока мы не связали нашу общую цель поддержания спокойствия в парке с теми случаями, которые мы не

ния спокойствия в парке с теми случаями, которые мы не рассмотрели или, возможно, не смогли рассмотреть (например игрушечная машина с электрическим двигателем), наша цель в этом аспекте неопределенна. Мы не разрешили, поскольку не предвидели, вопрос, который будет вызван нерассмотренным случаем, когда последний возникнет: следует ли пожертвовать некоторой долей спокойствия в парке ради детей, удовольствие или интерес которых заключается в использовании этих вещей, — или спокойствие должно быть защищено от них. Когда непредусмотренные случаи возникают, мы сталкиваемся с затрагиваемыми проблемами, и решаем вопрос, выбирая между конкурирующими интересами таким образом, который более всего удовлетворяет нас. Поступая таким образом, мы делаем более определенной нашу исходную цель и попутно решаем вопрос о значении общего понятия в отношении к целям данного правила.

Разные правовые системы или одна и та же система в различное время, могут либо игнорировать, либо признавать более или менее явно такую необходимость совершения дальнейшего выбора в приложении общих правил к частным случаям. Порок, известный в правовой теории как формализм или концептуализм, состоит в таком отношении к вербально сформулированным правилам, когда пытаются и скрыть, и минимизировать нужду в этом выборе, как только общее правило было установлено. Один из способов сделать это состоит в замораживании значения правила, так что его общие понятия должны иметь одно и то же значение в каждом случае, когда его применение находится под вопросом. Чтобы обеспечить это, мы можем прицепиться к определенным чертам, присутствующим в ясном случае, и настаивать, что они являются и необходимыми, и достаточными для того, чтобы уложить то, что обладает ими, в рамки правила независимо от того, обладает оно или нет какими-либо другими чертами, и независимо от того, какие социальные последствия вызовет точное применение этого правила. Делать это означает обеспечивать некоторую степень определенности или предсказуемости ценой слепого заранее вынесенного суждения по поводу того, что надлежит сделать в совокупности будущих случаев, о содержании которых мы не имеем представления. Таким образом, нам удастся разрешить заранее, но также вслепую, вопросы, которые могут быть разумно решены, лишь когда они возникают и идентифицируются. Этот метод принудит нас включить в рамки правила случаи, которые мы желали бы исключить для того, чтобы способствовать достижению разумных социальных целей, и которые свободно структурированные понятия нашего языка позволили бы нам исключить, если бы мы их менее строго определили. Ригидность наших классификаций вступит, таким образом, в конфликт с нашими целями, ради которых мы имеем или поддерживаем это правило.

Вершина этого процесса — это «рай понятий» для юристов; это достигается, когда общему понятию придается постоянное значение не только при каждом применении правила, но и всякий раз, когда он возникает в любом правиле правовой системы. Тогда не требуется и не прилагается никаких усилий для того, чтобы интерпретировать понятие в свете различных вопросов в различных возникающих случаях.

Фактически все системы разными способами достигают компромисса между двумя социальными целями: необходимостью в некоторых правилах, которыми индивиды могут руководствоваться во многих сферах жизни, не нуждаясь каждый раз в указаниях официальных лиц или в анализе общественной ситуации и необходимостью оставить для решения информированными официальными лицами проблемы, которые могут быть должным образом оценены и разрешены лишь тогда, когда они возникнут в том или ином конкретном случае. В некоторых правовых системах в какое-то время может быть так, что слишком многое приносится в жертву определенности и что судебная интерпретация статутов или прецедентов слишком формальна и, таким образом, не способна реагировать на сходства и различия между случаями, которые заметны лишь тогда, когда рассматриваются в свете социальных целей. В других системах или в другое время может быть заметным, что слишком многое трактуется судами как постоянно открытое и пересматриваемое по прецедентам и слишком мало уважения отдается таким ограничениям, которые язык законодательства, несмотря на открытость его структуры, все же ставит. В связи с этим правовая теория имеет любопытную историю, ибо она склонна то игнорировать, то преувеличивать неопределенности юридических правил. Чтобы избежать этого колебания между крайностями, необходимо напомнить себе, что неспособность человека предсказывать будущее, которая содержится в корне этой неопределенности, проявляется в разных областях поведения в различной степени и что правовые системы восполняют эту неспособность соответствующим разнообразием методов [64].

Иногда сфера, подлежащая правовому контролю, с самого начала признается такой, что особенности индивидуальных случаев, встречающихся в ней, будут настолько варьироваться в социально важных, но непредсказуемых отношениях, что однородные правила, которые применялись бы от случая к случаю без дальнейших официальных указаний, не могут быть эффективно законодательно сформулированы заранее [65]. Соответственно, чтобы регулировать такие сферы, легислатура устанавливает очень общие образцы и затем передает административному, вырабатывающему правила органу, знакомому с различными типами случаев, задание оформить правила, адаптированные к особым нуждам. Так законодатель может требовать от индустрии поддерживать опреде-

ленные стандарты: назначать только *справедливую цену* или обеспечивать *безопасные системы* работы. Вместо того чтобы предоставить различным предприятиям право применять эти неопределенные образцы самостоятельно, с риском того, что *ex post facto* обнаружится их нарушение, может быть решено, что лучше отложить применение санкций за нарушения до тех пор, пока административный орган с помощью регулирования не определит, что для данной отрасли следует считать «справедливой ценой» или «безопасной системой». Такие полномочия по выработке правил могут применяться только после того, как проведено нечто вроде судебного расследования фактов, касающихся данной отрасли, и выслушаны аргументы за и против данной формы регулирования.

Конечно, даже при очень общих образцах будут существовать ясные неоспоримые примеры того, что удовлетворяет или не удовлетворяет им. Некоторые крайние случаи того, что является или не является «справедливой ценой» или «безопасной системой», всегда будут идентифицируемы *ab initio*. Таким образом, на одном конце бесконечно разнообразного спектра случаев будет цена настолько высокая, что это заставит людей платить как бы огромный выкуп за жизненно важные услуги, принося при этом предпринимателям (entrepreneurs) громадные прибыли; с другого стороны будет цена настолько низкая, что исчезнут побудительные мотивы продолжать работу предприятия. И то и другое разными способами губит любую возможную цель, которую мы могли бы преследовать, регулируя цены. Но это только крайние точки в спектре различных факторов и вряд ли встретятся на практике; между ними появляются реальные сложные случаи, требующие внимания. Предсказуемых комбинаций релевантных факторов несколько, и это вносит относительную неопределенность в нашу исходную цель — справедливую цену или безопасную систему — и обусловливает необходимость дальнейшего официального выбора. В этих случаях ясно, что принимающий правила властный орган правила должен проявлять усмотрение, и нет никакой возможности трактовать вопрос, вызываемый различными случаями, так, как если бы можно было обнаружить единственно корректный ответ, отличный от разумного компромисса между многими конфликтующими интересами.

Второй, сходный, метод используется там, где подлежащая контролю сфера такова, что невозможно определить класс специфических действий, которые единообразно должны быть выполнены или от которых следует воздержаться, и сделать их объектом простого правила, но спектр обстоятельств, хоть и очень разнообразных, покрывает знакомые черты общего опыта. Здесь правом может использоваться общераспространенное мнение о том, что является «разумным». Этот метод предоставляет индивидам самим взвешивать и находить баланс между социальными требованиями, которые возникают в различных непредвидимых формах,

что может подлежать корректировке со стороны суда. В этом случае от них требуется сообразоваться с могущим изменяться стандартом *до того,* как он официально определен, и они могут узнать от суда лишь *ex post facto,* уже когда они нарушили его, соответствие какому стандарту, в категориях специфических действий или воздержания от таковых, требовалось от них. Там, где решения суда по таким делам воспринимаются как прецеденты, их (судов) спецификация меняющихся стандартов очень похожа на исполнение делегированной власти по принятию правил административным органом, хотя присутствуют также и очевидные различия.

Наиболее знаменитым примером этого метода в англо-американском праве является использование образца должной осторожности в случаях халатности [66]. Гражданские и, реже, уголовные санкции могут применяться к тем, кто не был в разумной степени осторожен во избежание причинения физического ущерба другим. Но что есть разумная или должная осторожность в конкретной ситуации? Мы можем, конечно, привести типичные примеры должной осторожности: например останавливаться, оглядываться по сторонам и прислушиваться там, где предполагается дорожное движение. Но всем нам хорошо известно, что ситуации, в которых требуется осторожность, чрезвычайно разнообразны и что, бывает, требуются многие другие действия, кроме или вместо того, чтобы «остановиться, оглядеться и прислушаться»; действительно, этого может быть недостаточно, и эти действия могут оказаться бесполезными, если взгляд по сторонам не поможет отвратить опасность. Наша цель в применении образцов разумной осторожности — обеспечить, что (1) будут предприняты меры предосторожности, которые отвратят причинение существенного ущерба, а также (2) что меры предосторожности таковы, что бремя, возлагаемое должной предосторожности не требует слишком сильно жертвовать другими заслуживающими уважения интересами. Ничем серьезным мы не жертвуем, останавливаясь, оглядываясь и прислушиваясь, если, конечно, не транспортируем находящегося при смерти, истекающего кровью человека в больницу. По причине необъятного разнообразия возможных случаев, в которых требуется осторожность, мы не можем *ab initio* предвидеть, какие совокупности обстоятельств возникнут, а также предвидеть, какие интересы и в какой степени необходимо будет принести в жертву, если нужно будет принять меры предосторожности. Следовательно, выходит так, что мы не можем точно рассмотреть до того, как возникнут частные случаи, какую жертву мы должны принести или на какой компромисс между интересами или ценностями пойти для того, чтобы уменьшить риск ущерба. И снова наша цель защитить людей от ущерба не определена до тех пор, пока мы не свяжем ее с возможностями и не испытаем ее на их фоне, что даст только

опыт; когда это произойдет, мы столкнемся с решением, которое, будучи принятым, сделает нашу цель *pro tanto* определенной.

Рассмотрение этих двух методов позволяет четко выделить характеристики тех широких областей поведения, которые успешно контролируются *ah initio* правилом, требующим конкретных действий, с очень небольшой открытой структурой, в отличие от могущего меняться стандарта [67]. Они характеризуются тем фактом, что некоторые различимые действия, события или положения дел настолько важны для нас с практической точки зрения как вещи, которые следует отвращать или осуществлять, что лишь очень немногие сопутствующие обстоятельства заставляют воспринимать их по-разному. Наиболее грубый пример этого — убийство человека. Мы способны создать правило против убийства вместо того, чтобы установить переменный стандарт («должное уважение к человеческой жизни»), хотя обстоятельства, в которых люди убивают других, очень различны; мы способны создать такое правило, поскольку очень немногие факторы кажутся нам перевешивающими или заставляющими нас пересмотреть оценку важности защиты жизни. Почти всегда убийство как таковое *доминирует* над другими факторами, которыми сопровождается, так что когда мы заранее запрещаем его как «убийство», мы не слепо предосуждаем ситуации, которые еще требуется сравнивать друг с другом. Конечно, существуют исключения и обстоятельства, которые перевешивают этот обычно доминирующий фактор. Есть убийство в целях самозащиты и другие формы оправданных убийств человека. Но их мало, и они устанавливаются в относительно простых категориях; они допускаются как исключения из общего правила.

Важно заметить, что доминирующий статус некоторого легко идентифицируемого действия, события или положения дел может быть в некотором смысле конвенциональным или искусственным, а не обусловленным его «естественной» или «истинной» важностью для нас как человеческих существ. Совершенно неважно, по какой стороне дороги предписывает дорожное правило двигаться и какие формальности (в разумных пределах) необходимо при этом соблюдать; однако в сильнейшей степени важно, чтобы была легко идентифицируемая и единообразная процедура, которая ясно устанавливает, что правильно, а что неправильно в этой ситуации. Когда она была установлена законом, важность следовать ей очень велика, за некоторыми исключениями; ибо лишь немногие сопутствующие обстоятельства могли бы ее перевесить, и те обстоятельства, что обладают такой способностью, легко можно установить как исключения и приспособить к правилу. Английский закон о недвижимости очень ясно иллюстрирует этот аспект правил.

Сообщение общих правил посредством авторитетного примера привносит (с ним), как мы видели, неопределенности более сложного

типа. Признание прецедента в качестве критерия юридической действительности означает разные вещи в разных системах и в одной системе в разное время [68]. Описания, присутствующие в английской «теории» прецедента, в определенных пунктах все еще весьма спорны: действительно, даже ключевые термины, используемые в теории, такие, как *ratio decedenti,* «вещественные факты», «интерпретация», имеют свою собственную полутень неопределенности. Мы не будем предлагать какого-либо нового общего описания, а просто попытаемся кратко охарактеризовать, как мы сделали в случае статута, сферу открытой структуры и творческой судебной деятельности внутри нее.

Любое честное описание использования прецедента в английском праве должно учитывать следующие пары противоположных фактов. *Во-первых,* не существует единого метода определения правила, для которого данный авторитетный прецедент является авторитетом. Несмотря на это в подавляющем большинстве рассмотренных случаев вызываемое этим сомнение очень мало. Краткое изложение основных вопросов по данному делу (head-note) обычно в достаточной степени корректно. *Во-вторых,* не существует авторитетной или единственно корректной формулировки какого-либо правила, извлекаемого из конкретных случаев. С другой стороны, очень часто, когда обсуждается отношение прецедента к более позднему случаю, существует общее согласие в том, что данная формулировка адекватна. *В-третьих,* какой бы авторитетный статус ни имело правило, извлеченное из прецедента, оно совместимо с исполнением судами, связанными им, следующих двух типов творческой или законодательной деятельности. С одной стороны, суды, впоследствии разбирающие сходный случай, могут достигнуть решения, противоречащего решению, вынесенному в прецеденте, сужая извлеченное из прецедента правило и допуская некоторое исключение из него, ранее не рассмотренное или, если рассмотренное, то оставленное нерешенным. Этот процесс «различения» более раннего случая включает поиск некоторого релевантного в правовом отношении отличия между ним и рассматриваемым случаем, а класс таких отличий никогда не может быть полностью определен. С другой стороны, следуя более раннему прецеденту, суды могут отбросить ограничение, найденное в правиле как сформулированное исходя из раннего случая, на том основании, что оно не требуется никаким правилом, установленным посредством статута или раннего прецедента. Делать так означает расширять правило. Несмотря на эти две формы законодательной активности, открытой в рамках связывающей силы прецедента, итогом развития английской системы прецедента стало продуцирование, в результате ее использования, корпуса правил (как первостепенной, так и второстепенной значимости), огромное количество которых являются определенными в такой же степени, как и

правила, установленные статутом. Теперь они могут быть изменены лишь посредством статута, как суды сами часто заявляют в случаях, когда видно, что «достоинства» («merits») вступают в противоречие с требованиями установленных прецедентов.

Открытость структуры права указывает на то, что существуют области поведения, в которых многое должно быть предоставлено на рассмотрение судов или должностных лиц, устанавливающих (с учетом конкретных обстоятельств) баланс между конкурирующими интересами, вес которых может варьироваться от случая к случаю. Тем не менее жизнь права в весьма значительной степени состоит в управлении и должностными, и частными лицами посредством определенных правил, которые, в отличие от применения переменных стандартов, в действительности *не* требуют от них нового решения в каждом новом случае. Этот яркий факт общественной жизни остается истинным, даже если в конкретном случае могут вмешаться неопределенности в отношении применимости какого-либо правила (писаного ли, сообщенного ли прецедентом). Здесь, на границе применимости правил, и в областях, которые теория прецедента оставляет открытыми, суды выполняют функцию продуцирования правил, которую административные органы выполняют самостоятельно, вырабатывая меняющиеся стандарты. В системе, где *stare decisis* твердо установлено, эта функция судов очень похожа на исполнение делегированных полномочий по выработке правил административным органом. В Англии этот факт часто затемняется внешними формами: суды часто отрекаются от любой такой креативной функции и настаивают на том, что настоящая задача толкования статутов и применения прецедентов заключается, соответственно, в том, чтобы выявить «намерение законодателя» и уже существующий закон.

2. РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ СКЕПТИЦИЗМА ПО ПОВОДУ ПРАВИЛ

Мы отвели некоторое время обсуждению открытой структуры права, поскольку важно видеть эту особенность в правильном ракурсе. Если не обращать должного внимания на это обстоятельство, то оно всегда будет приводить к преувеличениям, которые скроют другие особенности права. В любой правовой системе большая и важная область остается открытой для проявления усмотрения судами и другими должностными лицами в приведении исходно неясных стандартов в состояние определенности, в разрешении неопределенностей статутов или в развитии и квалифицировании правил, лишь приблизительно сообщенных авторитетными прецедентами. Тем не менее эти действия, важные, хотя и недоста-

точно изученные, не должны маскировать тот факт, что и те рамки, в которых они имеют место, и их главный конечный продукт относятся к общим правилам. Это правила, которые частные лица могут раз за разом применять к своим действиям, без дальнейшего обращения к официальным указаниям или усмотрению.

Может выглядеть странным, что мнение о том, что правила занимают центральное место в структуре правовой системы, могло бы когда-либо серьезно подвергнуться сомнению. Однако скептицизм по поводу правил (rule-scepticism), или утверждение, что разговор о правилах — это миф, скрывающий истину о том, что право состоит лишь из решений судов и предсказаний этих решений, может своей прямотой быть привлекательным для юристов [69]. Сформулированное без оговорок, в общем виде, так, что оно охватывает первичные и вторичные правила, оно действительно вполне противоречиво, ибо утверждение, что существуют решения судов, не может последовательно быть соединено с отрицанием того, что какие-то правила вообще существуют. Это так потому, что, как мы видели, наличие судов подразумевает существованием вторичных правил, наделяющих юрисдикцией сменяющих со временем друг друга меняющихся индивидов и делающих, таким образом, их решения авторитетными. В сообществе людей, которые поняли идеи решения и предсказания решения, но не поняли идею правила, идея *авторитетного* решения отсутствовала бы, — ас ней вместе и идея суда. Не было бы никаких средств различить решение частного лица и решение суда. С помощью понятия «повиновение по привычке» мы могли бы попытаться восполнить недостаток предсказуемости решения как основания для авторитетной юрисдикции, требуемой в суде. Но если мы сделаем это, мы увидим, что понятие привычки — в этом случае — страдает от всех неадекватностей, которые высветились, когда в четвертой главе мы рассмотрели его как замену правила, наделяющего законодательными полномочиями.

В некоторых более умеренных версиях этой теории может допускаться, что, если должны существовать суды, то должны быть юридические правила, которые конституируют их, а сами эти правила, следовательно, не могут быть просто предсказаниями решений судов. Однако в действительности одной только этой уступкой можно добиться лишь небольшого прогресса. Ибо для таких теорий характерным является утверждение, что до тех пор пока они не приняты судами, статуты являются не законами, а лишь источниками закона, а это несовместимо с утверждением, что единственными правилами, которые существуют, являются те, которые требуются для того, чтобы конституировать суды. Должны также существовать вторичные правила, дающие законодательную власть сменяющих друг друга лицам. Ибо теория на самом деле не отри-

цает, что существуют статуты; действительно, она указывает их просто как «источники» права и отрицает лишь то, что статуты являются законом до того как они приняты судами.

Хотя эти возражения и важны и уместны, когда выдвигаются против небрежной (incautious) формы этой теории, однако они не применимы к ней во всех ее формах. Вполне может быть, что скептицизм по поводу правил никогда не задумывался как отрицание существования вторичных правил, наделяющих судебной или законодательной властью, и никогда не сводился к утверждению, будто можно показать, что эти правила являются не чем иным, как решениями или предсказаниями решений. Определенно, примеры, из которых этот тип теории наиболее часто исходил, собраны из правил, налагающих обязанности на частных лиц или наделяющих их правами или полномочиями. Но даже если мы предположим, что отрицание того, что существуют правила и утверждение, что так называемые правила суть просто предсказания решений судов, должны быть ограничены таким образом, — все равно эта теория окажется явно ложной, по крайней мере в одном смысле. Ибо не приходится сомневаться, что, как бы то ни было, в отношении некоторых областей поведения в современном государстве индивиды в действительности проявляют весь тот спектр поведения и отношений, что мы назвали внутренней точкой зрения. Законы функционируют в их жизни не просто как привычки или базис для предсказания решений судов или действий других должностных лиц, а как принятые правовые образцы поведения. А именно они не только выполняют достаточно регулярно то, что требует от них закон, но смотрят на закон как на правовой образец поведения, ссылаются на него, критикуя других или обосновывая свои требования и допуская критику или требования, исходящие от других. При использовании правовых правил таким нормативным способом они, без сомнения, полагают, что суды и должностные лица будут продолжать принимать решения и вести себя определенным регулярным и, следовательно, предсказуемым образом в соответствии с правилами системы; однако вполне наблюдаемым фактом социальной жизни является то, что индивиды в действительности не рассматривают себя с внешней точки зрения, записывая и предсказывая судебные решения или возможные случаи санкций. Вместо этого они непрерывно выражают в нормативных категориях их общее принятие закона в качестве руководства к действию. В третьей главе мы подробно рассмотрели утверждение, что под нормативными терминами, такими как «обязанность», подразумевается не что иное, как предсказание поведения официальны. Если, как мы доказывали, это утверждение ложно, то юридические правила функционируют как таковые в общественной жизни; они *используются* как правила, а не как описания обычаев и предсказаний. Вне сомнения, они являются

правилами с открытой структурой, и в тех местах, где их структура открыта, индивиды могут лишь предсказывать, как суды решат, и соответственно как приспосабливать свое поведение.

Скептицизм требует от нас серьезного внимания, но лишь как теория функционирования правил в судебных решениях. В этой форме, допуская пока все возражения, на которые мы обратили внимание, она сводится к положению, что, покуда речь идет о судах, нет никакой возможности ограничить область открытой структуры права; так что неверно, если не бессмысленно, относиться к судам так, словно они сами подвластны правилам или «обязаны» разрешать вопросы так, как они их разрешают. Они могут действовать с достаточно предсказуемой регулярностью и единообразностью, чтобы другие смогли, по прошествии большого периода времени, жить, руководствуясь решениями суда как правилами. Судьи могут даже испытывать чувство принуждения, когда они выносят те решения, которые выносят, и это чувство также может быть предсказуемо; однако за этим не стоит ничего, что можно было бы охарактеризовать как правило, которое они видят. Нет ничего, что суды трактовали бы как образцы корректного судебного поведения, и, таким образом, ничего в их поведении, в чем проявлялась бы внутренняя точка зрения, характеризующаяся тем, что приняты какие-то правила.

Теория в этой форме ищет подкрепления в самых различных соображениях самой разной значимости. Скептик по поводу правил является порой разочарованным абсолютистом: он обнаружил, что правила — это совсем не то, чем они были бы в раю формалистов или в мире, где люди подобны богам и могут предсказывать все возможные сочетания фактов, так что открытая структура не была бы необходимым аспектом правил [70]. Концепция скептика о том, что означает для правила существовать, может, таким образом, быть недосягаемым идеалом, и когда он понимает, что его невозможно достичь посредством того, что называют правилами, он выражает свое разочарование, отрицая, что существуют или могут существовать какие-либо правила. Таким образом, тот факт, что правила, которые, по утверждению судей, ограничивают их в вынесении решений, имеют открытую структуру или исключения, которые невозможно заранее полностью специфицировать, и тот факт, что отклонение от правил не повлечет физических санкций по отношению к судьям, — эти факты часто используются для укрепления позиции скептика. На этих фактах делается упор, чтобы показать, что «правила важны постольку, поскольку они помогают предсказать, что сделают судьи. В этом заключается вся их важность за исключением того, что они еще и милые игрушки» [1]

[1] Llewellyn, The Bramble Bush (2nd edn.), p. 9.

Аргументировать таким образом означает не принимать во внимание, какие в действительности правила присутствуют в любой сфере реальной жизни. Это предполагает, что мы сталкиваемся с дилеммой: «Либо правила являются тем, чем они были бы в раю формалистов, и ограничивают, как путы; либо не существует никаких правил, а лишь предсказуемые решения и модели (patterns) поведения». Однако это, конечно, ложная дилемма. Мы обещаем посетить друга на следующий день. Когда приходит день, оказывается, что сдержать обещание означает пренебречь интересами кого-то опасно больного. Тот факт, что это считается адекватной причиной не сдерживать обещание, конечно, не означает, что не существует правила, требующего сдерживать обещания, а только лишь определенная регулярность в том, что их сдерживают. Из этого факта не следует, что такие правила имеют исключения, которые невозможно исчерпывающе установить, и что в любой ситуации нам предоставлена свобода действий и мы никогда не обязаны сдерживать обещания. Правило, которое завершается словами «если не...», — остается правилом.

Иногда существование правил, накладывающих ограничения на суды, отрицается, поскольку вопрос о том, проявляет ли лицо, действуя определенным образом, то, что оно посредством этого принимает какое-то правило, требующее от него действовать таким образом, смешивается с психологическими вопросами, относящимися к мыслительным процессам, через которые лицо прошло до или во время действования. Очень часто, когда человек принимает правило как обязывающее его и как нечто, что он и другие не вольны изменить, он может видеть то, что оно требует в данной ситуации, просто на уровне интуиции и делать это, не думая в первую очередь об этом правиле и о том, что оно требует. Когда мы двигаем шахматную фигуру в соответствии с правилами или останавливаемся на красный свет, наше подчиняющееся правилам поведение является прямой реакцией на ситуацию, не опосредованной подсчетами в категориях правил. Доказательством того, что такие действия являются подлинным применением правил, служит их ход в определенных обстоятельствах. Некоторые из них предшествуют тому или иному действию, другие следуют за ним, и некоторые из них устанавливаемы лишь в общих и гипотетических категориях. Наиболее важными из этих факторов, показывающих, что, действуя, мы приняли правило, является то, что *если* против нашего поведения возражают, мы склонны оправдывать его отсылкой к правилу; и подлинность нашего принятия правила может проявиться не только в прошлом и дальнейшем признании и следовании ему, но и по тому, что мы критикуем себя и других за отклонение от правила. На основании такого или подобного свидетельства мы действительно можем заключить, что если, до нашего «неосознанного» согласия с правилом, нас попросили бы сказать, как поступать правильно и поче-

му, мы, если отвечали бы честно, указали бы на правило. Именно это установление (setting) нашего поведения в таких обстоятельствах, а не сопровождение его явной мыслью о правилах является необходимым для различения действия, являющегося подлинным соблюдением правила, от того, которое просто случайно было совершено в согласии с ним. Таким образом мы отличили бы как согласованный с принятым правилом ход взрослого шахматиста от действия ребенка, который просто толкнул фигуру на правильное место.

Это не говорит о том, что притворство или «очковтирательство» («window dressing*) не является возможным, а иногда и успешным. Тесты, проверяющие, не просто ли притворялся человек *ex post facto,* что он действует по правилам, как и все эмпирические тесты изначально подвержены ошибкам, но они не безнадежно таковы. Возможно, что в данном обществе, судьи всегда могут сначала достигнуть своего решения интуитивно или на основе догадки («by hunches»), а затем просто выбрать из списка юридических правил одно, которое, как они делают вид, похоже на разбираемый случай; затем они могут заявить, что это оно было тем правилом, исходя из которого они вынесли решение, если даже ничего более в их действиях или словах не предполагает, что они относились к этому правилу как ограничивающему их. Некоторые судебные решения могут быть такими, но в действительности очевидно, что по большей части решения, как ходы шахматиста, достигаются либо в результате подлинного стремления соответствовать правилам, сознательно взятым в качестве руководящих образцов принятия решений, либо, если они достигаются интуитивно, оправдываются правилами, которые судьи до этого были настроены соблюдать и чья релевантность рассматриваемому случаю, в общем, может быть обоснована [71].

Последняя, но наиболее интересная форма скептицизма по поводу правил основывается ни на открытом характере юридических правил, ни на интуитивном характере многих решений, но на том факте, что решение суда имеет уникальную позицию как нечто авторитетное, и, в случае верховных трибуналов, окончательное. Эта форма теории, к которой мы обратимся в следующем разделе, имплицитно содержится в знаменитой фразе епископа Ходли, так часто повторяемой Греем в «Природе и источниках права»: «Если бы и имел кто-нибудь абсолютный авторитет интерпретировать любой писаный или неписаный закон, то это тот, кто является законодателем всех намерений и целей, а не тот, кто первым записал или сказал их».

3. ОКОНЧАТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОШИБОЧНОСТЬ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Верховный трибунал имеет последнее слово, чтобы сказать, что есть закон, и когда он сказал это слово, утверждение, что суд был «не прав», не вызовет никаких последствий внутри системы: в результате не изменятся ничьи права или обязанности. Это решение, конечно, может быть лишено правовой силы законодательством, однако тот самый факт, что обращение к нему необходимо, доказывает, что, в той мере, в какой дело касается права, утверждение, что решение этого суда было неправильно, является пустым. Рассмотрение этих фактов приводит к тому, что выглядит педантичным различать, в случае решений верховного трибунала, между их окончательностью и безошибочностью. Это ведет к другой форме отрицания того, что суды, вынося решения, когда-либо руководствуются правилами: «Право (или конституция) — это то, что суды называют таковыми» [72].

Наиболее интересной и поучительной чертой этой формы теории является то, что она эксплуатирует двусмысленность такого утверждения, как «право (или конституция) — это то, что суды называют таковыми», и то, что теория должна, для того, чтобы быть последовательной, отдавать отчет, как относятся не-официальные утверждения по поводу права к официальным постановлениям суда. Чтобы понять эту двусмысленность, мы отвлечемся и рассмотрим аналогичную ситуацию в случае игры. Во многие конкурентные игры играют без официального счетчика: несмотря на свои конкурирующие интересы, игроки достаточно честно применяют правила для ведения счета в отдельных случаях; они обычно согласны в своих суждениях, и возникает мало неразрешимых споров. И до введения официального счетчика высказывание о счете, делаемое игроком, представляет собой, если он честен, усилие оценить ход игры, обращаясь к частному правилу для ведения счета, принятому в этой игре. Такие высказывания о счете являются внутренними установлениями, применяющими правило для ведения счета, которые хотя и предполагают, что игроки будут в основном держаться правил и возражать против того, чтобы их нарушали, — не являются утверждениями или предсказаниями этих фактов.

Подобно изменениям от режима обычая к зрелой системе права, добавление в игру вторичных правил, обеспечивающих введение счетчика, постановления которого окончательны, привносит в систему новый тип внутренних высказываний, ибо, в отличие от высказываний игрока, относящихся к счету, определениям счетчика вторичными правилами дан статус, который делает их неоспоримыми. В *этом* смысле истинным является то, что в целях игры «счет — это то, что счетчик назвал таковым».

Однако важно видеть, что *правило* для ведения счета остается тем, чем оно было до этого, и обязанностью счетчика является применять его как можно лучше. «Счет — это то, что счетчик назвал таковым» было бы ложным высказыванием, если бы оно означало, что нет никакого правила для ведения счета, за исключением того, которое выбрал в предоставленной ему свободе действий счетчик. Действительно, могла бы существовать игра с таким правилом, и можно было бы получить некоторое удовольствие, играя в нее, если бы произвол счетчика отличался какой-нибудь регулярностью, но это была бы другая игра. Мы могли бы назвать такую игру игрой «по произволу счетчика».

Ясно, что приносимые счетчиком преимущества быстрого и окончательного завершения споров даются не даром. Учреждение счетчика может привести игроков в неприятное положение: желание, чтобы игра регулировалась, как прежде, правилом для ведения счета, и желание иметь окончательное авторитетное решение в отношении его применения, окажись оно сомнительным, могут оказаться конфликтующими между собой. Счетчик может искренне ошибаться, быть пьяным или беспричинно нарушать свою обязанность, состоящую в том, чтобы как можно лучше применять правило для ведения счета. Он может по любой из этих причин записать «пробежка», когда отбивающий мяч даже и не двигался. Можно предусмотреть корректировку его вердиктов, апелляцией к более высокому авторитету, но это должно когда-нибудь закончиться вынесением окончательного, авторитетного суждения, которое будет произведено склонным к ошибкам человеческим существом и, таким образом, будет сопровождаться тем же риском искренней ошибки, злоупотребления или нарушения. Невозможно предоставить правило для коррекции пробелов каждого правила.

Риск, заложенный в учреждении авторитета, осуществляющего окончательные авторитетные применения правил, может материализоваться в любой сфере. Тот, что материализуется в скромной сфере игры, стоит того, чтобы его рассмотрели, поскольку в особенно ясном виде показывает, что некоторые из выводов, делаемых скептиками по поводу правил, игнорируют определенные различения, которые необходимы для понимания этой формы авторитета, где бы она ни использовалась. Когда официальный счетчик установлен, и его определения счета делаются окончательными, высказывания о счете, делаемые игроками или другими не-официальными лицами, не обладают никаким статусом внутри этой игры: они иррелевантны ее результату. Если оказалось, что они совпали с установлением счетчика, — хорошо и замечательно; если же противоречат ему, то ими должно пренебречь при подсчете результата. Но эти весьма очевидные факты были бы искажены, если высказывания игроков классифицировались бы как предсказания постановлений счетчика, и

было бы абсурдным объяснять пренебрежение этими высказываниями, когда они противоречат постановлениям счетчика, говоря, что они являются предсказаниями этих постановлений, оказавшимися ошибочными. Игрок, высказываясь о счете после того как был введен официальный счетчик делает то, что он делал и до этого: а именно, оценивает ход игры, как только может, обращаясь к правилу ведения счета. Это же делает и сам счетчик в той мере, в какой он ответственно исполняет свою обязанность. Разница между ними состоит не в том, что один из них предсказывает то, что скажет другой, а в том, что высказывания игроков являются неофициальными применениями правила для ведения счета и, следовательно, не играют роли в подсчете результата, в то время как установления счетчика авторитетны и окончательны. Важно видеть, что если бы игра велась «по произволу счетчика», тогда отношение между неофициальными и официальными высказываниями было бы с необходимостью другим: высказывания игроков не только *были бы* предсказаниями постановлений счетчика, но и не *могли бы* быть ничем иным. Ибо в этом случае положение «счет — это то, что счетчик назвал таковым» само по себе было бы *правилом* для ведения счета; не было бы никакой возможности для того, чтобы установления игроков были просто неофициальными версиями того, что официально делает счетчик. Тогда постановления счетчика были бы и окончательными, и безошибочными, или, точнее, вопрос о том, ошибочны они или безошибочны, был бы бессмысленным, ибо для счетчика не было бы ничего, что он мог бы исполнять «правильно» или «неправильно». Но в обычной игре положение «счет — это то, что счетчик назвал таковым» не есть правило для ведения счета: это правило, придающее авторитетность и окончательность применению счетчиком правила для ведения счета в конкретных случаях.

Второй урок, который следует извлечь из этого примера авторитетного решения, затрагивает более фундаментальные вещи. Мы можем отличить нормальную игру от игры «по произволу счетчика» просто потому, что правило для ведения счета, хотя и имеет подобно другим правилам, свою сферу открытой структуры, где счетчик должен совершать выбор, — однако оно имеет ядро установленного значения (core of settled-meaning). Это то, от чего счетчик не волен отклоняться, и то что, в той мере, в какой оно действует, конституирует образец корректного и некорректного ведения счета — и для игрока, делающего неофициальные высказывания, относящиеся к счету, и для счетчика, в его официальных постановлениях. Это то, что делает истинным высказывание, что постановления счетчика хоть и окончательны, но небезошибочны. То же самое верно и для права.

В определенном смысле тот факт, что некоторые постановления, делаемые счетчиком, явно неправильны, не является несовместимым с тем,

что игра может продолжаться: они значимы в той же степени, что и очевидно корректные постановления; но есть предел, после которого терпимость к неправильным решениям будет несовместима с продолжением той же игры, и это имеет важную аналогию в области права. Тот факт, что терпятся изолированные или исключительные официальные аберрации, не означает, что игра в крикет или бейсбол не продолжается. С другой стороны, если эти аберрации часты, или если счетчик отвергает правило для ведения счета, должен наступить момент, когда игроки либо более не принимают неадекватных постановлений счетчика, либо, если они принимают их, изменяется игра. Это больше не крикет или бейсбол — а «произвол счетчика», ибо определяющей чертой этих других игр является то, что, в общем, их результат должен достигаться путем, которого требует ясный смысл правила, какой бы простор ни давала его открытая счетчику. В некоторых воображаемых условиях нам следовало бы сказать, что игра, которая идет, есть игра «по произволу счетчика», но тот факт, что во всех играх постановления счетчика окончательны, не означает, что все игры таковы.

Эти различия следует иметь в виду, когда мы оцениваем ту форму скептицизма по поводу правил, которая основывается на уникальном статусе судебных решений как окончательных, авторитетных установлений того, чем является закон в частном случае. Открытая структура закона предоставляет судам законотворческую власть, гораздо более широкую и важную, чем та, что предоставляется счетчикам, чьи решения не используются как законотворческие прецеденты. Что бы суды ни решили — ив случаях, когда дело относится к той части правила, которая кажется ясной для всех, и в случаях, когда оно относится к спорной пограничной области, — решение остается в силе, покуда оно не будет изменено в законодательством; и по поводу интерпретации последнего, суды снова будут иметь право произнести все то же авторитетное последнее слово. Тем не менее все еще остается различие между конституцией, которая, после учреждения системы судов, обеспечивает, что законом будет то, что верховный суд считает таковым, — и реальной Конституцией Соединенных Штатов (или, в этом смысле, конституцией любого современного государства). «Конституция (или закон) — это то, что судьи называют таковым» — это высказывание, если понимать его как отрицающее указанное различие, ложно. В любой данный момент судьи, даже относящиеся к верховному суду, являются частью системы, правила которой достаточно определенны в ее центральной части, для того чтобы обеспечить образцы корректных судебных решений. Они воспринимаются судами как нечто, чего они не вольны не принимать во внимание при исполнении своей авторитетной функции, вынося те решения, которые не могут быть оспорены внутри системы. Любой отдельно взятый судья,

вступая в свою должность, как и счетчик, вступая в свою, обнаруживает правило, такое как правило, что указы королевы в парламенте являются законом, — установленное как традиция и принятое в качестве образца поведения в рамках занимаемой должности. Оно ограничивает людей, занимающих эту должность, в их творческой активности. Такие стандарты, конечно, не могли бы продолжать существовать, если бы большинство судей одновременно не придерживались их, ибо их существование в любой данный период времени состоит просто в принятии и использовании их как образцов корректного суждения. Но в действительности это не делает тех судей, которые используют их, авторами этих стандартов, или, на языке Ходли, «законодателями», способными выносить решения по собственному усмотрению. Для поддержания стандартов требуется приверженность судьи, однако судья не производит их.

Конечно, возможно, что за щитом правил, которые делают судебные решения окончательными и авторитетными, судьи могут объединиться, отказываясь от существующих правил, и прекратить воспринимать даже наиболее ясный парламентский акт как накладывающий какие-либо ограничения на их решения. Если бы большинство их решений носили такой характер и были бы приняты, это привело бы к трансформации системы, схожей с превращением игры из крокета в игру «по произволу счетчика». Однако имеющаяся возможность такой трансформации не показывает, что система сейчас такова, какой она стала бы, если бы трансформация имела место. Невозможно заранее гарантировать, что то или иное правило будет принято или отвергнуто, ибо для человеческого существа никогда не является психологически или физически невозможным нарушить или отвергнуть его; и если совершать это в течение достаточно долгого времени, тогда правило прекратит свое существование. Но существование правил в любой данный период времени не требует, чтобы имели место эти невозможные гарантии против его разрушения. Сказать, что в данное время существует правило, требующее от судей принимать в качестве закона акты парламента или акты Конгресса, с необходимостью подразумевает, во-первых, что существует общее согласие с этим требованием и что судьи отклоняются от него или отвергают его лишь в редких случаях; во-вторых, что когда — или если — такое происходит, это трактуется или трактовалось бы подавляющим большинством как предмет серьезной критики и как неправильное, даже если результату последовательного решения в частном случае невозможно — из-за правила, касающегося окончательности решений, — противодействовать иначе как законодательным образом, чем признается его валидность, хотя также и некорректность. Логически возможно, что человеческие существа могут нарушать все свои обещания: сначала с ощущением того, что так поступать нехорошо, а затем без подобного ощущения. Тогда

правило, которое предписывает сдерживать обещания, прекратит свое существование; это, однако, было бы слабой предпосылкой для того взгляда, что никакого такого правила в действительности не существует и что обещания в реальности ни к чему не обязывают. Схожий аргумент в случае судей, базирующийся на возможности их организованного разрушения существующей системы, не является более сильным.

Прежде чем мы оставим тему скептицизма по поводу правил, мы должны сказать последнее слово о его позитивном утверждении, что правила являются предсказаниями решений судов. Ясно, и это часто отмечалось, что какая бы доля истины ни содержалась в нем, в лучшем случае оно может быть приложимо к высказываниям о праве, делаемых по частными лицами или их советниками. Оно неприложимо к собственно судебным установлениям правового правила. Последние должны быть либо, как требуют некоторые наиболее крайние «реалисты», вербальными прикрытиями проявлений ничем не скованной свободы действий, либо формулировками правил, которые действительно рассматриваются судами с внутренней точки зрения как образцы корректного решения. С другой стороны, предсказания судебных решений занимают безусловно важное место в праве. Когда область открытой структуры достигается, мы очень часто можем резонно предположить, что ответом на вопрос: «Что есть закон в этом случае?» — является осторожное предсказание того, что сделают суды. Более того, даже когда всем ясно, чего требуют правила, высказывание об этом часто может быть сделано в форме предсказания судебного решения. Однако важно отметить, что в последнем случае в основном (а в первом — в различной степени) базисом таких предсказаний является знание того, что суды воспринимают юридические правила не как предсказания, а как образцы, которым надлежит следовать в решениях, достаточно определенные, несмотря на открытость их структуры, для того, чтобы ограничить, хотя и не исключить, их свободу действий. Следовательно, во многих случаях предсказания того, что сделают суды, похожи на предсказания, которые можно сделать о том, что шахматист двинет слона по диагонали: они основываются в конечном счете на понимании не предсказательного аспекта правил и на внутренней точке зрения на правила как образцы, принятые теми, к кому относятся предсказания. Это лишь дальнейший аспект того факта, уже подчеркнутого в пятой главе, что хотя существование правил в любой социальной группе делает предсказания возможными и часто надежными, оно не может отождествляться с ними.

4. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ПРАВИЛЕ ПРИЗНАНИЯ

Формализм и скептицизм относительно правил — Сцилла и Харибда юридической теории; они являются великими преувеличениями, полезными, когда они корректируют друг друга, но истина лежит между ними. Действительно, многое, что не может быть предпринято здесь, необходимо сделать, чтобы охарактеризовать в информативных подробностях этот средний путь и показать различные типы аргументации, используемые судами при исполнении творческой функции, которую предоставляет им открытая структура права в форме статута или прецедента. Но мы уже сказали достаточно в этой главе, что позволяет нам вернуться, с пользой для дела, к важной теме, отложенной в конце шестой главы. Она касалась неопределенности не отдельных правовых правил, а правила признания и, таким образом, высших критериев, используемых судами при идентификации валидных правил права. Различие между неопределенностью частного правила и неопределенностью критерия, используемого в его идентификации как правила системы, не является само по себе ясным во всех случаях. Однако оно наиболее ясно, когда правила выражены в виде статута в форме авторитетного текста. Слова статута и то, что он требует в отдельном случае, могут быть совершенно ясными; однако могут присутствовать сомнения относительно того, имеет ли законодательный орган полномочия законодательствовать таким образом. Иногда для разрешения этих сомнений требуется лишь проинтерпретировать другое правило, которое дает законодательную власть, и валидность его может не быть под сомнением. Так будет, например, в случае, когда действительность указа, сделанного подчиненным властным органом, находится под вопросом, поскольку возникают сомнения относительно смысла исходного (parent) акта парламента, определяющего законодательную власть подчиненного властного органа. Это просто случай неопределенности или открытой структуры частного статута, и он не поднимает никаких фундаментальных вопросов.

Следует отличить от подобных ординарных вопросов такие, которые касаются правовой компетенции самого верховного законодательного органа. Они касаются высших критериев юридической действительности, и они могут возникать даже в правовой системе, подобной нашей собственной, в которой нет писаной конституции, определяющей компетенцию высшей легислатуры. В подавляющем большинстве случаев формула «Что бы ни постановила королева в парламенте — это и есть закон» является адекватным выражением правила, относящегося к правовой компетенции парламента, и эта формула принята как высший критерий для идентификации закона, какими бы открытыми ни были идентифицированные таким образом правила в их периферии. Однако

могут возникнуть сомнения относительно смысла этой формулы и сферы ее действия; мы можем спросить, что имеется в виду под «постановлено парламентом», и когда сомнения возникают, они могут быть разрешены судами. Какой вывод надлежит сделать относительно места судов внутри правовой системы из того факта, что высшее правило правовой системы может, таким образом, быть поставлено под сомнение и что суды могут разрешить это сомнение? Требует ли это определенного ограничения утверждения о том, что фундаментом правовой системы является принятое правило признания, определяющее критерии юридической действительности?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы рассмотрим здесь некоторые аспекты английской доктрины о суверенитете парламента, хотя, конечно, похожие сомнения могут возникнуть в отношении высших критериев правовой валидности в любой системе [73]. Под влиянием доктрины Остина о том, что закон по своей сути есть продукт не связанной правом воли, старейшие конституционные теоретики писали так, как будто логически необходимо, что должна быть законодательная власть, являющаяся сувереном в том смысле, что она свободна в каждый момент своего существования как непрерывно действующего органа не только от правовых ограничений, налагаемых *ab extra,* но также и от своего собственного предшествующего законодательства. То, что парламент является сувереном в этом смысле, сейчас может рассматриваться в качестве установленного факта, и тот принцип, что ранний парламент не может запретить своим «преемникам» отменить свое законодательство, составляет часть высшего правила признания, используемого судами для идентификации валидных правил правовой системы. Однако важно видеть, что нет никакой логической, и еще менее — естественной необходимости, говорящей, что должен быть такой парламент; это лишь одно из положений среди многих других, равно мыслимых, которое мы приняли в качестве критерия юридической Действительности. Среди этих других принципов есть еще один, который столь же, а возможно и более, достоин названия «суверенитет». Это принцип, заключающий, что парламент *не* должен быть неспособен необратимо ограничивать законодательную компетенцию своих преемников, но, наоборот, должен иметь эту широкую самоограничивающую власть. Тогда парламент, по крайней мере, однажды в своей истории, был бы способен использовать даже более широкую сферу законодательной компетенции, нежели позволяет ему принятая установленная доктрина. Требование, что в любой момент своего существования парламент должен быть свободным от правовых ограничений, включая даже те, которое он сам наложил на себя, является, кроме всего прочего, лишь одной из интерпретаций двусмысленной идеи правового всемогущества [74]. Как следствие, она делает выбор между *непрерывным (continuing)* всемогуществом во всех вопросах,

не влияющих на на законодательную компетенцию последующих парламентов, и неограниченным *самоохватывающим (self-embracing)* всемогуществом, исполнением которого можно удовольствоваться лишь однажды. Эти две концепции всемогущества имеют свои параллели в двух концепциях всемогущества Бога: с одной стороны — Бог, который в каждый момент своего существования обладает одним и тем же могуществом и, таким образом, не способный ограничить его, и с другой стороны — Бог, чье могущество включают власть разрушить в будущем свое всемогущество. Какой формой всемогущества — непрерывного или самоохватывающего — обладает наш парламент — это эмпирический вопрос, касающийся формы правила, которое принято как высший критерий при идентификации права. Хотя это вопрос о правиле, лежащем в основании правовой системы, — это еще и вопрос о факте, на который в данный момент времени, по крайней мере в некоторых пунктах, может быть дан совершенно определенный ответ. Таким образом, ясно, что принятое в настоящее время правило является правилом непрерывного суверенитета, так что парламент не может защитить свои статуты от того, чтобы их отменили в будущем.

Однако, как и со всяким другим правилом, тот факт, что правило о парламентском суверенитете определено в этом отношении, не означает, что оно таково во всех отношениях. По поводу него могут возникнуть вопросы, на которые к настоящему времени нет ответа, который был бы явно правильным или неправильным. Эти вопросы могут быть разрешены лишь посредством выбора, сделанного кем-то, авторитетность чьего выбора по этому поводу окончательно установлена. Такие неопределенности в правиле парламентского суверенитета проявляются следующим образом. Настоящим правилом признается, что парламент не может безусловно изъять статутом какой-либо предмет из сферы действия будущего парламентского законодательства; но может быть проведено различие между указом, просто предписывающим, что делать, и указом, который, оставляя пока парламенту свободу законодательствовать по любому вопросу, предписывает «способ и форму» законодательства. Последнее может, например, требовать, чтобы по определенным вопросам ни одно законодательство не имело силы, если оно не принято большинством из двух палат, заседающих вместе, или если оно не утверждено плебисцитом. Оно может «укрепить» такое положение условием, что это положение само по себе может быть отменено только в результате такого же особого процесса. Такое частичное изменение в законодательном процессе вполне может быть совместимо с существующим правилом, что парламент не может беспрекословно ограничить своих преемников, ибо то, что он делает, не столько *ограничивает (bind)* преемников, сколько избавляет их от зависимости *в отношении (quoad)* определенных вопросов и передает их законодательные полномочия по поводу этих вопросов

новому особому органу. Так что можно сказать, что в отношении этих специальных вопросов парламент не «ограничил» или «сковал» парламент или уменьшил его непрерывное всемогущество, — а «переопределил» парламент и то, что необходимо делать, чтобы законодательствовать [75].

Ясно, что если бы этот механизм был валидным, парламент смог бы достичь при его посредстве во многом тех самых результатов, что нынешняя доктрина о том, что он не властен ограничивать в чем-либо своих преемников, как кажется, делает недоступными его власти. Ибо хотя действительно разница между ограничением области, в которой парламент может законодательствовать, и просто изменением способа и формы законодательной деятельности достаточно ясна в некоторых случаях, в действительности эти две категории незаметно переходят друг в друга. Статут, который, зафиксировав размеры минимальной заработной платы для инженеров, обеспечил то, что ни один билль, касающийся платы инженерам, не должен иметь эффекта в качестве закона, если не подтвержден резолюцией Союза инженеров, и продолжал укреплять это положение, — может в действительности обеспечивать все то, что на практике можно было бы сделать с помощью статута, который зафиксировал бы заработную плату «навсегда» и, следовательно, жестко запретил бы полностью свою отмену. Тем не менее, можно привести аргумент, имеющий, как признали бы юристы, некоторую силу, чтобы показать, что хотя последний был бы недействителен при существующем правиле непрерывного парламентского суверенитета, — первый не был бы таковым. Шаги аргумента состоят в последовательности утверждений о том, что может делать парламент, каждое последующее из которых внушало бы все меньшее доверие, чем предыдущее, хотя и имело бы с ним некоторое сходство. Ни одно из них не может быть отвергнуто как неправильное или принято в уверенности, что оно правильно, ибо мы находимся в области открытой структуры наиболее фундаментального правила системы. Здесь в любой момент может возникнуть вопрос, на который не существует одного ответа — лишь ответы.

Таким образом, можно было бы признать, что парламент может необратимо изменить существующий состав парламента, полностью упразднив палату лордов и заходя, тем самым, дальше парламентских актов 1911 г. и 1949 г., которые обходились без согласия этой палаты и которые некоторые авторитеты предпочитают интерпретировать просто как могущую быть отозванной передачу некоторых парламентских полномочий королеве и палате общин [76]. Также может быть признано, что, как утверждает Дайси[1], парламент может полностью себя разрушить актом,

[1] The Law and Constitution (10th edn.), p. 68 n.

объявляющим его полномочия завершенными, и отменяющим законодательство, обеспечивающее избрание будущих парламентов. В этом случае парламент может валидно сопровождать это законодательное самоубийство актом передачи всех своих полномочий другому лицу, скажем, Манчестерской корпорации. Если он может сделать это, не может ли он, юридически действительным образом, сделать нечто меньшее [77]? Не может ли он пресечь свои полномочия законодательствовать по определенным вопросам и передать их новой сложной сущности, включающей в себя и некоторое добавочное лицо? На этом основании не может ли раздел 4 Вестминстерского статута, обеспечивающий согласие доминиона с любым законодательством, касающимся его него, уже в действительности сделать это в отношении полномочий парламента законодательствовать для доминиона? Утверждение о том, что это может быть валидным образом отменено без согласия этого доминиона, не только может быть, как сказал лорд Сэнки, «теорией», которая «не имеет отношения к действительности». Оно может быть плохой теорией — или, по крайней мере, не лучшей, чем противоположная ей. Наконец, если парламент может быть реконструирован такими способами посредством собственного акта, почему он не может реконструировать себя, обеспечивая, чтобы Союз инженеров был необходимым элементом, чье согласие требуется для определенных видов законодательства?

Вполне может оказаться, что некоторые из спорных высказываний, которые конституируют сомнительные, однако не очевидно ошибочные шаги этого аргумента, будут подтверждены или отброшены судом, созванным для решения этого вопроса. Тогда мы будем иметь ответ на вопросы, которые они вызывают, и этот ответ в течение всего времени существования системы будет иметь уникальный авторитетный статус среди ответов, которые только могут быть даны. Суды сделают в этом смысле определенным высшее правило, посредством которого идентифицируется валидный закон. Здесь высказывание «конституция — это то, что судьи называют таковой» *не* означает просто, что частные решения верховных трибуналов не могут быть оспорены. На первый взгляд, зрелище кажется парадоксальным: суды, проявляющие творческие полномочия, устанавливают высшие критерии, посредством которых валидность тех самых законов, который дает им юрисдикцию как судам, сама должна быть проверена. Как может конституция дать кому-то право сказать, что такое конституция? Но парадокс исчезает, если мы вспомним, что, хотя каждое правило может быть сомнительным в некоторых пунктах, необходимым условием существования правовой системы является в действительности то, что не каждое правило подвергается сомнению по всем пунктам. Возможность судов, имеющих авторитетную власть в любое данное время, решать эти ограничивающие вопросы, касающиеся выс-

ших критериев валидности, зависит лишь от того факта, что в это время (когда они имеют авторитетную власть) применение этих критериев к широкой сфере права, включающей правила, которые придают эту власть, не вызывает сомнений, хотя точная сфера их действий и границы вызывают эти сомнения.

Этот ответ, однако, для некоторых может выглядеть слишком быстрым решением вопроса. Может оказаться, что он весьма неадекватно характеризует деятельность судов на грани фундаментальных правил, которые специфицируют критерии юридической действительности; так может быть, поскольку он слишком уподобляет эту деятельность ординарным случаям, где суды исполняют творческий выбор, интерпретируя частный статут, который оказался неопределенным. Ясно, что такие ординарные случаи должны возникать в любой системе, и, таким образом, представляются частью, даже если только подразумеваемой частью, правил, в соответствии с которыми действуют суды, что суды имеют юрисдикцию решать их, выбирая между альтернативами, которые статут оставляет открытыми, даже если они предпочитают представлять этот выбор как открытие. Но, по крайней мере в отсутствие писаной конституции, вопросы, касающиеся фундаментальных критериев валидности, часто, по-видимому, *не* имеют этого предварительно представимого качества, которое позволяет утверждать, что, когда они возникают, суды уже имеют, при существующих правилах, явный авторитет разрешать вопросы такого рода.

Одна форма «формалистской» ошибки может, возможно, заключаться просто в том, что думают, будто каждый шаг, предпринимаемый судом, подпадает под некоторое общее правило, заранее придающее авторитет для того, чтобы предпринять этот шаг, так что творческие полномочия *всегда* являются формой делигированной законодательной власти. На самом деле может быть так, что когда суды разрешают непредвиденные ранее вопросы, касающиеся наиболее фундаментальных конституционных правил, их авторитет решать эти вопросы *становится* признанным уже после того, как те возникли и решение их было дано. То есть, все, что достигает успеха, успешно. Вполне мыслима ситуация, что вопрос, возникший по поводу конституции, может разделить общество слишком кардинально для того, чтобы разрешить его судебным путем. Проблемы в Южной Африке, касающиеся закрепленных статей Южно-Африканского акта 1909 г., одно время трактовались как слишком способные расколоть общество (divisive), чтобы отдать их на откуп судам. Но когда затрагиваются менее фундаментальные социальные проблемы, вполне незаметно может быть «проглочена» весьма значительная часть судебного законотворчества, касающаяся истинных истоков закона. Там, где это происходит, в *ретроспективе* будут часто говорить — и так может

и оказаться, — что всегда существовала «присущая» судам власть делать то, что они сделали. Но, если единственным доказательством этого является успех того, что было сделано, — это может быть благочестивой фикцией.

Манипуляция английских судов правилами, относящимися к ограничивающей силе прецедента, возможно, наиболее правдиво описывается в этом последнем случае как успешная попытка получить полномочия и использовать их. То есть власть приобретает авторитет уже *ex post facto* из успеха. Таким образом, до решения Уголовного Апелляционного суда в *Rex* v. *Taylor*[1] вопрос, имел ли этот суд авторитетное право постановить, что он не связан собственными прецедентами по вопросам, касающимся свободы субъекта, вполне мог оказаться полностью открытым. Но постановление было сделано, и теперь ему следуют как закону. Утверждение, что суд всегда имел присущую ему власть постановлять подобным образом, было бы, конечно, лишь способом представить ситуацию более опрятной, нежели она есть на самом деле. Следовательно, в этих пограничных вопросах мы должны приветствовать скептика по поводу правил в той мере, в какой он не забывает, что его приветствуют, именно на границе, и не ослепляет нас относительно того факта, что то, что делает возможным это удивительное развитие наиболее фундаментальных правил судами, — это, в большой степени, престиж, накопленный судами благодаря их неоспоримо руководимым правилами действиям в широких, центральных сферах права.

[1] [1950] 2 KB 368.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

Как мы обнаружили ранее, для того, чтобы выявить отличительные черты права как средства социального контроля, необходимо ввести некоторые элементы, которые невозможно сконструировать с помощью идей приказ, наказания, повиновения, привычек и всеобщности. Слишком многое из того, чем характеризуется право, искажается при попытке объяснения в этих простых категориях. Таким образом, мы сочли необходимым отличать понятие социального правила от понятия всеобщей привычки и акцентировать внимание на внутреннем аспекте правил, которые при их использовании проявляют себя как руководящие и критические образцы поведения. Далее мы провели среди правил различение между первичными обязывающими правилами и вторичными правилами признания, изменения и суда. Основная идея этой книги заключается в том, что очень многие отличительные функции закона, а также многие идеи, которые составляют каркас правовой мысли, нуждаются для прояснения своего содержания в ссылке на один или оба из этих типов правил, и что их единство (union) справедливо может рассматриваться как «сущность» права, хотя их и не всегда можно обнаружить вместе при всяком корректном использовании слова «право». Оправданием тому, что мы отводим центральное место этому единству первичных и вторичных правил, служит не то, что они при этом будут выполнять роль словаря, а то, что они обладают большой объяснительной силой.

Теперь мы должны обратить внимание на требование, которое в нескончаемой дискуссии по поводу «сущности», или «природы», или «определения» права чаще всего противопоставляется простой императивной теории, которую мы нашли неадекватной. Речь идет об общем утверждении о том, что между правом и моралью есть связь, которая является в некотором смысле «необходимой» и что именно это следует взять в качестве центрального пункта при любой попытке проанализировать или прояснить понятие права. Сторонников этого представления могут и не спорить с нашей критикой простой императивной теории. Они могли бы даже согласиться, что эта критика важна для дальнейших разработок и что в качестве исходного пункта для понимания закона единство пер-

вичных и вторичных правил действительно играет более важную роль, нежели приказы, подкрепленные угрозой наказания. Однако их возражение заключалось бы в том, что этого недостаточно: что даже эти элементы имеют хотя бы второстепенную важность и что до тех пор, пока не будет выявлена «необходимая» связь права с моралью и не будет понята исключительная важность этой связи, туман, столь долго окутывающий понятие права, невозможно будет развеять. С этой точки зрения спорными или сомнительными случаями было бы не только право первобытных обществ или международное право, которые считаются сомнительными ввиду отсутствия соответствующего законодательного органа, а также решений судов с обязательной юрисдикцией и централизованных санкций. Гораздо более спорными с этой точки зрения является то, заслуживают ли названия права те внутригосударственные системы, имеющие в наличии полный комплект *juge, gendarme et legislature,* которые не в состоянии сообразоваться с определенными фундаментальными требованиями справедливости или нравственности. Говоря словами Св. Августина: «Что суть государства без справедливости, как не разросшиеся разбойничьи шайки?» [1]

Положение о том, что между правом и моралью существует необходимая связь, высказывалось посредством различных формулировок, причем не все из них отличаются ясностью. Существует множество возможных интерпретаций ключевых терминов «необходимость» и «мораль», и эти интерпретации не всегда различаются и рассматриваются независимо как сторонниками, так и критиками этой точки зрения. Наиболее ясная — возможно потому, что она наиболее крайняя, — форма выражения этой точки зрения связана с томистской традицией естественного права. Эта формулировка включает в себя двоякое содержание: во-первых, что существуют определенные принципы истинной нравственности или справедливости, познаваемые человеческим разумом без помощи провидения, хотя и имеющие божественное происхождение; во-вторых, что человеческие законы, противоречащие этим принципам, не являются действительным законом. «Lex iniusta поп est lex». В других вариантах этой обобщенной точки зрения имеется отличный взгляд и на статус оснований нравственности, и на последствия конфликта между правом и моралью. Некоторые воспринимают мораль не как набор незыблемых принципов поведения или нечто, открывающееся разуму, а как выражение человеческих взглядов на поведение, которые могут меняться от общества к обществу или от индивида к индивиду. В таких теориях полагается также, что конфликт между законом и даже самыми фундаментальными требованиями нравственности недостаточен для то-

[1] Исповедь, IV.

го, чтобы лишить правило его статуса закона; они интерпретируют «необходимую» связь между законом и нравственностью другим образом. Считается, что для того чтобы существовала правовая система, должно быть широко распространенное, хотя и не обязательно всеобщее, признание моральной обязанности повиноваться закону, пусть даже эта обязанность может быть отменена в отдельных случаях более сильной обязанностью не подчиняться отдельным морально несправедливым законам.

Полное рассмотрение различных вариантов теории, утверждающей необходимую связь между правом и моралью, увело бы нас далеко вглубь философии морали [78]. Однако и с помощью меньших средств можно снабдить любого вдумчивого читателя всем необходимым для того, чтобы у него сформировался разумный взгляд на истинность и важность таких утверждений. Для этой цели более всего необходимо выделить и установить некоторые чрезвычайно запутанные вопросы, которые мы рассмотрим в этой и следующей главах. Первый из этих вопросов касается различения внутри общей сферы нравственности особой идеи справедливости и особых свойств, которые объясняют ее исключительно тесную связь с законом. Второй вопрос связан с характеристиками, которые отличают моральные правила и принципы не только от юридических правил, но и вообще от всех других форм социальных правил или образцов поведения. Эти два вопроса являются темой данной главы; третий — он будет темой следующей главы — касается множества различных смыслов и путей, посредством которых возможно выразить родство между правилами и моралью.

1. ПРИНЦИПЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Когда юристы хвалят или осуждают закон или его администрирование, они чаще всего используют термины «справедливый» и «несправедливый» и очень часто используют их так, как если бы понятия справедливости и нравственности были соразмерны. Действительно, существуют очень веские доводы в пользу того, почему справедливости следует отводить наиболее видное место в критике правовых установлений; однако важно видеть, что справедливость составляет отдельный раздел нравственности и что законы и администрирование законов могут иметь различного типа достоинства или не иметь их. Достаточно лишь немного поразмыслить над некоторыми общепринятыми типами моральных суждений, чтобы показать особый характер справедливости. Часто человека, проявившего большую жестокость по отношению к своему ребенку, осуждают как совершившего нечто *неправильное, плохое* или даже *пороч-*

ное с нравственной точки зрения или как пренебрегшего своей моральной *обязанностью* или долгом по отношению к своему ребенку. Но было бы странно критиковать его поведение как *несправедливое.* Это происходит не потому, что слово «несправедливый» слишком слабо по своей осуждающей силе, а потому, что суть моральной критики в терминах справедливости или несправедливости обычно отличается от других типов моральной критики и обладает особой спецификой, отличающей ее от других типов общей моральной критики, которые подходят в данном конкретном случае и выражаются словами «неправильный», «плохой» или «дурной». «Несправедливый» было бы подходящим определением, если бы человек произвольно выбрал одного из своих детей для более сурового наказания по сравнению с остальными при том, что виноваты они все одинаково, или если бы он наказал ребенка за некоторый проступок, не разобравшись при этом, действительно ли тот виновен. Таким же образом, когда мы переходим от критики индивидуального поведения к критике закона, мы можем выразить удовлетворение законом, который предписывает родителям отправлять своих детей в школу, говоря, что это хороший закон, и выразить наше неудовольствие законом, запрещающим критику правительства, называя этот закон плохим. Такая критика обычно не будет сформулирована в категориях «справедливость» и «несправедливость». «Справедливый» было бы, с одной стороны, подходящим выражением удовлетворения законом, распределяющим бремя налогов в соответствии с богатством, а «несправедливый» было бы подходящим выражением неудовольствия, вызываемого законом, который запрещает цветным людям пользоваться общественным транспортом или парками. То, что оценка в терминах справедливого и несправедливого является более специфической формой моральной критики, нежели оценка в категориях хорошего и плохого, или правильного и неправильного, ясно из того факта, что мы можем разумно заключить, что закон хорош, поскольку он справедлив, или что он плох, потому что несправедлив, — но не можем сделать обратный вывод: что он справедлив, потому что хорош, или несправедлив, потому что он плох.

Отличительные черты справедливости и их связь с правом проявляются, стоит только заметить, что большую часть критики, производимой в терминах «справедливый» и «несправедливый», можно почти равноценно передать с помощью слов «честный» и «нечестный». Честность не соотносится напрямую с нравственностью в целом; ссылки на нее релевантны главным образом в двух ситуациях в общественной жизни. Первая — когда мы касаемся не поведения отдельного индивида, а способа, каким обращаются с *классом* индивидов, когда среди них не удается распределить какое-то бремя или благо. Поэтому, то, что типично является честным или нечестным — это «доля». Другая ситуация — когда был на-

несен какой-то ущерб и требуется возмещение или исправление. Это не единственные контексты, где может производиться оценка в категориях справедливости или честности. Мы не только распределения или компенсации называем справедливыми или честными, но также и судей — справедливыми или несправедливыми; судебное разбирательство может быть честным или нечестным; лицо — справедливо или несправедливо обвиненным. Это производные приложения понятия справедливости, которые можно эксплицировать, как только понято первичное его приложение к вопросам распределения и компенсации.

Общий принцип, неявно содержащийся в этих различных приложениях идеи справедливости, заключается в том, что индивидам дано право занимать по отношению друг к другу определенную позицию — равенства или неравенства. Это то, что нужно учитывать в таких превратностях общественной жизни, когда надо распределить бремя или блага, а также это то, что должно быть восстановлено в случае нарушения. Следовательно, справедливость традиционно понимают как нечто поддерживающее или восстанавливающее *баланс* или *соотношение* и ее главное правило формулируют так: «Трактуй одинаковые случаи одинаково»; хотя здесь нам нужно добавить: «...а разные — по-разному». Итак, когда мы во имя справедливости протестуем против закона, запрещающего цветным людям использовать общественные парки, суть этого протеста заключается в том, что такой закон плох, ибо при распределении общественных благ среди населения он проводит различение среди индивидов, являющихся по всем существенным признакам одинаковыми. И наоборот, если закон одобряется как справедливый, поскольку он лишает некую особую группу привилегий или иммунитета, например в налогообложении, основная мысль заключается в том, что нет существенных различий между привилегированным классом и остальной частью общества, дающих этому классу право на особое отношение. Этих простых примеров вполне достаточно, чтобы показать, что хотя максима «Трактуй одинаковые случаи одинаково, а разные — по-разному» и является центральным элементом идеи справедливости, она несамодостаточна, и, пока ее не дополнить, не может предоставить сколько-нибудь определенного руководства для поведения. Это происходит потому, что в любой группе все человеческие существа, в нее входящие, в одних отношениях будут схожи друг с другом, а в других — различны, и до тех пор, пока не установлено, какие сходства и различия являются существенными, максима «Трактуй одинаковые случаи одинаково» с необходимостью будет оставаться пустой формой. Чтобы наполнить ее содержанием, мы должны знать, когда — для конкретных целей — случаи воспринимаются как одинаковые и какие различия существенны. Не дополнив максиму таким образом, мы не в состоянии будем критиковать законы или другие

социальные установления как несправедливые. Со стороны закона не является несправедливым, если он запрещает убийство человека, трактуя при этом рыжих убийц таким же образом, как и остальных; действительно, несправедливым было бы, если бы он относился к ним по-другому, а также если бы он не относился по-разному к психически больным и к нормальным людям.

Таким образом, в структуре идеи справедливости существует определенная сложность. Можно сказать, что эта идея состоит из двух частей: инварианта, или неизменной характеристики, суммируемой в правиле: «Трактуй одинаковые случаи одинаково», и из плавающего или варьирующегося критерия для определения, когда — для любой данной цели — случаи одинаковые или же различные. В этом отношении справедливость сходна с понятием о том, что есть подлинное, или высокое, или теплое, — которое содержит имплицитную ссылку на образец, меняющийся в зависимости от типа классификации, применяемой к вещи. Высокий ребенок может оказаться того же роста, что и низкий мужчина, теплая зима — с той же температурой, что и холодное лето, а фальшивый алмаз — подлинным антикварнатом. Но справедливость гораздо более сложна, чем указанные понятия, поскольку плавающий стандарт существенных сходств между различными фактами, включенный в понятие справедливости, не только меняется с типом объектов, к которым он прилагается, но часто может быть оспорен даже в применении к однотипным объектам.

В определенных случаях, действительно, сходства и различия между людьми, существенные для критики правовых установлений как справедливых или несправедливых, вполне очевидны. Это преимущественно случаи, когда мы касаемся справедливости и несправедливости не самого *закона,* а его *применения* в частных случаях. Ибо здесь существенные сходства и различия между индивидами, на которые должен обращать внимание служитель закона, определяются самим законом. Сказать, что закон против убийства применяется справедливо, означает сказать, что он беспристрастно применяется к тем, и только тем, кто схож в одном: они сделали то, что этот закон запрещает, и никакие предубеждения или интересы не мешали служителю закона трактовать их как *«равных».* Сообразно с этим такие процедурные стандарты, как *«audi alteram partem»* [1], «пусть никто не будет судьей в своем собственном деле» и т. п., считаются требованиями справедливости, и в Англии и Америке на них часто ссылаются как на принципы Естественной Справедливости (Natural Justice). Ибо они являются гарантами беспристрастности или объективности, призванными следить за тем, чтобы закон применялся ко всем тем, и

[1] «Выслушай обе стороны» ***(лат.).***

только тем, кто схож в одном существенном отношении, на которое указывает сам закон.

Очевидно, что связь между этим аспектом справедливости и самим понятием о том, как поступать по правилам, очень тесная. Действительно, можно сказать, что справедливо применять закон в различных случаях означает просто серьезно относиться к утверждению, что то, что должно применяться в разных случаях, — это одно и то же общее правило, без вмешательства предрассудков, заинтересованности или капризов. Эта тесная связь между справедливостью при исполнении закона и самим понятием правила подтолкнула некоторых знаменитых мыслителей отождествить справедливость с соответствием закону. Однако это, очевидно, ошибочно — если только «праву» не придается некоторый особо широкий смысл, ибо такое понимание справедливости не объясняет того факта, что критика во имя справедливости не ограничивается исполнением закона в отдельных ситуациях, — но часто сам закон подвергается критике как справедливый или несправедливый. Действительно, не будет никакого противоречия, если допустить, что несправедливый закон, закрывающий цветным людям допуск в парки, применялся справедливо, если виновные в нарушении этого закона наказывались в соответствии с ним в результате честного судебного разбирательства.

Когда мы переходим от справедливого или несправедливого применения закона к критике самого закона в этих же категориях справедливости, становится ясно, что сам по себе закон не может определить, какие сходства и различия среди индивидов должны быть приняты им во внимание, если его правила заключаются в том, чтобы трактовать одинаковые случаи одинаково и быть таким образом справедливым. Здесь, соответственно, открывается широкое пространство для сомнений и споров [79]. Фундаментальные различия, в общей моральной и политической перспективе, могут привести к непримиримым различиям и несогласию по поводу того, какие характеристики человеческих существ следует полагать существенными для критики закона как несправедливого. Таким образом, когда в предыдущем примере мы заклеймили закон, закрывающий цветным людям допуск в парки, как несправедливый, мы опирались на то, что по крайней мере в таком распределении общественных благ различия в цвете несущественны. В современном мире превалирует, хоть она и не общепринята, точка зрения, что существенным сходством между людьми, которое должен принимать во внимание закон, является то, что они способны мыслить, чувствовать и контролировать себя. Следовательно, в наиболее цивилизованных странах существует подавляющая степень согласия в том, что и уголовное право (мыслимое как не только ограничивающее свободу, но и обеспечивающее защиту от различных видов ущерба), и гражданское право (мыслимое как предлагаю-

щее возмещение ущерба) были бы несправедливыми, если бы в распределении бремени или благ они проводили различие между лицами, ссылаясь на такие характеристики, как цвет или религиозные убеждения. И если бы вместо этих хорошо известных *foci* людских предрассудков закон проводил различение на основании таких очевидно несущественных черт, как рост, вес или красота, он был бы одновременно и несправедливым, и нелепым. Если бы убийцы, принадлежащие официальной церкви, избегали уголовного наказания, если бы только члены сословия пэров могли преследовать за клевету, если бы нападения на цветных людей наказывались менее сурово, нежели нападения на белых, законы в большинстве современных обществ были бы осуждены как несправедливые на основании того, что prima facie человеческие существа должны рассматриваться на равных, а для этих привилегий и иммунитетов нет никаких существенных оснований.

Действительно, в сознании современного человека столь глубоко заложен принцип, что prima facie человеческие существа имеют право на то, чтобы их рассматривали на равных основаниях, — что практически везде, где закон действительно делает различие по таким характеристикам, как цвет или религиозная принадлежность, по крайней мере сам этот принцип признается хотя бы на словах [80]. Если такая дискриминация подвергается нападкам, законы часто защищаются утверждением, что класс, против которого дискриминация проводится, не имеет или еще не развил в себе определенных существенных человеческих качеств; или может быть заявлено, что, как ни прискорбно, но требования справедливости, взывающие к равному к ним отношению, должны быть пересмотрены для того, чтобы охранить нечто, считающееся чрезвычайно ценным, и что может подвергнуться опасности, если подобную дискриминацию не проводить. Однако несмотря на то что пустословие подобного рода поныне повсеместно распространено вполне можно представить себе нравственность, которая не прибегала бы к этим, часто неискренним, средствам для того, чтобы оправдать дискриминацию и неравенство, но открыто отрицала принцип, что prima facie человеческие существа должны рассматриваться на равных основаниях. Вместо этого могут считать, что человеческие существа естественным образом и неизменно попадают в различные классы таким образом, что одни из них свободны по природе, а другие являются их рабами или, как это формулировал Аристотель, живыми инструментами других [81]. С этой точки зрения, положение о равенстве prima facie среди людей будет бессмысленным. Какие-то элементы этой точки зрения можно найти у Аристотеля и Платона, хотя даже у них содержится более чем намек на то, что любая серьезная защита рабства должна включать в себя демонстрацию того, что те, кто предназначены для рабства, не имеют способностей к

независимому существованию или отличаются от свободных людей в своих способностях реализовывать идеал добродетельной жизни.

Следовательно, ясно, что критерии существенных сходств и различий часто могут меняться вместе с фундаментальными моральными взглядами данного лица или общества. Там, где это так, утверждения о справедливости или несправедливости закона могут быть встречены противоположениями, инспирированными другой моралью. Но иногда рассмотрение той цели, реализацию которой, как считается, призван обеспечить данный закон, может сделать ясными те сходства и различия, которые должен выделять справедливый закон, и тогда они едва ли могут быть оспорены. Если закон направлен на то, чтобы обеспечить пособиями неимущих, тогда требование принципа «Одинаковые факты трактуются одинаково» обязательно включает в себя требование обращать внимание на *нужду* в пособии, испытываемую людьми, испрашивающими его. Подобный критерий нужды в скрытом виде используется, когда бремя налогов структурируется согласно доходам облагаемых индивидов при помощи прогрессивного (graded) подоходного налога. Иногда существенными являются *способности* индивида выполнять специфическую функцию, к которой может быть привязано действие данного закона. Законы, которые отнимают право голоса у детей или душевнобольных или не дают им власти составлять завещания или контракты, считаются справедливыми, поскольку такие лица не способны рационально использовать эти возможности, а взрослые, как предполагается, обладают такими способностями. Такие различения делаются на основании, которое, очевидно, существенно, в то время как разделение в этих случаях между полами или людьми с разным цветом кожи не столь обосновано; хотя, конечно, в защиту дискриминации женщин или цветных людей приводились аргументы, что женщины или цветные не обладают способностями белых мужчин рационально мыслить и выносить решения. Приводить подобные аргументы означает, конечно, допускать, что равные способности выполнять отдельные функции являются критерием справедливости в случае такого закона, но в отсутствие сколь либо очевидных доказательств того, что такими способностями не обладают женщины и цветные люди, снова является лишь примером поддержки данного принципа лишь на словах.

До сих пор мы рассматривали справедливость и несправедливость законов, которые можно было рассматривать как *распределяющие* обязанности или блага среди индивидов [82]. Некоторые из этих благ осязаемы, например пособия бедным или талоны на продовольствие; другие неосязаемы, например защита от телесных повреждений, предоставляемая уголовным правом, или возможности, предоставляемые законами, связанными со способностью составлять завещания или заключать кон-

тракты, или с правом голоса. От распределения в этом широком смысле мы должны отличать *компенсацию* ущерба, причиненного одним лицом другому [83]. Здесь связь между тем, что справедливо, и центральным правилом справедливости «Трактуй одинаковые случаи одинаково, и различающиеся — по-разному», очевидно, менее прямая. Хотя она и не настолько запутанная, чтобы ее нельзя было проследить, и может быть замечена следующим образом. Законы, которые предписывают одному лицу компенсировать другому нанесенный физический или моральный ущерб, могут быть считаться несправедливыми по двум разным причинам. С одной стороны, они могут нечестным образом устанавливать привилегии или иммунитеты. Так было бы, если бы только сословие пэров могло преследовать за клевету, или если бы белый не был ответствен перед цветным за совершенное им нападение или посягательство на последнего. Такие законы напрямую нарушали бы принципы честного распределения прав и обязанностей возместить ущерб. Но такие законы могут также быть несправедливыми и в совершенно другом смысле, ибо, не проводя никаких нечестных различий, они могли бы быть не в состоянии предоставить возмещение определенных видов ущерба, причиненного одним лицом другому, даже в том случае, когда компенсация считалась бы обязательной с моральной точки зрения. В этом случае закон может быть несправедливым, рассматривая всех на одинаковых основаниях.

Недостатком таких законов было бы не неправильное распределение, а отказ всем в равной степени в возмещении ущерба, который, с моральной точки зрения, неправильно причинять другим. Наиболее грубым случаем такого несправедливого отказа в удовлетворении была бы система, в которой никто не мог бы получить компенсацию за беспричинно нанесенные физические увечья (то есть тот, кто причиняет вред, всегда имеет на то основания). Стоит заметить, что *эта* несправедливость остается даже в том случае, когда уголовное право запрещает подобные покушения под страхом наказания. Ясных примеров столь грубого нарушения немного, хотя неспособность английского права предоставить компенсацию за вторжение в частную собственность, нередко используемая в своих целях рекламными агентами, часто критиковалась с этой точки зрения. Неспособность предоставить возмещение там, где, с точки зрения морали, это необходимо, составляет также суть обвинения в несправедливости, выдвигаемого против технических сторон закона о компенсациях, или контракта, допускающего «несправедливое обогащение» за счет другого при помощи действий, считающихся морально предосудительными.

Связь между справедливостью и несправедливостью в возмещении ущерба, с одной стороны, и принципом «Трактуй одинаковые случаи одинаково и разные — по-разному», — с другой лежит в том факте, что

за пределами закона существует убеждение морального характера, что те, кого касается закон, имеют право на взаимное воздержание от определенного рода поведения, наносящего вред. Такая структура взаимных прав и обязанностей, запрещающая по крайней мере тягчайшие виды вреда, составляет основу нравственности любой социальной группы, хотя и не составляет всей ее нравственности в целом. Ее эффект состоит в том, чтобы создать среди индивидов моральное и, в некотором смысле, искусственное равенство для того, чтобы компенсировать природное неравенство [84]. Так что когда моральный кодекс запрещает одному человеку грабить другого или проявлять к нему насилие, даже при том, что его превосходящая сила или коварство позволяет ему сделать это безнаказанно, сильный и коварный ставится на один уровень со слабым и простоватым. И тот и другой с точки зрения морали одинаковы. Следовательно, сильный человек, пренебрегающий нравственностью и пользующийся своим преимуществом в силе, причиняя вред другому, воспринимается как нарушивший это равновесие, или порядок равенства, утвержденный моралью. Справедливость требует, чтобы этот моральный status quo был восстановлен, насколько это возможно, причинившим вред. В простых случаях воровства это просто означает возвращение назад того, что было взято, и компенсация других видов ущерба есть расширение этого первичного понятия. Тот, кто нанес физический вред другому, намеренно или по небрежности, рассматривается как похитивший нечто у своей жертвы; и хотя он не делал этого в буквальном смысле, этот образ не слишком искусственен, ибо он извлек некоторую пользу за счет своей жертвы, даже если польза эта заключалась лишь в удовлетворении желания причинить жертве вред или в нежелании поступиться своим досугом ради того, чтобы принять подобающие меры предосторожности. Таким образом, когда законы предоставляют компенсацию там, где этого требует справедливость, он не явно исходит из принципа «Трактуй одинаковые случаи одинаково...», восстанавливая, после того как произошло нарушение, status quo, при котором и жертва и нарушитель находятся в состоянии равенства и, таким образом, одинаковы. И опять-таки допустимо, что может существовать такой взгляд на мораль, который не ставит в этих случаях индивидов в положение взаимного равенства. Моральный кодекс может запрещать варварам нападать на греков, но разрешать грекам нападать на варваров. В этих случаях может считаться, что варвары морально обязаны возмещать грекам нанесенный ущерб, хотя и не имеют права требовать подобной компенсации для себя. Перед нами морального порядок неравенства при котором жертва и правонарушитель трактуются неодинаково. При таком взгляде, хоть он и отвратителен для нас, закон был бы справедливым только в том случае, если бы он отражал это различие и трактовал различающиеся факты по-разному.

В этом сжатом очерке справедливости мы рассмотрели только несколько из простейших приложений этого понятия, чтобы показать специфическую форму высокого достоинства, приписываемого законам, которые одобряются как справедливые. Справедливость не только отлична от других ценностей, которыми закон может обладать или не обладать, но иногда требования справедливости могут вступать в конфликт с другими ценностями. Это может проявиться, когда суд при осуждении обвиняемого в преступлении, которое стало широко распространенным, приговаривает его к более суровому наказанию, чем это обычно делается в других случаях, и делает это открыто, «как предупреждение». Здесь имеет место жертвование принципом «Одинаковые случаи трактуй одинаково» ради общей безопасности или благосостояния общества. В случае гражданских правонарушений подобный конфликт между правосудием и общим благом разрешается в пользу последнего, когда закон не предоставляет никакого средства предотвратить нарушение морали, поскольку, осуществление компенсации, может заключать в себе большие трудности в доказательстве, или вызвать перегруженность судов, или превратиться в чрезвычайно трудное предприятие. Есть предел тому исполнению закона, которое может позволить любое общество, даже когда произошло нарушение морали. И наоборот, закон, во имя общего блага в обществе, может настаивать на возмещении ущерба одним лицом другому, даже когда с моральной точки зрения, обращаясь к справедливости, может считаться, что этого делать не следует. Об этом часто говорится как о ситуации, когда субъект несет строгую (strict) ответственность за правонарушение, совершено ли оно намеренно или по халатности. Эту форму ответственности защищают иногда на том основании, что в интересах «общества» — возместить ущерб тем, кому случайно был причинен вред, и утверждается, что самый легкий путь сделать это — переложить бремя на тех, чьи действия, сколь тщательно они ни контролировались, приводят к таким несчастным случаям. Последние обычно имеют достаточно средств и возможностей застраховаться. Когда это так защищают, здесь присутствует скрытая апелляция ко всеобщему благосостоянию в обществе, которая хотя и может быть морально приемлема и даже называется иногда *«социальной* справедливостью», — тем не менее отличается от первичных форм справедливости, которые просто связаны с восстановлением, насколько это возможно, status quo между двумя индивидами.

Следует отметить важный момент, связывающий идеи справедливости и общественного блага или благосостояния [85]. Очень немногие социальные изменения или законы приемлемы одинаково всеми индивидами или в равной степени улучшают их благосостояние. Только законы, удовлетворяющие самые элементарные потребности, такие, как защита

со стороны полиции или дорожное сообщение, приближаются к тому, чтобы быть таковыми. В большинстве случаев закон предоставляет благо одной части населения лишь ценой лишения других того, что они предпочитают. Забота о бедных может быть обеспечена лишь за счет других; обязательное для всех школьное образование означает не только ущемление свободы тех, кто хочет обучать детей частным образом, ведь его финансирование можно обеспечить только за счет снижения или даже отказа от государственных инвестиций в индустрию, или пенсий, или бесплатных медицинских служб. Когда выбор между этими конкурирующими альтернативами уже сделан, его можно защищать как правильный на основании того, что он был сделан для «общего блага». Неясно, что означают подобные фразы, поскольку, видимо, нет такой шкалы, с помощью которой можно было бы измерить и четко установить вклад, вносимый каждой из этих альтернатив в общее благо, и выявить наилучшую. Однако ясно, что выбор, совершаемый без предварительного учета интересов всех частей общества, будет подвержен критике просто как предвзятый и несправедливый. Но выбор будет избавлен от *подобного рода* нападок, если требования всех были бы беспристрастно рассмотрены до принятия закона, даже если в результате притязания одной части общества будут предпочтены требованиям других.

Кто-то действительно может заявить, что все, что на самом деле имеется в виду под требованием, чтобы выбор между конкурирующими потребностями различных классов или интересов был сделан «для общего блага», — это чтобы требования всех были беспристрастно рассмотрены, прежде чем будет вынесено решение. Истинно это или нет, по-видимому, ясно, что справедливость в этом смысле является по меньшей мере необходимым условием, которому должен удовлетворять любой законополагающий выбор, имеющий целью быть что для общего блага. Здесь мы имеем дело с дальнейшим аспектом распределительной справедливости, отличающийся от тех простых форм, которые мы уже обсудили. Ибо в этом случае справедливо «распределяется» не какое-то специфическое благо среди группы тех, кто требует его, а беспристрастное внимание и учет конкурирующих требований различных благ.

2. МОРАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Справедливость составляет один сегмент нравственности, в первую очередь связанный не с индивидуальным поведением, а с подходами, в рамках которых трактуются *группы* индивидов. Именно это придает справедливости особую релевантность в критике права и других публичных или социальных институтов. Это наиболее публичная и наиболее право-

вая из добродетелей. Но принципы справедливости не исчерпывают идею нравственности, и не вся критика права, совершаемая на моральных основаниях, делается во имя справедливости. Законы могут осуждаться как плохие с моральной точки зрения лишь потому, что они требуют от человека, чтобы он совершал те или иные действия, которые нравственность запрещает индивидам совершать, или потому, что они требуют, чтобы человек воздерживался от таких действий, к которым мораль его обязывает [86].

Следовательно, необходимо охарактеризовать, в общих понятиях, те принципы, правила и стандарты, связанные с поведением индивидов, которые входят в сферу нравственности и делают поведение морально обязательным. Здесь перед нами возникают две связанные между собой трудности. Во-первых, слово «нравственность» и все другие, ассоциирующиеся с термином «этика» или являющиеся близкими к нему по смыслу, в значительной степени имеют свою область неопределенности или «открытой структуры». Существуют некоторые разновидности принципов или правил, которые некоторые определили бы как моральные, а другие нет. Во-вторых, даже когда существует согласие в этом пункте и определенные правила или принципы безоговорочно признаются принадлежащими сфере нравственности, все же могут иметь место значительные философские разногласия, касающиеся их *статуса* или связи с остальной частью человеческого знания и опыта. Являются ли они неизменными принципами, которые конституируют часть здания Вселенной, не человеком сотворенными, но ожидающими того, чтобы человеческий разум их открыл? Или же они суть выражения изменяющихся человеческих отношений, выборов, требований, чувств? Это грубые формулировки двух крайних точек зрения философии морали. Между ними лежит много сложных и тонких вариантов, которые философы разработали в попытке пролить свет на природу нравственности.

В дальнейшем мы будем стараться избегать этих философских сложностей. Позже, под заголовками «Важность», «Иммунитет к сознательному изменению», «Добровольный характер нарушений морали» и «Форма морального давления», мы определим четыре кардинальных свойства, которые постоянно присутствуют вместе в тех принципах, правилах и образцах поведения, которые являются, по общему мнению, «моральными». Эти четыре черты отражают различные аспекты характерной и важной функции, которые эти стандарты выполняют в общественной жизни или в жизни отдельных людей. Одно лишь это дало бы нам право выделять все, что обладает этими характеристиками, для отдельного рассмотрения, и более того, для противопоставления и сравнения с правом. Сверх того, утверждение о том, что нравственность обладает этими чертами, занимает нейтральную позицию по отношению к

соперничающим философским теориям относительно ее *статуса* и «фундаментального» характера. Очевидно, что большинство философов согласились бы с тем, что эти четыре свойства необходимо должны присутствовать в любом моральном правиле или принципе, хотя они предложили бы весьма различающиеся интерпретации или объяснения того факта, что нравственность обладает ими. Действительно, можно заявить, что эти свойства хотя и являются необходимыми, однако они *лишь* необходимы, но недостаточны для того, чтобы отличить нравственность от определенных правил или принципов поведения, которые мы исключили бы из сферы нравственного при более строгом рассмотрении. Мы будем ссылаться на факты, на которые опираются подобные заявления, но держаться более широкого толкования «морали». Нашим оправданием является здесь и то, что это согласуется с частым употреблением этого слова, и то, что подобное широкое понимание слова «нравственность» выполняет важную, заметную функцию в общественной и частной жизни.

В первую очередь мы рассмотрим социальный феномен, на который часто ссылаются как на «нравственность» *(the* morality) данного общества или как на «принятую» или «конвенциональную» нравственность данной социальной группы [87]. Эти фразы отсылают к образцам поведения, которые широко распространены в конкретном обществе и должны быть противопоставлены моральным принципам или моральным идеалам, которые могут управлять жизнью индивида и которые, однако, последний не разделяет со сколь либо значительным числом тех, с кем он живет. Основной элемент распространенной или принятой в социальной группе нравственности состоит из правил того типа, который мы уже описали в пятой главе, когда касались сюжета о прояснении общей идеи принуждения, и которые мы там назвали первичными правилами обязанности. Эти правила отличаются от других как серьезным общественным давлением, поддерживающим их, так и необходимостью в значительной степени жертвовать индивидуальными интересами или склонностями, что подразумевает поведение, согласное с этими правилам. В той же главе мы также нарисовали картину общества, находящегося на такой стадии развития, когда такие правила являются единственным средством социального контроля. Мы отметили, что на этой стадии может не быть ничего соответствующего четкому различению, проводимому в более развитых обществах между моральными правилами и правилами, устанавливаемыми законом. Возможно, некоторая зачаточная форма такого различения могла бы там присутствовать, если бы существовали некоторые правила, которые поддерживались бы в первую очередь угрозой наказания за их нарушение, и другие, поддерживаемые апелляциями к уважению этих правил, или к чувствам вины и раскаяния. Когда эта ранняя

стадия проходит и делается шаг от доправового мира к правовому, — так, что средства социального контроля включают теперь в себя систему правил, в которую входят правила признания, суда и изменения, — контраст между правовыми и другими правилами приобретает некоторую определенность. Первичные правила обязанности, устанавливаемые официальной системой, отделены теперь от других правил, которые продолжают существовать наряду с официально признанными. В действительности в нашем собственном и во всех других обществах, достигших этой стадии развития, существует множество типов социальных правил и образцов, находящихся вне правовой системы; только некоторые из них считаются и называются моральными, хотя определенные теоретики права использовали слово «моральный» для обозначения всех правил, не входящих в систему права.

Такие неправовые правила можно выявить и классифицировать множеством различных способов. Некоторые из них являются правилами ограниченного действия и касаются только частной области поведения (например одежды) или деятельности, возможной только в определенных обстоятельствах, создаваемых искусственно (церемонии и игры). Некоторые правила мыслятся как применимые к социальной группе в целом; другие — для особых подгрупп внутри нее, отмеченных некоторыми характеристиками в качестве отчетливо выделяющейся подгруппы, либо выделившихся по собственному выбору ради встреч и объединения для конкретных целей. Некоторые правила, как считается, обладают обязывающей силой в результате соглашения и могут допускать добровольную отмену; другие же считаются не имеющими своим истоком соглашение или какую-либо другую форму сознательного выбора. При нарушении некоторых правил может последовать не более чем замечание или напоминание о том, как следует поступать «правильно» (например этикет или правила корректной речи), нарушение других вызовет серьезное порицание или презрение, или более или менее длительное исключение из сообщества, с которым эти правила связаны. Хотя никакой точной шкалы создать невозможно, понимание относительной важности, придаваемой этим различным типам правил, отражается в том, что они требуют в различной степени жертвовать частными интересами, и что для того, чтобы индивиды соответствовали им, на них обществом оказывается различное давление.

Во всех обществах, где развилась правовая система, среди неправовых правил существуют такие, которые являются чрезвычайно важными и которые, несмотря на резкое отличие от закона, имеют с ним и много сходных черт. Очень часто лексикон «права», «обязанности» и «долг», использующийся для того, чтобы выразить требования правовых правил, используется с добавлением понятия «моральный» для выраже-

ния действий или воздержания от таковых, требуемых этими правилами. Во всех обществах налицо частичное пересечение содержания правовых и моральных обязанностей, хотя требования правовых правил более специфичны и окружены более подробными исключениями, чем требования моральных. Характерно, что моральные обязанности и долг, как многие правовые правила, чаще касаются того, что должно быть или не должно быть сделано в обстоятельствах, постоянно воспроизводящихся в жизни группы, нежели редких и перемежающихся действий в сознательно выбранных ситуациях. Такие правила требуют действий — или воздержания от таковых, — которые просты в том смысле, что не требуется особых физических или интеллектуальных способностей, чтобы их выполнить. Моральные обязанности, как большинство правовых обязанностей, лежат в пределах способностей нормального взрослого человека. Согласие с этими моральными правилами, как и с правовыми, принимается как само собой разумеющееся, так что нарушение их вызывает серьезное порицание, а соответствие моральным нормам, как и подчинение закону, не есть повод для похвалы, за исключением тех случаев, которые выделяются из общего ряда особой добросовестностью, выносливостью или способностью противостоять серьезному искушению. Моральные обязанности и разные виды морального долга можно классифицировать различными способами. Некоторые правила и обязанности принадлежат к таким, которые связаны с выполнением относительно четких, длительных функций, которые выполняются не всеми членами общества. Таковым является долг отца или мужа заботиться о своей семье. С другой стороны, существуют и общие моральные обязанности, которые, как считается, налагаются на всех нормальных взрослых людей на всю их жизнь (например воздержание от насилия) и особые обязательства, которые любой такой член общества налагает на себя, вступая в особые отношения с другими (например обязанность сдерживать обещания или отвечать услугой на услугу).

Обязанности и долг, выделяемые в моральных правилах этого наиболее фундаментального типа, могут варьировать от общества к обществу или внутри данного общества в разное время. Некоторые из них могут отражать просто ошибочные или даже основанные на предрассудках убеждения по поводу того, что требуется для здоровья или безопасности группы; в каком-то обществе долгом жены может быть броситься в погребальный костер ее мужа, а в других — самоубийство может считаться преступлением против принятой нравственности. Существует разница между моральными кодексами: одни могут проистекать из частных, однако реальных интересов данного общества, а другие — из предрассудков или невежества. Однако несмотря на это в обществах, достигших такой стадии развития, когда общественная мораль может быть отделена от их

законов, она всегда включает в себя определенные обязанности и долг, требующие жертвовать частными интересами или склонностями, и эти обязанности и долг играют существенную роль в выживании любого общества, пока люди и мир, в котором они живут, сохраняют наиболее знакомые и очевидные свои характеристики. Среди таких правил, очевидно необходимых для общественной жизни, присутствуют такие, которые запрещают или по крайней мере ограничивают свободное применение насилия, правила, требующие определенных форм честности и правдивости в отношениях с другими, и правила, запрещающие разрушать материальные предметы или отнимать их у других. Если соответствие этим наиболее элементарным правилам не воспринималось бы как само собой разумеющееся среди группы живущих в непосредственной близости друг с другом индивидов, то у нас появились бы сомнения насчет того, стоит ли характеризовать эту группу как общество, и было бы ясно, что эта группа не смогла бы сохраняться в течение долгого времени.

Следовательно, нравственность и правовые правила обязанностей и долга имеют некоторые поразительные сходства, которых достаточно для того, чтобы показать, что общность их лексикона не случайна [88]. Эти сходства могут быть подытожены следующим образом. Нравственность и правовые правила сходны в том, что задуманы для того, чтобы очертить границы поведения индивида независимо от его желания, и поддерживаются серьезным общественным давлением, направленным на то, чтобы индивиды соответствовали им; выполнение как моральных, так и правовых обязанностей считается не некоей заслугой, а минимальной данью индивида, отдаваемой общественной жизни, которая воспринимается как сама собой разумеющаяся. Далее, и право и мораль включают в себя правила, управляющие скорее поведением индивидов в ситуациях, постоянно воспроизводящихся в общественной жизни, нежели специфическими действиями или случаями, и хотя и мораль и право могут включать многое из того, что относится к реальным или воображаемым интересам отдельно взятого общества, и то и другое предъявляют требования, которым, очевидно, должна удовлетворять любая группа человеческих существ, согласившихся жить вместе. Следовательно, некоторые формы запрещения насилия по отношению к личности или собственности и некоторые требования честности и правдивости одинаково можно обнаружить и в праве, и в морали. Но несмотря на это для многих стало очевидным, что существуют определенные характеристики, которые не являются общими для права и морали, хотя, как показывает история юриспруденции, эти характеристики чрезвычайно трудно формулируемы.

Наиболее знаменитой попыткой выразить в сжатом виде сущностное различие закона и морали является теория, утверждающая, что в то

время как правовые правила требуют лишь «внешнего» соответствия поведения установленным образцам и не принимают во внимание мотивы, намерения или другие «внутренние» составляющие поведения, мораль, напротив, не требует каких-либо особых внешних проявлений деятельности, а только доброй воли, или должных намерений, или мотивов [89]. Это практически равнозначно неожиданному утверждению, что моральные и правовые правила, понимаемые должным образом, никогда не могли бы иметь что-либо общее в своем содержании; и хотя в этом действительно есть доля правды, будучи сформулировано таким образом, это положение, как представляется, глубоко ошибочно. Это заключение, хотя и ошибочное, на самом деле сделано на основании определенных важных характеристик морали и в частности, на основании определенных различий между моральным порицанием и правовым наказанием. Если кто-то делает нечто запрещаемое моральными правилами или ему не удается сделать нечто предписываемое ими, тот факт, что он сделал это ненамеренно и несмотря на все предпринятые им меры, общество прощает его вину перед *моралью,* тогда как правовая система или обычай могут содержать правила, постулирующие «строгую ответственность» (strict liability), согласно которой те, кто нарушил эти правила ненамеренно и без «вины», могут быть подвержены наказанию. Таким образом, в то время как идея «строгой ответственности» в морали является чем-то вроде противоречия в понятиях, — в правовой системе это нечто, всего лишь открытое для критики. Но это вовсе не означает, что мораль требует лишь благих намерений, мотивов или доброй воли. Действительно, рассуждать таким образом означает, как мы покажем позже, смешивать идею *извинения (excuse) с* идеей *оправдания (justification)* применительно к поведению.

Тем не менее существует нечто важное, что в карикатурном виде отображено в этом нечетком аргументе; смутный смысл того, что различие между законом и моралью связано с противопоставлением «внешнего характера» одного «внутреннему характеру» другого, — тема, слишком часто всплывающая в рассуждениях о законе и морали, чтобы быть совершенно безосновательной. Вместо того чтобы прекратить рассуждать об этом, мы будем толковать ее как сжатую формулировку четырех кардинальных, связанных друг с другом черт, которые вместе служат для того, чтобы отличать нравственность не только от правовых, но и от других форм социальных правил.

(i) *Важность.* Сказать, что существенной чертой *любого* морального правила или образца является то, что оно воспринимается как нечто столь важное, что требует своей поддержки, — может показаться и банальным, и неопределенным. Однако это свойство нельзя выпускать из внимания при любом добросовестном анализе (account) нравственности

любой социальной группы или индивида, — но его невозможно и сформулировать более четко. Оно проявляется различным образом: во-первых, в том простом факте, что нравственные стандарты утверждаются для противодействия буйной игре страстей, которую эти стандарты ограничивают, и ценой принесения в жертву интересов индивида в значительной степени; во-вторых, в серьезных формах социального давления, оказываемого не только для того, чтобы привести индивидуальные случаи к однообразию, но и для того, чтобы обеспечить передачу нравственных стандартов и обучение им как чему-то само собой разумеющемуся во всем обществе; в-третьих, во всеобщем признании того, что если бы нравственные стандарты не были общепринятыми, в жизни индивидов произошли бы далеко идущие и неприятные изменения. В противоположность морали правила хороших манер, одежды, хорошего тона и некоторые, хотя и не все, юридические правила (rules of law) занимают относительно низкое место на шкале, оценивающей серьезное к ним отношение. Может быть утомительным следовать им, но они не требуют великих жертв: не оказывается никакого серьезного давления, чтобы добиться соответствия им, и если их не соблюдать или изменить их, то в других сферах социальной жизни не последует больших изменений. В значительной степени важность, приписываемая поддерживанию моральных правил, очень просто можно объяснить достаточно рационально, так как, хотя они и требуют от личности жертвовать частными интересами, соответствие им обеспечивает жизненные интересы, разделяемые всеми в равной мере. Это происходит либо посредством прямой защиты лица от явного ущерба, либо путем сохранения структуры терпимого, упорядоченного общества. Но хотя рациональность значительной части общественной нравственности, например необходимость защиты от явного ущерба, можно оправдывать таким образом, этот простой утилитарный подход не всегда возможен, и даже когда он возможен, не стоит применять его, чтобы представить точку зрения тех, кто живет нравственно. Ко всему прочему, наиболее явственная часть нравственности любого общества состоит из правил, касающихся сексуального поведения, и далеко не ясно, связана ли придаваемая этим правилам важность с убежденностью в том, что поведение, запрещаемое ими, вредит другим; и не всегда возможно показать, что такие правила оправдываются подобным образом. Даже в современном обществе, которое перестало рассматривать собственную нравственность как предписанную богами, подсчет причиняемого другим людям вреда не объяснит той важности, которая приписывается моральной регуляции сексуального поведения, такой, как обычное вето на гомосексуализм. Сексуальные функции и чувства являются вопросом большой важности и эмоционально касаются всех, так что отклонения от принятых, или нормальных, форм их проявления с

легкостью облекаются в одеяния неотъемлемого от них «стыда» или значимости (an intrinsic "pudor" or importance). К ним питают отвращение не из убеждения в том, что они вредны для общества, а просто потому, что они «неестественны» или отвратительны сами по себе. Однако было бы абсурдным отрицать право называться нравственностью за эмфатическими социальные вето подобного рода; действительно, сексуальная нравственность является, возможно, наиболее явственным аспектом того, что, по мнению обычного человека, должна представлять собой нравственность. Конечно, тот факт, что общество может рассматривать свою нравственность в этом «неутилитарном» ключе, не означает, что его правила неуязвимы для критики или осуждения, когда их поддержание расценивают как бесполезное или осуществляемое ценой больших страданий.

Правила закона, как мы видели, могут соответствовать моральным правилам в смысле требования или запрещения того же самого поведения. Те, что действительно таковы, безусловно воспринимаются как столь же важные, что и соответствующие им моральные правила. Однако важность несущественна для статуса всех правил закона, как это происходит в случае моральных правил. Правило закона может в общем считаться совершенно не стоящим того, чтобы его поддерживать; действительно, все могут соглашаться, что его следует отменить, однако оно остается правовым правилом до тех пор, пока его не отменили. С другой стороны, было бы абсурдным считать правило частью нравственности общества, игнорируя то, что никто уже не считает его важным или стоящим того, чтобы его поддерживать. Старые обычаи и традиции, поддерживаемые в настоящее время лишь в память о прошедших эпохах, могли, конечно, когда-то иметь статус моральных правил, но таковой их статус испарился вместе с важностью, придаваемой их соблюдению и нарушению.

(ii) *Иммунитет к сознательному изменению.* Характеристикой правовой системы является то, что новые правовые правила могут быть введены, а старые изменены или отменены сознательным актом (enactment), даже если некоторые законы защищены от изменений писаной конституцией, ограничивающей компетенцию высшей законодательной власти. И наоборот: моральные правила или принципы *невозможно* вызвать к жизни таким способом (brought into being), или изменить, или элиминировать. Утверждать эту «невозможность» не означает, однако, отрицать, что некоторые мыслимые состояния дел имеют место в действительности, как это было бы в случае утверждения, что люди «не могут» изменить климат. Вместо этого, данное утверждение указывает на следующее. Совершенно нормальный смысл будут иметь заявления вроде «Начиная с 1 января 1960 года более не будет незаконным поступать так-то и так-

то» или «Начиная с 1 января 1960 года поступать так-то и так-то более не будет уголовным преступлением», которые подкрепляются ссылками на соответствующие принятые или отмененные законы. И напротив, такие заявления, как «С завтрашнего дня более не будет аморальным делать то-то и то-то» или «С 1 января этого года стало аморальным делать то-то и то-то» и попытки подкрепить их ссылкой на сознательно принятое постановление (deliberate enactment) были бы удивительными парадоксами, если бы вообще имели смысл. Ибо то, что моральные правила, принципы или образцы следует воспринимать, подобно законам, как вещи, которые можно создавать или изменять сознательно принятыми актами, несовместимо с той ролью, которую нравственность играет в жизни индивидов. Нормам поведения невозможно придать моральный статус — и последний не может быть у них отнят — по человеческому «да будет так» *(fiat),* хотя ежедневное использование таких понятий (concepts), как установление или отмена, показывает, что сказанное неверно по отношению к законам.

Большая часть философии морали посвящена объяснению этого свойства нравственности и прояснению смысла того, что нравственность есть нечто уже имеющее место и то, что распознается («there» to be recognized), а не создается сознательным выбором людей. Но сам этот факт, вне его объяснения, не является отличительной особенностью моральных правил. Именно поэтому это свойство нравственности, хотя оно и чрезвычайно важно, не может служить само по себе в качестве критерия, позволяющего отличить нравственность от других социальных норм. Ибо в этом отношении — хотя и не в других — любая общественная традиция схожа с моралью: традицию также невозможно принять или отменить по человеческому *да будет так! (fiat).* Возможно, апокрифическая история о том, что глава новой английской школы заявил, что с начала следующей четверти школьной традицией станет то, что старшие мальчики должны будут носить определенную одежду, производит комическое впечатление именно потому, что понятие традиции логически несовместимо с понятием сознательного установления или выбора. Правила приобретают или теряют статус традиций в процессе их роста, распространения, отказа от исполнения и разложения; а правила, осуществляемые или отменямые иначе, нежели посредством этого медленного, непроизвольного процесса, не смогли бы приобрести или потерять статус традиции.

Тот факт, что мораль и традиции невозможно изменить, как законы, прямым законодательным актом, нельзя путать с иммунитетом от других форм изменения. Действительно, хотя моральное правило или традицию невозможно изменить или отменить посредством сознательного выбора или указа, введение или отмена законов вполне может выступать в каче-

стве одной из причин изменения или разложения некоторого нравственного стандарта или некоторой традиции. Если традиционную практику, такую, как празднество в «Ночь Гая Фокса», запретить законом и за участие в подобном праздновании наказывать, то эта практика может прекратиться, а традиция исчезнуть. И наоборот, если законы требуют от некоторых групп проходить военную службу, это может в конце концов вырасти в традицию среди них, которая будет существовать вполне независимо от закона. Так правовые акты могут устанавливать образцы чести и гуманности, которые в итоге изменят и возвысят имеющуюся нравственность; и наоборот, правовое подавление практик, считающихся морально необходимыми, может в итоге послужить причиной утраты ощущения их важности и, таким образом, утраты ими своего морального статуса; несмотря на это, очень часто законы проигрывают такие битвы с устоявшейся нравственностью, и моральное правило продолжает действовать в полную силу наряду с законом, который запрещает то, что этим правилом предписывается.

Эти способы изменения традиции и нравственности, где закон может служить причиной изменений, необходимо отличать от законодательного изменения и отмены. Так как, хотя о приобретении или потере *правового* статуса в результате указа можно действительно говорить как о «правовом эффекте» введенного в действие статута, это не есть зависящее от обстоятельств каузальное изменение, каковым является конечное воздействие статута на мораль и традицию. Эту разницу легко можно усмотреть в том факте, что в то время как всегда можно сомневаться в том, приведет ли к изменению морали конкретный ясный, юридически действительный акт, подобные сомнения неуместны при ответе на вопрос, изменяет ли законодательство некий ясный, валидный правовой акт.

Несовместимость идеи нравственности или традиции с идеей сознательно предпринятого изменения также необходимо отличать от иммунитета, даруемого определенным законам в некоторых системах ограничительными статьями конституции. Такой иммунитет не является необходимым элементом статуса закона как такового, поскольку этот иммунитет может быть снят конституционной поправкой. В отличие от такого правового иммунитета к изменениям, совершаемым законодательным путем, невозможность подобным образом воздействовать на мораль или традицию не есть нечто меняющееся от общества к обществу или из эпохи в эпоху. Такая невозможность предполагается самим значением этих терминов; идея нравственного законодательного органа, компетентного производить или изменять нравственность, полностью несовместимо с понятием нравственности. Когда мы приступим к рассмотрению международного права, мы увидим, насколько важно отличать простое отсутствие *de facto* законодательного органа, которое возможно воспринимать

как дефект системы, от фундаментальной непоследовательности, которая, как мы специально подчеркиваем здесь, латентно присутствует в идее о том, что моральные правила или стандарты можно учредить или отменить законодательным образом.

(iii) *Добровольный характер нарушений морали.* Старая концепция того, что мораль связана исключительно с «внутренним», в то время как право касается только «внешнего» поведения, отчасти ложно представляет те два свойства, что мы уже обсудили. Но эту концепцию чаще всего трактуют как указание на определенные важные свойства моральной ответственности и моральной вины. Если человеку, чьи действия, осуждаемые *ab extra,* нарушили моральные правила или принципы, удается доказать, что он сделал это неумышленно и вопреки всем им мерам предосторожности, которые ему было возможно принять, он освобождается от моральной ответственности, и наказать его в этих условиях само по себе считалось бы морально предосудительным. Моральная вина тогда исключается, поскольку он сделал все, что мог сделать. В любой развитой правовой системе в определенной степени имеет место то же самое, ибо основное требование *mens rea* является элементом уголовной ответственности, который разработанное для того, чтобы те, кто совершил преступление не по халатности, несознательно или в условиях, в которых они не могли, физически или психически, следовать закону, были оправданы [90]. Правовая система была бы открыта для серьезного морального осуждения, если бы дело обстояло не так, по крайней мере в случае серьезных преступлений, влекущих суровое наказание.

Тем не менее допущение таких оправданий во всех правовых системах ограничивается различным образом. Реальные или предполагаемые трудности доказательства психологических фактов могут привести к тому, что правовая система откажется расследовать психические состояния или способности отдельных индивидов и вместо этого будет использовать «объективные тесты», где полагается, что индивид, обвиняемый в преступлении, способен к контролю и компетентен принимать меры предосторожности, каковыми качествами должен обладать нормальный или «благоразумный» человек. Некоторые системы могут отказаться рассматривать неспособность к «волевому» действию как отличную от неспособности к «сознательному» поведению; если так, то эти системы ограничивают спектр оправдательных обстоятельств, оставляя таковыми лишь отсутствие намерений или недостаточную информированность. И снова, правовая система может для определенных видов преступлений наложить «строгую ответственность» («strict liability*) и сделать ответственность всецело независимой от *mens rea* за исключением, возможно, минимального требования, чтобы обвиняемый обладал нормальным мускульным контролем.

Поэтому ясно, что правовая ответственность не устраняется с необходимостью при демонстрации того, что обвиняемое лицо не смогло удержаться в рамках закона, который оно нарушило; в морали, напротив, «Я не мог не» всегда является оправданием, и моральная обязанность разительно отличалась бы от того, чем она является, если бы моральное «должен» не подразумевало бы в этом смысле «можешь». Несмотря на это, важно иметь в виду, что «Я не мог не» — это только извинение (хотя и хорошее), и необходимо отличать извинение (excuse) от оправдания (justification), ибо, как мы уже сказали, положение о том, что мораль не требует внешнего поведения, покоится на смешении этих двух понятий [91]. Если бы добрые намерения являлись оправданием для совершения того, что моральные правила запрещают делать, в действии человека, который случайно и несмотря на все предпринятые им меры предосторожности убил другого, не было бы ничего, достойного сожаления. Мы должны были бы смотреть на это, как мы смотрели бы на убийство человека человеком, когда последнее требуется для необходимой самозащиты. Последнее *оправданно,* поскольку в таких обстоятельствах это есть вид поведения, которое система не нацелена предотвращать и может даже поощрять, хотя, конечно, это является исключением из всеобщего запрета на убийство. Когда же с кого-то *снимается вина* на том основании, что он совершил преступление неумышленно, это не основывается на том моральном соображении, что совершенное действие относится к типу действий, которые в интересах закона допускаются или даже приветствуются; моральное соображение состоит в том, что когда мы расследуем психическое состояние отдельного преступника, мы находим, что он не обладал способностью нормального человека соответствовать требованиям закона. Следовательно, этот «внутренний» характер морали вовсе не означает, что мораль не является формой контроля внешнего поведения; это означает лишь, что необходимым условием моральной ответственности является то, что индивид должен владеть определенным типом контроля над своим поведением. Даже в морали существует разница между «Он не совершал этого плохого действия» и «Он не мог не совершить того, что он совершил».

(iv) *Форма морального давления.* Следующая отличительная черта нравственности — характерная форма морального давления, которое оказывается для ее поддержки. Это свойство тесно связано с предыдущим и, как и первое, сыграло немаловажную роль в формировании неопределенного ощущения, что мораль касается «внутреннего». Факты, которые привели к этой интерпретации морали, таковы. Если бы в действительности было так, что всякий раз, как некто находится на грани того, чтобы нарушить правило поведения, *лишь* угроза физического наказания или возникновения неприятных последствий служили бы аргу-

ментом, удерживающим его от этого, — было бы невозможно рассматривать такое правило как часть нравственности общества, хотя это не служило бы препятствием трактовать это правило как закон. Действительно, будет вполне возможным сказать, что типичная форма правового давления состоит в таких угрозах. Однако в морали типичная форма давления состоит в апелляции к уважению, которое должны внушать правила как вещи, важные сами по себе и которые, как предполагается, разделяют все те, кому они адресованы. Таким образом, моральное давление, как правило, хоть и не исключительно, оказывается не угрозами или апелляциями к страху или заинтересованности, а напоминанием о моральном характере обдумываемого действия и требованием соблюдать нравственность: «Это будет ложью», «Это будет нарушением твоих обещаний». На фоне всего этого действительно существуют «внутренние» моральные аналогии страха наказания, ибо считается, что увещевания вызовут в тех, к кому они обращаются, чувство стыда и вины: они могут быть «наказаны» собственной совестью. Конечно, иногда такие отчетливо моральные апелляции сопровождаются угрозой физического наказания или отсылками к обыкновенной индивидуальной заинтересованности; отклонения от морального кодекса встречают различные формы общественной реакции, варьирующиеся от относительно неформального выражения презрения до разрыва социальных отношений и остракизма. Но настойчивые напоминания о том, чего требуют правила, воззвания к совести и вера в то, что чувство вины и угрызения совести подействуют, является характерными и наиболее существенными формами давления, используемого для поддержки общественной нравственности. То, что давление следует поддерживать именно этими способами, есть простое следствие принятия моральных правил и стандартов как вещей, которые чрезвычайно важно и с очевидностью необходимо поддерживать. Стандарты, не поддерживаемые таким образом, не могли бы занимать в общественной и личной жизни то место, которое характерно для нравственных обязанностей.

3. НРАВСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ И СОЦИАЛЬНАЯ КРИТИКА

Моральная обязанность и долг являются краеугольным камнем общественной нравственности, но они не исчерпывают ее содержание. Однако прежде чем мы приступим к исследованию других форм, мы рассмотрим возражение по поводу способа, которым мы охарактеризовали моральную обязанность. Четвероякий критерий, который мы использовали в последнем разделе для того, чтобы отличить ее от других форм социальных стандартов или правил (важность, иммунитет к сознательному из-

менению, добровольный характер нарушений морали и особая форма социального давления), является в каком-то смысле *формальным.* Он не ссылается прямо на какое-либо необходимое содержание, которое должны иметь правила или образцы для того, чтобы быть моральными, а также не связывается с какой-либо целью, которой они должны служить в общественной жизни. Действительно, мы настаиваем на том, что во всех моральных кодексах будут присутствовать некоторые формы запрещения использования насилия по отношения к людям и вещам и требования правдивости, честных отношений и сдерживания обещаний. Можно заметить, что эти вещи, при допущении лишь некоторых весьма очевидных трюизмов насчет человеческой природы и характера физического мира, должны быть существенны, если человеческие существа собираются долгое время жить вместе, в непосредственной близости; и, следовательно, было бы из ряда вон выходящим, если бы правила, обеспечивающие все это, не наделялись везде моральной важностью и статусом. Мы уже говорили об этом выше. Ясно, по-видимому, что жертвование личными интересами, которого такие правила *требуют,* есть цена, которую необходимо заплатить в таком мире, как наш, для того чтобы жить с другими; и защита, которую они *дают (afford),* является тем минимумом, который делает для таких существ, как мы, жизнь с другими стоящей. Как мы обоснуем в следующей главе, эти простые факты устанавливают ядро неоспоримой истины в доктринах естественного права.

Многие моралисты желали бы внести в определение нравственности кажущуюся столь очевидной связь между нравственностью и человеческими нуждами и интересами в качестве еще одного критерия помимо предложенных нами четырех [92]. Они бы настаивали на том, что ничто нельзя относить к нравственности, если оно не может выдержать рациональной критики в категориях человеческих интересов и не покажет, таким образом, что оно служит этим интересам (возможно, даже некоторым честным или равным образом) в обществе, чьими правилами они являются. Некоторые даже могут пойти дальше и отказаться считать моральными любые принципы или правила поведения, если выгода от действий или воздержания от таковых, требуемых ими, не распространяется за пределы отдельного общества на всех тех, кто сам желал и мог бы уважать эти правила. Мы, однако, умышленно предприняли более широкий взгляд на нравственность, чтобы включить в нее все социальные правила и стандарты, которые в действительной общественной практике проявляют отмеченные нами четыре свойства. Некоторые из них выдержат критику в свете этих предложенных дальнейших тестов, другие — нет, и могут быть признаны неразумными, или непросвещенными, или даже варварскими. Мы сделали это не просто потому, что вес слова «мораль-

ный» благоприятствует этому расширенному толкованию, но потому, что если предпринять более узкий, ограниченный взгляд, который исключил бы те правила, которые не удовлетворяют указанным выше дополнительным требованиям, это заставило бы нас разделить совершенно нереалистичным образом элементы в социальной структуре, которые действуют одинаково в жизни тех, кто живет ими. Моральные запреты на поведение, которое не может в действительности навредить другим, не только воспринимаются с тем же инстинктивным почтением, что и те, которые запрещают поведение, приносящее вред; они входят, вместе с требованиями более рационально оправданных правил, в набор критериев, с помощью которых производятся социальные оценки личности, и вместе с ними формируют часть общепринятой картины жизни, которую, как это ожидается и предполагается, ведут индивиды.

Однако истиной, причем важной, является то, что нравственность включает в себя гораздо больше, чем *обязательства* и *обязанности* которые признаются в реальной практике социальной группы. Обязанность и долг являются лишь краеугольным камнем нравственности, даже социальной нравственности, и существуют формы нравственности, которые распространяются за пределы общепринятой морали отдельных обществ. Два следующих аспекта нравственности требуют здесь внимания. Первый: даже внутри нравственности отдельного общества наряду со структурой обязательных моральных обязанностей и долга, и относительно ясных правил, которые определяют их, существуют моральные *идеалы.* Их реализация воспринимается уже не как само собой разумеющееся, как в случае долга, а как свершение, заслуживающее похвалы. Герой и святой — экстремальные типы тех, кто делает *больше,* нежели требует их долг. То, что они выполняют, не похоже на исполнение обязательства или обязанности, на что-то, что можно требовать от них, и неудача в выполнении не воспринимается как нечто плохое или как повод для критики. На более низкой ступени, нежели герой или святой, находятся те члены общества, которые заслуживают похвалы за моральные добродетели, которые они утверждают в повседневной жизни, такие, как храбрость, милосердие щедрость, терпение или целомудрие. Связь между такими признанными обществом идеалами и добродетелями и первичными обязательными формами социальных обязанностей и долга вполне ясна. Многие моральные добродетели являются качествами, состоящими в способности и предрасположенности идти дальше того, что требует долг, заботясь об интересах других людей, или жертвовать личными интересами, как того требует долг. Щедрость и милосердие суть примеры этого. Другие нравственные добродетели, такие, как умеренность, терпение, смелость или совестливость, являются в некотором смысле вспомогательными: это качества характера, проявляемые в исключительной

приверженности долгу или в следовании содержательным нравственным идеалам перед лицом особого искушения или опасности.

Дальнейшие пределы нравственности ведут нас различными путями за пределы обязанностей и идеалов, признаваемых в отдельных социальных группах, к принципам и идеалам, использующимся в моральной критике самого общества; но даже здесь остаются важные связи с изначальными общественными формами нравственности. Когда мы приступаем к исследованию нравственности, принятой в нашем или каком-то другом обществе, всегда возможно, что мы найдем многое, что подлежит критике: в свете наличествующих знаний мораль может оказаться без нужды репрессивной, жестокой, суеверной или непросвещенной. Она может попирать человеческую свободу, особенно в вопросе обсуждения или исповедания религии или экспериментирования с различными образами жизни, даже когда тем самым обеспечиваются ничтожные блага для других. Кроме всего прочего, данная общественная мораль может распространять свою защиту только на членов данного общества или даже на определенные классы, отдавая рабов или крепостных на милость их хозяев. В этом типе критики, которая (даже если она будет отвергнута) определенно будет восприниматься как «моральная» критика, имплицитно содержится предположение, что установления общества, включая принятую в нем мораль, удовлетворяют двум формальным условиям; одно — условие рациональности, а другое — всеобщности. Таким образом, в такой критике подразумевается, во-первых, что социальные установления не должны покоиться на убеждениях, ошибочность которых можно показать, и, во-вторых, что защита от ущерба, которую нравственность по определению предоставляет, требуя каких-то действий или воздержания от оных, должна распространяться на всех тех, кто способен и желает сам соблюдать подобные ограничения. Такая нравственная критика общества, которая заключается в лозунгах свободы, братства, равенства и стремления к счастью, утверждает свой моральный характер исходя из того факта, что она призывает к реформе либо во имя некоторых ценностей или комбинации ценностей, которые уже признаны (хотя, возможно, и в недостаточной степени) во всех реально существующих разновидностях общественной нравственности, — либо же во имя некоторой их версии, рафинированной и расширенной настолько, чтобы удовлетворить требованиям рациональности и всеобщности.

Конечно, из того факта, что критика принятой нравственности или других социальных устоев во имя свободы или равенства сама является *моральной* критикой, не следует, что ее отклонение во имя других ценностей не может также быть моральным. Обвинение в ущемлении свободы может быть встречено утверждением, что жертвование свободой для социального или экономического равенства или обеспеченности оправдан-

но само по себе. Такие различия в весе или значительности, придаваемых различным моральным ценностям, могут оказаться непримиримыми. Они могут привести к радикально разным идеальным концепциям общества и составить нравственную противостоящих друг другу политических партий. Одним из величайших оправданий демократии является то, что она допускает экспериментирование и могущий быть пересмотренным выбор между такими альтернативами.

Наконец, не все расширения нравственности за пределы обязанностей и идеалов, общепризнанных в данном обществе, должны принимать форму социальной критики. Важно помнить, что нравственность имеет свой частный аспект, проявляющийся в признании индивидом идеалов, которые он не обязательно должен разделять с другими, или рассматривать в качестве отправного пункта критики других, и еще менее — общества в целом. Жизни могут направляться посвящением их достижению героического, романтического, эстетического или интеллектуального идеалов или, что менее приемлемо, умерщвлению плоти. Здесь также можно было бы приводить доводы в пользу того, что если мы говорим о нравственности, то мы говорим так потому, что ценности, таким образом преследуемые индивидом, по меньшей мере аналогичны некоторым из признаваемых в нравственности общества, где эти индивиды существуют. Но аналогия здесь проводится, конечно, не по содержанию, а по форме и функции. Ибо такие идеалы играют в жизни индивидов такую же роль, какую нравственность играет в обществе. Они занимают наиважнейшее место, так что следование им воспринимается как долг, которому должны быть принесены в жертву другие интересы и желания; хотя обращения возможны, идея того, что такие идеалы могут быть приняты, изменены или устранены с помощью преднамеренного выбора, является химеричной; и, наконец, отклонения от таких идеалов «наказываются» теми же чувством вины и угрызениями совести, что и те, к которым общественная мораль апеллирует в первую очередь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПРАВО И МОРАЛЬ

1. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО И ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ

Существует множество разных видов отношений между правом и моралью, и нет ничего, что могло бы быть удачно выделено в качестве (единственного) *отношения* между ними. Вместо этого важно различать некоторые из многих различных смыслов, в которых могут пониматься утверждение или отрицание того, что мораль и право взаимосвязаны. Иногда то, что утверждается, является такой связью между ними, которую когда-либо отрицали немногие или вообще никто; но ее неоспоримое существование может быть воспринято как признак некоторой более сомнительной связи или даже принято за такую связь. Так, невозможно всерьез отрицать, что на развитие права, везде и во все времена, действительно оказывали глубокое воздействие как обыденная мораль и идеалы отдельных социальных групп, так и просвещенная моральная критика со стороны тех индивидов, чьи нравственные горизонты глубоко превосходили принятую в данное время мораль. Но вполне можно использовать эту истину недозволенным образом как основание для иного утверждения, а именно, что правовая система *должна* демонстрировать некоторое конкретное соответствие с моралью или справедливостью или *должна* основываться на широко распространенном убеждении, что есть моральное основание ей подчиняться. Опять же, хотя это утверждение может быть, в некотором смысле, верным, из него не следует, что критерии юридической силы конкретных законов, применяемые в какой-либо правовой системе, должны включать, неявным или даже явным образом, ссылку на мораль или справедливость.

Не только эти, но и многие другие вопросы касаются отношений между правом и моралью. В этой главе мы рассмотрим только два из них, хотя оба будут сопровождаться рассмотрением многих других. Первый из них — это вопрос, который все еще может быть осмысленно описан как спор между естественным правом [93] и юридическим позитивизмом [94], хотя каждое из этих названий стало использоваться для обозначения ряда различных утверждений о праве и морали. Здесь мы примем,

что юридический позитивизм означает простое утверждение о том, что ни в каком смысле не является необходимой истиной то, что законы воспроизводят или удовлетворяют некоторым требованиям морали, хотя фактически они часто это делают. Но именно потому, что принявшие это воззрение либо молчали о природе морали, либо придерживались очень разных мнений об этом, необходимо рассмотреть два различных способа отвергнуть юридический позитивизм. Один из них яснее всего выражается в классических теориях естественного права, согласно которым есть некоторые принципы поведения людей, ожидающие открытия человеческим разумом, с которыми должно совпадать принятое людьми законодательство для того, чтобы оно имело юридическую силу. Другой принимает иное, менее рационалистическое, представление о морали и предлагает другое понимание путей соединения юридической действительности и моральной ценности. Мы рассмотрим первый способ в этой главе и следующей.

В обширной литературе, от Платона до наших дней, посвященной утверждению, а также отрицанию положения о том, что принципы, в соответствии с которыми должны вести себя люди, могут быть открыты человеческим разумом, часто кажется, что спорящий говорит оппоненту: «Вы слепы, если не видите этого», только для того, чтобы получить ответ: «Вы бредите». И это потому, что утверждение о существовании истинных, открываемых разумом принципов правильного поведения обычно не выдвигалось в качестве отдельной доктрины: первоначально оно было выдвинуто и долгое время обосновывалось как часть общей концепции природы, неодушевленной и живой. Это мировоззрение во многих отношениях прямо противоположно той общей концепции природы, которая составляет основу современной светской мысли. Поэтому теория естественного права ее критикам казалась проистекающей из глубоких старых заблуждений, от которых современная мысль триумфально освободилась, в то время как сторонникам теории критики кажутся всего лишь настаивающими на поверхностных общих местах, игнорирующими более глубокие истины.

Таким образом, многие современные критики полагают, что утверждение, что законы должного поведения могут быть открыты человеческим разумом, основывалось просто на двусмысленности слова «закон» и что когда эта двусмысленность была раскрыта, естественное право получило смертельный удар. Именно таким образом Джон Стюарт Милль обошелся с Монтескье, который в первой части *Esprit de Lois* наивно спрашивает, почему, когда неодушевленные вещи, такие, как звезды, а также животные повинуются «закону их природы», человек так не делает, но впадает во грех [95]. Это, думал Милль, демонстрирует вечную путаницу между законами, формулирующими ход или регулярность при-

родных событий, и законами, требующими от людей вести себя определенным образом. Первые, которые открываются с помощью наблюдений и размышлений, могут быть названы «дескриптивными», и поэтому открывать их должен ученый; последние не могут быть установлены таким образом, ибо они не утверждения и не описания фактов, но «предписания», или требования, чтобы люди вели себя определенным образом. Поэтому ответ на вопрос Монтескье прост: прескриптивные законы могут нарушаться и, тем не менее, оставаться законами потому, что это означает только то, что люди не делают того, что им говорят делать; но бессмысленно говорить о законах природы, открытых наукой, что они могут или что они не могут нарушаться. Если звезды ведут себя вопреки научным законам, предназначенным описывать их регулярное движение, эти законы не нарушаются, но теряют право именоваться «законами» и должны быть переформулированы. Этим различиям в смысле слова «закон» соответствуют отличия в сопутствующих словах, таких как «должен», «обязан», «следует». Так что, с этой точки зрения, вера в естественное право сводится к очень простой ошибке: неспособности воспринимать весьма различные смыслы, в которых могут употребляться эти связанные со словом «закон» понятия. Это как если бы сторонник этой теории не мог различить очень разное значение таких слов в предложениях: «Вы обязательно должны явиться на военную службу» и «Обязательно будет заморозок, если ветер сменится на северный».

Такие критики, как Бентам и Милль, наиболее яростно нападавшие на естественное право, часто объясняли путаницу своих оппонентов в этих различных смыслах понятия «закон» сохранением веры в то, что наблюдаемые регулярности в природе были предписаны или поведены божественным правителем вселенной [96]. В рамках такого теократического представления единственная и сравнительно незначительная разница между законом гравитации и десятью заповедями — законом божьим для человека — заключалась, как это утверждал Блэкстоун, в том, что люди были единственными из творений, наделенными разумом и свободой воли и поэтому, в отличие от вещей, могли открыть божественные предписания и не повиноваться им. Однако естественное право не всегда было связано с верой в божественного правителя или законодателя вселенной, и даже когда было, его типичные особенности логически не зависели от этой веры. И соответствующее понимание слова «естественный», характеризующего естественное право, и его общее мировоззрение, минимизирующее столь очевидные и важные для современных умов отличия между прескриптивными и дескриптивными законами, коренятся в древнегреческой мысли, которая была в этом отношении вполне светской. Действительно, продолжающееся вновь и вновь утверждение той или иной формы естественноправовой доктрины отчасти

связано с тем, что ее привлекательность не зависит от божественного или человеческого авторитета, и с тем фактом, что, несмотря на терминологию и малоприемлемую сегодня метафизику, она содержит некоторые элементарные истины, важные для понимания как морали, так и права. Именно их мы попытаемся извлечь из их метафизической оболочки и сформулировать более просто.

Для современной светской мысли мир неодушевленных и одушевленных тел, животных и людей есть место регулярно повторяющихся событий и изменений, воплощающих некоторые регулярные взаимосвязи. По крайней мере некоторые из них были открыты людьми и сформулированы в качестве законов природы. С этой современной точки зрения, понимание природы есть использование знания этих повторяющихся процессов. Структура великих научных теорий, конечно, не отражает каким-то простым образом наблюдаемые факты, события или изменения. Действительно, значительная часть этих теорий состоит из абстрактных математических формул, не имеющих прямых прототипов среди наблюдаемых фактов. Их связь с наблюдаемыми явлениями и событиями заключается в том, что из этих абстрактных формул могут быть выведены обобщения, которые относятся к наблюдаемым событиям и могут быть ими подтверждены или опровергнуты. Поэтому претензии научной теории на то, что она продвигает вперед наше понимание природы, зависят, в конечном счете, от ее способности предсказывать будущие события, которая опирается на обобщения относительно регулярно происходящего. Закон гравитации и второй закон термодинамики для современной мысли являются законами природы, чем-то большим, чем просто математические конструкции, благодаря сообщаемой ими информации относительно повторяющихся закономерностей в наблюдаемых явлениях.

Доктрина естественного права есть часть более древнего понимания природы, в которой наблюдаемый мир не просто место действия подобных повторяющихся процессов, и знание природы не просто знание их. В рамках этого древнего мировоззрения все существующие тела (неодушевленные, одушевленные и люди) понимаются не только как поддерживающие свое существование, но как стремящиеся к определенному оптимальному состоянию, являющемуся особым благом — или *целью (tslog, finis)* для них.

Это телеологическая концепция природы, содержащей в себе уровни совершенства, которых достигают вещи. Ступени, по которым любая вещь поднимается до ее особой или должной цели, упорядочены и могут быть выражены в обобщениях, описывающих характерный для вещи способ изменения, или действия, или развития; до этой степени телеологическое представление о природе совпадает с современным. Различие в том, что, с телеологической точки зрения, события, регулярно случаю-

щиеся с вещами, мыслятся не *просто* происходящими регулярно, и вопросы о том, *действительно* ли они происходят регулярно, и *должны* ли они происходить регулярно, или *хорошо* ли то, что они происходят, не рассматриваются как отдельные вопросы. Напротив (за исключением некоторых редких уродств, приписываемых «случаю»), то, что обычно происходит, может быть и объяснено и оценено как благо или то, что обязано происходить, путем демонстрации того, что это шаг к должной цели или задаче описываемой вещи. Поэтому законы развития вещи должны демонстрировать и как она регулярно ведет себя или изменяется, и как она должна это делать.

Этот образ мышления о природе кажется странным, когда формулируется абстрактно. Он может показаться менее фантастическим, если мы вспомним, как мы говорим по крайней мере о живых созданиях, ибо телеологические представления все еще отражаются в обычных описаниях их развития. Так, для желудя вырастание в дуб есть нечто не только регулярно достигаемое желудями, но и характеризуемое (в отличие от загнивания, которое тоже происходит регулярно) как оптимальное состояние зрелости, в свете которого промежуточные стадии и объясняются, и оцениваются как хорошие или плохие, и выделяются «функции» различных частей и структурные изменения. Нормальный рост листьев нужен для того, чтобы получать влагу, необходимую для «полного» или «должного» развития, и «функцией» листьев является обеспечение этим[1]. Поэтому мы думаем и говорим об этом росте как о том, что «должно естественно происходить». В случае действий или движений неодушевленных вещей говорить о них таким образом кажется намного менее оправданным, если только это не артефакты, изготовленные людьми с определенной целью. Представление о том, что камень, падая на землю, реализует некую соответствующую «цель» или возвращается на «должное место», как лошадь, скачущая в конюшню, сейчас выглядит довольно комично.

Действительно, одна из трудностей в понимании телеологического взгляда на природу заключается в том, что так же, как он минимизировал разницу между утверждениями о том, что регулярно происходит и что должно происходить, так же он минимизирует и различие, столь важное для современной мысли, между людьми с их собственными целями, которые они сознательно стремятся реализовать, и другими живыми или неодушевленными телами. Ибо в рамках телеологических представлений о мире человек, как и другие природные объекты, мыслится в качестве стремящегося к особому оптимальному состоянию или цели, заданной

[1] Так у Г. Харта. Естественно, что важнейшей функцией листьев является фотосинтез. — *Примеч. перев.*

для него, и тот факт, что он, в отличие от других созданий, может делать это сознательно, не рассматривается как радикальное отличие между ним и всей остальной природой. Эта особая цель или благо человека, как и других живых существ, отчасти обусловливается биологической зрелостью и развитыми физическими силами. Но она также включает, как отчетливо человеческий элемент, развитие и совершенство интеллекта и характера, проявляющееся в мысли и поведении. В отличие от других природных объектов, человек способен путем размышления и созерцания обнаружить, что включает в себя достижение этого совершенства ума и характера, и желать этого. Но даже так, с этой телеологической точки зрения, это оптимальное состояние не есть благо или цель человека потому, что он его желает; напротив, он желает его потому, что это уже есть его естественная цель.

Опять же, многое из этих телеологических представлений сохранилось в том, как мы думаем и говорим о человеке. Оно скрывается в определении некоторых вещей как человеческих *потребностей,* удовлетворение которых есть *благо,* и некоторых вещей, причиненных или испытанных людьми как *вред или ущерб.* Так, хотя и верно то, что некоторые люди могут отказаться есть или отдыхать потому, что хотят умереть, мы думаем о еде и отдыхе как о чем-то большем, чем то, что люди регулярно делают или просто желают. Еда и отдых суть потребности человека, даже если некоторые отказываются от них несмотря на то, что нуждаются. Поэтому мы говорим не только то, что для всех людей естественно есть и спать, но и что все люди должны иногда есть и отдыхать, или что делать это является естественным благом. Сила слова «естественно» в подобных суждениях о поведении людей состоит в разграничении их как от суждений, отражающих просто условности или принятые в обществе предписания («вы должны снять вашу шляпу»), содержание которых не может быть открыто размышлением или созерцанием, так и от суждений, которые просто отмечают, что требуется для достижения некоторой частной цели, которую в данное время один человек может иметь, а другой — нет. То же мировоззрение присутствует в представлении о *функциях* органов тела и в том разграничении, которое мы проводим между ними и всего лишь причинно-следственными характеристиками. Мы говорим, что функцией сердца является перекачивание крови, но не утверждаем, что функцией раковой опухоли является вызывать смерть.

Эти грубые примеры, придуманные для того, чтобы проиллюстрировать телеологические элементы, все еще присутствующие в обыденном мышлении о поведении людей, заимствованы из «низкой» сферы биологических фактов, общих для человека и животных. Будет правильным заметить, что то, что придает смысл этому способу мыслить и выражаться, есть нечто вполне очевидное: это молчаливое допущение, что долж-

ной целью деятельности человека является выживание, и это основывается на том простом сопутствующем факте, что большинство людей большую часть времени хотят продолжать существование. Действия, которые мы характеризуем как те, которые естественно хорошо делать, суть те, которые требуются для выживания; понятия потребностей людей, вреда, и *функций* органов тела или изменений основываются на том же простом факте. Конечно, если мы остановимся на этом, то получим только очень ослабленную версию естественного права, ибо для его классиков выживание *(perseverare in esse suo)* было всего лишь низшим уровнем значительно более сложной и значительно более спорной идеи цели человека или его блага. Аристотель включал в это понятие бескорыстное культивирование интеллекта, Аквинат — познание Бога, и обе эти ценности могут быть (и были) оспорены. Но другие мыслители, и среди них Гоббс и Юм, были готовы направить взоры долу. Они видели в скромной цели выживания центральный и бесспорный элемент, придающий хороший эмпирический смысл терминологии естественного права. «Человек по своей природе не может выжить без ассоциации индивидов, и эта ассоциация невозможна там, где пренебрегают законами честности и справедливости» \

Эта простая мысль на самом деле очень сильно связана с особенностями и права, и морали, и она может быть отделена от более спорных элементов телеологического мировоззрения, для которых цель или благо человека выступает как какой-то конкретный образ жизни, по поводу чего среди людей возможны глубокие разногласия. Более того, говоря о выживании, мы можем отбросить, как слишком метафизическое для современных умов, представление о том, что оно есть некая заранее фиксированная должная цель или задача людей, и поэтому они необходимым образом стремятся к этому. Вместо этого мы можем считать, что это чисто сопутствующий факт, и что могло бы быть иначе, что в общем люди желают жить, и что мы, называя выживание целью или задачей людей, можем иметь в виду не более того, что люди этого желают. Но даже если мы будем смотреть на это с такой точки зрения здравого смысла, выживание все же сохранит особый статус в отношении к поведению людей и к тому, как мы думаем об этом, что находит параллели в той важности и необходимости, которые приписывают ему ортодоксальные формулировки естественного права. Дело не просто в том, что подавляющее большинство людей хотят жить, пусть даже в ужасающей нищете, но в том, что это отражено в структурах нашей мысли и языка, с помощью которых мы описываем мир и друг друга. Мы не можем убрать

[1] Юм, Трактат о человеческой природе, кн. 3, ч. 2 («О справедливости и несправедливости»).

это общее желание жить и оставить при этом в целости такие понятия, как опасность и безопасность, вред и выгода, необходимость и функция, болезнь и лекарство, ибо все эти понятия — это способы одновременно описывать и оценивать вещи в плане того, насколько они способствуют выживанию, которое нами принимается как цель.

Есть, однако, более простые, менее философские соображения, которые показывают, что принятие выживания как цели необходимо в смысле, имеющем более прямое отношение к обсуждению права и морали в человеческом обществе. Мы привержены ему как чему-то, что предполагается самими понятиями, употребляемыми в этих дискуссиях, ибо нас волнуют социальные механизмы для продолжения существования, а не проблемы организации клуба самоубийц. Мы желаем знать, есть ли среди этих социальных механизмов те, которые могут быть осмысленно классифицированы как естественные законы, открываемые разумом, и каково их отношение к принятым людьми законам и морали. Чтобы поднять этот или любой другой вопрос о том, *как* люди должны жить вместе, мы должны исходить из того, что их целью в общем-то является жить. С этого момента аргументация становится простой. Размышление о некоторых весьма очевидных обобщениях, даже трюизмах относительно природы человека и мира, в котором живут люди, показывает, что, пока это все остается в силе, есть некоторые правила поведения, которые должна иметь любая социальная организация для того, чтобы быть жизнеспособной. И действительно такие правила являются обычной составной частью права и обыденной морали всех обществ, достигших той степени, где их можно выделить как различные формы социального контроля. Вместе с ними и в праве, и в морали находится много того, что является специфичным для каких-то конкретных обществ, и много того, что кажется произвольным или просто следствием какого-то выбора. Такие признанные универсальными принципы поведения, имеющие основание в элементарных истинах относительно человеческих существ, их естественного окружения и целей, могут рассматриваться как *минимальное содержание* естественного права, в противоположность более грандиозным и более спорным конструкциям, часто предлагавшимися под этим наименованием. В следующем разделе мы рассмотрим, в виде пяти трюизмов, наиболее бросающиеся в глаза характеристики природы человека, на которых основывается этот скромный, но важный минимум.

2. МИНИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА

Рассматривая излагаемые здесь простые трюизмы и их связь с правом и моралью, важно видеть, что в каждом случае упомянутые факты пред-

ставляют *основание* того, почему при принятии выживания за цель право и мораль должны включать в себя определенное содержание. Общая идея этой аргументации состоит просто в том, что без такого содержания право и мораль не могут способствовать минимальной задаче выживания, стоящей перед объединяющимися друг с другом людьми [97]. При отсутствии такого содержания люди, такие, как они есть, не имели бы оснований добровольно подчиняться каким-либо правилам, и без минимального добровольного сотрудничества тех, кто находит, что в их интересах подчиняться правилам и поддерживать их, принуждение остальных, добровольно не подчиняющихся, было бы невозможным. Важно подчеркнуть отчетливо рациональную связь между естественными фактами и содержанием юридических и моральных правил в рамках этого подхода, потому что и возможно и важно задаться вопросом о различных формах связи между естественными фактами и юридическими или моральными правилами. Так, все еще молодые науки — психология и социология — могут открыть, или, возможно, даже уже открыли, что, пока некоторые физические, психологические или экономические условия не удовлетворены, например пока маленькие дети в семье не питаются или не воспитываются определенным образом, не может быть установлено никакой системы законов или правил морали, или что успешно функционировать могут только законы определенного типа. Такие связи между естественными условиями и системами правил не опосредованы *основаниями,* ибо они не соотносят существование некоторых правил с сознательными целями или задачами тех, чьи это правила. Может быть продемонстрировано, что тот или иной способ кормления младенцев является необходимым условием или даже *причиной* того, что данная группа населения развивает или сохраняет какую-либо систему юридических или моральных правил, но это не *основание* для таких действий этой группы. Конечно, подобные каузальные связи не противоречат связям, основывающимся на целях или сознательных стремлениях; действительно, первые можно посчитать более важными или фундаментальными, чем последние, ибо они (первые) могут на самом деле объяснить, почему люди имеют эти сознательные стремления или цели, которые принимаются за отправной момент естественным правом. Каузальные объяснения такого рода не основываются на трюизмах и не опосредованы сознательными задачами или целями: они должны быть найдены социологией или психологией, как и другими науками, с помощью обобщения и теоретизирования, основывающегося на наблюдении и, где возможно, на эксперименте. Поэтому такие связи отличны от тех, которые соотносят содержание некоторых юридических и моральных правил с фактами, сформулированными в следующих трюизмах.

(i) *Уязвимость людей.* Обычно право и мораль требуют в основном не активного оказания услуг, но воздержания от некоторых действий, что, как правило, формулируется в негативной форме как запреты. Наиболее важными из них для общественной жизни являются те, которые ограничивают применение насилия путем убийства или нанесения телесных повреждений. Фундаментальный характер таких правил может быть выявлен при помощи следующего вопроса: если бы этих правил не было, какой тогда смысл существам вроде нас было бы иметь правила *любого* другого рода? Сила этого риторического вопроса основывается на том факте, что люди одновременно и уязвимы для телесных повреждений, и склонны наносить их. Но, хотя это и трюизм, это не является необходимой истиной: дела могли и, возможно, еще будут обстоять по-другому. Есть виды животных, чья физическая организация (включающая экзоскелет или панцирь) делает их практически неуязвимыми для нападения со стороны других представителей своего вида и животных, не имеющих органов, позволяющих это сделать. Если бы люди потеряли свою уязвимость друг перед другом, исчезло бы одно очевидное основание для наиболее характерного требования права и морали: *неубий.*

(ii) *Примерное равенство.* Люди отличаются друг от друга по своей физической силе, ловкости и еще более — интеллектуальным способностям. Тем не менее весьма важный факт для понимания различных форм права и морали состоит в том, что ни один индивид не настолько сильнее остальных, чтобы быть в состоянии, не прибегая к сотрудничеству, доминировать над остальными или подчинить их на более чем краткое время. Даже сильнейший иногда должен спать, и когда спит, временно теряет свое превосходство. Этот факт примерного равенства более чем какой-либо другой делает очевидной необходимость системы взаимной сдержанности и компромиссов, лежащей в основе и правовых, и моральных обязанностей. Общественная жизнь, с ее правилами, требующими таких уступок, иногда утомительна, но она, во всяком случае, менее отвратительна, менее груба и менее коротка[1] для таких примерно равных существ, чем это было бы при несдерживаемой агрессии. Конечно, с этим вполне совместимо и является в равной степени трюизмом то, что, когда устанавливается такая система сдержанности, всегда найдутся те, кто пожелает злоупотреблять ею, одновременно и живя под ее защитой, и нарушая ее ограничения. Это действительно, как мы покажем дальше, является одним из естественных фактов, делающих необходимым шаг от только моральных к организованным, правовым формам контроля.

[1] Скрытая цитата из «Левиафана» Т. Гоббса. «Грубой, короткой и отвратительной» Гоббс называет жизнь в условиях «естественного состояния», т. е. полной свободы до возникновения государства. — *Примеч. пер.*

Опять же, могло бы быть и по-другому. Вместо приблизительного равенства могли бы существовать некоторые люди, неизмеримо более сильные, чем остальные, и лучше способные с ними справиться либо потому, что некоторые в этом отношении значительно превосходили бы нынешний средний уровень, либо потому, что большинство было бы намного ниже его. Такие исключительные люди могли бы многого добиться агрессией и мало чего — взаимной сдержанностью или компромиссами с другими. Но нам не нужно обращаться к фантазиям о гигантах среди пигмеев для того, чтобы увидеть принципиальную важность факта приблизительного равенства, ибо это можно лучше проиллюстрировать фактами международной жизни, там где есть (или было) большое неравенство в силе или уязвимости между государствами. Как мы позднее увидим, это неравенство между субъектами международного права является одним из тех факторов, которые придали ему характер столь отличный от внутригосударственного права и ограничили степень, в которой оно способно действовать как организованная система принуждения.

(iii) *Ограниченный альтруизм.* Люди — не дьяволы, у которых господствует желание уничтожить друг друга, и демонстрация того, что при наличии всего лишь скромной цели выживания основные правила закона и морали являются необходимостью, не должна отождествляться с ложным представлением о том, что люди преимущественно эгоистичны и не имеют никакого бескорыстного интереса в выживании и благосостоянии своих собратьев. Но если люди не дьяволы, они и не ангелы; и тот факт, что они — нечто среднее между этими двумя крайностями, делает систему взаимной сдержанности и необходимой, и возможной. Для ангелов, никогда не подверженных искушению вредить другим, правила, диктующие сдержанность, не были бы необходимостью. Для дьяволов, готовых уничтожать невзирая на то, чего это будет стоить им самим, эти правила не были бы возможны. Но вещи таковы, что альтруизм людей ограничен в своих пределах и непостоянен, а тенденция к агрессии проявляется достаточно часто, чтобы стать фатальной для общественной жизни, если эту агрессию не контролировать.

(iv) *Ограниченные ресурсы.* Это всего лишь случайный факт, что люди нуждаются в еде, одежде и крыше над головой; что все это не имеется под рукой в неограниченном изобилии, но скудно, должно быть выращено или отвоевано у природы или построено трудом. Сами по себе эти факты делают необходимой какую-то минимальную форму института собственности (хотя не обязательно индивидуальной собственности) и определенной формы власти, требующей ее (собственность) уважать. Простейшие формы собственности можно видеть в правилах, запрещающих всем, кроме «владельца», входить на какой-то земельный участок, или пользоваться им, или брать и использовать какие-то матери-

альные вещи. Для роста посевов необходимо, чтобы по полю не мог ходить кто угодно, и пища, в промежутках между ее ростом или поимкой и потреблением, должна быть защищена от посторонних лиц. Во все времена и везде сама жизнь зависит от этих минимальных проявлений сдержанности. И опять, в этом отношении дела могли бы обстоять по-другому. Организм человека мог бы быть устроен как у растений, мог бы извлекать пищу из воздуха, или же все, что требуется, могло расти в беспредельном изобилии.

Правила, которые до сих пор были рассмотрены, *статичны* в том смысле, что налагаемые ими обязанности и сфера действия этих обязанностей не варьируют от индивида к индивиду. Но разделение труда, которое должны развить все, кроме самых малых групп, для того чтобы получать достаточное количество продуктов, порождает необходимость *динамичных* правил в том смысле, что они позволяют индивидам создавать обязанности и менять сферу их охвата. Среди них — правила, позволяющие людям передавать, менять или продавать произведенное ими, ибо эти сделки предусматривают способность менять охват первоначальных прав и обязанностей, определяющих простейшую форму собственности. То же неизбежное разделение труда и постоянная потребность в сотрудничестве являются также факторами, делающими необходимыми для жизни социума другие формы динамичных или создающих обязанности правил. Такие правила гарантируют признание обещаний как источника обязательств. С помощью этого механизма индивиды имеют возможность словами, устными или письменными, сделать себя подлежащими порицанию или наказанию за несовершение некоторых оговоренных действий. Где альтруизм не является безграничным, требуется установленная процедура для таких действий по связыванию самих себя обязательствами для того, чтобы создать минимум уверенности в будущем поведении других и обеспечить предсказуемость, необходимую для сотрудничества. Это с особенной очевидностью необходимо там, где совместно планируются или обмениваются взаимные услуги или где товары, подлежащие обмену или продаже, не всегда одновременно или немедленно имеются в наличии.

(v) *Ограниченное понимание и сила воли.* Факты, делающие необходимыми для общественной жизни правила об уважении индивидов, собственности и обещаний, просты, и взаимная выгода от этих правил очевидна. Большинство людей способны это видеть и жертвовать ближайшими краткосрочными интересами, чего требует подчинение этим правилам. Действительно, они могут повиноваться, исходя из разных мотивов: некоторые — из продиктованных благоразумием соображений о том, что приобретения стоят жертв, некоторые — из бескорыстной заинтересованности в благополучии других и некоторые потому, что воспри-

нимают правила как сами по себе заслуживающие уважения и находят свой идеал в преданности им. С другой стороны, ни понимание долгосрочных интересов, ни сила или благость воли, от которых зависит эффективность этих различных мотиваций для повиновения, не разделяются всеми людьми в равной степени. Все временами испытывают искушение отдать предпочтение своим собственным ближайшим интересам, и в отсутствие особой организации для обнаружения и наказания многие поддались бы искушению. Несомненно, что преимущества взаимной сдержанности столь ощутимы, что число и сила тех, кто добровольно сотрудничал бы в поддержании системы принуждения, обычно будет значительно больше, чем любое возможное объединение преступников. Но, за исключением очень маленьких, объединенных тесными узами обществ, подчинение системе ограничений было бы глупостью, если бы не было организации для принуждения тех, кто попытался бы пользоваться преимуществами системы, не подчиняясь при этом налагаемым ею обязанностям. Поэтому «санкции» требуются не в качестве нормального мотива для подчинения, но как гарантия, что те, кто подчинились добровольно, не станут жертвами тех, кто этого не сделал. Подчиняться без этого означало бы рисковать оказаться в безвыходном положении. Учитывая эту постоянную опасность, разум требует *добровольного* сотрудничества в системе *принуждения.*

Следует заметить, что тот же естественный факт примерного равенства между людьми имеет решающее значение для эффективности организованных санкций. Если бы некоторые люди были значительно сильнее других и не так зависели от проявлений сдержанности с их стороны, сила преступников могла бы превзойти силу сторонников закона и порядка. При таком неравенстве использование санкций не могло бы быть успешным и было бы связано с угрозами не меньшими, чем те, которые предполагалось подавить. При таких обстоятельствах вместо общественной жизни, основанной на взаимной сдержанности, лишь изредка с применением силы против меньшинства преступников, единственно жизнеспособной системой была бы та, при которой слабые подчинились бы сильным на лучших условиях, которые они могли бы получить, и жили под их «защитой». Это, в связи со скудостью ресурсов, привело бы к возникновению нескольких конфликтующих центров силы. Каждый из них группировался бы вокруг своего «сильного человека»; они время от времени воевали бы друг с другом, хотя возможная санкция в виде риска поражения, всегда сколько-нибудь значимая, могла бы обеспечить с трудом поддерживаемый мир. Тогда могли бы быть приняты правила для урегулирования вопросов, из-за которых «державы» не желали воевать. И снова нам не нужно заниматься фантазиями о пигмеях и гигантах для того, чтобы понять простую логику примерного равенства и его важность для права. Международная

арена, где игроки очень разнятся в силе, предоставляет достаточно иллюстраций. В течение столетий неравенство между государствами привело к такой системе, где организованные санкции были невозможны и право было ограничено вопросами, не затрагивающими «жизненно важные» темы. Остается увидеть, насколько атомное оружие, став доступным всем, выровняет неравенство сил и сделает формы контроля более напоминающими внутригосударственное уголовное право.

Простые трюизмы, рассмотренные нами, не только выявляют ядро здравого смысла в доктрине естественного права. Они жизненно важны для понимания права и морали и объясняют, почему определение их базовых форм в чисто формальных понятиях, без указания на какое-либо содержание или социальные потребности, оказалось столь неадекватным. Возможно, наибольшая польза этого мировоззрения для юриспруденции в том, что оно дает выход из некоторых вводящих в заблуждение дихотомий, которые часто затемняют обсуждение особенностей права. Так, например, традиционный вопрос о том, *должна ли* каждая правовая система обеспечивать санкции, может быть изложен в свежем и более ясном виде, когда в нашем распоряжении будет тот взгляд на вещи, которым характеризуется эта простая версия естественного права. Нам больше не придется выбирать между двумя неподходящими альтернативами, которые часто считаются единственными: с одной стороны, утверждением, что этого требует «само» значение слов «право» и «правовая система», и, с другой, утверждением, что это «всего лишь факт», что большинство правовых систем действительно обеспечивают санкции. Ни одна из этих альтернатив не является удовлетворительной. Нет никаких установленных принципов, запрещающих использование слова «право» по отношению к системам, где отсутствуют централизованные санкции, и есть хорошие основания (хотя нет и принуждения) использовать выражение «международное право» в отношении системы, их не имеющей. С другой стороны, нам необходимо выявить то место, которое санкции должны занимать в рамках системы внутригосударственного права для того, чтобы она служила минимальным целям существ, устроенных так, как люди. Мы можем сказать, учитывая структуру естественных фактов и целей, которые делают санкции и возможными и необходимыми в гражданском праве, что это — *естественная необходимость;* и какая-то фраза в таком же роде нужна для того, чтобы выразить статус минимальных форм защиты личности, собственности и обещаний, которые сходным образом являются обязательными характеристиками внутригосударственного права. Именно такую форму должен принять наш ответ на позитивистский тезис о том, что «право может иметь любое содержание». Ибо довольно важная истина в том, что для адекватного описания не только права, но и многих других социальных институтов должно быть зарезервировано место не только для дефиниций и

фактуальных утверждений, но и для высказываний третьего рода: тех, чья истинность зависит от человеческих существ и мира, в котором они живут, от сохранения их наиболее характерных особенностей.

3. ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И МОРАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

Защита и выгоды, обеспечиваемые системой взаимной сдержанности, лежащей в основе и права и морали, может распространяться на очень различный круг лиц. Верно, что лишение такой элементарной защиты любой группы людей, готовых принять соответствующие ограничения, оскорбляет принципы морали и справедливости, которым все современные государства отдают дань по крайней мере на словах. Исповедуемые ими моральные взгляды в целом проникнуты представлениями о том, что по крайней мере в принципе, люди имеют право на равное обращение и что различия в обращении требуют большего обоснования, чем просто указание на то, что это в чьих-то интересах.

Однако очевидно и то, что ни право, ни принятая в обществах мораль не должны обязательно распространять свою минимальную защиту и выгоды на всех, кого они охватывают, и что часто они этого и не делали. В рабовладельческих обществах доминирующая группа может потерять ощущение того, что рабы — это человеческие существа, а не просто объекты эксплуатации. И однако при этом члены доминирующей группы могут оставаться чрезвычайно нравственно чувствительными к притязаниям и интересам друг друга. Гекльберри Финн, когда его спросили о том, не причинил ли кому-нибудь вреда взрыв парового котла на корабле, ответил: «Нет, мэм. Убило ниггера». Замечание тетушки Салли: «Да, повезло, потому что иногда бывают человеческие жертвы» — в концентрированной форме выражает мораль, часто преобладавшую среди человечества [98]. Там, где она действительно преобладает, распространение на рабов той заботы о других, которая естественна между членами доминирующей группы, может (как Гек узнал на своем горьком опыте) рассматриваться как серьезное моральное преступление, влекущее за собой все последствия моральной вины. Нацистская Германия и Южная Африка также предоставляют неприятно близкие нам по времени аналогии [99].

Хотя право некоторых обществ иногда бывало впереди их общепринятой морали, обычно право следует за моралью, и даже убийство раба может рассматриваться только как растрата общественных ресурсов или преступление против его хозяина. Даже там, где нет официально признанного рабства, дискриминация на почве расовой принадлежности или рели-

гии может породить правовую систему и общественную мораль, не признающие, что все люди имеют право на минимум защиты от остальных.

Эти тягостные факты истории человечества достаточны для того, чтобы показать, что хотя общество для того, чтобы быть жизнеспособным, должно предложить *некоторым* из своих членов систему взаимной сдержанности, оно, к сожалению, не нуждается в том, чтобы предложить ее всем. Действительно, как мы уже подчеркивали, обсуждая необходимость и возможность санкций для того, чтобы система правил могла быть силой навязана кому-либо, должно быть достаточное количество тех, кто принимает ее добровольно. Без их добровольного сотрудничества, тем самым создающего *власть,* принудительная сила закона и правительства не может быть установлена. Но принудительная сила, установленная таким образом властью, может использоваться двумя основными способами. Она может применяться только против преступников, которые, хотя им предоставлена защита правил, эгоистично нарушают их. С другой стороны, она может применяться для покорения и удержания в подчиненном положении подвластной группы, чьи размеры, по отношению к господствующей группе, могут быть большими или малыми, в зависимости от средств принуждения, солидарности и дисциплины последней, и беззащитности или неспособности организоваться первой. Для тех, кто так угнетен, в системе может не быть ничего, способного вызвать их лояльность, кроме средств устрашения. Они жертвы системы, а не выигравшие от нее.

В предшествующих главах этой книги мы подчеркивали тот факт, что существование правовой системы есть социальное явление, всегда имеющее два аспекта, и мы должны учитывать оба, если хотим, чтобы наши представления о нем были реалистичными. Они включают в себя отношения и поведение, характерные для добровольного принятия правил, и более простые отношения и поведение, связанные с простым повиновением или смирением перед ними.

Следовательно, общество, имеющее право, состоит, в частности, из тех, кто смотрит на его (права) правила с внутренней точки зрения как на принимаемые стандарты поведения, а не просто надежные предсказания того, что будет с ними, если они не будут повиноваться и попадут в руки должностных лиц. Но оно также включает тех, кому (потому что они либо преступники, либо беззащитные жертвы системы) эти правовые стандарты должны быть навязаны силой или угрозой силы; правила ими воспринимаются как всего лишь источник возможного наказания. Соотношение между этими двумя группами определяется множеством различных факторов. Если система справедлива и действительно заботится о жизненных интересах всех, от кого требует повиновения, она может получить и сохранять приверженность большинства большую часть време-

ни и, соответственно, будет стабильной. С другой стороны, она может быть узкой и исключающей системой, действующей в интересах доминирующей группы и непрерывно становящейся все более репрессивной и нестабильной в связи с латентной угрозой социального взрыва. Между этими двумя крайностями находятся различные сочетания этих двух отношений к праву, часто и в одном и том же индивиде.

Размышление об этом аспекте дел выявляет отрезвляющую истину: шаг от простого общества, где первичные правила обязанности являются единственным средством социального контроля к правовому миру, с его централизованной законодательной системой, судами, официальными лицами и санкциями, приносит внушительные приобретения, но определенной ценой. Приобретения — приспособляемость к изменениям, точность и эффективность — грандиозны; цена — риск того, что централизованная власть может так же успешно использоваться для угнетения множества тех, без чьей поддержки она может обойтись, что не было возможным для более простого режима первичных правил. Поскольку эта опасность уже материализовалась и может случиться снова, утверждение, что право *должно* соответствовать морали в каком-то более далеко идущем отношении, чем то, которое мы продемонстрировали как минимальное содержание естественного права, нуждается в очень серьезной проверке. Многие из таких утверждений либо не в состоянии прояснить смысл, в котором связь между правом и моралью объявляется необходимой; или, в результате анализа, оказывается, что они значат нечто одновременно истинное и важное, но представлять это как необходимую связь между правом и моралью только запутывает дело. Мы закончим эту главу рассмотрением шести видов таких утверждений.

(i) *Власть и авторитет.* Часто говорят, что правовая система должна основываться на чувстве нравственного долга или на убежденности в моральной ценности системы, поскольку она не основывается и не может основываться только на власти человека над человеком. Мы сами подчеркивали в предшествующих главах этой книги недостаточность приказов, подкрепленных угрозами, и привычки к повиновению для понимания оснований правовой системы и идеи юридической действительности. Дело не только в том, что они, как мы видели это в четвертой главе, для своего объяснения требуют понятия принятого правила признания. Но и в том, что, как мы видели в данной главе, необходимым условием существования принудительной власти является то, что по крайней мере некоторые должны добровольно сотрудничать в этой системе и принимать ее правила. В этом смысле верно то, что принудительная сила закона предполагает признание его авторитета. Но дихотомия «закона, базирующегося только на силе», и «закона, принятого как морально обязывающего», не является исчерпывающей. Не только большие

группы людей могут подвергаться принуждению при помощи законов, которые они не признают в качестве морально обязывающих. Неверно даже и то, что те, кто принимает систему добровольно, должны считать себя морально обязанными это делать, хотя система и будет наиболее стабильной в этом последнем случае. На самом деле их верность системе может основываться на множестве различных соображений: расчете относительно долгосрочных интересов; бескорыстной заинтересованности в благе других; неотрефлексированном унаследованном или традиционном отношении или всего лишь желании поступать так, как другие. Действительно, нет причины, по которой те, кто принимает авторитет системы, не могут посоветоваться со своей совестью и решить, что морально они не должны принимать систему, но в силу различных причин продолжать это делать.

Эти общие места могут быть затемнены в силу обычного использования одних и тех же слов для выражения и правовых, и моральных обязанностей, признаваемых людьми. Те, кто принимает авторитет правовой системы, смотрят на нее с внутренней точки зрения и выражают свое понимание ее требований во внутренних утверждениях, сформулированных на нормативном языке, общем для права и морали: «я (ты) обязан», «я (ты) должен», «у меня (у них) есть обязанность». Но тем самым они не обязаны принимать *моральное* суждение о том, что исполнять предписанное законом морально правильно. Нет сомнения, что если ничего более не говорится, то имеется презумпция, что тот, кто высказывается таким образом о своих или чужих правовых обязанностях, не думает, что есть моральные или иные основания не выполнять их. Это, однако, не показывает, что ничто не может быть признано юридически обязательным, если оно не принято в качестве морально обязательного. Упомянутая нами презумпция основывается на том факте, что часто будет бессмысленным признавать или указывать на правовую обязанность, если говорящий имеет убедительные основания, моральные или иные, высказываться против ее выполнения.

(ii) *Влияние морали на право.* Право любого современного государства демонстрирует в тысячах проявлений влияние и общепринятой морали, и более широких моральных идеалов [100]. Эти влияния входят в право либо резко и открыто — через законодательство, либо тихо и постепенно — через судебный процесс. В некоторых правовых системах, таких, как система Соединенных Штатов, предельные критерии юридической действительности открыто включают в себя принципы справедливости или содержательные моральные ценности. В других, таких, как английское право, где нет формальных ограничений компетенции высшей законодательной власти, законодательство, тем не менее, может скрупулезно соответствовать справедливости и морали. Есть мириады

иных путей, в которых право отражает мораль, и они все еще недостаточно изучены: статуты могут быть всего лишь юридической оболочкой и в прямых выражениях требовать своего наполнения с помощью моральных принципов; сфера подлежащих выполнению контрактов может быть ограничена ссылками на концепции нравственности и честности; строгость наказания за административные и уголовные преступления может быть изменена так, чтобы соответствовать господствующим представлениям о моральной ответственности. Ни один «позитивист» не может отрицать реальность этих фактов или того, что стабильность правовых систем частично зависит от таких видов соответствия их морали. Если это то, что подразумевается под необходимой связью права и морали, то следует признать ее существование.

(iii) *Интерпретация.* Законы требуют интерпретации для того, чтобы применяться к конкретным случаям, и как только мифы, затемняющие природу судебного процесса, развеиваются реалистическим исследованием, становится ясно, что, как мы показали в шестой главе, открытая структура права оставляет широкое поле для творческой деятельности, которую некоторые называют законодательной [101]. Ни в интерпретации статутов, ни прецедентов судьи не ограничены альтернативой либо слепого, произвольного выбора, либо «механического» выведения решения из правил с предопределенным значением. Очень часто в своем выборе они руководствуются той посылкой, что цель правил, которые они интерпретируют, разумна, так что правила не предназначены для того, чтобы творить несправедливость или оскорблять установившиеся моральные принципы. Решения судей, особенно в вопросах высокого конституционного значения, часто включают в себя выбор между моральными ценностями, а не только применение какого-то одного выдающегося морального принципа, ибо глупо верить в то, что, когда значение закона вызывает сомнения, мораль всегда может предложить ясный ответ. В этот момент судьи могут снова сделать выбор, не являющийся ни произвольным, ни механическим, и часто проявляют здесь характерные судебные добродетели, особая пригодность которых для принятия юридических решений объясняет, почему некоторые не испытывают охоты называть такую судебную деятельность «законодательной». Эти добродетели таковы: беспристрастность и нейтральность в изучении альтернатив; учет интересов всех, кто будет затронут решением суда; и забота о том, чтобы использовать некий приемлемый общий принцип как разумную основу для решения. Несомненно, что поскольку всегда могут быть применены несколько таких принципов, то невозможно *продемонстрировать,* что решение суда единственно верное: но оно может быть сделано приемлемым как разумный продукт просвещенного беспристрастного выбора. Во всем этом присутствуют «взвешивающие» и «балансирую-

щие» черты попытки найти справедливость между соперничающими интересами.

Не многие будут отрицать важность этих элементов, которые вполне могут быть названы «моральными», для того чтобы сделать решения приемлемыми: и нечеткие и меняющиеся традиции или каноны интерпретации, которые в большинстве систем правят интерпретацией, часто в достаточно неопределенной форме включают их. Но если эти факты подаются как свидетельство *необходимой* связи права и морали, нам следует помнить, что те же самые принципы столь же часто сопутствовали нарушению, а не соблюдению закона. Ибо — от Остина до наших дней — напоминания о том, что такие элементы *должны* руководить решением, исходили в основном от критиков, находивших, что судейское законотворчество часто было слепым по отношению к социальным ценностям, «автоматическим» или недостаточно обоснованным.

(iv) *Критика права.* Иногда высказывание о том, что существует необходимая связь между правом и моралью, представляет не более чем утверждение, что *хорошая* правовая система должна соответствовать в некоторых отношениях, таких, как те, что уже упомянуты в последнем параграфе, требованиям справедливости и морали. Некоторые могут расценивать это как очевидный трюизм, но это не тавтология, и, на самом деле, в критике права могут быть разногласия в отношении как должных моральных стандартов, так и требуемых аспектов соответствия. Означает ли мораль, которой право должно соответствовать, чтобы быть хорошим, общепринятую мораль той группы, чье это право, даже если эта мораль основывается на предрассудках или лишает своих благ и защиты рабов или подчиненные классы? Или мораль означает просвещенные стандарты в том смысле, что они основываются на рациональных представлениях о фактах и рассматривают всех людей как имеющих право на равное внимание и уважение?

Несомненно, утверждение, что правовая система должна рассматривать всех людей в пределах своего действия как имеющих право на некоторые основные свободы и защиту, сейчас является общепринятым как формулировка идеала, явно значимого в критике права [102]. Даже там, где практика отклоняется от него, за этим обычно следуют заверения на словах в верности этому идеалу. Возможно даже то, что философия может продемонстрировать, что мораль, не принимающая этого воззрения о праве всех людей на равное принятие во внимание, содержит некоторое внутреннее противоречие, догматична или иррациональна. Если так, то просвещенная мораль, признающая эти права, обладает особыми достоинствами истинной морали, а не просто одной из возможных. Это утверждения, которые здесь не могут быть подвергнуты изучению, но даже если признать их правоту, они не могут изменить, и не должны затем-

нять тот факт, что внутригосударственные правовые системы, с их характерной структурой первичных и вторичных правил, долго существовали несмотря на то, что попирали эти принципы справедливости. Что (если хоть что-либо) можно приобрести отрицанием того, что крайне несправедливые правила являются законом, мы рассмотрим ниже.

(v) *Принципы легальности и справедливости.* Могут сказать, что различение хорошей правовой системы, соответствующей в некоторых отношениях принципам морали и справедливости, и правовой системы, им не соответствующей, является ошибочным, поскольку некоторый минимум справедливости с необходимостью реализуется тогда, когда поведение людей управляется общими правилами, публично провозглашенными и применяемыми в судах. Действительно, мы уже указали[1], анализируя идею справедливости, что ее простейшая форма (справедливость в применении закона) состоит не более чем в принятии всерьез идеи о том, что к множеству различных лиц должно применяться то же самое общее правило, не искаженное предрассудком, заинтересованностью или капризом. Эта беспристрастность есть то, для обеспечения чего разработаны процедурные стандарты, известные английским и американским юристам как принципы «естественной справедливости». Поэтому, хотя справедливо могут применяться и самые одиозные законы, в самой по себе идее применения общего правила закона есть, по крайней мере, зачатки справедливости [103].

Дальнейшие аспекты этой минимальной формы справедливости, которая может вполне быть названа «естественной», проявляются в ходе изучения того, что на самом деле подразумевает любой метод социального контроля — правила игры в той же мере, как и право, — состоящий преимущественно из общих стандартов поведения, сообщенных группам лиц, от которых затем ожидается, что они поймут правила и будут следовать им без дальнейших официальных распоряжений. Для того чтобы социальный контроль такого рода мог осуществляться, эти правила должны удовлетворять некоторым условиям: они должны быть доступны пониманию, быть такими, чтобы большинство было в состоянии им подчиняться, и в целом не должны быть ретроспективными, хотя в исключительных случаях такое может быть. Это означает, что те, кого в конце концов наказывают за нарушение правил, в большей части случаев были способны и имели возможность им подчиняться. Прямым образом эти особенности контроля через правила тесно связаны с требованиями справедливости, которые юристы называют принципами легальности. Действительно, один из критиков позитивизма увидел в этих аспектах

[1] См. первый раздел («Принципы справедливости») восьмой главы («Справедливость и нравственность»).

контроля с помощью правил нечто доходящее до необходимой связи между правом и моралью и предложил называть их «внутренней моралью права». Опять же, если в этом заключается значение необходимой связи между правом и моралью, мы можем принять ее. К сожалению, она совместима с очень большой несправедливостью.

(vi) *Юридическая действительность и сопротивление праву.* Немногие теоретики права, отнесенные в разряд позитивистов, как бы неосторожно они ни формулировали свои общие воззрения, постарались бы отрицать те формы связи права и морали, которые мы обсудили в предыдущих пяти параграфах. В чем тогда был смысл великих боевых кличей юридического позитивизма: «Существование закона — это одно; его достоинства или недостатки — другое» [1]; «Закон государства есть не идеал, но нечто реально существующее... Это не то, что должно быть, но то, что есть» [2]; «Правовые нормы могут иметь любое содержание»? [3]

То, чему эти мыслители прежде всего старались способствовать, были ясность и честность при формулировании теоретических и моральных проблем, поднимаемых в связи с существованием отдельных законов, которые были с моральной точки зрения чудовищно несправедливыми, но были приняты в должном виде, ясны по значению и удовлетворяли всем признанным критериям действительности в правовой системе. Их мнение заключалось в том, что, думая о таких законах, и теоретик, и несчастный чиновник или частное лицо, призванные применять или повиноваться им, могут быть только приведены в замешательство приглашением отказать им в праве называться «законами» или «действительными» законами. Они думали, что для того чтобы справиться с этой проблемой, имеются более простые и прямые средства, которые позволят значительно лучше поставить в центр внимания все относящиеся к делу интеллектуальные и моральные соображения: мы должны сказать: «Это закон, но он слишком чудовищный для того, чтобы исполнять его или подчиняться ему».

Противоположная точка зрения кажется привлекательной тогда, когда после революции или иных больших потрясений суды в какой-либо правовой системе должны рассмотреть свое отношение к крайним моральным несправедливостям, совершенным в правовой форме частными или официальными лицами при прежнем режиме. Их наказание может казаться социально желательным, но обеспечить его откровенно ретроактивным законодательством, делающим преступным то, что разрешалось или даже требовалось законами предыдущего режима, может быть

[1] Austin, The Province of Jurisprudence Defined, Lecture V, pp. 184-185.
[2] Gray, The Nature and Sources of Law, p. 213.
[3] Kelsen, General Theory of Law and State, p. 113.

нелегким, а также морально одиозным или, может быть, невозможным делом. В этих обстоятельствах может показаться естественным воспользоваться моральным подтекстом, латентно присутствующим в языке закона, и особенно в таких словах, как *ius, Recht, diritto, droit*[1], которые нагружены теорией естественного права. Тогда может показаться соблазнительным сказать, что законодательные акты, которые предписывали или позволяли крайнюю несправедливость, не должны признаваться действительными или обладающими качествами закона, даже если система, в которой они были приняты, не признавала никаких ограничений законодательной компетенции своей легислатуры. Именно в этом виде аргументация естественного права была возрождена в Германии по завершении последней войны в ответ на острые социальные проблемы, порожденные злодеяниями нацистского правления и его поражением [104]. Должны ли быть наказаны доносчики, которые в личных целях отправляли других в тюрьму за нарушения чудовищных статутов, принятых при нацистском режиме? Возможно ли было вынести им приговор в судах послевоенной Германии на том основании, что эти статуты нарушали естественное право и поэтому были юридически ничтожны, так что тюремное заключение за нарушение этих статутов было на самом деле противозаконным, и способствовать ему само по себе было преступлением?[2] Хотя вопрос кажется простым для тех, кто принимает, и тех, кто отвергает представление о том, что морально чудовищные правила не могут быть законом, спорящие стороны, как кажется, часто очень неясно представляют себе общий характер этого вопроса. Верно то, что здесь мы рассматриваем альтернативные способы сформулировать моральное решение не применять, не повиноваться и не позволять другим использовать при своей защите нравственно чудовищные правила, но проблему плохо представляют как чисто вербальную. Ни одна из сторон спора не удовлетворится, если сказать ей: «Да, вы правы: чтобы правильно выразить на английском (или немецком) языке эту идею, надо сказать то, что вы сказали». Поэтому, хотя позитивист может указать на авторитет английского словоупотребления, демонстрируя, что нет никакого противоречия в утверждении, что закон слишком несправедлив, чтобы ему подчиняться, и что из заявления, что закон слишком несправедлив, чтобы ему подчи-

[1] «Право» по-латыни, по-немецки, по-итальянски и по-французски соответственно. В этих языках, как и в русском, возможно разграничение между «правом» и «законом», в отличие от английского, где существует только одно слово «law». — *Примеч. пер.*

[2] См. решение от 27 июля 1945 г., Oberlandesgericht Bamberg, 5 *Sbddeutsche Juristen-Zeitung,* 207; обсуждается в подробностях в: Hart H. L. A. Legal Positivism and the Separation of Laws and Morals, in 71. *Harvard Law Rev.* (1958) 598, и в: Fuller L. Positivism and Fidelity to Law, ibid., p. 630.

няться, не следует, что это недействительный закон, — их оппоненты вряд ли расценят это как опровержение их дела.

Ясно, что мы не сможем должным образом разобраться с этой проблемой, если будем рассматривать ее как языковую. Ибо то, что на самом деле является объектом дискуссии, это сравнительные достоинства широкого и узкого понимания или способа классификации правил, принадлежащих к системе правил, в целом действующих в общественной жизни. Осмысленный выбор между этими пониманиями должен быть сделан на том основании, что одно из них лучше другого в теоретическом плане, или в объяснении и развитии наших размышлений о морали, или и в том и другом.

Более широкое из этих соперничающих пониманий права включает в себя более узкое. Если мы примем широкое понимание, это приведет нас в наших теоретических исследованиях к тому, чтобы группировать и рассматривать вместе как «право» все правила, которые действительны в силу формальных критериев системы первичных и вторичных правил, даже несмотря на то, что некоторые из них оскорбляют нравственность данного общества или то что мы считаем просвещенной, или истинной, моралью. Принимая узкое понимание, мы должны исключить из «права» такие оскорбляющие нравственность правила. Кажется ясным, что ничто в теоретическом или научном изучении права как социального явления не приобретается путем принятия более узкой концепции: она привела бы нас к исключению некоторых правил даже несмотря на то, что они демонстрируют все другие комплексные характеристики права. Конечно, ничего, кроме путаницы, не может последовать от предложения оставить изучение таких правил другой дисциплине, и, конечно, никакая история права или другие виды юридических исследований не посчитали полезным это сделать. Если мы примем широкое понимание права, мы сможем в рамках его найти место для изучения любых особенностей морально чудовищных законов и общественной реакции на них. Поэтому использование узкой концепции неизбежно приведет к раздроблению и путанице в наших усилиях понять и развитие, и потенциальные возможности особого метода социального контроля, наблюдаемого в системе первичных и вторичных правил. Изучение его употребления включает в себя изучение и злоупотреблений.

Что тогда следует сказать о практических достоинствах узкого понимания права для мышления о морали? В каком отношении лучше, столкнувшись с чудовищными с точки зрения нравственности требованиями, думать: «Это ни в каком смысле не закон», чем «это закон, но слишком чудовищный для того, чтобы ему подчиняться или применять его»? Сделает ли это людей мыслящими более ясно или более готовыми не повиноваться, когда этого требует мораль? Даст ли это лучшие воз-

можности решения таких проблем, как оставленные после себя нацистским режимом? Несомненно, идеи обладают влиянием; но представляется, что попытка обучить людей использовать более узкое понимание юридической действительности, в которой нет места для действительных, но морально чудовищных законов, вряд ли приведет к усилению сопротивления злу пред лицом угроз организованной власти или к более четкому пониманию того, что поставлено на карту, когда требуют повиновения. До тех пор пока часть людей может объединяться ради достижения господства над другими, те или иные формы закона будут использоваться в качестве одного из средств для этого. Порочные люди будут принимать порочные правила, которые другие будут применять. Несомненно, для того чтобы сделать людей проницательными в противостоянии злоупотребления официальной властью, наиболее необходимо, чтобы они сохраняли чувство того, что удостоверение чего-либо как юридически действительного не дает окончательного ответа на вопрос о повиновении, и что как велика ни была бы аура величия или авторитета системы официальной власти, ее требования должны в окончательном итоге подвергаться проверке с точки зрения морали. Это чувство того, что за пределами официальной системы есть нечто, обращение к чему для индивида является последним средством для решения проблемы повиновения, несомненно с большей вероятностью будет живо среди тех, кто привык думать, что законы могут быть крайне несправедливыми, чем среди тех, кто думает, что ничто несправедливое не может иметь статуса закона.

Но, возможно, более сильным основанием предпочесть широкое понимание права, которое позволит нам думать и говорить: «Это закон, но крайне несправедливый», является то, что непризнание несправедливых правил законом может чрезвычайно и необоснованно упростить разнообразие моральных проблем, ими порождаемых. Старые авторы, такие как Бентам и Остин, настаивали на различении того, какое право есть и каким оно должно быть. Они делали это отчасти потому, что считали, что, если не проводить этого разграничения, люди могут, не учитывая урона, который будет нанесен этим обществу, выносить поспешные суждения о том, что законы недействительны и им не следует подчиняться. Но, кроме этой опасности анархии, очень возможно, что преувеличенной, есть и другая форма упрощенчества. Если поставить вопрос более узко и подумать только о человеке, вынужденном *подчиняться* порочным правилам, может показаться безразличным, думает ли он, что сталкивается с действительной нормой «права» или нет, пока он видит ее моральную чудовищность и делает то, чего требует нравственность. Но кроме нравственной проблемы повиновения (должен ли я делать это порочное дело?) есть и сократовский вопрос о подчинении: должен ли я принять наказание за неповиновение

или попытаться избежать его? Есть также и вопрос, с которым сталкивались суды в послевоенной Германии: «Должны ли мы наказывать тех, кто делал дурные дела тогда, когда это разрешалось аморальными правилами, имевшими тогда силу?» Этими вопросами поднимаются очень разные проблемы морали и справедливости, которые надо рассматривать независимо одну от другой. Они не могут быть решены отказом, сделанным раз и навсегда, признавать аморальные законы действительными в каком-либо отношении. Это слишком грубый способ обращения со сложными и деликатными моральными проблемами.

Понимание права, позволяющее отличать недействительность закона от его аморальности, позволяет видеть сложность и разнообразие этих отдельных проблем. В то же время узкое понимание права, отрицающее юридическую действительность несправедливых правил, может сделать нас невосприимчивыми к ним. Можно признать, что доносчики в Германии, в собственных целях добивавшиеся наказания других согласно чудовищным законам, делали то, что запрещает мораль. Но мораль может также требовать, чтобы государство наказывало только тех, кто, творя зло, делал то, что государство в то время запрещало. В этом заключается принцип *nulla poena sine lege*[1]. Если посягательства на этот принцип должны осуществляться для того, чтобы предотвратить нечто, считающееся большим злом, чем пожертвование этим принципом, жизненно необходимо, чтобы затрагиваемые вопросы были ясно обозначены. Случаи ретроактивного наказания не должны преподноситься как обычное наказание за незаконное в то время деяние. В пользу простой позитивистской доктрины о том, что морально чудовищные правила все-таки могут быть правом, по крайней мере может быть сказано то, что она никак не пытается замаскировать выбор между одним и другим злом, который, в крайних обстоятельствах, возможно, придется делать.

[1] Лат. «Нет наказания без закона». — *Прим. пер.*

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

1. ИСТОЧНИКИ СОМНЕНИЙ

Идея единства первичных и вторичных правил, которой было отведено столь важное место в этой книге, может рассматриваться как среднее между юридическими крайностями. Ибо правовая теория иногда искала ключ к пониманию права в простой идее приказа, подкрепленного угрозами, а иногда — в сложной идее нравственности. И с тем и с другим правовая теория определенно имеет многие сходства и связи; однако, как мы видели, существует постоянная опасность их преувеличения, а также затушевывания особых черт, отличающих право от других средств социального контроля. Достоинство той идеи, которую мы приняли в качестве центральной, в том, что она позволяет нам увидеть множественные связи между правом, принуждением и нравственностью такими, как они есть, и рассмотреть снова, в каком, если вообще в каком-либо смысле, они являются необходимыми.

Хотя идея единства первичных и вторичных правил имеет эти достоинства и хотя было бы согласно с этим словоупотреблением трактовать существование этого характерного единства правил как достаточное условие для использования выражения «правовая система», — мы все же не утверждали, что слово «право» должно определяться в этих категориях. Именно потому, что мы не требовали указывать и регулировать таким способом использование слов вроде «право» или «правовой», эта книга предлагается в качестве прояснения *понятия* права, нежели как определение «права», которое, как было бы естественно ожидать, предоставило бы правило или правила для использования этих выражений. В соответствии с этой целью мы исследовали в предыдущей главе утверждение, выдвигавшееся в ходе судебных процессов в Германии, что названия действительного права должны быть лишены определенные правила, вследствие их крайней моральной несправедливости, пусть даже они принадлежат некоторой существующей системе первичных и вторичных правил. В конце главы мы отвергли это утверждение, но сделали это не потому, что оно противоречило тому взгляду, что правила, принадлежащее

такой системе, должно называть «правом», и не потому, что это противоречило весомой традиции такого словоупотребления. Вместо этого мы подвергли критике попытку сузить класс действительных законов путем исключения того, что является морально несправедливым, — на основании того, что это не продвигало и не проясняло как теоретические исследования, так и нравственные рассуждения. В этих целях более широкое понимание, которое хорошо согласуется с обычным употреблением, позволит нам рассматривать правила, какими бы несправедливыми они ни были, как законы, на поверку оказавшиеся неадекватными.

Международное право представляет противоположный случай. Ибо, хотя согласуется с обыкновением последних 150 лет использовать здесь выражение «право», отсутствие международной законодательной власти, судов с принудительной юрисдикцией и централизованных санкций инспирировало опасения, во всяком случае в душе правовых теоретиков. Отсутствие этих институтов означает, что правила для государств напоминают ту простую форму социальной структуры, состоящую только из первичных правил обязанности, которую мы обнаружили среди сообществ индивидов и противопоставили развитой правовой системе. Действительно, существуют аргументы, и мы это покажем, в пользу того, что международное право не имеет не только вторичных правил изменения и суда, которые необходимы для осуществления законодательной власти и судов, но и унифицирующего правила признания, специфицирующего «источники» права и дающего общие критерии для идентификации его правил. Эти отличия действительно разительны, и вопрос: «Действительно ли международное право является правом?» — едва ли можно оставить в стороне [105]. Однако и в данном случае мы не станем развеивать сомнения, знакомые многим, путем простого напоминания о существующем словоупотреблении; равным образом мы не намерены просто подтвердить их, основываясь на том, что единство первичных и вторичных правил есть необходимое и достаточное условие для правильного использования выражения «правовая система». Вместо этого мы подробно исследуем характер возникших сомнений и, как в случае с германскими процессами, спросим себя, затрудняет ли обычное широкое употребление выражения «международное право» достижение какой-нибудь практической или теоретической цели.

Мы посвятим этому сюжету лишь одну главу, однако некоторые авторы предлагали еще более краткое толкование проблем, касающихся характера международного права. Им кажется, что вопрос: «Действительно ли международное право является правом?» — возник или продолжал существовать лишь потому, что тривиальный вопрос о значении слов ошибочно принимался за серьезный вопрос о природе вещей. Так как факты, которые отличают международное право от внутригосударст-

венного, ясны и хорошо известны, единственный вопрос, который надлежит разрешить, заключается в том, следует ли нам соблюдать существующее соглашение или выйти из него; а это такой вопрос, который каждый решает для себя. Но этот краткий путь решения вопроса, конечно, слишком легок. Действительно, среди причин, которые заставили теоретиков колебаться в отношении распространения слова «право» на международное право, некоторую роль сыграл упрощенный и действительно абсурдный взгляд на то, что оправдывает применение одного и того же слова ко многим различным вещам. Разнообразие типологии принципов, которые обычно руководят охватом общих классифицирующих терминов, слишком часто игнорировалось в юриспруденции. Тем не менее источники сомнения относительно международного права более глубоки и более интересны, чем эти ошибочные взгляды на использование терминов. Более того, две альтернативы, предлагаемые этим простым способом разрешения вопроса («Будем ли мы соблюдать существующее соглашение или откажемся от него?»), не исчерпывающие, ибо, помимо них, существует альтернатива эксплицировать и исследовать те принципы, которые в действительности управляют существующим словоупотреблением [106].

Предлагаемый легкий путь действительно был бы уместным, если бы мы имели дело с именами собственными. Если бы некто спросил, является ли место, называемое «Лондон», *действительно* Лондоном, все, что мы могли бы сделать, это напомнить ему о соглашении и позволить ему либо удовлетвориться этим, либо выбрать другое название на свой вкус. Было бы абсурдным в таком случае спросить, следуя какому принципу Лондон был так назван и приемлем ли такой принцип. Это было бы абсурдным, поскольку, в то время как распределение имен собственных покоится *только* на соглашении *ad hoc,* охват общих терминов любой серьезной дисциплины всегда имеет свое основание или логический принцип, хотя может быть и неочевидным то, в чем он заключается. Когда, как в настоящем случае, этот охват подвергается сомнению теми, кто на самом деле говорит: «Мы знаем, что это называется правом, но действительно ли это право?», — то, что требуется (конечно, туманно), — это чтобы этот принцип был эксплицирован и была исследована его правомочность.

Мы рассмотрим два основных источника сомнений относительно правового характера международного права и с ними те шаги, которые теоретики предпринимают для того, чтобы отразить эти сомнения.

Обе формы сомнений возникают из противопоставления международного права праву внутригосударственному, которое рассматривается как ясный, стандартный пример того, что такое право. Первая форма имеет свои корни глубоко в концепции права, фундаментальным обра-

зом состоящего из приказов, подкрепленных угрозами, и противопоставляет характер *правил* международного права правилам внутригосударственного права. Вторая форма сомнений возникает из смутного убеждения, что государства в принципе не могут быть субъектами правовых обязанностей, и противопоставляет характер *субъектов* международного права субъектам внутригосударственного права.

2. ОБЯЗАННОСТИ И САНКЦИИ

Сомнения, которые мы рассмотрим, часто выражаются во вводных главах книг по международному праву в форме вопроса «Как международное право может быть обязывающим («binding»)?» [107] Однако в этой излюбленной форме вопроса есть нечто, очень запутывающее, и прежде чем мы сможем заняться этим, мы должны обратиться к первоочередной вопрос, ответ на который совершенно неясен. Этот первоочередной вопрос таков: Что имеется в виду, когда о целой системе права говорится, что она «обязывающая»? Положение о том, что частное правило системы ограничивает частное лицо, знакомо юристам, и его смысл в достаточной степени ясен. Мы можем перефразировать его как утверждение, что рассматриваемое правило является действительным и подлежащее ему рассматриваемое лицо имеет некоторое обязательство или обязанность. Кроме этого, существуют некоторые ситуации, описываемые более общими утверждениями, выраженными в такой форме. При определенных обстоятельствах мы можем сомневаться, применима ли та или иная правовая система к частному лицу. Такие сомнения могут возникнуть в ситуации правовой коллизии (при конфликте законов) или в международном публичном праве. В первом случае мы можем задаться вопросом, обязывает ли французский или английский закон частное лицо относительно частной транзакции, а в последнем случае мы можем спросить, были ли жители, например оккупированной врагом Бельгии, связаны тем, что правительство в изгнании считало бельгийским правом, или же они были подчинены законам оккупационных властей? Но в обоих случаях эти вопросы являются вопросами о праве, которые возникают *внутри* некоторой системы права (внутригосударственного или международного), и разрешаются отсылкой к правилам или принципам этой системы. Они не задаются вопросом об общем характере этих правил, а только их сфере действия или применимости в данных обстоятельствах к частным лицам или транзакциям. Определенно, вопрос: «Обязывает ли международное право?» и связанные с ним вопросы: «Каким образом международное право может обязывать?» или «Что делает международное право обязывающим?» — это вопросы другого порядка. Они выра-

жают сомнение не относительно применимости, а относительно общего правового статуса международного права; это сомнение будет более прямо выражено в форме: «Можно ли осмысленно и с достоверностью сказать, что такие правила, как эти, порождают обязанности?» Как показывают книжные дискуссии, один источник сомнений по этому пункту заключается просто в отсутствии системы централизованных санкций. Это один пункт противопоставления внутригосударственному праву, правила которого берутся как непререкаемо «обязывающие» и как парадигмы правовой обязанности. Последующая аргументация проста: если по этой причине правила международного права не являются «обязывающими», то совершенно неоправданно всерьез воспринимать их классификацию как права, ибо какими бы толерантными ни были способы общего употребления слов, это слишком большая разница, чтобы не замечать ее. Всякое рассуждение о природе права начинается с принятия того, что его существование по крайне мере делает определенное поведение обязательным.

Рассматривая этот аргумент, мы будем толковать в его пользу любые сомнения, касающихся фактов международной системы. Мы примем, что ни статья 16 Конвенции Лиги Наций, ни глава VII Хартии Организации Объединенных Наций (United Nation Charter) не вводят в международное право чего-либо, что можно было бы приравнять к санкциям внутригосударственного права. Несмотря на Корейскую войну и на то, какую бы мораль ни вывели из суэцкого инцидента, мы будем полагать, что, как бы важно ни было их использование, те правовые положения Хартии ООН, которые предусматривают проведение закона в жизнь, вполне могут быть парализованы с помощью вето, и, должно сказать, существуют лишь на бумаге [108].

Приводить доводы в пользу того, что международное право не является обязывающим ввиду отсутствия организованных санкций, означает молчаливо признавать анализ обязанности, содержащийся в теории о том, что право, в сущности, есть приказы, подкрепленные угрозами. Эта теория, как мы видели, отождествляет «иметь обязанность», или «быть обязанным» с «вероятным претерпеванием санкций или наказаний, налагаемых за неподчинение». Однако, как мы показали, это отождествление искажает роль, которую играют во всей правовой мысли и рассуждениях идеи обязательств и обязанностей. Даже во внутригосударственном праве, где существуют эффективно организованные санкции, мы должны отличать, по различным причинам, указанным в седьмой главе, смысл внешнего предсказательного утверждения «Я буду (ты будешь), вероятно, наказан за неподчинение» от внутреннего нормативного утверждения «Я имею (ты имеешь) обязанность действовать таким образом», которое

оценивает положение частного лица с точки зрения правил, принятых в качестве руководящих образцов поведения.

Верно то, что не все правила порождают обязательства или обязанности; верно и то, что правила, которые делают это, обычно призывают жертвовать в какой-то мере частными интересами и обычно поддерживаются серьезными требованиями соответствовать им и настойчивой критикой отклонений. Но как только мы освобождаемся от предсказательного анализа и от породившей его концепции права как, в сущности, приказа, подкрепленного угрозами, по-видимому, нет хороших оснований в пользу сведения нормативной идеи обязанности к правилам, поддерживаемых организованными санкциями.

Мы должны, однако, рассмотреть другую форму аргументации, более правдоподобную ввиду того, что она не привержена определению обязанности в категориях вероятности санкций, которыми угрожают. Скептик может указать, что во внутригосударственной правовой системе существуют (что мы сами и подчеркивали) определенные положения, которые оправданно называются необходимыми; среди них первичные правила обязанности, запрещающие свободное использование насилия и правила, обеспечивающие официальное использование силы как санкции, за нарушение этого и других правил. Если такие правила и организованные санкции, их поддерживающие, необходимы в этом смысле для внутригосударственного права, не равным ли образом являются они таковыми и в случае международного права? То, что это так, могут утверждать и не настаивая на том, что это следует из самого смысла слов типа «обязывающий» или «обязанность».

Ответ на аргументацию в такой форме должен быть найден в тех элементарных истинах о человеческих существах и их окружении, которые конституируют продолжительное психологическое и физическое устройство (setting) внутригосударственного права. В сообществах индивидов, приблизительно равных по физической силе и уязвимости, физические санкции и необходимы и возможны. Они требуются для того, чтобы те, кто добровольно подчинится ограничениям закона, не были простыми жертвами преступников, которые, в отсутствие таких санкций, пожинали бы плоды уважения закона со стороны других, сами не уважая его. Среди индивидов, живущих в тесном соседстве друг с другом, возможности нанесения ущерба другим посредством обмана, если не прямого нападения, столь велики, а шансы избежать последствий столь значительны, что никакие простые естественные удерживающие факторы в любой, кроме самой простейшей, форме общества, не могли бы быть достаточными для того, чтобы ограничить тех, кто слишком порочен, глуп или слаб для того, чтобы подчиняться закону. Однако из-за того же факта приблизительного равенства и очевидных преимуществ подчине-

ния системе ограничений, никакое сборище преступников, вероятно, не превзойдет по силе тех, кто будет добровольно сотрудничать по поддержанию этой системы ограничений. В таких обстоятельствах, которые конституируют фон внутригосударственного права, санкции успешно могут использоваться против преступников при относительно малом риске: их угроза многое добавит к тому, чем являются естественные удерживающие факторы. Но просто потому, что простые трюизмы, которые хорошо подходят в случае индивидов, мало пригодны в случае государств и фактический фон для международного права настолько отличается от фона национального права, — в случае международного права не существует ни подобной необходимости для санкций (пусть даже желательным будет поддержание ими международного права), ни подобной перспективы их надежного и эффективного использования.

Это так потому, что агрессия между государствами очень непохожа на агрессию между индивидами. Использование насилия между государствами должно быть публичным, и хотя не существует международной полицейской силы, маловероятно, что раздор между агрессором и его жертвой останется их частным делом, как это могло бы произойти в случае убийцы или вора в отсутствие полиции. Начать войну даже для сильнейшей державы — значит пойти на большой риск в отношении последствий, которые редко предсказуемы с обоснованной уверенностью. С другой стороны, из-за неравенства государств не может быть устойчивой уверенности в том, что соединенная мощь тех, кто стоит на стороне международного порядка, обязательно превзойдет силы агрессоров. Следовательно, организация и использование санкций сопряжены с огромным риском, и угроза их мало что добавляет к естественным сдерживающим факторам. На фоне этих совершенно других фактов, международное право развивается в форме, совершенно отличной от формы внутригосударственного права. Если бы не было организованного подавления и наказания преступности, среди населения современного государства можно было бы ожидать постоянного насилия и воровства; но в истории государств разрушительные войны перемежаются долгими годами мира. Эти годы мира ожидаемы только рационально, учитывая риски и угрозы войны и взаимные нужды государств; но годы мира стоят того, чтобы регулировать их с помощью правил, которые отличаются от правил внутригосударственного права, среди прочего еще и тем, что не обеспечивают их проведения в жизнь каким-либо центральным органом. И все же о том, что требуют эти правила, мыслят и говорят как о чем-то обязательном; существует общее давление, направленное на соответствие этим правилам; утверждения и допущения базируются на них, и полагается, что их нарушение оправдывает не только настоятельные требования компенсации, но и репрессалии и контрмеры. Когда этими правилами

пренебрегают, это делается не на том основании, что они необязывающие; вместо этого, делаются попытки скрыть факты. Можно, конечно, сказать, что такие правила эффективны лишь до тех пор, пока они касаются таких проблем, из-за которых государства не расположены сражаться. Это может быть так, и может негативным образом сказаться на важности системы и ее ценности для человечества. И все же уже установленное показывает, что из необходимости организованных санкций во внутригосударственном праве, с его структурой физических и психологических фактов, невозможно вывести простое заключение, что без этих санкций международное право, в его совершенно иных фактических обстоятельствах, не налагает никаких обязанностей, не «обязывает» и, как следствие, не заслуживает названия «право» [109].

3. ОБЯЗАННОСТИ И СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВ

Великобритания, Бельгия, Греция, Россия имеют права и обязанности в соответствии с международным правом и, таким образом, являются его субъектами. Это произвольный пример государств, о которых обычный человек думает как о независимых, а юрист признает их «суверенными» [110]. Одним из наиболее постоянных источников замешательства насчет обязательного характера международного права была трудность, чувствующаяся в принятии или объяснении того факта, что государство, являющееся суверенным, может также быть «связано» международным правом или иметь обязанности в согласии с ним. Эта форма скептицизма, в некотором смысле, более сильная, нежели отрицание того, что международное право не обязывает, поскольку не имеет санкций. Ибо, если однажды международное право будет укреплено системой санкций, то это будет ответом на это отрицание. Но настоящее возражение базируется на радикальной несовместимости, о которой говорится — или чувствуется, что она существует, — в концепции государства, одновременно суверенного и являющегося субъектом права.

Исследование этого возражения включает критический разбор понятия суверенитета, прилагаемого не к законодательной власти или какому-то другому элементу или лицу *внутри* государства, а к самому государству. Когда слово «суверен» появляется в юриспруденции, всегда есть тенденция связывать с ним идею лица над законом, чье слово закон для его подчиненных подданных. Мы видели в ранних главах этой книги, каким плохим руководством является это соблазнительное понятие для структуры внутригосударственной правовой системы; но оно было даже более важным источником замешательства в теории международного права. Конечно, *возможно* думать о государстве так, словно оно разно-

видность Супермена — Существо, по сути своей беззаконное, но являющееся источником права для своих подданных. С шестнадцатого столетия и далее символическое отождествление государства и монарха («L'etat c'est moi»), возможно, поощряло эту идею, которая была сомнительным вдохновением многих политических теорий, так же как и правовых. Но для понимания международного права важно разрушить эти ассоциации. Слово «государство» не есть имя некоторой персоны или вещи, по сути или «по природе» своей находящейся вне закона; это способ отсылки к двум фактам: во-первых, что население, проживающее на определенной территории, живет при той форме организованной власти, которая обеспечивается правовой системой с характерными для нее структурой законодательного органа, судами и первичными правилами; во-вторых, что эта власть обладает не ясно определенной степенью независимости.

Слово «государство», конечно, имеет свою значительную область неопределенности, но то, что было сказано, вполне раскрывает его центральный смысл [111]. Государства, такие, как Великобритания или Бразилия, Соединенные Штаты или Италия и т. д., обладают очень большой степенью независимости и от правового, и от фактического контроля со стороны каких-либо властей или лиц вне их границ и выступают как «суверенные государства» в международном праве. С другой стороны, отдельные государства, являющиеся членами федерального союза, такого, как Соединенные Штаты, подчинены во многих отношениях авторитету и контролю федерального правительства и конституции. Однако, независимость, которую сохраняют даже эти федеративные государства (штаты), велика по сравнению с положением, скажем, английского графства, по отношению к которому слово «государство» («штат») вовсе не используется. Графство может иметь местный совет, исполняющий в своей области некоторые функции законодательного органа, но его скудные полномочия подчинены власти парламента, и, за исключением определенных незначительных аспектов, территория графства подчинена тем же законам и правительству, что и вся остальная страна.

Между этими крайностями существует множество различных типов и степеней зависимости (и, таким образом, и независимости) территориальных единиц, обладающих организованным правительством. Различные колонии, протектораты, сюзеренитеты, подмандатные территории, конфедерации предоставляют увлекательные проблемы для классификации. В большинстве случаев зависимость одной единицы от другой выражается в правовых формах, так что то, чем является закон на территории зависимой единицы, будет по крайней мере в определенных вопросах, полностью зависеть от законотворческой деятельности в другой единице, от которой зависит первая.

В некоторых случаях, однако, правовая система зависимой территории может не отражать своей зависимости. Это может случиться, если она лишь формально независима, и на самом деле через марионеток управляется извне, или же потому, что зависимая территория имеет реальную автономию в своих внутренних, но не внешних делах, и ее зависимость от другой страны во внешних делах не нуждается в закреплении в ее внутреннем праве. Зависимость одной территориальной единицы от другой в этих различных видах не является, однако, единственной формой, в которой ее независимость может быть ограничена. Ограничивающий фактор может быть не властью или авторитетом другой такой единицы, а международной властью, влияющим на единицы, которые одинаково независимы друг от друга. Можно представить множество различных форм международной власти и, соответственно, много различных ограничений независимости государств. Возможности включают, среди многих других, мировую законодательную власть по модели Британского парламента, обладающую не ограниченными правом полномочиями регулировать внутренние и внешние дела всех; федеральную законодательную власть по модели конгресса, с правовой компетенцией заниматься лишь оговоренными делами или с компетенцией, ограниченной гарантиями особых прав составляющих единиц; режим, при котором единственная форма правового контроля состоит из правил, общепринятых как приложимые ко всем; и, наконец, режим, при котором единственная признаваемая форма обязанности является контрактной или самоналагаемой, так что независимость государства правовым образом ограничена лишь посредством собственного акта.

Полезно рассмотреть этот спектр возможностей просто потому, что осознание, что существует много возможных форм и степеней зависимости и независимости, — это шаг по направлению к ответу на утверждение, что поскольку государства суверенны, они *«не могут»* быть подчинены международному праву или быть связанными им, или *«могут»* быть связаны лишь некоторой специфической формой международного права. Ибо слово «суверенность» означает здесь не более чем «независимость»; и, как и последнее, определяется негативно (negative in force): суверенное государство — это государство, *не* являющееся объектом определенных форм контроля, и его суверенность — это та область поведения, в которой оно автономно. Некоторая мера автономности привносится, как мы видели, простым смыслом слова «государство», но утверждение, что автономия *«должна»* быть неограниченной или *«может»* быть ограниченной лишь определенного типа обязательствами, является в лучшем случае утверждением требования, что государства должны быть свободными от всех других ограничений, и в худшем — не подкрепленной разумными доводами догмой. Ибо, если в действительности мы

находим, что среди государств существует данная форма международной власти, суверенитет государств в некоторой степени ограничен, и он присутствует лишь в той мере, в какой это позволяют правила. Следовательно, мы можем лишь знать, какие государства суверенны, и в какой мере они суверенны, когда мы знаем, каковы эти правила. Так же как мы можем знать, свободен ли англичанин или американец и какова степень его свободы только тогда, когда знаем каково английское или американское право. Правила международного права действительно неопределенны и противоречивы во многих отношениях, так что сомнений насчет области независимости остается для государств гораздо больше, нежели сомнений насчет степени свободы гражданина в рамках национального права. Тем не менее эти трудности не подтверждают аргумент a priori, который пытается вывести общий характер международного права из абсолютной суверенности, которая принимается безотносительно к международному праву, как нечто принадлежащее государствам.

Стоит заметить, что некритическое использование идеи суверенитета распространило подобное замешательство в теории и внутригосударственного, и международного права, и в обоих случаях требует аналогичных коррективов. Под ее влиянием нас вели к убеждению, что в каждой национальной правовой системе *должен* быть суверенный законодатель, не подчиненный никаким правовым ограничениям, так же, как и к убеждению, что международное право *должно* быть определенного характера, поскольку государства суверенны и не подлежат правовым ограничениям, кроме как самими установленным. В обоих случаях убежденность в необходимом существовании не ограниченного правом суверена предрешает вопрос, на который мы можем ответить, единственно лишь изучая действительные факты. Вопрос для внутригосударственного права таков: каковы пределы высшей законодательной власти, признаваемой в этой системе? Для международного права: какова максимальная область автономии, которую допускают для государств правила?

Таким образом, простейший ответ на настоящее возражение заключается в том, что оно переворачивает порядок вопросов, подлежащих рассмотрению. Нет способа узнать, какой суверенитет имеют государства, пока мы не узнаем, каковы формы международного права и являются они или нет просто пустыми формами. Большинство юридических дебатов были запутанны, поскольку игнорировался этот принцип, и полезно рассмотреть в свете этого те теории международного права, которые известны как «волюнтаристские» или теории «самоограничения» [112]. Они пытаются примирить (абсолютный) суверенитет государств с существованием обязывающих правил международного права, трактуя все международные обязанности как самоналагаемые, подобно обязательствам, которые возникают из обещания. Такие теории в международном

праве являются двойниками теорий общественного договора в политической науке. Последние искали объяснения тому факту, что индивиды, «по природе» свободные и независимые, связаны, однако, внутригосударственным правом, трактуя обязанность повиноваться закону как возникшую из договора, который связанные им индивиды заключили друг с другом и в некоторых случаях со своими правителями. Мы не будем рассматривать здесь ни хорошо известные возражения против этой теории, когда она воспринимается буквально, ни ее ценность в качестве поясняющей аналогии. Вместо этого мы выведем из ее истории троякий аргумент против волюнтаристских теорий международного права.

Во-первых, эти теории не могут полностью объяснить, каким образом известно, что государства «могут» быть связаны лишь самоналагаемыми обязательствами или почему этот взгляд на их суверенность следует принимать в предварение любому исследованию действительного характера международного права. Есть ли еще что-либо, говорящее в пользу этого представления, кроме как того, что его часто повторяли? Во-вторых, есть нечто несовместное в аргументе, разработанном, чтобы показать, что государства, по причине их суверенности, *могут* быть подчинены или связаны лишь правилами, которые они сами наложили на себя. В некоторых крайних формах теории «самоналожения» соглашения государств или договорные обязательства толкуются как простые декларации их предполагаемого будущего поведения, и неосуществление их не рассматривается как нарушение какого-либо обязательства [113].

Это хотя во многом и противоречит фактам, имеет, по крайней мере, достоинство последовательности, ибо согласуется с простой теорией, что абсолютный суверенитет государств несовместим с обязанностями любого рода, так что, подобно парламенту, государство не может связать себя. Менее крайний взгляд, что государство может налагать обязательства на себя обещанием, соглашением или договором, не согласуется, однако, с теорией, что государства подчинены только правилам, которые они сами наложили на себя. Ибо для того чтобы слова, сказанные или написанные, функционировали в определенных обстоятельствах как обещание, соглашение или договор, и, таким образом, порождали обязательства и даровали права, которые другие могли бы требовать, *правила* должны уже существовать, обеспечивая то, что государство обязано делать все то, что оно соответствующими словами взяло на себя. Такие правила, предполагаемые в самом понятии самоналагаемого обязательства, очевидно, не могут извлечь *свой* обязательный статус из самоналагаемого обязательства подчиняться им.

Действительно, каждое конкретное *действие,* которое данное государство было обязано делать, могло бы теоретически получить свой обязательный характер из обещания; тем не менее это могло бы иметь место лишь в случае, если бы *правило* о том, что обещания и подобные формы

волеизъявления создают обязательства, было применимо к государству независимо от любого обещания. В любом обществе, состоящем ли из индивидов или из государств, необходимым и достаточным условием того, чтобы слова обещания, соглашения или договора порождали обязательства, является то, что правила, обеспечивающие это и специфицирующие процедуру для этих самоограничивающих операций, должны быть общеприняты, хотя и нет необходимости в том, чтобы они были приняты абсолютно каждым. Где они признаны, там индивид или государство, которые разумно используют эти процедуры, тем самым связаны ими, независимо от того, предпочитают они быть связаны или нет. Следовательно, даже эта наиболее волюнтаристская форма социальной обязанности включает некоторые правила, которые связывают независимо от выбора того, кого они связывают, и это, в случае государств, несовместимо с предположением о том, что суверенитет требует свободы от всех таких правил.

В-третьих, существуют факты. Мы должны отличать утверждения a priori, которые мы только что критиковали, что государства *могут* связываться лишь самоналагаемыми обязательствами, от утверждения, что хотя они и могли бы быть связаны другими способами, в другой системе, — в современном международном праве не существует никакой другой формы обязанностей для государств. Возможно, конечно, что система могла бы иметь такую всецело консенсуальную форму, — и отстаивание, и отрицание этого взгляда на ее характер можно найти в трудах юристов, во мнениях судей, даже судей международных судов, и в декларациях государств. Только беспристрастное исследование действительной практики государств может показать, корректен такой взгляд или нет. Действительно, современное международное право является в очень большой степени договорным правом, и были проделаны тщательные попытки показать, что правила, которые, как кажется, связывают государства без их предварительного на то согласия, в действительности покоятся на согласии, хотя оно и могло быть дано «молчаливо» или должно быть «выведено» («inferred*). Хотя не все они являются фикциями, но по меньшей мере некоторые из этих попыток свести все формы международных обязанностей к одной, вселяют то же подозрение, что и понятие «молчаливой команды», которое, как мы видели, было разработано для того, чтобы представить похожее, хотя и более очевидно ложное, упрощение внутригосударственного права.

Подробное рассмотрение утверждения, что все международные обязанности возникают из согласия связанной стороны, не может быть предпринято здесь, однако следует отметить два ясных и важных исключения из этой доктрины. Первое — это случай нового государства [114].

Никогда не подвергалось сомнению, что когда новое, независимое государство возникает, как Ирак в 1932 г. или Израиль в 1948 г., оно связано общими обязанностями международного права, включающего, среди прочих, правила, которые придают связующую силу договорам.

Здесь попытка обосновать международные обязательства нового государство «молчаливым» или «выведенным» согласием кажется полностью избитой. Второй случай — когда государство, присоединяющее территорию или осуществляющее некоторое другое изменение, попадает в первый раз в сферу действия обязанностей, налагаемых теми правилами, которые оно да этого не имело возможности ни соблюдать, ни нарушать, и на которые не было случая дать или не дать согласие. Если государство, первоначально не имевшее доступа к морю, присоединяет морскую территорию, ясно, что этого достаточно, чтобы сделать его подчиненным всем правилам международного права, относящимся к территориальным водам и открытому морю. Кроме этого, существуют более спорные случаи, относящиеся главным образом к воздействию на тех, кто не участвует в общих или многосторонних договорах [115]; но этих двух важных исключений достаточно, чтобы обосновать подозрение в том, что общая теория о том, что все международные обязанности являются самоналагаемыми, была вдохновлена слишком абстрактной догмой и слишком малым уважением к фактам.

4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И МОРАЛЬ

В пятой главе мы рассмотрели простую форму социальной структуры, которая состоит единственно из первичных правил обязанности, и видели, что для всех, кроме мельчайших и наиболее тесно сплоченных и изолированных, обществ она страдает серьезнейшими дефектами. Такой режим должен быть статичным, а его правила изменяться только в результате медленных процессов роста и разложения; идентификация правил должна быть неопределенной, и выяснение факта их нарушения в частных случаях и применение социального давления на преступников должны быть случайными, затратными по времени и слабыми. Мы нашли проясняющим дело думать о вторичных правил признания, изменения и суда, характеризующих внутригосударственное право, как отличных, хоть и связанных с первичными правилами, средствах устранения этих дефектов.

Формально международное право похоже на такой режим первичных правил, даже если содержание его часто изощренных правил весьма не похоже на правила первобытного общества и многие из его понятий, методов и механизмов такие же, как и в современных национальных законодательствах. Очень часто юристы думают, что эти формальные от-

личия между внутригосударственным и международным правом лучше всего могут быть выражены, если классифицировать последнее как «мораль». Но кажется ясным, что отмечать это различие таким образом, означает внести путаницу [116].

Иногда настояние на том, что правила, управляющие отношениями между государствами, являются лишь нравственными правилами, вдохновляется старой догмой о том, что любая форма социальной структуры, не сводимая к приказам, подкрепленным угрозами, может быть лишь формой «морали». Можно, конечно, использовать слово «мораль» таким простым объемлющим образом; используемое так, оно предоставляет концептуальную «корзину для мусора» («wastepaper basket»), куда пойдут правила игр, клубов, этикета, фундаментальных положений конституционного права и международного права вкупе с правилами и принципами, которые мы обычно воспринимаем как моральные, такие, как общие запрещения жестокости, бесчестия и лжи. Возражение против этой процедуры заключаются в том, что между вещами, которые классифицируются как «мораль», существуют такие важные различия и по форме, и по социальным функциям, что столь грубая классификация не может служить никакой мыслимой цели — ни практической, ни теоретической. Внутри категории «мораль», так искусственно расширенной, нам пришлось бы выделять заново старые отличия, которые она затушевывает.

В частном случае международного права существует ряд различных причин для того, чтобы сопротивляться классификации его правил в качестве «морали». Первая причина заключается в том, что государства часто упрекают друг друга в аморальном поведении или хвалят себя или других за то, что живут в соответствии с международной нравственностью. Без сомнения, одна из добродетелей, которую государства могут проявить или не проявить, — это что они живут в согласии с международным правом, но это не означает, что это право является моралью. В действительности оценка поведения государств в категориях нравственности, явно отличается от формулирования утверждений, требований и признаний прав и обязательств, налагаемых правилами международного права. В пятой главе мы перечислили определенные черты, которые можно принять в качестве определяющих характеристик общественной морали: среди них была отличительная форма морального давления, посредством которого моральные правила поддерживаются в первую очередь. Оно состоит не из апелляций к страху, или из угроз возмездия, или из требований компенсации, — а из апелляций к совести, делаемых в ожидании того, что когда лицу, к которому обращаются, напоминают о моральном принципе, который может быть нарушен, чувство вины или стыда может привести его к тому, чтобы оно уважало этот принцип и исправилось.

Требования, порожденные международным правом, не излагаются в таких категориях, хотя, конечно, как в национальном праве, они могут быть даны вкупе с апелляциями к морали. В аргументах, часто технических, которые государства обращают друг другу в спорных делах международного права, преобладают ссылки на прецеденты, договоры и юридические труды. Чаще всего никакого места не отводится рассуждениям о моральной правоте или неправоте, добре или зле. Следовательно, утверждение, что пекинское правительство имеет или не имеет права, по международному праву, изгнать националистические силы с Формозы, очень сильно отличается от вопроса, честно, справедливо ли, или хорошо или плохо с моральной точки зрения поступать так, — и подкрепляется это существенно другими аргументами. Нет сомнений, что в отношениях между государствами существуют возможные компромиссы между тем, что явно является законом, и тем, что явно является нравственностью, аналогично образцам вежливости и учтивости, признаваемым в частной жизни. Такова сфера международного «взаимоуважения», воплощаемого в привилегии, распространяющейся на дипломатических посланников, получения благ, предназначенных для персонального пользования, свободного от таможенных пошлин.

Более важным основанием для различения является следующее. Правила международного права, подобно правилам внутригосударственного права, часто совершенно индифферентны к морали. Правило может существовать, поскольку удобно или необходимо иметь ясное четкое правило относительно вопросов, которых оно касается, а не потому что этому частному правилу придается какая-либо нравственная важность. Оно вполне может быть лишь одним из огромного числа возможных правил, любое из которых работало бы в равной степени хорошо.

Следовательно, правила закона, внутригосударственные или международные, обычно содержат множество конкретных подробностей и проводят произвольные различения, которые были бы непонятны в качестве элементов моральных правил или принципов. Верно то, что мы не должны быть догматичны относительно возможного содержания общественной нравственности: как мы видели в пятой главе, нравственность социальной группы может содержать многое, предписывая то, что может показаться абсурдным или предрассудочным, когда рассматривается в свете современного знания. Таким образом, возможно, хотя и трудно, представить, что люди с общими представлениями, весьма отличающимися от наших, могли бы прийти к тому, чтобы придавать *нравственную* значимость вождению по левой стороне дороги вместо правой или могли бы чувствовать моральную вину в случае нарушения обещания, засвидетельствованного двумя свидетелями, но не чувствовать такой вины, если был всего лишь один свидетель. Хотя такие странные формы нравствен-

ности возможны, все же остается истинным то, что нравственность не может (логически) содержать правила, которые в основном воспринимаются теми, кто подписался под ними, никак не более предпочтительными, чем альтернативы им, и не обладающими никакой самостоятельной важностью. Право, однако, хотя также содержит многое, что обладает нравственной значимостью, может и действительно содержит как раз такие правила и произвольные различения, формальности и в высшей степени конкретные детали, которые будет наиболее трудно понять как часть нравственности. В то же время это не мешает им оставаться естественными и легко понятными чертами права. Ибо одной из типичных функций права, в отличие от морали, является вводить как раз такие элементы для того, чтобы максимизировать определенность и предсказуемость и облегчить доказательство и оценку требований. Внимание к формам и деталям, доведенное до крайности, принесло праву упреки в «формализме» и «легализме»; однако важно помнить, что эти пороки являются преувеличениями некоторых отличительных свойств права.

Именно по этой причине мы как раз и ожидаем, что внутригосударственная правовая система, а не мораль, скажет нам о том, сколько свидетелей необходимо иметь для того, чтобы завещание было действительно, — точно так же мы ожидаем и от международного права, а не от нравственности, что оно скажет нам такие вещи, как количество дней, которое судно воюющей стороны может оставаться в нейтральном порту для заправки или ремонта; как ширина территориальных вод; как методы, которые надлежит использовать для их измерения. Необходимо и желательно, чтобы все эти вещи делали *правила закона,* но пока остается понимание, что эти правила могут в равной мере принимать одну из нескольких форм или важны лишь как одно из многих возможных средств достижения конкретной цели, они остаются отличными от правил, которые имеют статус моральных в личной или общественной жизни. Конечно, не все правила международного права такого формального, произвольного или морально нейтрального типа. Идея здесь только в том, что правила закона *могут,* а правила морали *не могут* быть такого типа.

Разница в характере между международным правом и чем-либо, что мы естественно можем воспринимать как нравственность, имеет и другой аспект. Хотя может оказаться, что действие закона, требующего или запрещающего определенные практики, в конечном счете осуществит перемены в морали группы, понятие законодательной власти, производящей или отменяющей нравственные правила, абсурдно, как мы видели в седьмой главе. Законодательная власть не может ввести новое правило и придать ему статус морального правила по своему велению (fiat, «да будет так»), так же как невозможно теми же средствами придать правилу статус традиции, хотя причины, почему это так, могут не быть одними и

теми же в двух разных случаях. Соответственно, нравственности не просто не хватает или она, по случайности, не имеет законодательного органа: сама идея изменения посредством человеческого законодательного повеления (fiat) противна идее нравственности. Это так потому что мы осознаем нравственность как окончательный образец, по которому оцениваются человеческие действия (законодательные или другие). Контраст с международным правом очевиден. Нет ничего в природе или в функциях международного права, что было бы подобным образом несовместимо с идеей о том, что правила могут быть объектом законодательного изменения; отсутствие законодательного органа можно воспринимать просто как дефект, который однажды исправят.

Наконец, мы можем отметить параллель в теории международного права с аргументом, подвергнутым критике в пятой главе, о том, что даже если частные правила внутригосударственного права и могут конфликтовать с нравственностью, тем не менее система как целое должна покоиться на общераспространенном убеждении, что существует моральная обязанность подчиняться ее правилам, хотя особых исключительных случаях нечто может их перевесить. В дискуссии об «основаниях» международного права часто говорится, что как последнее средство правила международного права *должны* покоиться на убежденности государств, что существует моральная обязанность подчиняться им [117]; однако если это означает более, нежели то, что обязанности, которые они признают, не могут быть проведены в жизнь официально организованными санкциями, то, по-видимому, нет причины принимать это утверждение о моральности международного права. Конечно, возможно помыслить обстоятельства, которые определенно оправдали бы наше мнение, что государство рассматривает некоторый курс поведения, требуемый международным правом, как морально обязательный, и действует по этой причине. Оно могло бы, например, продолжать исполнять обязательства обременительного договора из-за явного вреда для человечества, который последует, если уверенность в договорах будет сильно поколеблена, или из-за ощущения, что единственно честным будет возложить на себя утомительное бремя кодекса, из которого оно, в свою очередь, извлекло пользу в прошлом, когда бремя возлагалось на других. Чьи в точности мотивы, мысли и чувства в таких случаях моральной убежденности надлежит приписать государству — это вопрос, которым нам нет нужды обременять себя здесь.

Но хотя и *может* быть такое чувство моральной обязанности, трудно понять, почему или в каком смысле это *должно* иметь место как условие существования международного права. Очевидно, что в практике государств постоянно уважаются определенные правила даже ценой некоторых жертв; требования формулируются со ссылкой на них; наруше-

ние правил подвергает нарушителя серьезной критике и является поводом к требованиям компенсации или возмездия. Все это, конечно, является элементами, требуемыми для поддержки утверждения, что среди государств существуют правила, налагающие на них обязанности. Доказательство того, что «обязывающие» правила существуют в каком-либо обществе, состоит просто в том, что о них думают, говорят как о таковых, и они функционируют как таковые. Что еще требуется в качестве «оснований», и почему, если требуется что-то еще, оно должно быть основанием моральной обязанности? Конечно, истинным является то, что правила могли бы не существовать или не функционировать в отношениях между государствами, если подавляющее большинство не приняло бы правила и добровольно не кооперировалось для их поддержания. Истинно также и то, что давление, оказываемое на тех, кто нарушил или угрожает нарушить правила, часто относительно слабо и обычно было децентрализованно или неорганизованно. Но, как и в случае индивидов, которые добровольно принимают гораздо более принудительную систему внутригосударственного права, мотивы для добровольной поддержки такой системы могут быть крайне разнообразны. Вполне может быть, что любая форма правового приказа находится в самой здравой форме, когда существует общераспространенное ощущение, что морально обязательно подчиниться приказу. Тем не менее приверженность закону может мотивироваться не этим, а расчетами долгосрочного интереса, или желанием продолжать традицию, или свободной от личных интересов заботой о других. По-видимому, нет хороших оснований идентифицировать что-либо из этого как условие существования права — как среди индивидов, так и среди государств.

5. АНАЛОГИИ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ

Для неискушенного взгляда, формальная структура международного права, не имеющего законодательной власти, судов с принудительной юрисдикцией и официально организованных санкций, кажется весьма отличной от структуры национального права. Оно похоже, как мы сказали, по форме, хотя не по содержанию, на простой режим первичного или обычного права. Несмотря на это некоторые теоретики, в своем стремлении защитить от скептиков право международного права называться «правом», поддались искушению минимизировать эти формальные различия и преувеличить аналогии, которые могут быть найдены в международном праве, с законодательством или другими желательными формальными аспектами внутригосударственного права. Так, утверждалось, что война, заканчивающаяся договором, в результате которого побеж-

денная сторона уступает территорию или принимает обязательства, или принимает некоторую урезанную форму независимости, есть, в сущности, законодательный акт, ибо, как и законодательство, оно есть навязанное правовое изменение [118]. Сейчас немногие были бы впечатлены этой аналогией или подумали бы, что она помогла показать, что международное право имеет равное с внутригосударственным основание называться «правом»; ибо одним из ярких различий между национальным и международным правом состоит в том, что первое обычно не признает действительность соглашений, навязанных силой, — а последнее признает.

Разнообразие других, более респектабельных, аналогий подчеркивалось теми, кто считал, что возможность называться «правом» зависит от них. Тот факт, что почти во всех случаях решение Международного суда и его предшественника, Постоянного суда международной справедливости, было должным образом исполнено участниками, часто акцентируется, как нечто компенсирующее тот факт, что, в противоположность национальным судам, ни одно государство не может предстать перед этими международными трибуналами без его предварительного согласия. Аналогии также находят и между правовым образом регулируемым и официально осуществляемым использованием силы и санкцией национального права — и «децентрализованными санкциями» [119], то есть, когда государство, которое утверждает, что его права, данные международным законодательством, ущемлены другим государством, прибегает к войне или силовому возмездию. Ясно, что здесь есть некоторая аналогия; но ее значение должно оцениваться в свете равным образом очевидного факта, что в то время как внутригосударственный суд имеет принудительную юрисдикцию расследовать правильные и неправильные стороны «самопомощи», и наказывать тех, кто неправомерно прибегнул к ней, — нет международного суда, имеющего подобную юрисдикцию.

Некоторые из этих сомнительных аналогий были, по-видимому, в большой степени усилены обязательствами, которые государства приняли в соответствии с Хартией Организации Объединенных Наций. Но, опять-таки, любая оценка их силы мало стоит, если игнорирует степень, в которой положения Хартии о правовом принуждении, восхитительные на бумаге, парализуются с помощью вето, а также идеологическими делениями и альянсами великих держав. Ответ, даваемый иногда, что положения о правовом принуждении национального права также *могут* быть парализованы общей забастовкой, едва ли убедителен, ибо, сравнивая внутригосударственное и международное право, мы интересуемся тем, что существует в действительности, и невозможно отрицать, что фактическое положение здесь разное.

Однако существует одна предлагаемая формальная аналогия между международным и внутригосударственным правом, которая заслуживает

здесь некоторого рассмотрения. Кельзен и многие современные теоретики настаивают на том, что, подобно национальному праву, международное право обладает и действительно должно обладать «базовой нормой» («basic norm») — или тем, что мы обозначили как правило признания, при ссылке на которую оценивается действительность других правил системы и благодаря которой правила составляют единую систему [120]. Противоположный взгляд состоит в том, что эта структурная аналогия ложна: международное право просто состоит из *набора* отдельных первичных правил обязанности, которые не объединены указанным образом. Это, в обычной терминологии специалистов по международному праву, набор обычных правил, одним из которых является и правило, дающее обязывающую силу договорам. Печально известно, что те, кто предпринимали попытки сформулировать «базовую норму» международного права, натолкнулись на громадные трудности. Кандидаты на это положение включают в себя принцип pacta sunt servanda. Это, однако, было отброшено большинством теоретиков, поскольку представляется несовместимым с тем фактом, что не все обязанности по международному праву возникают из «pacta», как бы широко этот термин ни понимался. Таким образом, он был заменен чем-то менее знакомым: так называемым правилом эстоппель, согласно которому «государствам следует поступать так, как они обычно поступают».

Мы не будем обсуждать достоинства этих и других конкурирующих формулировок базовой нормы международного права; вместо этого мы поставим под вопрос то исходное допущение, согласно которому оно должно содержать такой элемент. Первый и, возможно, последний вопрос, который надлежит задать, таков: почему мы должны делать такое допущение a priori (ибо оно таково и есть) и тем самым заранее судить о действительном характере правил международного права? Ибо, конечно, мыслимо (и, возможно, часто и случалось), что общество может жить посредством правил, налагаемых на его членов как «связывающие», хоть они и воспринимаются просто как набор отдельных правил, не объединяемых каким-либо базовым правилом и не получающих свою действительность от него. Ясно, что простое существование правил не подразумевает существование такого базового правила. В большинстве современных обществ существуют правила этикета, и, хотя мы не думаем о них как о накладывающих обязанности, мы вполне можем говорить о таких правилах как существующих; однако мы не будем искать и не смогли бы найти базовое правило этикета, из которого выводится действительность отдельных правил. Такие правила формируют не систему, а простой набор, и, конечно, когда речь идет о вопросах гораздо более важных, нежели этикет, неудобства этой формы социального контроля значительны. Они уже были описаны в пятой главе. Несмотря на это, если правила в действительности приняты как стандарты

если правила в действительности приняты как стандарты поведения и поддерживаются соответствующими формами социального давления, отличающего обязательные правила, более ничего не требуется, чтобы показать, что они — обязывающие правила, даже если при простых формах социальной структуры у нас нет чего-то, что есть во внутригосударственном: а именно, способа доказательства валидности отдельных правил отсылкой на некоторое высшее правило системы.

Существует, конечно, ряд вопросов, которые мы можем задать относительно правил, конституирующих не систему, а простой набор. Мы можем, например, спросить об их историческом происхождении или о причинных влияниях, которые благоприятствовали росту этих правил. Мы можем также спросить о ценности правил для тех, кто живет по ним, и спросить, рассматривают ли те сами себя как морально обязанных подчиняться им или как подчиняющихся по каким-то другим мотивам. Но существует такой тип вопроса, который мы не можем задать в простейшем случае — хотя и можем задать его в случае системы, обогащенной базовой нормой или вторичным правилом признания, как, например, система внутригосударственного права. В простейшем случае мы не можем спросить: «Из какого высшего положения системы правила получают свою действительность или "обязывающую силу"?» Ибо там не существует такого положения, и оно и не нужно. Следовательно, ошибкой будет полагать, будто базовое правило или правило признания является необходимым вообще условием существования правил обязанности или «обязывающих» правил. Это не необходимость, а роскошь, находимая в развитых социальных системах, чьи члены не просто постепенно приходят к принятию отдельных правил, но принимают заранее общие классы правил, указанных общими критериями валидности. В простейшей форме общества мы должны ждать и смотреть, будет ли правило принято как правило или нет; в системе с базовым правилом признания мы можем сказать до того, как правило в действительности создано, что оно *будет* действительным, *если* соответствует требованиям правила признания.

То же самое можно представить в другой форме. Когда такое правило признания добавляется к простому набору отдельных правил, оно не только привносит с собой преимущества системы и легкость идентификации, но и в первый раз делает возможной новую форму утверждения. Мы имеем в виду внутренние утверждения о действительности правил, ибо мы теперь можем спросить в новом смысле: «Какое положение системы делает это правило обязывающим?» или, на языке Кельзена: «Что внутри системы является причиной ее действительности?» Ответы на эти новые вопросы обеспечиваются базовым правилом признания. Но хотя в простейшей структуре действительность правил не может быть таким

образом доказана отсылкой к какому-либо базовому правилу, это не означает, что есть некоторые вопросы относительно правил, или их обязывающей силы, или действительности, которые остаются необъясненными. Это не тот случай, когда существует некоторая тайна относительно того, почему правила в такой простой социальной структуре обязывают, — которую базовое правило, если только мы смогли бы найти его, разрешило бы. Правила простой структуры, подобно базовому правилу более развитой системы, — обязывающие, если они принимаются и функционируют как таковые. Однако эти простые истины о различных формах социальной структуры легко могут быть затемнены упрямым поиском единства и системы там, где эти желательные элементы фактически невозможно найти.

В самом деле, присутствует некоторый комизм в попытках оформить базовое правило для большинства простых форм социальной структуры, которые существуют без такого правила.

Это как если бы мы настаивали, что голый дикарь *должен* быть на самом деле одет в некоторую невидимую разновидность современной одежды. К сожалению, здесь также присутствует устойчивая вероятность смешения. Мы можем быть убеждены, что необходимо трактовать в качестве базового правила нечто, что является пустым повторением простого факта, что рассматриваемое общество (индивидов или государств) соблюдает определенные стандарты поведения как обязательные правила. Действительно, статус странной базовой нормы будет иметь формула, предложенная для международного права: «Государствам следует поступать так, как они обычно поступают». Ибо она говорит лишь, что принимающий определенные правила, должен также соблюдать правило, что правила должны соблюдаться. Это простое бесполезное удвоение того факта, что набор правил принимается государствами в качестве обязывающих правил.

Снова, как только мы освободили себя от предположения, что международное право *должно* содержать базовое правило, вопрос, на который надлежит ответить, становится вопросом фактическим. Каков действительный характер правил, действующих в отношениях между государствами? Конечно, возможны разные интерпретации наблюдаемых феноменов; но утверждается, что не существует базового правила, предоставляющего общие критерии действительности правилам международного права, и что правила, которые в действительности работают, конституируют не систему, а набор правил, среди которых правила, обеспечивающие обязывающую силу договорам. Верно, что во многих важных вопросах отношения между государствами регулируются многосторонними договорами, и иногда приводятся аргументы в пользу того, что они могут связывать государства, которые не являются их участниками.

Если бы это было общепризнанно, такие договоры действительно были бы законодательными актами и международное право имело бы четкие критерии действительности своих правил. Базовое правило признания могло бы быть тогда сформулировано, и оно представляло бы действительное свойство системы, и было бы чем-то большим, нежели пустой перефразировкой того факта, что набор правил в действительности соблюдается государствами. Возможно, международное право в настоящее время находится на стадии перехода к принятию этой или других форм, которые подвели бы его ближе в структуре к внутригосударственной системе. Если, и когда, этот переход завершится, формальные аналогии, которые нынче слабы и даже обманчивы, приобретут содержание, и последние сомнения скептиков относительно правового «качества» международного права будут тогда развеяны. Пока эта стадия не достигнута, аналогии, конечно же, являются аналогиями по функциям и по содержанию, а не аналогиями по форме. Аналогии по функциям возникают в наиболее чистом виде, когда мы размышляем о том, каким образом международное право отличается от морали, и некоторые из этих отличий мы исследовали в последнем разделе. Аналогии по содержанию [121] состоят в ряде принципов, понятий и методов, которые являются общими и для внутригосударственного, и для международного права и делают методы юристов свободно переносимыми с одного на другое. Бентам, изобретатель выражения «международное право», обосновывал его, просто говоря, что оно «достаточно сходно»[1] с внутригосударственным правом. К этому, возможно, стоит добавить два комментария. Во-первых, что это аналогия по содержанию, а не по форме; и во-вторых, что в этой аналогии по содержанию никакие другие социальные правила не близки настолько внутригосударственному праву, как правила международного права.

[1] Principles of Morals and Legislation, xvii. 25, n. I.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВАМ

Текст этой книги самодостаточен, так что читатель, возможно, предпочтет сначала прочитать каждую главу целиком, а затем уже обратиться к этим примечаниям. Сноски в самом тексте отсылают лишь к источникам цитирования, прецедентам и статутам. Нижеследующие примечания предназначены для того, чтобы обратить внимание читателей на следующее. (1) В них содержатся дальнейшие иллюстрации и примеры, поясняющие общие положения, высказанные в основном тексте; (2) дается дальнейший разбор и критика сочинений, о которых упоминается в тексте; (3) наконец, предлагаются возможные пути для дальнейшего исследования вопросов, обсуждаемых в книге. Ссылки на основной текст даются на главу и раздел, например глава V, раздел 1.

Используются следующие сокращения:

Austin, *The Province*	Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (ed. H. Hart, London, 1954).
Austin, *The Lectures*	Austin, *Lectures on the Philosophy of Positive Law.*
Kelsen, *General Theory*	Kelsen, *General Theory of Law and State.*
BYBIL	*British Year Book of International Law.*
HLR	*Harvard Law Review.*
LQR	*Law Quarterly Review.*
MLR	*Modern Law Review.*
PAS	*Proceedings of the Aristotelian Society.*

Примечание переводчиков. *В оригинальном издании книги примечания отсылают к конкретным страницам печатного издания. В данном переводе мы предпочли непрерывную нумерацию примечаний со ссылками на них в квадратных скобках в тексте книги. Нам представляется, что эта форма позволит читателям лучше ориентироваться в структуре книги. Библиографические ссылки сохранены в той форме, в какой они приводятся автором в оригинале.*

ГЛАВА I

1. Каждая из цитат в тексте из работ Ллевелина, Холмса, Грея, Остина и Кельзена представляет собой парадоксальный или преувеличенный способ выразить отдельные аспекты права, которые, по мнению автора, либо затемнены традиционной правовой терминологией, либо необоснованно игнорировались теоретиками права. В случае с каждым значительным юристом до того, как решить, является ли данное утверждение истинным или ложным в буквальном смысле слова, зачастую полезно сначала выяснить в деталях, какие основания он приводит в поддержку своих утверждений и, во-вторых, какую концепцию или теорию права его утверждение намерено опровергнуть.

Аналогичные парадоксальные или преувеличенные утверждения нередко используются философами для того, чтобы подчеркнуть значение упущенных из виду истин. См. Wisdom J., Metaphysics and Verification ***II*** *Philosophy and Psychoanalysis* (1953); Frank, *Law and the Modern Mind* (London, 1949), Appendix VII («Notes on Fictions*).

Доктрины, высказанные или предполагаемые в каждой из этих цитат, обсуждаются в разделах 2 и 3 главы VII (Holmes, Gray, и Llewellyn); разделах 3 и 4 главы IV (Austin) и в разделе 1 главы III (Kelsen).

2. *Стандартные и пограничные случаи.* Особенности словоупотребления, здесь обсуждаемые, подробнее рассмотрены в разделе 1 главы VII под заголовком «Открытая структура права». Это обстоятельство следует иметь в виду не только при попытке определения таких общих терминов, как «право», «государство», «преступление» и др., но и для характеристики рассуждений, касающихся применения правил, сформулированных в общих категориях, по отношению к конкретным случаям. Среди авторов, которые уделили этому обстоятельству особое внимание, можно упомянуть следующих: Austin, *The Province,* Lecture VI, pp. 202-7, и *Lectures in Jurisprudence* (5th edn., 1885), p. 997 («Note on Interpretation*); Glanville Williams, International Law and the Controversy Concerning the Word «Law» ***II*** *22 SYBIL* (1945), и «Language in the Law» (five articles) ***II*** *61* and *62 LQR* (1945-6). По поводу последнего см. комментарии J. Wisdom в «Gods» и «Philosophy, Metaphysics and Psycho-Analysis*, оба в *Philosophy and Psycho-Analysis* (1953).

3. *Остин об обязанности.* См. *The Province,* Lecture I, pp. 14-18; *The Lectures,* Lectures 22 and 23. Идея обязанности и различие между высказываниями «был должен» и «имел обязанность» в силу принуждения детально рассмотрено во втором разделе главы V. Об анализе Остина см. ниже примечание 13 к главе II.

4. *Правовые и моральные обязанности.* Утверждение, что право лучше всего можно понять через его связь с моралью, рассматривается в

главах VIII и IX. Оно принимает множество различных форм. Иногда в классических и схоластических теориях естественного права это утверждение связывается с положением о том, что фундаментальные моральные различения являются «объективными истинами», которые можно обнаружить рациональными средствами; однако многие другие юристы, в равной мере стремящиеся подчеркнуть взаимозависимость права и морали, не придерживаются этого представления о природе права. См. примечание 93 к главе IX.

5. *Скандинавская теория права и идея обязывающего правила.* Важнейшими работами этой школы для читающих по-английски являются: Hflgerstnmi (1868-1939), *Inquiries into the Nature of Law and Morals* (trans. Broad, 1953) и Olivecrona, *Law as Fact* (1939). Наиболее ясное описание их воззрений на природу правил закона можно найти в Olivecrona, op. cit. Его критика предсказательного анализа юридических правил принимается многими американскими юристами (см. op. cit., pp. 85-8, 213-15) и сопоставима с аналогичной критикой со стороны Кельзена *(General Theory,* pp. 165ff., «The Prediction of the Legal Function*). Имеет смысл рассмотреть, почему эти два юриста приходят к столь различным заключениям о характере юридических правил несмотря на значительное согласие по другим поводам. Критику позиции скандинавской школы см. Hart, review of Hflgerstnrm, op. cit. ***II*** *30 Philosophy* (1955); «Scandinavian Realism* ***II*** *Cambridge Law Journal* (1959); Marshall, «Law in a Cold Climate*// *Juridical Review* (1956).

6. *Скептицизм по поводу правил в американской теории права.* См. главу VII, разделы 1 и 2, где рассматриваются некоторые доктрины, получившие название «юридический реализм».

7. *Сомнения по поводу значения общих понятий.* О случаях, касающихся значения понятий «sign» или «signature», см. 34 Halsbury, *Laws of England* (and edn.), paras. 165-9 и в In the Estate of Cook (1960), 1 AER 689 и упоминаемые там случаи.

8. *Определение.* Современный взгляд на формы и функции определений см. Robinson, *Definition* (Oxford, 1952). Неадекватность традиционного определения *per genus et differentiam* в качестве метода прояснения значения правовых терминов обсуждается Бентамом: *Fragment on Government* (примеч. к главе V, раздел 6); см. Ogden, *Bentham's Theory of Fictions* (pp. 75-104). См. также Hart, «Definition and Theory in Jurisprudence* ***II*** 70 *LQR* (1954) и Cohen and Hart, «Theory and Definition in Jurisprudence* ***II*** *PAS* Suppl. vol. xxix (1955).

Определение понятия «law» см. Glanville Williams, op. cit.; R. Wollheim, «The Nature of Law* ***II*** *2 Political Studies* (1954); Kantorowicz, *The Definition of Law* (1958), esp. Chapter I. О необходимости и проясняющей роли определения терминов даже в тех случаях, когда их повседневное

употребление не вызывает сомнений, см. Ryle, *Philosophical Arguments* (1945); Austin, «A Plea for Excuses* ***II*** 57 *PAS* (1956-7), pp. 15 ff.

9. *Общие понятия и общие качества.* Некритическая вера в то, что, если общее понятие (такое, как право, государство, нация, преступление, благо, справедливость) употреблено корректно, то все случаи, к которым оно применяется, должны разделять некоторые «общие качества», является источником многих заблуждений. Много времени и изобретательности зря потрачено в юриспруденции в бесплодных попытках открыть, с целью определения, общие качества, которые, с этой точки зрения, являются *единственным* оправданием употребления одного и того же слова для обозначения многих различных вещей (см. Glanville Williams, op. cit). Однако важно отметить, что это ошибочное представление о характере общих понятий не обязательно ведет к дальнейшему смешению «вопросов о словах» с вопросами о фактах, как полагает этот автор.

Понимание различных способов связи нескольких случаев употребления того или иного общего термина особенно важно для правовых, этических и политических терминов. Аналогию этому см. Аристотель, *Никомахова этика* I 6 (где показано, как могут соотноситься различные случаи употребления понятия «благо»), Austin, *The Province,* Lecture V, pp. 119-24. О различных отношениях к базовому значению, например понятия «здоровье» см. Аристотель, *Категории* I и примеры в *Топике* I 15, II 9 (о «паронимии»). О концепции «семейного сходства» см. Wittgenstein, *Philosophical Investigations,* i, paras. 66-76. Ср. раздел 1 главы VIII о структуре термина «справедливый». Совет Витгенштейна (op. cit, para. 66) особенно подходит для анализа правовых и политических терминов. Рассматривая определение «игры», он пишет: «Не говори, что *должно* быть что-то общее, иначе они не назывались бы играми, но *взгляни* и *посмотри,* нет ли в них чего-нибудь такого, что было бы общим для них всех. Ибо, рассмотрев их все, ты не увидишь ничего общего для *всех* них, но только сходства, связи и серию подобий».

ГЛАВА II

10. *Разновидности императивов.* Классификация императивов как «приказов, «прошений», «замечаний» и др., которая зависит от многих обстоятельств, таких, как социальная ситуация, отношения сторон и их намерений по поводу применения силы, — это почти неисследованная область. Философские дискуссии по этому поводу в основном касаются: (1) отношения между императивом и индикативным или описательным языком и возможности свести первый к последнему (см. Bohnert, «ТЪе Semiotic Status of Commands* ***II****12 Philosophy of Science* (1945)), или (2) во-

проса о том, существует ли между различными типами императивов дедуктивная связь, и, если да, то какая (см. Hare, «Imperative Sentences* ***II*** 58 *Mind* (1949); *The Language of Morals* (1952); Hofstadter and McKinsey, «The Logic of Imperatives* ***II*** *6 Philosophy of Science* (1939); Hall, *What is Value* (1952), chap. 6; Ross, «Imperatives and Logic* ***II*** *11 Philosophy of Science* (1944)). Исследование этих логических вопросов важно; однако есть большая потребность в различении разновидностей императивов по отношению к контексту, задаваемому социальной ситуацией. Вопрос о том, в каких стандартных ситуациях употребление высказываний в повелительном наклонении может быть классифицировано как «приказ», «прошение», «запрос», «команда», «указание» или «инструкция», является методом не только обнаружения лингвистических фактов, но и способом выявления сходств и различий между всевозможными социальными ситуациями и отношениями, распознаваемых в языке. Понимание всего этого очень важно для изучения права, морали и социологии.

11. *Императивы как выражение желания, чтобы другие действовали определенным образом или воздержались от действий.* Характеризуя стандартный способ употребления повелительного наклонения в языке, следует внимательно отличать случай, когда говорящий просто сообщает о том, что он желает, чтобы другой поступил определенным образом, в качестве информации о себе самом, от случая, когда он говорит с намерением сделать так, чтобы другой действительно поступил указанным образом. Для первого случая обычно будет уместно изъявительное, а не повелительное наклонение (см. об этом разделении: Hflgerstnrm, *Inquiries into the Nature of Law and Morals,* chap. 3, s. 4, pp. 116-26). Стандартная характеристика повелительного наклонения необходима, но не достаточна для того, чтобы выявить намерение говорящего заставить другого поступить так, как он желает; так как необходимо, чтобы говорящий хотел дал понять адресату, что цель его именно такова, и тем самым оказать на него влияние, побуждающее поступить именно так, как говорящий желает. Об этой дополнительной сложности (опущенной в тексте) см. Grice, «Meaning» ***II*** *66 Philosophical Review* (1957) и Hart, «Signs and Words» ***II*** *11 Philosophical Quarterly* (1952).

12. *Ситуация с вооруженным грабителем, приказом и повиновением.* Одной из сложностей, с которой сталкивается каждый, анализирующий общее понятие «императив», является то обстоятельство, что для приказов, команд, просьб и других разнообразных форм императивов не существует общего слова, которое бы точно выразило намерение говорящего, чтобы другой совершил или воздержался от совершения определенного действия; аналогично, нет одного слова и для обозначения совершения или воздержания от совершения этого действия. Все обычные выражения (такие, как «приказы», «требования», «повиновение», «подчинение»)

содержат в себе оттенки тех различных ситуаций, в которых они обычно используются. Даже наиболее бесцветные высказывания, такие, как «сказать кому-то» (telling to), предполагают определенное превосходство одной стороны над другой. Для описания ситуации с вооруженным грабителем мы использовали выражения «приказ» и «повиновение» потому, что выглядит естественным сказать, что грабитель *приказал* служащему отдать ему деньги, а служащий действительно ему *повиновался.* Верно, что абстрактные *существительные* «приказ» и «повиновение» едва ли адекватно описывают эту ситуацию, так как первое предполагает авторитетность отдающего приказ, а последнее нередко расценивается как добродетель. Однако, описывая и критикуя теорию права как приказа, подкрепленного силой, мы использовали эти существительные, так же как и глаголы «приказывать» и «повиноваться», пренебрегая имплицитно заложенными в них смыслами авторитетности или уместности. Это сделано для удобства и не предполагает заранее никакой интерпретации. Как Бентам *(Fragment of Government,* chap. 1, note to para. 12), так и Остин *(The Province,* p. 14) используют термин «повиновение» в этом смысле. Бентам прекрасно осознавал упомянутые здесь сложности (см. *Of Laws in General,* 298 n.a.).

13. *Законы как принуждающие приказы: отношение к доктрине Остина.* Простая модель закона как приказа, подкрепленного угрозой, сконструированная в разделе 2 главы II, отличается от доктрины Остина, изложенной в *The Province,* в следующих отношениях.

(a) Терминология. Фразы «приказ, подкрепленный угрозами» (order backed by threats) и «принуждающие приказы» (coercive orders) используются вместо «команды» по указанным в тексте причинам.

(b) Универсальность законов. Остин (op. cit., p. 19) проводит разграничение между «законами» и «отдельными командами» и утверждает, что команда является законом или правилом, если она «как правило, обязывает к действиям или воздержанию от действий определенного класса» (obliges generally to acts or forbearances of a class). С этой точки зрения команда была бы законом, даже если бы она была обращена сувереном к отдельно взятому лицу и предписывала ему совершать или воздерживаться от определенного класса или типа действий, а не только конкретного действия или ряда различных действий, индивидуально специфицированных. В модели правовой системы, сконструированной в тексте, приказы носят общий характер в том смысле, что они относятся как к классам людей, так и к классам действий.

(c) Страх и обязанность. Остин считает, что данное лицо только тогда связано или обязано, если оно *реально* боится санкции (op. cit., pp. 15, 24, и *The Lectures,* Lecture 22 (5th edn.), p. 444): «Сторона связана или обязана делать или воздерживаться от деяния, потому что ей неприятно зло

и потому что боится его». Однако его основной установкой, по-видимому, является утверждение, согласно которому в действительности достаточно *«малейшего* шанса того, что произойдет незначительное зло», независимо от того, боится ли этого лицо или нет *(The Province,* p. 16). В нашей модели принуждающих приказов мы предполагаем лишь, что должно иметь место *общее убеждение,* что неповиновение может привести к злу, которым угрожают.

(d) Власть и правовая обязанность.. Аналогично, анализируя команды и обязательства, Остин сначала допускает, что автор команд должен обладать действительной властью (be «able and willing*) причинить возможный вред; однако затем он ослабляет это требование, предполагая, что на самом деле достаточно малейшего шанса малейшего зла (op. cit., pp. 14, 16). Об этих двусмысленностях в определении Остином команд и обязательств см. Hart, «Legal and Moral Obligation* ***II*** Melden, *Essays in Moral, Philosophy* (1958) и второй раздел главы V данного исследования.

(e) Исключения. Остин трактует декларативные, разрешающие (например аннулирующие те или иные постановления) и несовершенные законы как исключения из общего определения права в категориях команд (op. cit., pp. 25-9). Это обстоятельство не учитывалось в тексте книги.

(f) Легислатура как суверен. Остин считал, что в демократическом обществе электорат, а не его представители в законодательном органе, конституируют или формируют часть суверенного образования, хотя в Англии единственным проявлением суверенитета электората является назначение представителей и делегирование им всей остальной суверенной власти. И хотя он говорит, что «выражаясь аккуратно», эта позиция верна, он позволяет себе говорить (как это делают все специалисты по конституционному праву), что парламент обладает суверенитетом (op. cit., Lecture VI, pp. 228-35). В тексте этой главы законодательный орган, такой, как парламент, идентифицируется с сувереном; детальный анализ этого аспекта доктрины Остина см. в разделе 4 главы IV.

(g) Уточнение в доктрине Остина и оговорки в ней. В последних главах этой книги детально рассмотрены определенные идеи, которые использовались для защиты теории Остина от его критиков, однако в модели, построенной в данной главе, они не нашли отражения. Эти идеи были высказаны самим Остином в ряде случаев, хотя фрагментарно и несовершенно предвосхитив доктрины последующих авторов, таких как Кельзен. В их число входят понятия «молчаливой» команды (см. главу III, раздел 3, и главу IV, раздел 2); ничтожности как санкции (глава III, раздел 1); доктрина «реального» права как правила, адресованного официальным лицам и предписывающего им применить санкцию (глава III, раздел 1); электората как экстраординарного суверенного законодателя (глава

IV, раздел 4); единства и непрерывности суверенного органа (глава IV, раздел 4). При анализе позиции Остина следует обратить внимание на работу W. L. Morison, «Some Myth about Positivism* ***II*** *68 Yale Law Journal,* 1958, в которой указывается на серьезные заблуждения ранних исследователей Остина. См. также главу 5 книги A. Agnelli, *John Austin alle origini delpositivismo giuridico* (1959).

ГЛАВА III

14. *Разновидности права.* Попытки дать общее определение права затемняют различия в формах и функциях юридических правил различных типов. В данной книге доказывается, что различия между правилами, которые налагают обязанности или обязательства, и правилами, которые облекают властью, имеют принципиальное значение для юриспруденции. Право лучше всего понимать как единство этих двух различных типов правил. К этому сводится основное разграничение типов юридических правил, отмеченное в этой главе, однако кроме того можно и, для некоторых целей, должно провести еще целый ряд разграничений (см. Daube, *Forms of Roman Legislation* (1956), где приводится ясная классификация законов, отражающая их различные социальные функции, о чем нередко свидетельствует лингвистическая форма, в которой они выражены).

15. *Обязанности в уголовном и гражданском праве.* Для того чтобы сфокусировать внимание на различии между правилами, налагающими обязанности, и правилами, облекающими властью, мы пренебрегли многими различиями между типами обязанностей в уголовном праве, равно как и в деликтном и контрактном праве. Некоторые теоретики, впечатленные этими различиями, настаивали на том, что в контракте и деликте «первичные» или «предшествующие» обязательства осуществить или воздержаться от определенного действия (например осуществить действие, о котором достигнута договоренность, или воздержаться от клеветы) иллюзорны, в то время как «подлинными» обязанностями являются лишь те, которые подкреплены требованием возмещения или санкциями, предписывающими уплату компенсации при определенных обстоятельствах, в том числе таких как невозможность выполнить так называемые «первичные» обязательства (см. Holmes, *The Common Law,* chap. 8, критикуется Buckland в *Some Reflections on Jurisprudence,* p. 96, и в «The Nature of Contractual Obligation* ***II*** *8 Cambridge Law Journal* (1944); cf. Jenks, *The New Jurisprudence,* p. 179).

16. *Долг и обязанности (Obligation and duty).* В англо-американском праве эти термины ныне практически синонимичны, хотя, за исключе-

нием абстрактных рассуждений о требованиях права (например при анализе правовых обязанностей в противоположность моральным), говорить об уголовных законах как налагающих обязанности не принято. Слово «обязанность», возможно, чаще всего используется в отношении контрактов и в других случаях, таких как обязанность уплатить компенсацию в случае совершения деликта, когда одно лицо имеет право требовать эту компенсацию от другого определенного лица (право *in personam).* В других случаях чаще говорят об «долге» (duty). Это все, что сохранилось в современном английском праве от римского термина «obligation» как правовых пут *(vinculum juris),* связывающих определенных частные лица (см. Salmond, *Jurisprudence,* 11th edn., chap. 10, p. 260 and chap. 21; см. также главу V, раздел 2).

17. *Правила, дающие власть.* В континентальных правовых системах правила, которые дают правовые полномочия, иногда называются «нормами компетенции» (см. Kelsen, *General Theory,* p. 90 и A. Ross, *On Law and Justice* (1958), pp. 34, 50-9, 203-25). Росс делает различие между частной и социальной компетенцией (а также между частными распоряжениями, такими как контракты, и публичными правовыми актами). Он также замечает, что нормы компетенции не налагают обязанностей. «Норма компетенции сама по себе не является непосредственной директивой, она не предписывает какой-либо процедуры в качестве обязанности <. . .> Сама норма компетенции не говорит, что компетентное лицо обязано осуществлять свою компетенцию» (op. cit, p. 207). И все же, несмотря на проведенное различение, Росс принимает точку зрения, критикуемую в этой главе, согласно которой нормы компетенции можно свести к «нормам поведения», так как оба типа норм следует «истолковывать как директивы судам» (op. cit., p. 33).

Рассматривая нашу критику различных попыток элиминировать различие между этими типами правил, или показать, что эти различия носят внешний характер, следует помнить и о других формах социальной жизни, где это различение представляется важным. В сфере морали неопределенные правила, которые определяют, связано ли данное лицо данным им обещанием, наделяют индивидов ограниченными полномочиями морально законодательствовать, а значит, должны отличаться от правил, которые налагают обязательства *in invitum* (см. Melden, «Оп Promising* ***II*** 65 *Mind* (1956); Austin, «Other Minds» ***II*** PAS Suppl. vol. xx (1946), перепечатано в *Logic and Language,* 2nd series; Hart, «Legal and Moral Obligation* ***II*** Melden, *Essays on Moral Philosophy).* С этой же точки зрения можно исследовать правила любой достаточно сложной игры. Некоторые правила (подобно нормам уголовного права) запрещают, под страхом наказания, определенный тип поведения, например, жульничество или неуважение к судье. Другие определяют юрисдикцию официальных

лиц (судьи, счетчика очков или арбитра); а некоторые определяют, что следует делать, чтобы получать очки (например, забивать гол или совершать забег). Выполнение правил, по которым забивается гол или совершается забег, принципиально важно для победы; невыполнение их лишает очков, и с этой точки зрения «ничтожно». На первый взгляд, перед нами разные виды правил, выполняющие различные задачи в игре. Однако теоретик может заявить, что они могут и должны быть сведены к одному типу либо потому, что отсутствие очков («ничтожность») может быть понято как «санкция» или наказание за запрещенное поведение, либо потому, что все правила могут быть интерпретированы как указания официальным лицам предпринимать определенные действия (например засчитывать очки или удалять игроков с поля) при некоторых обстоятельствах. Однако сведение двух типов правил к одному в данном случае затемняет их природу и подчиняет то, что важно в игре тому, что носит вспомогательный характер. Полезно рассмотреть, как редукционистские правовые теории, критикуемые в данной главе, подобным же образом затемняют различные функции, которые различные типы правил выполняют в социальной жизни, частью которой они являются.

18. *Правила, дающие судебную власть, и дополнительные правила, обязывающие судью.* Различие между этими двумя типами правил остается в силе, хотя одно и то же поведение может *одновременно* трактоваться как превышение полномочий, которое влечет за собой ничтожность судебного решения, так и нарушение обязанности, устанавливаемой специальным правилом, которое предписывает судье не выходить за пределы его юрисдикции. Эта ситуация будет иметь место, если получено предписание, запрещающее судье рассматривать дело, выходящее за пределы его юрисдикции (или же какими-либо другими способами сделать свое решение недействительным), или же в случае, когда за подобное поведение предписано наказание. Точно так же, если в официальной процедуре принимает участие дисквалифицированное лицо, то это может подвергнуть его наказанию, а саму процедуру сделать недействительной. О подобных наказаниях говорится в Local Government Act 1933, s. 76; *Rands v. Oldroyd* (1958), 3 AER 344. Правда, в этом акте устанавливается, что деятельность органа местной власти не должна признаваться недействительной лишь по причине недостаточной квалификации его участников (ib. Schedule III, Part 5 (5).

19. *Ничтожность как санкция.* Остин принимает, хотя и не развивает эту концепцию в *The Lectures,* Lecture 23; см. критику в Buckland, op. cit., chap. 10.

20. *Правила, дающие власть, как фрагменты правил, налагающих обязанности.* Предельный вариант этой теории был разработан Кельзеном в соединении с идеей о том, что первичные правила являются пра-

вилами, предписывающими судам и официальным лицам применять санкции при выполнении определенных условий (см. *General Theory,* pp. 58-63 и — по отношению к конституционному праву — ib., pp. 143-4. «Итак, конституционные нормы — это не независимые полные нормы; они — внутренне присущая часть всех правовых норм, которые должны применять суды и другие органы»). По поводу этой доктрины делается оговорка, что она является всего лишь «статическим», а не «динамическим» представлением права (ib., p. 144). Теория Кельзена также усложняется заявлением, что в случае с правилами, дающими власть частным лицам, например, заключить договор, «вторичные нормы» или обязанности, созданные договором, «не являются лишь вспомогательными конструктами юридической теории» (op. cit., pp. 90, 137). Однако базовые положения теории Кельзена в данной главе не критикуются. Более элементарную версию см. в работах Росса, согласно которому «нормы компетенции являются нормами поведения, сформулированными косвенным образом» (Ross, op. cit., p. 50). Еще более умеренную теорию, в которой все правила сведены к правилам, налагающим обязанности, см. в Bentham, *Of Laws in General,* chap. 16 и Appendices A-B.

21. *Правовые обязанности как предсказания и санкции как налоги (taxes) на поведение.* Обе эти теории описаны у Холмса: Holmes, «The Path of the Law» (1897), in *Collected Legal Papers.* Холмс думал, что идею долга (duty) необходимо отмыть в «цинической кислоте», так как ее часто смешивают с моральным долгом. «Мы наполняем это слово содержанием, извлеченным из сферы морали» (op. cit. 173). Однако концепция юридических правил как стандартов поведения вовсе не обязательно предполагает их идентификацию с моральными стандартами (см. главу V, раздел 2). Критику Холмсовой идентификации долга и «предсказания, что если нехороший человек совершит определенные действия, то будет подвергнут неблагоприятным воздействиям», см. в A. H. Campbell, review of Frank's «Courts on Trial», *13 MLR* (1950); а также главу V, раздел 2, главу VII, разделы 2 и 3.

Американские суды столкнулись с проблемой различения штрафа и налога в связи со статьей 8 раздела I Конституции США, согласно которой право устанавливать налоги принадлежит Конгрессу. См. *Charles C. Steward Machine Co. v. Davis,* 301 US 548 (1937).

22. *Частное лицо как носитель долга и частный законодатель.* См. анализ правоспособности и частной автономии, который проделывает Kelsen, *General Theory,* pp. 90 and 136.

23. *Закон, связывающий законодателя.* Критику императивной теории права на том основании, что в ней приказы и команды применимы только к другим, см. Baier, *The Moral Point of View* (1958), pp. 136-9. Некоторые философы тем не менее признают идею команд, адресованных

себе, и даже используют их при анализе личных моральных суждений (см. Hare, *The Language of Morals,* chaps. 11 and 12 on «Ought»). Об аналогии, проведенной в тексте, между законодательством и обещанием, см. Kelsen, *General Theory,* p. 36.

24. *Обычай и молчаливые команды.* Доктрина, критикуемая в данном месте, восходит к Остину (см. *The Province,* Lecture I, pp. 30-3 и *The Lectures,* Lecture 30). О понятии молчаливой команды и ее использовании для объяснения, согласующегося с императивной теорией признания различных форм права, см. доктрину Бентама об «адаптации» (adoption) и «принятии» (susception): *Of Laws in General,* p. 21; Morison, «Some Myth about Positivism*, *68 Yale Law Journal* (1958); а также главу IV, раздел 2. Критику понятия молчаливой команды см. в: Gray, *The Nature and Sources of the Law,* ss. 193-9.

25. *Императивная теория и интерпретация статутов.* Доктрина, согласно которой законы по своей сути являются приказами и в этом качестве выражением воли или намерения законодателя, открыта для многих возражений кроме тех, которые уже рассмотрены в этой главе. Некоторые критики считают, что именно эта теория отвечает за ошибочное представление о том, с какой целью следует заниматься интерпретацией статутов. В соответствии с этой теорией оказывается, что интерпретация статутов призвана выявить «намерение» законодателя, что упускает из виду как тот факт, что там, где легислатура является сложным искусственным образованием, могут быть трудности не только в том, как найти или предоставить свидетельства ее намерений, но неясно и значение фразы «намерение законодательного органа» (см. Hflgerstnim, *Inquiries into the Nature of Law and Morals,* chap. 3, pp. 74-97, а также о фикции в идее законодательного намерения см. Payne, «The Intention of the Legislature in the Interpretation of Statute*, *Current Legal Problems* (1956); cf. Kelsen, *General Theory,* p. 33, о «воле» законодателя).

ГЛАВА IV

26. *Остин о суверенитете.* Теория суверенитета, рассматриваемая в этой главе, соответствует изложенной им в *The Province,* Lectures V-VI. Его позицию мы истолковываем не просто как формальное определение или абстрактную схему логически возможной правовой системы, но как фактическое утверждение, согласно которому во всех обществах, таких, как Англия или США, где есть право, где-то должен быть суверен с приписываемыми ему Остином атрибутами, хотя это может быть затемнено различными конституционными и правовыми формами. Некоторые теоретики интерпретировали Остина иначе, как не делающего таких факти-

фактических утверждений (см. Stone, *The Province and Function of Law,* chaps. 2 and 6, and especially pp. 60, 61, 138, 155, в которых попытки Остина идентифицировать суверена в различных обществах истолковываются как несущественные отклонения от его основной цели). О критике такого подхода к доктрине Остина см. Morison, «Some Myth about Positivism* ***II*** loc. cit., pp. 217-22. Cf. Sidgwick, *The Elements of Politics,* Appendix (A) «On Austin's Theory of Sovereignty*.

27. *Непрерывность законодательного авторитета по Остину.* Краткие ссылки в *The Province* на лица, которые «становятся суверенами в порядке наследования» (Lecture V, pp. 152-4), наводят на некоторые мысли, но не ясны. Остин, по-видимому, признает, что для того чтобы объяснить непрерывность суверенитета в последовательности сменяющихся лиц, необходимо нечто большее, чем его ключевые понятия «привычное повиновение» и «команды», однако он так и не определил этот элемент отчетливо. В этой связи он говорит о «титуле» и «притязаниях» на наследование, а также о *«законном* титуле», хотя все эти выражения в их нормальном использовании предполагают существование *правила,* регулирующего порядок наследования, а не просто привычку повиноваться сменяющим друг друга суверенам. Объяснение Остином этих терминов, равно как и понятий «родового титула» и «родового модуса» приобретения суверенной власти (op. cit., Lecture V, pp. 145-55) приходится выводить из его доктрины «определенного» характера суверенитета. Здесь он различает случай, когда лицо или лица определяются в качестве суверенов индивидуально, например по имени, и случай, когда они идентифицируются «как отвечающие определенному родовому описанию». Так (в простейшем случае) в наследственной монархии родовым описанием может быть правило: «старший ныне здравствующий потомок мужского рода» некоторого предка; в парламентской демократии таким описанием может быть комплексное правило, определяющее условия, которым должны удовлетворять члены законодательного органа.

По Остину получается, что, когда лицо удовлетворяет такому «родовому» описанию, имеет «титул» или «право» наследовать. Это объяснение в терминах родового *описания* в той форме, как оно представлено у Остина, неадекватно, если только он не имел в виду, что «описание» в данном контексте означает принятое *правило,* регулирующее порядок наследования. Ведь очевидно, что есть разница между случаем, когда каждый из членов общества *фактически* по привычке подчиняется любому тому, кто в данный момент отвечает определенному описанию, и случаем, когда принято правило, согласно которому любой, отвечающий данному описанию, имеет *право* или *титул,* и поэтому ему следует повиноваться. Подобным же образом человек может передвигать фигуры на шахматной доске по привычке, а может делать это, приняв правило, ко-

торое объясняет ему, как *правильно* делать ходы. Для того чтобы было «право» или «титул» наследника, должно быть и правило, объясняющее порядок наследования. Доктрина Остина о родовых описаниях не может встать на место этого правила, хотя она очевидным образом выявляет необходимость его существования. Сходную критику неспособности Остина допустить идею правила, определяющее некоторых лиц в качестве законодателей, см. Gray, *The Nature and Sources of the Law,* chap. 3, esp. ss. 151-7. Рассматривая в Lecture V единство и корпоративные или «коллегиальные» полномочия суверенного органа, Остин допускает ту же ошибку (см. раздел 4 этой главы).

28. *Правила и привычки.* Внутренний аспект правил, о котором здесь говорится, подробнее обсуждается в главе V, разделах 2 и 3, а также в главе VI, разделе 1, и главе VII, разделе 3. См. также Hart, «Theory and Definition in Jurisprudence* ***II*** *29 PAS* Suppl. vol. (1955), pp. 247-50. Подобный же подход развивают Winch, «Rules and Habits» ***II*** *The Idea of a Social Science* (1958), chap. 2, pp. 57-65, chap. 3, pp. 84-94; Piddington, «Malinowski's Theory of Needs» ***II*** *Man and Culture* (ed. Firth).

29. *Универсальное признание фундаментальных конституционных правил.* Комплекс различных подходов к правилам закона со стороны официальных лиц и простых граждан, который включает в себя признание конституций, равно как и существование правовой системы, рассматривается далее в главе V, раздел 2, и главе VI, раздел 2. См. также Jennings, *The Law of the Constitution* (3rd edn.), Appendix 3: «A Note on the Theory of Law».

30. *Гоббс и теория молчаливых приказов.* См. выше, главу III, раздел 3, и примечания к этому месту; см. также Sidgwick, *Elements of Politics,* Appendix A. Отчасти сходную «реалистскую» теорию, согласно которой даже статуты, принятые современным законодательным органом, не являются правом до тех пор, пока они не применены на практике, см. в Gray, *The Nature and Sources of the Law,* chap. 4; J. Frank, *Law and the Modem Mind,* chap. 13.

31. *Правовые ограничения законодательной власти.* В отличие от Остина, Бентам считал, что верховная власть может быть ограничена «явным соглашением» («express convention*), и законы, нарушающие это соглашение, будут ничтожны. См. *A Fragment on Government,* chap. 4, paras. 26, 34-8. Аргумент Остина против возможности правового ограничения власти суверена базируется на исходном допущении, что подлежать такому ограничению значит подчиняться *обязанности* определенного рода: *The Province,* Lecture VI, pp. 254-68. На самом же деле ограничения законодательной власти состоит в *«неспособностях»,* а не в обязанностях (см. Hohfeld, *Fundamental Legal Conceptions* (1923), chap. 1).

32. *Предписания, касающиеся способа и формы законодательной деятельности.* Сложности, с которыми сталкивается каждый, пытающийся отличить их от субстанциональных ограничений законодательной власти, подробнее рассмотрены в главе VII, разделе 4. См. Marshall, *Parliamentary Sovereignty and the Commonwealth* (1957), chaps. 1-6, где проводится исчерпывающее рассмотрение различия между «определением» и «ограничением» полномочий суверена.

33. *Защита конституции и конституционный надзор.* О конституциях, не допускающих конституционного надзора со стороны судебного органа, см. Wheare, *Modern Constitutions,* chap. 7. Здесь рассмотрены конституции Швейцарии (за исключением законодательства кантонов), Третьей республики во Франции, Голландии и Швеции. Отказ Верховного Суда США выносить решения по поводу неконституционности в ситуациях, порождающих «политические вопросы» см. *Luther* v. *Borden, 1* Howard I 12 L. Ed. 581 (1849); Frankfurter, «The Supreme Court» *II 14 Encyclopaedia of the Social Sciences,* pp. 474-6.

34. *Избиратели как «экстраординарный» законодательный орган.* Об использовании этого понятия Остином с целью избежать возражения, что во многих системах обычный законодательный орган подлежит правовым ограничениям, см. *The Province,* Lecture VI, pp. 222-33.

35. *Законодатели как частные лица и законодатели в своем официальном статусе.* Остин нередко проводит различение между законодателями, «рассматриваемыми как отдельные лица» (considered severally), и законодателями «рассматриваемыми в качестве членов, или в их коллегиальном и суверенном качестве» *(The Province,* Lecture VI, pp. 261-6). Однако это различение включает в себя идею правила, регулирующего законодательную деятельность суверена. Остин только намекает на анализ понятия официального или коллегиального качества в неудовлетворительных терминах, такие, как «родовое описание» (generic description). См. примечание к стр. 54 выше.

36. *Ограничения власти вносить изменения.* См. условие (proviso) в статье V Конституции США. Статьи 1 и 20 Базовой Конституции Федеративной Республики Германия (1949) не могут быть вообще изменены, на основе правил изменения, установленных в статье 79 (3). См. также статьи 1 и 102 Конституции Турции (1945).

ГЛАВА V

37. *Обязанность как вероятность исполнения угрозы.* О «предсказывающем» характере обязательств см. Austin, *The Province,* Lecture I, pp. 15-24, и *The Lectures,* Lecture 22; Bentham, *A Fragment on Government,* chap. 5,

esp. para. 6 и примечания; Holmes, *The Path of the Law.* Анализ Остина критикуется в: Hart, «Legal and Moral Obligation*, in Melden, *Essays in Moral Philosophy.* Об общем понятии обязанности см. Nowell-Smith, *Ethics* (1954), chap. 14.

38. *Обязанность как правовые путы (vinculum juris).* См. A. H. Campbell, *The Structure of Stairs Institute* (Glasgow, 1954), p. 31. Термин «долг» («duty») восходит к фр. слову *devoir,* происходящему от лат. *debitum.* Отсюда латентная идея долгового обязательства.

39. *Обязанность и чувство принуждения.* Росс анализирует понятие действительности в аспекте двух составляющих, а именно, эффективности правила и «того, насколько оно воспринимается мотивирующим, то есть социально связывающим». Это включает в себя анализ обязанности в категориях ментального опыта, сопровождающего испытываемые образцы поведения. См. Ross, *On Law and Justice,* chaps. 1-2, и *Kritik der sogenannten praktischen Erkenntniss* (1933), S. 280. Понятие долга в связи с его субъективным восприятием подробно рассматривается в: Hflgerstnrm, *Inquiries into the Nature of Law and Morals,* pp. 127-200, а также Broad, «Hflgerstnim's Account of Sense of Duty and Certain Allied Experiences* ***II*** *26 Philosophy* (1951); Hart, «Scandinavian Realism* ***II*** *Cambridge Law Journal* (1959), pp. 236-40.

40. *Внутренний аспект правил.* Противопоставление внешней предсказывающей точки зрения наблюдателя и внутренней точки зрения участника, принимающего и использующего правила в качестве руководства, проводится, хотя и в других терминах, Dickinson, «Legal Rules. Their Function in the Process of Decision* ***II*** *79 University of Pennsylvania Law Review,* p. 833 (1931). Cf. L. J. Cohen, *The Principles of World Citizenship* (1954), chap. 3. Следует отметить, что с внешней точки зрения, то есть с позиции наблюдателя, который не принимает правила общества, которые он наблюдает, можно сделать целый ряд утверждений различного типа, а именно: (i) он может просто отмечать регулярности поведения тех, кто действует в согласии с правилами, так, как если бы это были только привычки, не указывая на тот факт, что эти паттерны рассматриваются членами общества в качестве стандартов правильного поведения; (ii) кроме того, он может отмечать регулярно повторяющиеся негативные реакции на отклонения от обычных паттернов поведения как нечто обычное, снова не указывая на тот факт, что такие отклонения рассматриваются членами данного общества как основание и оправдание для такой реакции; (iii) он может отмечать не только такие наблюдаемые закономерности поведения и реакции, но также и *тот факт, что* члены общества признают определенные правила в качестве стандарта поведения, равно как и то, что наблюдаемое поведение и реакции рассматриваются *ими самими* как предписанные или оправдываемые правилами.

Важно различать между внешней констатацией того факта, что члены данного общества принимают то или иное правило, и внутренним суждением о правиле, сделанном одним из тех, кто принимает его. См. Wedberg, «Some Problems on the Logical Analysis of Legal Science* ***II*** *17 Theoria* (1951); Hart, «Theory and Definition in Jurisprudence* ***II*** 29 PAS Suppl. vol. (1955), pp. 247-50. См. также главу VI, раздел 1.

41. *Обычные правила в примитивных обществах.* Существовало и существует немного обществ, в которых законодательные и судебные органы и централизованно исполняемые санкции, вообще отсутствовали бы. Исследование случаев, наиболее близких к такому состоянию, см. в Malinowski, *Crime and Custom in Savage Society;* A. S. Diamond, *Primitive Law* (1935), chap. 18; Llewellyn and Hoebel, *The Cheyenne Way* (1941).

42. *Adjudication (присуждение) без организованных санкций.* О первобытных обществах, в которых установлено разрешение споров рудиментарными формами присуждения, хотя централизованно организованной системы санкций, обеспечивающей выполнение этих решений, не существует, см. Evans-Pritchard об «упорядоченной анархии» в *The Nuer* (1940), pp. 117 ff, цитируется в Gluckman, *The Judicial Process among the Barotse* (1955), p. 262. В римском праве развитая система судебного процесса появилась гораздо раньше отлаженного механизма государственных мер для обеспечения исполнения решений по гражданским делам. Вплоть до позднеримского времени истец, выигравший процесс, получал право самостоятельно захватить ответчика или его имущество в случае, если тот не платил долг. См. Schulz, *Classical Roman Law,* p. 26.

43. *Переход от доправового к правовому обществу.* См. Baier, «Law and Custom* in *The Moral Point of View,* pp. 127-33.

44. *Правило признания.* Дальнейший анализ этого элемента правовой системы и его отношение к базовой норме (Grundnorm) Кельзена см. раздел 1 в главе VI, и раздел 5 в главе X, а также соответствующие примечания.

45. *Авторитетные кодификации правил.* Согласно традиции, римский Закон двенадцати таблиц был выгравированы на бронзовых таблицах и выставлен на рыночной площади по требованию плебеев опубликовать «авторитетный» источник права. Из немногочисленных сохранившихся свидетельств можно заключить, что Закон двенадцати таблиц немногим отличался от традиционных правил обычного права.

46. *Контракты, завещания и т. д. как формы выражения законодательной власти.* См., для сравнения, Kelsen, *General Theory,* p. 136, о правовой транзакции как «законотворческом акте».

ГЛАВА VI

47. *Правило признания и «базовая норма» Кельзена.* Одним из центральных тезисов этой книги является утверждение, что основанием правовой системы является не всеобщая привычка повиновения суверену, власть которого правом не ограничена, но некое высшее правило признания, дающее критерии выявления действующих правил системы. Этот тезис отчасти напоминает понятие базовой нормы Кельзена и, еще более точно, недостаточно разработанную концепцию «высших правовых принципов» Салмонда (см. Kelsen, *General Theory,* pp. 110-24, 131-4, 369-73, 395-6, и Salmond, *Jurisprudence,* 11th edn., p. 137 and Appendix I). Однако терминология, принятая в этой книге, отличается от той, которой оперирует Кельзен, так как изложенная здесь теория отличается от теории Кельзена в следующих важных отношениях.

1. Вопрос о том, существует ли правило признания и каково его содержание, то есть каковы критерии юридической действительности данной конкретной правовой системы, в этой книге рассматривается как эмпирический, хотя и сложный вопрос факта. Это положение остается верным несмотря на то, что юрист, действующий в рамках системы, когда утверждает, что некоторое конкретное правило действительно, обычно не *указывает эксплицитно,* но *молчаливо предполагает* тот факт, что правило признания (обращаясь к которому он проверил действенность отдельного правила) существует в качестве признанного правила в рамках данной системы. В случае сомнений то, что предполагается, но остается невысказанным, может быть установлено обращением к фактам, то есть реальной практике судов и официальных лиц, действующих в рамках данной системы и идентифицирующих законы, которые следует применить в том или ином случае. В терминологии Кельзена базовая норма является «юридической гипотезой» (ib. xv), «гипотетичной» (ib. 396), «постулируемым предельным правилом» (ib. 113), «правилом, существующим в сознании юристов» (ib. 116), «допущением» (ib. 396), что затемняет, если не противоречит положению этой книги, согласно которому вопрос о критерии действительности в любой правовой системе является вопросом фата. Он является фактическим вопросом несмотря на то, что касается существования и содержания правила Ср. Ago, «Positive Law and International Law» ***II*** *51 American Journal of International Law* (1957), pp. 703-7.

2. Кельзен говорит о «предположении юридической действительности» базовой нормы. По причинам, обсуждаемым в тексте, ни один вопрос о действительности или недействительности универсально принимаемого правила признания не может быть поставлен в отрыве от вопроса о фактическом существовании такого правила.

3. Базовая норма Кельзена в некотором смысле всегда имеет одно и то же содержание, ибо во всех правовых системах она просто сводится к правилу, согласно которому следует повиноваться конституции или «тем, кто создал первую конституцию» *(General Theory,* pp. 115-16). Это видимое единообразие и простота может вводить в заблуждение. Если конституция, специфицирующая различные источники права, является живой реальностью в том смысле, что суды и официальные лица этой системы действительно идентифицируют закон в согласии с теми критериями, которые она предоставляет, то конституция является признанной и существующей на самом деле. Но в таком случае предположение существования какого-либо иного правила, гарантирующего, что конституции (или тем, кто ее создал) должно подчиняться, было бы излишним удвоением правила. Это особенно ясно проявляется в правовых системах стран, подобных Великобритании, где нет писаной конституции: здесь, как представляется, нет места правилу, «чтобы конституции подчинялись» в дополнение к правилу, согласно которому законы идентифицируются на основании определенных критериев действительности (например, если они являются постановлениями Королевы в Парламенте). Это правило признано само по себе, и вводило бы в заблуждение говорить о правиле, чтобы первому правилу подчинялись.

4. Согласно Кельзену *(General Theory,* pp. 373-5, 408-10) невозможно по логическим основаниям считать определенное правило закона действительным и в то же время признавать в качестве морально обязывающего другое моральное правило, запрещающее поведение, предписываемое правилом закона. Ничего подобного не следует из описания юридической действительности, данного в этой книге. Одной из причин использования термина «правило признания» вместо *«базовой* нормы» было стремление избежать какой-либо приверженности представлениям Кельзена о конфликте между правом и моралью.

48. *Источники права.* Некоторые авторы различают «формальные» или «правовые» от «исторических» или «материальных» источников права (Salmond, *Jurispr* 11th edn., chap. v). Это разделение критикуется Allen, *Law in the Making,* 6th edn., p. 260, однако в целом различение двух смыслов слова «источник» важно (см. Kelsen, *General Theory,* pp. 131-2, 152-3). В одном смысле (материальном или историческом) источник — это просто исторические или причинно-следственные воздействия, которые объясняют существование данного правила закона в данное время и в данном месте. В этом смысле источником некоторых английских законов могло быть римское право, каноническое право или даже нормы народной морали. Но в тех случаях, когда говорится, что источником права является статут, слово «источник» указывает не просто на исторические или каузальные влияния, но отсылает к критериям юридической дейст-

вительности, принятым в данной правовой системе. Факт принятия статута компетентным законодательным органом является *основанием,* по которого данное правило статута является законом, а не просто *причиной* его существования. Различие между историческими причинами появления и основанием валидности данного правила можно провести лишь в рамках той системы, которая включает в себя правило признания, которое определяет условия принятия и отличительные признаки юридически действительного закона (например издание его компетентным органом, обычай или прецедент).

Это строгое различение исторических и каузальных источников с одной стороны, и правовых или формальных с другой, может быть размыто в реальной практике, что заставило таких авторов, как Аллен (ук. соч.), подвергнуть критике само различение. В системах, где статуты являются формальным или юридическим источником права, суд, разбирающий конкретное дело, обязан применить конкретный статут, хотя и обладает значительной свободой интерпретации смысла и языка статута (см. главу VII, раздел 1). Однако иногда судье предоставлены права большие, нежели просто свобода истолкования. В случае, если он считает, что ни один статут или другой формальный источник права не позволяет решить разбираемый случай, он может основать свое решение, к примеру, на тексте *Дигест* или сочинении какого-нибудь известного французского юриста (см., например, Allen, op. cit., 260 f.). Правовая система не *предписывает* использовать эти источники, однако признает подобное поведение судьи совершенно приемлемым. Так что подобные источники являются не просто историческими или причинно-следственными влияниями, так как подобные тексты признаются в качестве хороших оснований для вынесения решения. Возможно, такие источники права следует отнести к категории «допустимых», чтобы отличить их от «необходимых» правовых или формальных источников с одной стороны от исторических или материальных — с другой.

49. *Юридическая действительность и эффективность.* Кельзен проводит различие между эффективностью правового порядка в целом и эффективностью отдельной нормы *(General Theory,* pp. 41-2, 118-22). По его представлению норма действительна тогда, и только тогда, когда принадлежит системе *в целом* эффективной (efficacious). Это же положение он высказывает более туманно, говоря, что эффективность системы в целом — это *conditio sine qua non* (необходимое условие), однако не *conditio per quam* (достаточное условие: *sed quaere)* действенности ее правил. В терминологии данной книги это положение может быть сформулировано так. Общая эффективность системы не является критерием действительности, обеспечиваемым правилом признания данной правовой системы, однако предполагается, хотя и не высказывается явно, что

каждый раз, когда данное правило идентифицируется в качестве действительного правила системы ссылкой на ее критерии действительности, невозможно сформулировать ни одного осмысленного утверждения о действительности, если система в целом не эффективна. В отличие от Кельзена мы считаем, что, хотя эффективность системы является *нормальным контекстом* для утверждений о юридической действительности, тем не менее в особых обстоятельствах, такие утверждения могут быть осмысленными даже и тогда, когда сама система уже неэффективна.

Под заголовком «неупотребимость» (desuetudo) Кельзен обсуждает возможность правовой системы, делающей юридическую действительность правила зависящей от его продолжающейся эффективности. В этом случае эффективность (конкретного правила) была бы частью критерия действительности системы, а не просто «предположением» (op. cit., pp. 119-22).

50. *Действительность и предсказание.* По поводу представления о том, что утверждение о действительности закона есть предсказание будущего поведения судей и мотивирующих их чувств, см. Ross, *On Law and Justice,* chaps. 1-2; и критику: Hart, «Scandinavian Realism* ***II*** *Cambridge Law Journal* (1959).

51. *Конституция с ограниченной возможностью внесения поправок.* См. случаи Западной Германии и Турции и примечание 36 к главе IV.

52. *Конвенциональные категории и конституционные структуры.* О как будто бы полном разделении «закона» и «конвенции» см. Dicey, *Law of the Constitution,* 10th edn., pp. 23 ff.; Wheare, *Modern Constitutions,* chap. 1.

53. *Правило признания: право или факт?* Аргументацию за и против квалификации его как политического факта см. в Wade, «The Basis of Legal Sovereignty* ***II*** *Cambridge Law Journal* (1955), esp. p. 189; Marshall, *Parliamentary Sovereignty and the Commonwealth,* pp. 43-6.

54. *Существование правовой системы, привычки повиноваться и принятие правила признания.* Об опасности упрощения сложного социального явления, которое включает в себя как повиновение обычных граждан, так и признание конституционных правил со стороны официальных лиц, см. главу IV, раздел 1, а также Hughes, «The Existence of a Legal System* ***II*** 55 *New York University LR* (1960), p. 1010, справедливо критикующую в данной связи терминологию, применяемую в Hart, «Legal and Moral Obligation* ***II*** *Essays in Moral Philosophy* (Melden edn., 1958).

55. *Частичное разрушение правового порядка.* Лишь немногие из возможных промежуточных состояний между полным нормальным существованием и отсутствием правовой системы упомянуты в тексте. Революции с правовой точки зрения обсуждаются в Kelsen, *General Theory,* pp. 117 ff., 219 ff, и подробно Cattaneo в *Concetto di Revolutions nella Scienza del Diritto* (1960). Разрыв в функционировании правовой системы в резуль-

тате враждебной оккупации может также выражаться в различных формах, некоторые из которых получили описание в работах по международному праву. См. McNair, «Municipal Effects of Belligerent Occupation* ***II*** *56 LQR* (1941), и теоретическое обсуждение Goodhart в «An Apology for Jurisprudence* ***II*** *Interpretations of Modem Legal Philosophies,* pp. 288 ff.

56. *Эмбриология правовой системы.* Процесс перехода от колонии к доминиону рассмотрен в Wheare, *The Statute of Westminster and Dominion Status,* 5th edn., и является интересной областью изучения для теории права. См. также Latham, *The Law and the Commonwealth* (1949). Этот автор был первым, кто интерпретировал конституционное развитие Британского Содружества в категориях формирования новой базовой нормы с «местными корнями». См. Также: Marshall, op. cit., esp. chap, vii on Canada, and Wheare, *The Constitutional Structure of the Commonwealth* (1960), chap. 4 on «Autochthony».

57. *Отказ от законодательной власти.* См. обсуждение правового эффекта ст. 4 Вестминстерского статута в Wheare, *The Statute of Westminster and Dominion Status,* 5th edn., pp. 297-8; *British Coal Corporation* v. *The King* (1935), AC 500; Dixon, «The Law and the Constitution* ***II*** 57 *LQR* (1935); Marshall, op. cit, pp. 146ff; а также главу VII, раздел 4.

58. *Независимость, не признаваемая родительской (parent) системой.* Об Ирландском Свободном Государстве см. Wheare, op. cit.; *Moore* v. *AG for the Irish Free State* (1935), AC 484; *Ryan* v. *Lennon* (1935), IRR 170.

59. *Фактические утверждения и правовые положения, касающиеся существования правовой системы.* Идея Кельзена (op. cit., pp. 373-83) о возможной связи между внутригосударственным и международным правом («приоритет национального права или приоритет международного права») исходит из предположения, что утверждение о существовании правовой системы *должно* быть правовым утверждением (a statement of law), сделанным с точки зрения одной правовой системы о другой, так что другая система признается юридически действительной и формирующей единую с этой первой систему права. Основанное на здравом смысле утверждение, что внутригосударственное право и международное право представляют собой отдельные правовые системы, включает трактовку утверждения о существовании правовой системы (национальной или международной) как утверждения о факте. Для Кельзена это неприемлемый «плюрализм» (Kelsen, loc. cit.; Jones, «The "Pure" Theory of International Law» ***II****16 BYBIL* 1935), см. Hart «Kelsen's Doctrine of the Unity of Law» ***II*** *Ethics and Social Justice,* vol. 4 of *Contemporary Philosophical Thought* (New York, 1970).

60. *Южная Африка.* Подробнее о важном уроке, который можно извлечь из проблем с конституционным правом в ЮАР, см. Marshall, op. cit., chap. 11.

ГЛАВА VII

61. *Сообщение правил посредством примеров.* Характеристику использования прецедента в этих категориях см. в Levi, «Ап Introduction to Legal Reasoning*, s. 1 ***II*** 75 *University of Chicago Law Review* (1948). Витгенштейн в *Philosophical Investigations* (esp. i, ss. 208-38) делает многие важные замечания об идее обучения и следования правилам. См. об этом Winch, *The Idea of a Social Science,* pp. 24-33, 91-3.

62. *Открытая структура словесно сформулированных правил.* Об идее открытой структуры (open texture) см. Waismann о «вербальности» в *Essays on Logic and Language,* i (Flew edn.), pp. 117-30. Об ее релевантности для юридической аргументации, см. Dewey, «Logical Method and Law» ***II****10 Cornell Law Quarterly* (1924); Stone, *The Province and Function of Law,* chap, vi; Hart, «ТЪеогу and Definition in Jurisprudence* ***II*** *29 PAS* Suppl. vol., 1955, pp. 258-64, and «Positivism and the Separation of Law and Morals» ***II****11 HLR* (1958), pp. 606-12.

63. *Формализм и концептуализм.* Близкими синонимами для этих выражений являются такие высказывания, встречающиеся в правовой литературе, как «механическая» или «автоматическая» юриспруденция, «юриспруденция концепций», «чрезмерное использование логики». См. Pound, «Mechanical Jurisprudence* ***II*** *8 Columbia Law Review* (1908) и *Interpretations of Legal History,* chap. 6. Не всегда ясно, о каком именно пороке говорится в этих категориях. См. Jensen, *The Nature of Legal Argument,* chap. 1 и рецензия Нопогй ***II****14 LQR* (1958), p. 296; Hart, op. cit. ***II*** *71 HLR,* pp. 608-12.

64. *Правовые стандарты и конкретные правила.* Наиболее ясное общее обсуждение особенностей и взаимосвязи между этими двумя формами правового контроля см. Dickinson, *Administrative Justice and the Supremacy of Law,* pp. 128-40.

65. *Правовые стандарты, создаваемые административным нормотворчеством (rule-making).* В США федеральные управляющие агентства, такие, как Межштатная комиссия по коммерции (the Interstate Commerce Commission) и Федеральная торговая комиссия (the Federal Trade Commission), создают правила, обеспечивающие общие стандарты «честной конкуренции», «справедливых и разумных цен» и т. д. (См. Schwartz, *An Introduction to American Administrative Law,* pp. 6-18, 33-7.) В Англии подобная нормотворческая функция осуществляется органами исполнительной власти, хотя обычно квазиюридическая практика выслушивания мнения заинтересованных сторон, характерная для США, не практикуется. Ср. Welfare Regulations, установленные в соответствии со статьей 46 Factories Act 1957 и Building Regulations, установленные статьей 60 того же акта. Власть, данная по Transport Act 1947 Транспортному трибуналу

(Transport Tribunal) устанавливать «систему оплаты» после выслушивания заинтересованных сторон, более похожа на американскую модель.

66. *Стандарты заботы (саге).* Ясный анализ составляющих обязанности заботы см. в мнении Learned Hand J. ***II*** *US* v. *Carroll Towing Co.* (1947), 159 F 2nd 169, 173. О желательности замены общих стандартов конкретными правилами см. Holmes, *The Common Law,* Lecture, 3, pp. 111-19, и критику Dickinson, op. cit., pp. 146-50.

67. *Контроль с помощью конкретных правил.* Об условиях, делающих строгие и быстрые правила, а не гибкие стандарты подходящей формой контроля, см. Dickinson, op. cit., pp. 128-32, 145-50.

68. Прецедент и законотворческая деятельность судов. Современный общий очерк английской практики использования прецедента см. в R. Cross, *Precedent in English Law* (1961). Хорошо известную иллюстрацию процесса сужения, о которой упоминается в тексте, см. в *L. & S. W. Railway Co.* v. *Gomm* (1880), 20 Ch.D. 562, сужения правила— *Tulk* v. *Moxhay* (1848), 2 Ph. 774.

69. *Разнообразные формы скептицизма по поводу правил.* Американские сочинения по этому вопросу лучше всего выясняются из ведущейся полемики. Так, аргументы, высказанные Франком (Frank) в *Law and the Modem Mind* (esp. chap. 1 и Appendix 2, «Notes on Rule Fetishism and Realism*), и Llewellyn, *The Bramble Bush,* следует изучать в свете Dickinson, «Legal Rules: Their Function in the Process of Decision* ***II*** *79 University of Pennsylvania Law Review* (1931); «The Law behind the Law» ***II*** *29 Columbia Law Review* (1929); «The Problem of the Unprovided Case» ***II*** *Recueil d'LItudes sur les sources de droit en I'honneur de F. Geny,* 11 chap. 5; и Kantorowicz, «Some Rationalism about Realism* ***II****43 Yale Law Review* (1934).

70. *Скептик как разочаровавшийся абсолютист.* См. Miller, «Rules and Exceptions* ***II*** *66 International Journal of Ethics* (1956).

71. *Интуитивное применение правил.* См. Hutcheson, «The Judgment Intuitive*; «The Function of the "Hunch" in Judicial Decision* ***II*** *14 Cornell Law Quarterly* (1928).

72. *«Конституция— это то, что о ней говорят судьи» («The constitution is what the judges say it is»).* Это высказывание приписывается члену Верховного Суда США Хьюджу (Hughes) в Hendel, *Charles Evan Hughes and the Supreme Court* (1951), pp. 11-12. См., однако: C. E. Hughes, *The Defense Court of the United States* (1966 edn.), pp. 37, 41, об обязанностях судей интерпретировать Конституцию независимо от личных политических взглядов.

73. *Альтернативный анализ суверенитета парламента.* См. H. W. R. Wade, «The Basis of Legal Sovereignty* ***II*** *Cambridge Law Journal* (1955), критика в Marshall, *Parliamentary Sovereignty and the Commonwealth,* chaps. 4-5.

74. *Суверенитет парламента и божественное всемогущество.* См. Mackie, «Evil and Omnipotence* ***II*** *Mind,* 1955, p. 211.

75. *Связывание или переопределение (redefining) парламента.* Об этом различении см. Friedmann, «Trethowan's Case, Parliamentary Sovereignty and the Limits of Legal Change* ***II*** *24 Australian Law Journal* (1950); Cowen, «Legislature and Judiciary* ***II*** *16 MLR* (1952), и *16 MLR* (1953); Dixon, «The Law and the Constitution* ***II*** 57 *LQR* (1935); Marshall, op. cit, chap. 4.

76. *Парламентские Акты 1911 и 1949 гг.* Об истолковании этих актов как авторизующих форму делегированного законодательства см. H. W. R. Wade, op. cit., и Marshall, op. cit, pp. 44-6.

77. *Вестминстерский статут, ст. 4.* Авторитетное толкование этого положения гласит, что эта статья не может представлять собой неоспоримое необратимое прекращение власти создавать законодательство для доминиона без его согласия. См. *British Coal Corporation* v. *The King* (1935), AC 500; Wheare, *The Statute of Westminster and Dominion Status,* 5th edn., pp. 297-8; Marshall, op. cit., pp. 146-7. Противоположная точка зрения, согласно которой «свобода, единожды данная, не может быть отобрана», выражена судом Южной Африки в *Ndlwana* v. *Hofmeyr* (1937), AD 229 at 237.

ГЛАВА VIII

78. *Справедливость как особый раздел морали.* Аристотель в *Никомаховой этике* (V 1-3) демонстрирует, что справедливость особенно касается достижения или восстановления баланса или пропорции (analogia) между лицами. Лучший современный очерк идеи справедливости см. в Sidgwick, *The Method of Ethics,* chap. 6, и Perelman, *De la Justice* (1945), за которым следует Ross, *On Law and Justice,* chap. 12. Очень интересно историческое исследование Del Vecchio, *Justice,* рецензия Hart ***II*** *28 Philosophy* (1953).

79. *Справедливость как применение права.* Искушение полностью свести идею справедливости к этому, возможно, объясняет положение Гоббса, согласно которому «ни один закон не может быть несправедливым» *(Leviathan,* chap. 30). Остин в *The Province,* Lecture VI, p. 260 п. считает, что «справедливый — это понятие относительное» и «употребляется в отношении к определенному закону, который говорящий считает образцом для сравнения». Так что, по его представлению, закон может быть несправедливым с моральной точки зрения, если его сравнить с позитивной моралью или законом Бога. По мнению Остина, Гоббс всего лишь имел в виду, что закон не может быть несправедливым с *правовой* точки зрения.

80. *Справедливость и равенство.* Поучительное обсуждение статуса принципа о том, что prima facie люди должны считаться равными, и его связи с идеей справедливости, см. в Benn and Peters, *Social Principles and the Democratic State,* chap. 5, «Justice and Equality*; J. Rawls, «Justice as Fairness* *II Philosophical Review* (1958); Raphael, «Equality and Equity* *II 21 Philosophy* (1946); «Justice and Liberty* *II* 51 *PAS* (1951-2).

81. *Аристотель о рабстве.* См. *Политику* (I, 3-22). Он считал, что некоторые из рабов не были таковыми «по природе», так что для них рабское состояние несправедливо и неприемлемо.

82. *Справедливость и компенсация.* Этот тип справедливости ясно отличался у Аристотеля от справедливости распределения *(Никомахова этика* V, 4), хотя объединяющий принцип, согласно которому во всех приложениях идеи справедливости должна быть соблюдена или восстановлена «справедливая» или подобающая пропорция (analogia), также неоднократно подчеркивался. См. H. Jackson, *Book* 5 *of the Nicomachean Ethics* (Commentary: 1879).

83. *Правовая компенсация за вмешательство в частную жизнь.* Аргументацию в пользу того, что закон должен уважать частную жизнь, и что принципы обычного права требуют ее признания, см. в Warren and Brandeis, «The Right to Privacy* *II 4 HLR* (1890) и особое мнение Грея: Gray J. *II Roberson* v. *Rochester Folding Box Co.* (1902), 171 NY 538. Английское деликтное право не защищает частную жизнь как таковую, в то время как в США она сейчас широко защищается. Об английском праве см. *Tolleyv.J. S. Fry and Sons Ltd.* (1931), AC333.

84. *Конфликт в плане справедливости между индивидами и более широкими общественными интересами.* О строгой и замещающей ответственности в деликтном праве см. главы 10-11 книги Поссера (Prosser, *Torts)* и пятую главу Friedmann, *Law in a Changing Society.* Обоснование необходимости строгой ответственности за преступление см. в Glanville Williams, *The Criminal Law,* chap. 7; Friedmann, op. cit., chap. 6.

85. *Правосудие и «общее благо».* См. Benn and Peters, *Social Principles and the Democratic State,* chap. 13, где поиск общего блага идентифицируется со справедливыми действиями или беспристрастным соблюдением интересов всех членов общества. Такое отождествление «общего блага» и справедливости признается не всеми. См. Sidgwick, *The Method of Ethics,* chap. 3.

86. *Моральные обязательства.* О необходимости различать долг и обязанности общественной нравственности от моральных идеалов и личной морали см. Urmson, «Saints and Heroes» *II Essays on Moral Philosophy* (Melden ed.); Whiteley, «On Denning "Morality"* *II 20 Analysis* (1960); Strawson, «Social Morality and Individual Ideal* *II Philosophy* (1961); Bradley, *Ethical Studies,* chaps. 5-6.

87. *Мораль социальной группы.* Остин в *The Province* использует выражение «позитивная мораль» для того, чтобы отличить реальную мораль, наблюдаемую в обществе, от «божественных законов», которые, по его представлению, выражают высшие стандарты, при помощи которых можно проверять как позитивную мораль, так и позитивное право. В результате отмечается очень важное различие между социальной моралью и теми моральными принципами, которые выходят за ее пределы и могут быть использованы для ее критики. Однако «позитивная мораль» Остина включает в себя все правила, отличные от позитивного права; в нее входят правила этикета, игр, клубов, международного права, а также все то, о чем обычно говорят и думают как о морали. Такое расширение термина затемняет слишком многие важные различия в ее формах и социальных функциях (см. главу X, раздел 4).

88. *Существенные правила.* См. главу IX, раздел 2, где говорится о правилах, ограничивающих насилие и предписывающих уважение к частной собственности и обещаниям, которые создают «минимальное содержание» естественного права, лежащего в основании как позитивного права, так и социальной морали.

89. *Право и внешнее поведение.* Критикуемая в тексте идея о том, что право предписывает внешнее поведение, в то время как мораль — нет, унаследовано юристами от кантовского различения легальных и моральных законов. См. общее введение к «Метафизике морали» в Hastie, *Kant's Philosophy of Law* (1887), pp. 14, 20-4. Современная формулировка этой доктрины содержится в работе Kantorowicz, *The Definition of Law,* pp. 43-51, критикуемой в Hughes, «The Existence of a Legal System* ***II*** *35 New York University LR* (1960).

90. *Mens rea и объективные стандарты.* См. Holmes, *The Common Law,* Lecture 11; Hall, *Principles of Criminal Law,* chaps. 5-6; Hart, «Legal Responsibility and Excuses* ***II*** *Determinism and Freedom* (ed. Hook).

91. *Оправдание (justification) и извинение (excuse).* О различии этих терминов в уголовном праве см. Kenny, *Outlines of Criminal Law* (24th edn.), pp. 109-16. О важности различения в целом см. Austin, «A Plea for Excuses* ***II*** 57 *PAS* (1956-7); Hart, «Prolegomenon to the Principles of Punishment* ***II*** *60 PAS* (1959-60), p. 12. Подобное различение проводит и Бентам: *Of Laws in General,* pp. 121-2 (об «освобождении от ответственности» («exemption») и «оправдывающем обстоятельстве» («exculpation»).

92. *Мораль, человеческие потребности и интересы.* О том, что критерием для называния правила моральным, является то, что оно есть результат разумного и непредубежденного рассмотрения интересов заинтересованных лиц, см. Benn and Peters, *Social Principles of the Democratic State,* chap. 2. Сравни: Devlin, *The Enforcement of Morals* (1959).

ГЛАВА IX

93. *Естественное право.* Существование обширной литературы о классических, схоластических и современных доктринах естественного права, а неясности, связанные с выражением «позитивизм» (см. ниже) нередко не дают возможности понять, что именно обсуждается при противопоставлении естественного права и юридического позитивизма. В тексте была предпринята попытка выявить один из таких вопросов. Однако чтение только вторичных источников может мало что дать для рассмотрения этой проблемы. Некоторое знание терминологии и философских предпосылок первоисточников совершенно необходимо. Элементарный минимум можно извлечь из следующего набора текстов: Аристотель, *Физика* II 8; Фома Аквинский, *Сумма теологии,* вопросы 90-7 (см., например, в переводе D'Entreves, *Aquinas: Selected Political Writings,* Oxford, 1948); Гроций, *О праве войны и мира: Пролегомены* (The Classics of International Law, vol. 3, Oxford, 1925); Blackstone, *Commentaries,* Introduction, s. 2.

94. *Юридический позитивизм.* Термин «позитивизм» в современной англо-американской литературе используется для обозначения одного или нескольких из следующих утверждений: (1) что законы— это команды, отданные людьми; (2) что нет необходимой связи между правом и моралью, или правом каким оно должно быть и правом как оно есть на самом деле; (3) что анализ смысла правовых понятий важен сам по себе и может быть отделен (но вовсе не обязательно противопоставлен) историческим и социологическим исследованиям правовых институтов, равно как и критической оценке права с точки зрения морали, социальных целей, функций и др.; (4) что правовая система — это «закрытая логическая система», в которой правильные решения могут быть выведены на основании предустановленных правил средствами одной логики; (5) что моральные суждения не могут, в отличие от высказываний о фактах, быть установлены на основе рациональных рассуждений, свидетельств и доказательств (нон-когнитивизм в этике).

Бентам и Остин придерживались воззрений, выраженных в положениях (1), (2) и (3), однако не принимали (4) и (5); Кельзен признавал положения (2), (3) и (5), однако отрицал (1) и (4). Положение (4) часто приписывается «аналитическим юристам», однако, по всей видимости, без достаточных оснований.

В континентальной традиции выражение «позитивизм» часто используется для общего опровержения утверждения о том, что некоторые принципы или правила человеческого поведения могут быть открыты средствами одного разума. Ценное обсуждение проблемы неопределен-

ности термина «позитивизм» см. в Ago, op. cit. ***II*** 57 *American Journal of International Law* (1957).

95. *Милль о естественном праве.* См. его эссе о природе в *Nature, the Utility of Religion and Theism.*

96. *Блэкстоун и Бентам о естественном праве.* Blackstone, loc. cit., и Bentham, *Comment on the Commentaries,* ss. 1-6.

97. *Минимальное содержание естественного права.* Эта эмпирическая версия естественного права основывается Hobbes, *Leviathan,* chaps. 14 -15, и Hume, *Treatise of Human Nature,* Book III, part 2; esp. ss. 2 and 4-7.

98. *Гекльберри Финн.* Роман Марка Твена является глубоким исследованием моральной дилеммы, порожденной наличием общественной морали, которая противоречит личным симпатиям индивида и гуманности. Это является ценной поправкой к идентификации всей морали с последним.

99. *Рабство.* Высказывание Аристотеля о рабе как «говорящем орудии» см. *Политика* 1,2-4.

100. *Влияние морали на право.* Ценные исследования того, как *развитие* права испытало влияние морали, см. в Ames, «Law and Morals» ***II*** *22 HLR* (1908); Pound, *Law and Morals* (1926); Goodhart, *English Law and the Moral Law* (1953). Остин полностью осознавал эту фактическую или каузальную связь. См. *The Province,* Lecture V, p. 162.

101. *Интерпретация.* О месте моральных соображений в интерпретации права см. Lamont, *The Value Judgment,* pp. 296-31; Wechsler, «Towards Neutral Principles of Constitutional Law» ***II*** ***73*** *HLR* i, p. 960; Hart, op. cit. ***II*** ***11*** *HLR,* pp. 606-15, и критика Фуллера, ib. 661 *ad fin.* О признании Остином существования сферы, открытой для выбора судей между «конкурирующими аналогиями», и его критике неспособности судей сделать их решения соответствующими стандарту полезности, см. *The Lectures,* Lectures 37-38.

102. *Критика законодательства и право всех людей на равное внимание.* См. Benn and Peters, *Social Principles and the Democratic State,* chaps. 2-5, и Baier, *The Moral Point of View,* chap. 8, о том, что признание этого права является не просто одной из возможных моралей, но определяющей характеристикой истинной морали.

103. *Принципы легальности и справедливости.* См. Hall, *Principles of Criminal Law,* chap. 1; о «внутренней морали права» см. Fuller, op. cit. ***III*** *HLR* (1958), pp. 644-8.

104. *Возрождение естественноправовых доктрин в послевоенной Германии.* См. обсуждение поздних воззрений Радбруха (Radbruch) и ответ Фуллера см.: Hart, op. cit. ***II*** ***11*** *HLR* (1958). Обсуждение решения Oberlandsgericht Bamberg (июль 1949), в котором жена, сдавшая своего мужа нацистам за нарушение действующего тогда статута 1934 г., была

признана незаконно лишившей его свободы, исходило из предположения, что описание этого казуса в *64 HLR* (1951), p. 1005, было корректно и что германский суд признал статут 1934 г. недействующим. Точность этого описания была недавно подвергнута сомнению Паппе: Pappe, «On the Validity of Judicial Decisions in the Nazi Era», *23 MLR* (1960). Критика доктора Паппе вполне обоснованна, поэтому наше обсуждение этого казуса следует рассматривать как гипотетическое. Как показал доктор Паппе (op. cit., p. 263), в данном конкретном деле суд (Апелляционный суд провинции), после признания теоретической возможности того, что статут может быть признан незаконным, если он нарушает естественное право, пришел к выводу, что данный нацистский статут не нарушает его; обвиняемая был признана виновной за незаконное лишение своего мужа свободы потому, что она не обязана была информировать власти, но сделала это по личным соображениям и должна была понимать, что подобный поступок в данных обстоятельствах «противоречил здравой совести и чувству справедливости, общим для всех честных людей». Следует рассмотреть в этой связи тщательный анализ д-ром Паппе решения Верховного Суда Германии по поводу другого сходного случая: ib., p. 268 *ad fin.*

ГЛАВА X

105. *Является ли международное право настоящим правом?* О том взгляде, что это всего лишь словесный вопрос, ложно принимаемый за вопрос факта, см. Glanville Williams, op. cit. ***II****22 BYBIL* (1945).

106. *Источники сомнения.* Конструктивный общий очерк см. в A. H. Campbell, «International Law and the Student of Jurisprudence* ***II*** 35 *Grotius Society Proceedings* (1950); Gihl, «The Legal Character and Sources of International Law» ***II*** *Scandinavian Studies in Law* (1957).

107. *Каким образом международное право может быть обязывающим?* Этот вопрос (иногда обозначаемый как «проблема обязывающей силы» международного права) был поднят Fischer Williams, *Chapters on Current International Law,* pp. 11-27; Brierly, *The Law of Nations,* 5th edn. (1955), chap. 2; *The Basis of Obligation in International Law* (1958), chap. 1. См. также Fitzmaurice, «The Foundations of the Authority of International Law and the Problem of Enforcement* ***II*** 19 *MLR* (1956). Эти авторы не обсуждают в явной форме смысл утверждения, что система правил является (или не является) обязывающей.

108. *Санкции в международном праве.* О статье 16 Устава Лиги Наций см. Fischer Williams, «Sanctions under the Covenant* ***II*** 77 *BYBIL* (1936). О санкциях главы 7 Чартера ООН см. Kelsen, «Sanctions in International Law under the Charter of U.N.» ***II*** *31 Iowa LR* (1946); Tucker, «The Interpretation

of War under present International Law» ***II*** *4 The International Law Quarterly* (1951). О войне в Корее см. Stone, *Legal Controls of International Conflict* (1954), chap, ix, Discourse 14. Конечно, спорно то, что Резолюция об объединении ради мира (the Uniting for Peace Resolution) показала, что ООН не была «парализована».

109. *Международное право, мыслимое или обсуждаемое как обязательное.* См. Jessup, *A Modem Law of Nations,* chap. 1; «The Reality of International Law» ***II****18 Foreign Affairs* (1940).

ПО. *Суверенитет государств.* Ясное изложение представления о том, что «суверенитет — это только имя, данное той область международных отношений, которую закон оставил для индивидуального действия государств», см. в Fischer Williams, op. cit, pp. 10-11, 285-99, *Aspects of Modern International Law,* pp. 24-6, Van Kleffens, «Sovereignty and International Law» ***II*** *Recueil des Cours* (1953), i, pp. 82-3.

111. *Государство.* О понятии «государство» и типах зависимых государств см. Brierly, *The Law of Nations,* chap. 4.

112. *Волюнтаристские теории и теории «самоограничения» (Autolimitation).* Важнейшие авторы: Jellinek, *Die Rechtliche Natur der Staatsvertrdge;* Triepel, «Les Rapports entre le droit interne et la droit internationale» ***II*** *Recueil des Cours* (1923). Крайней позиции придерживается: Zorn, *Grundzbge des Vulkerrechts.* См. критическое обсуждение этой формы «позитивизма» в Gihl, op. cit. ***II*** *Scandinavian Studies in Law* (1957); Starke, *An Introduction to International Law,* chap, i; Fischer Williams, *Chapters on Current International Law,* pp. 11-16.

113. *Обязанность и согласие.* Представление о том, что ни одно правило международного права не связывает государство без его предварительного, явного или молчаливого, согласия, выражено английскими судами (см. *R.* v. *Keyn* 1876, 2 Ex. Div. 63, «The Franconia») и Постоянным судом по международным делам (Permanent Court of International Justice). См. *The Lotus,* PCIJ Series A, N. 10.

114. *Новые государства и государства, приобретающие приморские территории.* См. Kelsen, *Principles of International Law,* pp. 312-13.

115. *Воздействие международных соглашений на неприсоединившиеся стороны (non-parties).* См. Kelsen, op. cit., 345 ff.; Starke, op. cit., chap. 1; Brierly, op. cit., chap, vii, pp. 251-2.

116. *Всестороннее использование термина «мораль».* См. мнение Остина о «позитивной морали» в *The Province,* Lecture V, pp. 125-9,141-2.

117. *Моральная обязанность подчиняться международному праву.* О том, что это положение является «фундаментом» международного права, см. Lauterpacht, Introduction to Brierly's *The Base of Obligation in International Law,* xviii, and Brierly, ib., chap. i.

118. *Договор, навязанный силой, как закон.* См. Scott, «The Legal Nature of International Law» ***II*** *American Journal of International Law* (1907) at pp. 837, 862-4. Критику распространенного представления о общих договоров как «международного законодательства» см. в Jennings, «The Progressive Development of International Law and its Codification* ***II*** *24 BYBIL* (1947) at p. 303.

119. *Децентрализованные санкции.* См. Kelsen, op. cit., p. 20, и Tucker in op. cit. ***II****4 International Law Quarterly* (1951).

120. *Базовая норма международного права.* Формулировку такой нормы, как *pacta sunt servanda,* см. в Anzilotti, *Corso di diritto internazionale* (1923), p. 40. О замещении ее положением «государства должны вести себя так, как они обычно ведут себя» (эстоппель *) см. Kelsen, *General Theory,* p. 369, и *Principles of International Law,* p. 418. Важный критический разбор см. в: Gihl, *International Legislation* (1937) и op. cit. ***II*** *Scandinavian Studies in Law* (1957), pp. 62 ff. Подробное развитие доктрины о том, что в международном праве нет базовой нормы, см. Ago, «Positive Law and International Law» ***II*** 57 *American Journal of International Law* (1957); *Scienza giuridica e diritto internazionale* (1958). Gihl приходит к заключению, что, несмотря на статью 38 Закона о международном суде (Statute of the International Court), международное право лишено формальных источников права. Попытка сформулировать «исходные гипотезы» международного права, которую можно критиковать по тем же основаниям, что и предложенную в тексте, предпринята в: Lauterpacht, *The Future of Law in the International Community,* pp. 420-3.

121. *Аналогия по содержанию в международном праве и внутригосударственном праве.* См. Campbell, op. cit. ***II*** 35 *Grotius Society Proceedings* (1950), p. 121 *ad fin.,* обсуждение договоров и правил, регулирующих приобретение территорий, получение их по давности владения (prescriptions), в аренду, мандаты, сервитута и др., см. в Lauterpacht, *Private Law Sources and Analogies of International Law* (1927).

[1] См. Каламкарян П.А. *Эстоппель в международном публичном праве.* М., 2001. — *Примеч. пер.*